

國立臺灣大學法律學院法律學研究所

碩士論文

Department of Law

College of Law

National Taiwan University

Master Thesis

論行政法上義務之概括繼受

The Universal succession of the Obligation in Administrative Law

邱稚宸

Chih-Chen Chiu

指導教授：李建良　博士

Advisor : Chien-Liang Lee , PhD

中華民國 106 年 6 月 30 日

June 2017

doi:10.6342/NTU202000774

謝辭

這本論文之所以能夠順利完成，一定要感謝我的指導教授李建良老師，從一開始李老師爽朗的答應我，成為我的指導教授，直到論文口試順利完成，李老師總是認真的回應我每一個光怪陸離的問題，讓自己對於想寫的議題，能夠有更全面的思路，並且李老師十分照顧並關心學生，讓自己得以無後顧之憂的寫完這本論文，真的很謝謝李老師 >///<。

並且感謝林昱梅老師與詹鎮榮老師擔任論文的口試委員，林老師與詹老師給予了不同方面及深度的議題以及建議，讓這本論文的架構得以更加完整，也謝謝兩位老師對這本論文的鼓勵。

感謝我的外婆，總是默默地支持著我完成自己的目標，給我最真誠的愛，讓我得已前進。感謝我的爸媽一路支持我到現在，我才能沒有後顧之憂地將學業順利完成。

謝謝鈺嵐，我們的友情從國中到現在已經超過十年了> <，這本論文的寫作當中，我曾遇到許多困難以及壓力，我們常常不需要多說什麼，只要一起吃頓飯，一起發個呆就已足夠，總而言之，阿嵐的陪伴都讓我都撐過去了，揪咪。

謝謝瑋珊與眞綝，我們的友情都是在特別的時候發出光芒，自

doi:10.6342/NTU202000774

從在研究所組了妄想女子會後，我們的生活充斥著各種有趣的出動，第一出動到第四出動都慰藉了我們疲累的研究生生活，希望之後能聽到眞緌的第四出動唷 <3！希望瑋珊的工作及眞緌的論文都一切順利。

謝謝陳薇及政寬，我們的緣分真的蠻特別的，在研究生的生涯中，從不定期早餐約會，才發現我們是這樣的合拍（笑），還記得在我最低潮的時候，陪我坐在植物園大哭 XD，以及透過寬哥的人脈取得超難拿到的文獻，這些都讓我感動到不行。

謝謝繹捷，從之前一起在補習班準備公法組考試，到現在各自生活越來越穩定，即使我們身在不同的校園，仍會相互關心，為彼此打氣，真的很感動拉^^。謝謝彥琪，希望托福與在美國工作一切順利。謝謝東政及均彥，廣義同門的聚會真的讓人好舒壓，謝謝羿靜，總是在我最低潮的時候出現。

最後謝謝建輝，生命的交集在我們 25 歲時，願這樣的交集可以一直到永恆。

doi:10.6342/NTU202000774

中文摘要

本論文的核心在於是在概括繼受之法律概念，試著對公法領域中，人民對國家的義務加以研究，在我國行政法上義務概括繼受的發展，討論上並不如其他公法領域之議題，然而概括繼受之發生，實乃必定發生，故理論的建立、要件的釐清、法規範的探尋、正當程序的建構，為本文的探討重心。

首先就「概括繼受」此種制度加以介紹，先以繼受一詞概念分析，並試著就我國各該法領域之繼受概念的代表詞彙整哩，接著就概括繼受之目的及涉及基本權利的侵害，置於憲法領域加以討論。再者就本文討論概括繼受之標的——公法上義務，加以細究其內涵，試著比較公法上與民法上之義務差別，以及公法上義務與責任之差別，以更深度了解何謂義務。

接著，就概括繼受的要件思考流程為介紹，藉由學理文獻之整理，將概括繼受之要件作更具體的說明，並且將重心聚焦於概括繼受法規範部分，因我國公法領域對此尚未有一般性規範，然為符合法律保留原則的要求，嘗試就我國民法、公司法、行政執行法的規定涉及概括繼受之一般性規定，細究其要件及用語，以得出公法上義務藉由其他法規範概括繼受之空間，並給予立法論上的建議，達到根本完整公法上概括繼受制度之理想。又，就概括繼受之正當法律程序部分的建構，亦完整概括繼受之程序保障。

接續著提出我國具備代表性概括繼受案例，以土汙法的整治義務、罰鍰義務及公法上不當得利返還義務作為核心，本於前述建構之概括繼受要件，試著就具體案例加以剖析，以得出結論。

doi:10.6342/NTU202000774

最後對於前述概括繼受之理論面、實務面及本文見解加以整理，作為本論文之總結。

關鍵字：行政法上義務、概括繼受、罰鍰、不當得利。

doi:10.6342/NTU202000774



英文摘要

The purpose of the study was focused on the universal succession, especially in the people's obligation of Administration law. Since there are not much literature addressed the issue in Taiwan , it would be necessary to establish the system of the universal succession in Administrative law. As a result, it has to analyze its elements , statutes and due process.

First of all, the study introduced the system of the universal succession in terms of Constitution Law. Also, it is crucial to realize "the obligation of administrative law". By means of comparing with the obligation of Civil law and the obligation of Administrative law , it could be clearer to understand it.

In addition, by deducting from literature , the study explained the factors and tried to be specific. It emphasized on the principle of legal reservation. By seeking other fields of law such as Civil law, Company law and Administrative Execution Law , some articles could be adapted in obligation of administrative law. However the best way to complete the system is that law makers must reform the Administrative law in legislative technology. Besides, the study tried to construct the due process of law for universal succession. It would complete its procedure guarantee function.

doi:10.6342/NTU202000774

Furthermore, the study provided some significant cases such as duty of pollution Remediation by Soil and Groundwater Pollution Remediation Act, duty of fines and Unjust Enrichment obligation. By analyzing them, it could assist to comprehend the concept and how to apply it properly.

In conclusion, The study analyzed practical cases, could serve as a guide for further research.

Key words : obligation of Administration law ; universal succession ; fine ;Unjust Enrichment obligation.

doi:10.6342/NTU202000774

目次

第一章 緒論 1
第一節 研究動機與目的 1
第一項 研究動機 2
壹、我國法公法上義務繼受制度之建構尚未達成熟 2
貳、公法上義務概括繼受乃實務運作必須解決之課題 3
第二項 研究目的 4
壹、歸納整理我國法規範概括繼受之依據 4
貳、分析我國法發生之義務概括繼受實例 5
第二節 研究範圍 5
第一項 針對公法上人民對國家之「義務」之概括繼受 5
壹、公法上權利的概念 5
貳、公法上義務的概念 6
參、聚焦於公法上「人民對國家」之「義務」之概括繼受 7
第二項 針對「概括」繼受之態樣 8
第三項 針對「人民與人民間」的義務繼受 8
第三節 研究方法 8
第四節 研究架構 9
第二章 行政法之義務繼受概念 14
第一節 行政法上義務「繼受」制度之內涵 14
第一項 行政法上「繼受」用語概念 14
壹、個別繼受 14
貳、概括繼受 15
參、小結 15
第二項 其他法規範有關繼受之用語辨析 16
第三項 概括繼受於公法領域中之適用 18
第四項 公法上概括繼受之目的 19
第五項 義務概括繼受涉及之憲法課題 21
壹、「繼承制度」於憲法上之定位 21
一、「繼承」係本於財產權保障之意旨因應而生之制度 21
二、「遺產」的定位 23
三、繼承制度賦予繼受客體可繼受性之正當性考量 25
四、賦予概括繼承客體具有可繼受性之憲法上利益權衡判斷 26
五、小結 26
貳、「概括繼受」義務之基本權利干預探究 27

doi:10.6342/NTU202000774

一、財產權 27
二、一般行為自由 29
三、概括繼受公法上義務將涉及對繼承人之限制 30
四、法律保留原則於公法上概括義務繼受之思考 35
第二節　行政法之「義務」內涵 35
第一項　行政法義務的概念與種類 35
壹、義務的基本定義及概念 35
貳、行政法上義務概念與種類 36
一、行政法上義務之概念 37
二、行政法上義務之種類 37
參、行政法與民法上義務之比較 40
一、民法上義務之內涵、解釋 40
二、公法與民法「義務」概念比較 42
第二項　行政法上義務與責任辨析 42
壹、秩序行政概念與內涵 43
貳、責任是抽象的行政法規範，義務乃責任具體展現 45
一、我國法學緒論角度之理解 45
二、公法（行政法）角度理解 46
第三項　行政法之責任類型 50
壹、責任人概念 51
貳、責任類型之區分 52
一、 行為責任 53
二、 狀態責任 55
三、 緊急責任 60
參、行政法責任與行政秩序罰之區辨 61
一、以秩序行政脈絡以觀，兩者乃屬不同階段之概念 61
二、以定義及內涵以觀，兩者亦屬完全之概念 62
肆、行政法上責任與義務之體系辨析 62
一、階段一：尚處秩序行政法依據 62
二、階段二：構成行政法上抽象責任 63
三、階段三：發生具體行政法上義務 63
第三章　義務概括繼受之要件及法依據探討 66
第一節　概括繼受義務思考脈絡及制度要件 66
第一項　發生繼受事實 66
第二項　義務具備「可繼受性」 67
壹、該義務須為「具體行政法上義務」 68
貳、該義務不具備一身專屬性 70
一、一身專屬性之「判斷標準」 70

doi:10.6342/NTU202000774

二、一身專屬性之「消滅」 71
第三項　概括繼受義務之法律依據 79
壹、概括繼受行政法上義務之法律保留思考 79
一、法律保留原則概念 80
二、我國學理對於概括繼受義務之法律保留程度上有爭議 81
三、小結 83
貳、 自然人的概括繼受依據 84
一、民法繼承編之規範解析 84
二、公法上義務適用民法繼承編之探究 92
參、 法人的概括繼受依據 99
一、公司法之規範概述 99
二、公司合併的概念 99
三、公司法第 75 條作為法人合併概括繼受依據之探討 100
四、小結 105
肆、非法人團體之概括繼受依據 108
伍、執行程序之概括繼受依據 109
一、罰鍰於行政執行程序之繼受依據 109
二、罰金於刑事執行程序之繼受依據 113
第四項　我國公法上義務概括繼受之法體系建構及立法論建議 116
第二節　不真正繼受概念探討 118
第一項　行為責任與狀態責任下義務繼受之差異 118
第二項　不真正繼受概念爭議 119
第三項　本文見解 121
第三節　概括繼受之正當法律程序建構 122
第一項　概括繼受之正當行政程序 124
壹、繼受義務之調查 124
貳、另作成行政處分送達繼承人 125
參、繼承人應享有聽證權 126
肆、處分中應為理由說明 127
第二項　概括繼受之正當爭訟程序 127
壹、訴願（訟）標的義務具一身專屬性 128
一、釋憲實務見解 130
二、法院實務見解 133
三、學說見解 134
四、本文見解 136
貳、訴願（訟）標的義務非一身專屬性 147
第三項　繼受之正當執行程序 148
壹、義務具有一身專屬性 148

doi:10.6342/NTU202000774

貳、義務不具有一身專屬性 149
第四章　我國法概括繼受實例探討 152
第一節　土汙法整治義務之概括繼受 152
第一項　概說 152
第二項　案例事實 152
第三項　大法官釋字第 714 號解釋意旨 153
第四項　整治義務可繼受性探討 154
壹、土汙法之「汙染義務人」係負行為責任 155
貳、土汙法第 53 條規範辨析 156
一、以「行為責任」作為溯及既往之基礎 156
二、屬適法之「真正溯及既往」規定 157
參、汙染行為人之整治義務具有可繼受性 159
肆、行為責任溯及既往與義務概括繼受之交集探討 161
一、施行前發生污染行為，施行後行政機關先對行為人課予整治義務，後再發生概括繼受事由 161
二、施行前發生汙染行為，施行後發生概括繼承事由且行政機關對繼承人課與整治義務 161
三、施行前先發生汙染行為，再發生概括繼承事由，施行後行政機關對繼承人課與整治義務 163
四、小結 165
伍、概括繼受土汙法行為責任或整治義務之比例原則適用 165
第五項 釋字第 714 號之背景事實評析 167
第六項　小結 168
第二節　罰鍰義務之概括繼受 169
第一項　概說 169
第二項　案例事實 169
第三項　大法官釋字第 621 號解釋意旨 170
第四項　罰鍰義務可繼受性探討 172
壹、行政秩序罰之概念 172
貳、罰鍰義務的目的 173
參、罰鍰義務可繼受性探討 174
一、實務見解 174
二、學理見解 176
三、本文見解 177
肆、釋字第 621 號之背景事實評析 179
第五項　小結 180
第三節　不當得利返還義務之概括繼受 181
第一項　概說 181

doi:10.6342/NTU202000774

第二項　案例事實.....181
第三項　法院見解.....182
第四項　不當得利返還義務之可繼受性探討.....183
壹、不當得利返還制度內涵.....183
貳、成立金錢授益處分之不當得利「返還義務」.....186
一、公法與民法上不當得利返還義務之比較.....186
二、公法上不當得利返還義務成立要件.....188
三、返還義務產生之類型討論.....189
參、公法上不當得利返還義務概括繼受容許性探討.....195
一、屬具體行政法上義務.....195
二、屬非一身專屬性義務.....196
三、概括繼受返還義務之方式.....198
第五項 案例評析.....199
第六項　小結.....201
第五章　結論.....204
第一節　行政法上義務概括繼受基本體系建構.....204
第一項　行政法上義務概括繼受概念.....204
壹、行政法上義務之辨析.....204
貳、行政法上概括繼受之辨析.....205
第二項　憲法框架下之義務概括繼受.....205
第二節　釐清義務繼受思考流程.....206
第一項　發生義務概括繼受事由.....206
第二項　義務具有可繼受性.....207
壹、具體行政法上義務.....207
貳、不具備一身專屬性.....207
第三節　建構我國法公法上概括繼受法律依據.....208
第四節　建立概括繼受之正當法律程序.....209
第一項　行政程序.....209
第二項　行政爭訟程序.....210
第三項　執行程序.....211
第五節　行政法上義務繼受之展望.....211
參考資料.....214

doi:10.6342/NTU202000774

第一章 緒論

第一節 研究動機與目的

行政法的發展，從著重「行政行為的性質」，到現今行政任務之複雜，以及社會事實的變化，單純以行政行為形式去思考國家與人民多變的互動，無疑遠遠不足，是以逐漸轉變以「行政法上之法律關係」加以思考，其乃成為現今行政法上重要的概念。在行政法律關係的概念下，所著重者係法規範下，作為「人」之數個權利主體，對於特定之生活事實所發生的法律上連結，其中的核心要素通常為權利與義務[1]。

在「行政法之法律關係」觀點獲得理解及證例之時，行政法律的內涵即可得到更廣泛、完整的涵蓋，其中若聚焦於「行政法權利主體之間的變動」，最重要者乃行政法上權利義務之繼受制度概念。又，繼受的議題對於法律關係所規制的對象是「人的屬性」抑或是「物的屬性」而具備區別實益，蓋前者乃「屬人性的法律關係」，後者則屬「屬物性的法律關係」，權利義務繼受的課題在此兩者分類上會牽涉得否繼受、如何繼受[2]。職是，探討權利義務之繼受對於行政法律關係體系的建構極具價值。

所謂繼受，概念上係指不同權利主體間就同一權利義務之移轉，雖然目前我國公法實務上並沒有明確界定「公法權利義務之繼受」具體概念，但在我國行政法領域，行政法義務的繼受課題，於實務上層出不窮，蓋「繼受」之發生

[1] 李建良（2016），〈第六講 行政法律關係序說〉，《行政法基本十講》，6 版，頁 201-202，台北：元照。
[2] 李建良（2016），〈第六講 行政法律關係序說〉，《行政法基本十講》，6 版，頁 214-215，台北：元照。

doi:10.6342/NTU202000774

在實然面上乃社會事實上無可避免者。

權利及義務乃法律世界中最基本、原始之概念，當人們進入法治的文明，即代表了受到權利及義務的規制，而權利主體的存續就像是一條線，法律繼受制度猶如連結線與線之間的點，將權利客體加以延續。

第一項　研究動機

壹、我國法公法上義務繼受制度之建構尚未達成熟

啟發本文的寫作動機，其一原因在於，概括繼受的發生，是社會事實及行政實務不可避免所發生之情事，目前我國對於公法上義務繼受的了解、制度安排及應用上似乎尚未達到高度發展、廣泛討論的地步。比較德國法行政法領域，就公法權利義務之繼受早期亦受到忽略，然在學理的批判、觀念轉換及實務解決問題的需要下，逐漸地公法上權利義務的繼受成為其行政法學之通念[3]。反觀我國，對於公法上權利義務之繼受，尚未達到我國法行政法領域上「通念」之地步，在我國法上建構尚須多加討論。

繼受制度，在私法領域有較高度且健全的發展，例如我國民法繼承篇中對於自然人死亡後，已設有完整的繼承制度，從繼承的客體、程序、效果均有明確的規定依據。然而，反觀在公法領域中，除了部分個別特殊的行政法規有明定得繼受的情事外，在基本行政法體系之中，卻缺乏如私法體系明確的制度規範，且概念尚屬模糊。我國學理上對於行政法權利義務之繼受，多是引進德國

[3] 李建良（2006），（行政法上義務繼受問題初探－兼評高雄高等行政法院九十二年度訴字第八○六號判決暨最高行政法院九十四年度判字第六二二號判決），《2005 行政管制與行政爭訟》，頁79，台北：中央研究院法律學研究所籌備處。

doi:10.6342/NTU202000774

法之文獻加以說明繼受之一般性要件，對我國法本身實踐的部分，以我國行政法規、法理及實務運作作為基礎所建構出完整的理論體系並不多見。

貳、公法上義務概括繼受乃實務運作必須解決之課題

另一原因則在於，近期行政法院的判決及訴願決定對於行政法義務概括繼受議題有所相關，最近作出的大法官釋字第 714 號解釋，涉及土壤及地下水污染整治法第 48 條之整治義務是否得概括繼受之議題，極為可惜的是，大法官解釋並未進一步對整治義務概括繼受之議題加以論述、闡釋。然而該號釋字案例事實，對我國行政法義務之繼受課題實踐之探討極具研究價值。除了土汙法整治義務此種「非金錢給付義務」之概括繼受的課題值得研究外，在「金錢給付義務」部分，例如公法上不當得利返還義務之繼受，實務上亦需要明確的理論脈絡加以解決。

現今行政實務已面臨許多公法上權利義務繼受之情事，然而實務有時會避開正面解決繼受體系與制度之機會。例如大法官釋字第 622 號解釋中，針對被繼承人死亡前已發生的稅捐債務，於稅捐稽徵機關做成課稅處分前死亡，繼承人是否應概括繼承被繼承人之稅捐債務，或是僅以遺產範圍內負擔責任? 就此爭議，過去最高行政法院 92 年 9 月 18 日庭長法官聯席會議決議認為「被繼承人於死亡前三年內為贈與，於贈與時即負有繳納贈與稅之義務，贈與稅捐債務成立，被繼承人死亡時，稅捐稽徵機關縱尚未對被繼承人核發課稅處分，亦不影響該稅捐債務之效力。此公法上之財產債務，不具備一身專屬性，可依民法 1148 條之規定，其繼承人繼承之，故稽徵機關於被繼承人死亡後，自應以其繼承人為納稅義務人，於核課期間內，核課其承之贈與稅」，大法官在此認為，遺產與贈與稅法第 15 條及稅捐稽徵法第 14 條中並未有規定繼承人應作為納稅義

doi:10.6342/NTU202000774

務人而有繳納稅捐之義務，前述之決議以民法第 1148 條之規定類推適用於納稅義務之中，係違反租稅法律主義，故大法官採繼承人所負者乃「代繳義務」之觀點作為解套，也即繼承人乃本於代繳義務人之地位履行被繼承人其生前以成立之稅捐債務，而非繼受其稅捐義務。

細究該解釋之脈絡，大法官針對決議內容之稅捐債務是否具備一身專屬性部分，並未加以詳述、評析稅捐債務之性質，進一步辨析稅捐責任之繼受課題之有無及其內涵。而是以稅捐稽徵法第 14 條[4]作為解釋繼承人負擔繳納義務之基礎，似乎有注意到該條以繼承人「概括繼承有限責任」作為要件[5]。由此可知，大法官在釋憲實務中應已意識到公法上義務繼受此一議題之存在，然仍未能定紛止爭，實殊可惜。

第二項　研究目的

壹、歸納整理我國法規範概括繼受之依據

本文的寫作目的，係希望透過我國本身行政法制對於「義務」、「概括繼受」的觀察，在立法者尚未對於公法上繼受制度制定出基本處理模式以前，藉由爬梳學說及實務見解，本於干預行政之法律保留原則下，試著比較我國現行法規範是否有公法上之義務繼受之依據，進而嘗試對「義務」一詞比較公法上與私法上的內涵，以整理出兩者概念是否有相似內涵者，試著對照民法繼承

[4] 稅捐稽徵法第十四條規定：「納稅義務人死亡，遺有財產者，其依法應繳納之稅捐，應由遺囑執行人、繼承人、受遺贈人或遺產管理人，依法按稅捐受清償之順序，繳清稅捐後，始得分割遺產或交付遺贈（第一項）。遺囑執行人、繼承人、受遺贈人或遺產管理人，違反前項規定者，應就未清繳之稅捐，負繳納義務（第二項）」。

[5] 陳清秀（2007），〈稅捐債務可否繼承-評析釋字第六二二號解釋-〉，《台灣本土法學雜誌》，91 期，頁 305。

doi:10.6342/NTU202000774

編、公司法第 75 條、行政執行法第 15 條、刑事訴訟法第 470 條第 3 項之規定，是否有容納公法上義務繼受之空間，藉由不同領域的規範及法律名詞概念相互比較，試著歸納、整理公法上義務概括繼受依據。

貳、分析我國法發生之義務概括繼受實例

待統整、分析我國公法上義務概括繼受之依據之後，進一步對我國已發生之概括繼受實例──土壤及地下水污染整治法之整治義務、公法上不當得利返還義務之繼受、罰鍰義務之繼受加以評析。針對最前者為行政法上非金錢給付義務代表性案例，及後兩者為金錢給付義務繼受的代表性案例，試著分析、檢討並提出以我國法為基礎的繼受議題之解決模式。

第二節　研究範圍

第一項　針對公法上人民對國家之「義務」之概括繼受

關於公法上權利義務之概括繼受此一課題，尚可以分成「公法上權利的概括繼受」及「公法上義務之概括繼受」此兩者，在概括繼受的思考脈絡中，兩者截然有別。以下就公法上之權利及義務的基本概念先為釐清。

壹、公法上權利的概念

所謂權利，其廣義性定義乃可享受特定利益之法律上之力[6]，亦稱為法的主

[6] 鄭玉波著、黃宗樂修訂（2016），《法學緒論》，22 版，頁 134-135，台北：三民。

doi:10.6342/NTU202000774

觀意義，係透過法律賦予個別主體法律之力，一方有要求他方為一定作為、不作為或容忍之權利。權利之內涵與外沿法律規範內涵互有關聯。法律於一定要件之下，賦予個人之力量，始之享有特定利益，並加以保護，本於法律保障的權利下，權利主體使得請求特定人為一定之的作為[7]。

將「權利」聚焦於「公法上權利」，其概念可對應為行政法學中之「主觀公權利」之概念，又可稱作為「公權利」、「公權」，係指人民得基於公法（行政法）的規定，享有一定法律之權利，得以向國家請求一定作為、不作為或容忍，以實現個人的利益，權利在私法領域與公法領域存在不同的表現，民法的整體構造大致以權利及義務相互性為中心，然公法領域中權利及義務的表現具有不對等性，其原因在於行政權的發動及運作具有以公益取向的特徵，公法規範乃針對多數人民，若全然承認人民享有公法上權利，將會造成公法上權利過於浮濫之嫌[8]。

貳、公法上義務的概念

所謂義務，其廣義性概念為法律上所課之作為或不作為之拘束，負有義務之人必須履行其義務，否則即違反義務將遭受到制裁[9]。析言之，是指一法律主體依法律規定，或是經由國家機關依據法律所為之要求，應為特定的行為，也即應為特定之行為、容忍或不作為時，即成立一項義務[10]。

所謂公法上義務，具體而言是指行政法上之義務，人民依行政法的規定，

[7] 李建良（2016），〈行政法第十講：公法上權利的概念、理論與運用〉，《行政法基本十講》，6版，頁 291，台北：元照。
[8] 李建良（2016），〈行政法第十講：公法上權利的概念、理論與運用〉，《行政法基本十講》，6版，頁 291-295，台北：元照。
[9] 鄭玉波（著）、黃宗樂（修訂）（2016），《法學緒論》，22 版，頁 135-136，台北：三民。
[10] 陳敏（2016），《行政法總論》，9 版，頁 253，台北：新學林。

doi:10.6342/NTU202000774

應服從行政之公權力，作為特定之作為、容忍或不作為時，即成立人民之行政法上義務，大多與高權主體之權利相對應，法律直接對公行政授予權利，公行政則據以對服從其公權力之人民，將其抽象之義務具體化及現實化，從而實現公共利益，完成行政任務[11]。

參、聚焦於公法上「人民對國家」之「義務」之概括繼受

了解公法上權利及義務概念之區辨，可知以概括繼受人之角度而言，繼受公法上之權利或是義務乃截然不同之態樣與結果。若繼受人取得公法上之權利，對於繼受人而言，乃獲得向國家請求一定作為、不作為或容忍，以實現個人的利益之地位。在基本權利層次上，係不受有任何限制，則繼受權利的有無對於被繼受人而言實無干涉其基本權利，討論繼受權利制度之內涵較無實益。然而，若是繼受人取得為公法上義務，則勢必須履行義務，無疑對繼受人而言，須履行被繼受人之義務，造成繼受人憲法所保障的基本權利之限制。在憲法法治國之價值下，基本權利之限制並非漫無界限，故對於「義務」的繼受必須細緻化體系之建構始能貫徹憲法之精神，對於人民基本權利之保障與行政實務問題之解決十分具有實益。

又，關於行政法上義務中，其義務面向包括「人民對國家之義務（國家課與人民之義務）」，及「國家對人民之義務」此兩種，前者通常是國家以行政處分具體化人民之義務加以課予之，後者則是人民本於一定之依據之下，向國家請求履行一定之義務。本文欲探究之範圍，限於「人民對國家之義務」此一面向，因人民對國家之義務，乃基本權利保障之核心，是否賦予、如何賦予人民義務與比例原則地拿捏息息相關。

[11] 陳敏（2016），《行政法總論》，9 版，頁 268，台北：新學林。

doi:10.6342/NTU202000774

第二項　針對「概括」繼受之態樣

所謂繼受，廣義的概念是指同一權利義務從一權利主體轉移至另一權利主體，但繼受尚可再分成「個別繼受」及「概括繼受」，前者是指對權利主體基於法律行為將其可處分之標的移轉於其他權利主體；後者則是指發生特定法律事實，使一權利主體所有之權利義務同一、整體地移轉於其法定繼受人。權利主體為自然人時，以「死亡」作為原因；權利主體為法人或非法人團體時，以「合併」作為主要原因。本文所欲討論者，乃後者之「概括」繼受，發生的原因來自於特定事實，而非法律行為，故此種繼受在公法上之法律保留原則討論更重要，故本文聚焦以概括繼受為討論。又，本文就法人及非法人團體的概括繼受事由，僅以「合併」事由作為討論。

第三項　針對「人民與人民間」的義務繼受

可作為行政法律關係義務之主體者，主要存在於行政主體與人民之間[12]，義務繼受之情況，尚可進一步可排列組合為，行政主體繼受行政主體之義務、行政主體繼受人民之義務、人民繼受行政主體之義務、人民繼受人民之義務之四種可能[13]。本文係欲針對人民與人民之間的義務繼受作為論述之主軸。

第三節　研究方法

[12] 陳敏（2016），《行政法總論》，9 版，頁 242，台北：新學林。
[13] 李建良（2006），〈行政法上義務繼受問題初探－兼評高雄高等行政法院九十二年度訴字第八○六號判決暨最高行政法院九十四年度判字第六二二號判決〉，《2005 行政管制與行政爭訟》，頁 80，台北：中央研究院法律學研究所籌備處。

doi:10.6342/NTU202000774

在研究的方法上，針對本文之核心──公法上之義務概括繼受，欲採取文獻分析及歸納整理之方式。關於義務繼受制度相關之文獻，比較法的部分以德國法討論最為廣泛，而國內法的部分討論的文獻早期較為稀少，近期則有增長之情況，是以欲試著以理解德國法所建構之概括繼受制度之一般抽象要件為基礎，進一步爬梳、整理我國法涉及義務概括繼受之實務見解及學術文獻，以歸納、剖析我國法之概括繼受依據、內涵及行政實務繼受之研究。

第四節　研究架構

本文欲研究之架構，以各章節作為分類試述如下。

關於第二章部分，若欲先探究「行政法上義務概括繼受」此課題，首先釐清何謂「概括繼受」之概念，分析在公法領域中對於概括繼受概念是否存在，其存在的目的為何。接著，「義務概括繼受」在憲法中層次定位、正當性為何，究竟將會限制繼受人何種基本權利之態樣，抑是值得探究。透過析論繼受人概括繼受行政法上義務之本質，在憲法體系中對於基本權利限制究竟限制何種權利、限制的力道如何，始能進一步思考義務概括繼受，應如何建構其法律保留原則的內涵、強度以及比例原則之展現。再者，須對於「行政法上義務」以及「民法上義務」之定義、概念及分類為完整理解，除有助釐清概括繼受之標的；還有藉由比較公法與民法上之「義務」一詞，探求兩者有無相通之可能，以便尋找現行法概括繼受之依據。了解「義務」之內涵後，尚必須進一步對「責任」概念、行政法領域中之定位與種類討論，以釐清義務與責任兩者概念在公法領域內的區分與概括繼受之基礎，並幫助了解本文第三章第二節之「不真正繼受」概念，及其後對概括繼受實例之探討與辨析。

doi:10.6342/NTU202000774

關於第三章部分，藉由整理學理文獻，提出對於公法上義務概括繼受的思考脈絡與要件，此部分重要者在於判斷行政法上義務有無「可繼受性」之討論。本章重心乃義務概括繼受之「法律保留原則」部分，本文欲探求以我國現行法規範為基礎，試以尋找公法上義務繼受之法規依據。雖法律保留的嚴謹度有不同之學理爭議，有認為必須以公法法規作為依據，另有認為不必以公法法規作為唯一，尚可以類推公法以外的法規範，然而本章節欲拋開學理見解之歧異，藉由第二章對於公法上與民法上義務之辨析、概念比較之結果，觀察我國現行概括繼受法規範，有無容納公法上義務之空間，以解釋出現行義務繼受的依據，供後續行政實務之解決。首先在此議題中，須說明法律保留原則之內涵，進而將本文欲探究之核心「概括繼受」，區分為「自然人死亡之概括繼受」、「法人合併之概括繼受」、「非法人團體之概括繼受依據」及「執行程序下之繼受」四種類型，於各個類型中一一探尋其有無繼受之依據，及學理與司法實務如何應用作為整理歸納，並試著提出自己的論證以及立法論建議，以建立完整的義務繼受之依據體系。最後，再就概括繼受之正當法律程序，嘗試提出於行政程序、行政爭訟及執行程序領域中，應賦予概括繼受人在不同的階段中何種正當法律程序，始能滿足義務概括繼受之「程序正當性」要求。

關於第四章部分，係本於前兩章探討建構我國法概括繼受之法體系之後，再著眼於我國行政法實務已發生之案例，藉由我國法規範及法理之角度，解決我國發生之概括繼受課題。對此，本文在此章欲提出一個我國法行政法之非金錢給付義務概括繼受爭議，以及兩個我國行政法之金錢給付義務概括繼受實例分別探討。首先就非金錢給付義務部分，以「土汙法中之整治義務之繼受」爭議為代表，其以大法官釋字第 714 號解釋之背景為主軸；另外就金錢給付義務之繼受部分，則以「不當得利返還義務」及「罰鍰義務繼受」為代表，關於不當得利返還義務繼受，以目前行政法院的判決作為代表；另外就罰鍰義務繼受部分則是以大法官釋字第 621 號解釋主軸作為討論。希冀透過本文第二到四章

doi:10.6342/NTU202000774

的討論，使公法上義務繼受制度的基礎面部分扎穩根基，體系化我國之公法上義務概括繼受根據，再本於此立證之結果檢驗我國法發生之實例，並加以檢討。

最後，以第五章作為本文之總結及個人見解之提出，以期建構以我國法為基礎之公法之義務概括繼受制度。

doi:10.6342/NTU202000774



doi:10.6342/NTU202000774



doi:10.6342/NTU202000774

第二章　行政法之義務繼受概念

第一節　行政法上義務「繼受」制度之內涵

第一項　行政法上「繼受」用語概念

所謂「繼受」，涉及法律關係的「主體變更」，係指原權利主體所受有之權利義務原封不動地移轉至另一權利主體。

在公法領域中，對於繼受概念的用語，並未有特別的敘述用語，目前學理對於繼受的概念，仍然是直接以「繼受」一詞作為描述。進一步「繼受」，還可分為「個別繼受」及「概括繼受」之子概念，以下就此兩者概念分析。

壹、個別繼受

個別繼受是指特定權利義務之移轉，原權利主體將其可處分之標的移轉於他權利主體[14]。在私法領域，因權利主體間均立於平等之地位，較不具有公益之考量，故私法上權利義務個別繼受之情事十分常見，例如：民法之買賣契約、債之移轉、贈與等等。然而在公法領域，集中於前述「行政法上義務」之思考，與私法領域有所不同。可想而知，個別繼受可能發生於人民受處分後，**義務未完成前，本於自己的意思移轉所課予該人民之義務之標的物於他人**[15]。

[14] 黃啟禎（2002），〈干涉行政法上責任人之探討〉，《當代公法新論（中），翁岳生教授七秩誕辰祝壽論文集》，頁 313，台北：元照。
[15] 黃啟禎（2002），〈干涉行政法上責任人之探討〉，《當代公法新論（中），翁岳生教授七秩誕辰祝壽論文集》，頁 314，台北：元照。

doi:10.6342/NTU202000774

雖此種公法上之義務並不因此限制受處分人行使私法上之權利，此種個別繼受行政法義務之情況，尚必須繼續探究受處分人原所負之責任性質為何，始得釐清是否產生個別繼受之效果。

貳、概括繼受

所謂概括繼受是指某一事由之發生，將產生被繼受人原所有之權利義務以同一、整體、概括地移轉於繼受人之效果[16]。通常是以下兩種事由，一種發生於自然人死亡時，依民法繼承編之第 1148 條作為自然人概括繼受之依據；另一種則是發生於法人合併時，以公司法第 75 條、第 319 條或企業併購法作為法人概括繼受之依據。在公法領域部分，只有極少數特別行政法規範提及，例如：老年農民福利津貼暫行條例條第 4 條[17]規定對於溢領老年農民福利津貼者，其本人或是「繼承人」負有返還責任，由此可知，立法者將溢領老年農民福利津貼而產生之不當得利返還義務，除了規範溢領的本人（被繼承人）應負返還責任，亦規定其繼承人須概括繼受其被繼承人之不當得利返還義務，而屬返還義務之主體，負返還津貼之義務。

參、小結

個別繼受係基於法律規定或是當事人的法律行為；概括繼受則是僅能基於法律規定而發生，最明顯的區別實益在於「繼受的原因是否來自於權利主體的

[16] 黃啟禎（2002），〈干涉行政法上責任人之探討〉，《當代公法新論（中），翁岳生教授七秩誕辰祝壽論文集》，頁 309，台北：元照。

[17] 老年農民福利津貼暫行條例條第 4 條第 7 項規定：「不符本條例資格而領取福利津貼者，其溢領之福利津貼應由本人或法定繼承人自事實發生之日起三十日內繳還；未繳還者，應依法追訴。」

doi:10.6342/NTU202000774

法律行為」[18]。針對個別繼受的情況，既然其發生的關鍵，多半源自於被繼受人與繼受人兩人間之「法律行為」，故個別繼受之繼受人，對於繼受的事實與法律效果應該具備預見可能性。然而，於概括繼受之情形，因發生原因來自於法律事實，就自然人部份，係以發生死亡之原因，繼受人對於繼受該權利義務並未有其意思介入，對於繼受人而言欠缺預見可能性，故公法上義務之概括繼受，本身即屬繼受人之權利干預，此時對其法律保留層面之討論顯得更加的重要，屬本文欲探究之核心。

惟較特殊的是，法人、非法人團體係因組織合併發生概括繼受，法人、非法人團體的代表或負責的自然人在合併之前，事前早已明瞭將承受被消滅法人之權利義務，其情況略不同於自然人死亡，故法人及非法人團體合併之概括繼受情形，法律保留的程度應不宜與自然人死亡之概括繼受相同程度較為合理。

第二項　其他法規範有關繼受之用語辨析

公法的繼受用語，學理上係直接以「繼受」一詞加以敘述，並可分為「概括繼受」、「個別繼受」兩者子概念，並直接作為用語。然而在其他法規範中，繼受的概念是以何種用語作為規範，亦可討論並與公法之概念相比較。

「繼受」概念在不同的法領域，有不同的名詞加以描述。在民法財產法中，這樣的概念，類似於民法第 294 條到第 306 條的「債之移轉」，此係指民法上之債之關係不變更其同一性情況，相當於公法領域中「個別繼受」的概念。又，進一步聚焦在民法上義務的債之移轉，通常會稱之為「債務承擔」，類型分

[18] 陳敏（2016），《行政法總論》，9 版，頁 295，台北：新學林。

doi:10.6342/NTU202000774

別有民法第 300 條[19]之併存的債務承擔及第 301 條[20]之免責之債務承擔，債務承擔係起因於債權人或是債務人對第三人作成一法律行為，使特定的債權債務關係，其債務人地位移轉由該第三人承擔債務，概念乃民法財產法上「債務（義務）」的個別繼受，在民法第 300、301 條，係以債之「承擔」加以描述。

在身分法中，繼承編民法第 1148 條第 1 項[21]中，該條對於自然人因死亡所發生概括繼受情況，係以「承受」一動詞，描述被繼承人概括繼受財產上之一切權利、義務的動態。表示概括繼受之名詞，從民法「繼承」編的名稱，亦可得知「繼承」係在表示身分法之概括繼受權利義務之名詞，並且僅「自然人死亡」作為概括繼受原因之表示。由此可知私法領域中，自然人之概括繼受，是以「承受」一詞加以表現其概括繼受之動作；而以「繼承」作為名詞描述。並且在概括繼受主體描述部分，也是「繼承人」及「被繼承人」來加以敘述。

在公司法中，針對公司合併的情事，依公司法第 75 條[22]，規定其權利義務，應由合併後存續或另立之公司「承受」。公司發生概括繼受之情況，公司法與民法繼承編的用語相同，皆是以「承受」一詞加以形容。

承上所述，公法領域對於繼受概念的用語，並未發展有如民法財產法、身分法、公司法有其法規範的特殊用語來描述，並且將其明文之。對於欠缺其特定的描述用語的情況，原因可能來自於公法領域欠缺關於繼受制度的一般性規定，導致學理上直接以「繼受」、「概括繼受」、「個別繼受」之詞加以敘述、說

[19] 民法第 300 條：「第三人與債權人訂立契約承擔債務人之債務者，其債務於契約成立時，移轉於該第三人」。
[20] 民法第 301 條：「第三人與債務人訂立契約承擔其債務者，非經債權人承認，對於債權人不生效力」。
[21] 民法第 1148 條第 1 項：「繼承人自繼承開始時，除本法另有規定外，承受被繼承人財產上之一切權利、義務。但權利、義務專屬於被繼承人本身者，不在此限」。
[22] 公司法第 75 條：「因合併而消滅之公司，其權利義務，應由合併後存續或另立之公司承受」。

doi:10.6342/NTU202000774

明。



第三項　概括繼受於公法領域中之適用

在早期，公法領域內並無概括繼受的概念及制度存在，其原因在於早期學者對於課予公法上之義務之行政處分，乃視為處分機關與相對人間的特殊規範關係，故認為公法上之義務具有高度屬人性，除涉及財產權之法律關係外，原則上公法上之義務均不具有可移轉及繼受之能力[23]。

然現今學理及實務則肯定行政法上義務有概括繼受之適用，摒棄早期認為除了財產權之法律關係外，公法上義務均為高度屬人性之看法。進一步探究概括繼受制度，所謂「繼受」之意義，乃一項權利或義務在法律上脫離原有之權利人或義務人，改由第三人享有或負擔，以該不具備義務第三人為權利人或義務人[24]。故概念邏輯上，義務之轉出之主體與繼受義務之主體兩者間須是「非同一性」，若繼受人若「取代」前手之義務地位，成為「新的」義務人，則非屬繼受之概念，繼受人所繼受之義務內容及標的，必須與前手之義務內容與標的兩者間具有同一性，綜上可知，繼受之概念應掌握「主體不同一性」、「義務（標的）同一性」特徵[25]。

由於繼受本身即是以「權利主體變動」作為前提要件，繼受人所負擔之義務係來自於前手原本應負擔之義務，繼受人繼受該權利義務即是因前手具有該

---

[23] 李建良（2006），（行政法上義務繼受問題初探－兼評高雄高等行政法院九十二年度訴字第八○六號判決暨最高行政法院九十四年度判字第六二二號判決），《2005 行政管制與行政爭訟》，頁 79-80，台北：中央研究院法律學研究所籌備處。

[24] 陳敏（2009），〈人民公法上權利義務之繼受〉，《政治思潮與國家法學：吳庚教授七秩華誕祝壽論文集》，頁 461，台北：元照。

[25] 李建良（2006），（行政法上義務繼受問題初探－兼評高雄高等行政法院九十二年度訴字第八○六號判決暨最高行政法院九十四年度判字第六二二號判決），《2005 行政管制與行政爭訟》，頁 85，台北：中央研究院法律學研究所籌備處。

doi:10.6342/NTU202000774

相對應之義務而派生而出。換言之，義務繼受乃義務客體持續存在下，義務主體發生變更、替換之情形。



第四項　公法上概括繼受之目的

思考「繼受」制度於法秩序存在之理由及其正當性，原則上權利與義務之於人而言，應以人存續時始展現其權利與義務之存在，何種考量下會使自然人死亡或是法人因合併消滅時，由其繼承人或是合併後法人加以承繼權利及義務，乃是討論繼受制度前不可或缺之思考。

先試著以私法領域角度思考，私法上的權利及義務移轉至繼承人，對內關係上，乃著重財產儲蓄功能發揮及自然人繼承人之生存照顧；對外關係上，則係為了追求法律關係之安定、債權人之保障及社會交易安全，使生前或合併前的債權與債務不因當事人的死亡或是合併而遭受影響[26]。然而，避免此種法律關係的承繼、延續將過度的侵害其他權利主體之權利，「法安定性及交易安全保護」及「保障債權人」之原則並非無限上綱，法規範仍設有相當之界線，例如：民法第 1148 條第 2 項[27]針對自然人之繼承，明文採「概括繼承有限責任」之原則，也即繼承人就其所繼承債務，所負之責任以繼承財產為限，不致使繼承人以自己固有財產清償被繼承人所負債務。國家針對私法領域之繼承制度考量目的，係站在中立者之立場，將私法關係中當事人受有債權利益、法安定性之保障與繼承人受有基本權利規制之間加以衡平考量，以實踐憲法對人民賦有基本權保護義務之功能。

[26] 黃宗樂、郭振恭、陳棋炎（2014），《民法繼承新論》，9 版，頁 4-6，台北：三民。
[27] 民法第 1148 條第 2 項：「繼承人對於被繼承人之債務，以因繼承所得遺產為限，負清償責任」。

doi:10.6342/NTU202000774

另著眼於公法領域之角度思考，公法領域之「繼承制度」目的何在，考量之出發點與私法領域應非完全相同，本文所聚焦之繼承乃「人民對於國家所負之義務」，勢必應以國家之行政權課予人民義務之目的出發。國家課予人民義務多半來自於「秩序行政」之規制，而秩序行政之重要任務在於維護社會秩序及公共安全，行政機關對有影響社會秩序或是對社會造成危害者，可以由行政機關自己抑或是委託第三人排除該危害或是加以防止之，抑或是在法有明文授權下，行政機關尚可本於法規範依據加以對負有行政法上責任之人課予其危害防止、排除之義務，是以在國家安全與秩序之運作上，行政機關與人民皆負有對於其所生活、生存之社會負有共同維護秩序、使之永續經營[28]。當人民死亡時，如其應所負之義務將因欠缺權利主體負擔而消滅，可想像的是，所有因死亡或是其他權利主體消滅之事由發生，都將使原本背負著秩序行政目的之義務呈現「無人履行之狀態」，則社會秩序的妨礙及已發生之危害卻依舊存在，一旦時間經過，將導致該妨礙及危害有不斷擴大、惡化之可能，且無人履行的義務亦將累積越來越多，此種後果絕非國家及人民之福。另一方面，公法上義務亦可能不帶有秩序行政之色彩，例如：公法上不當得利返還義務，本身義務的發生與社會秩序的危害產生與否較無涉，其定位並非屬典型的秩序行政，此種義務亦可能具有可繼受性，其得以概括繼受之目的，應是考量即使義務未達成，雖不至於構成對社會秩序的危害擴大，但仍對公益的維護及圓滑履行有所減損，基於此目的，非涉及秩序行政的義務，亦有概括繼受的正當目的存在。

承上所述，國家就此情況之發生，勢必應建立一套「概括繼受」制度加以處理，此套「概括繼受」制度可得而知係為追求兩個目的及原則，一個是國家徹底實踐公法上義務之目的，以避免造成社會秩序維護之漏洞，並加強公益之

[28] 李建良（2006），（行政法上義務繼受問題初探－兼評高雄高等行政法院九十二年度訴字第八○六號判決暨最高行政法院九十四年度判字第六二二號判決），《2005 行政管制與行政爭訟》，頁 80-81，台北：中央研究院法律學研究所籌備處。

doi:10.6342/NTU202000774

維護；另一則是對義務繼受人其權利的干預、侵害必須通過憲法第 23 條所揭示之比例原則等法治國原則而「不得過度」侵害之誡命。此兩者目的之追求猶如光譜之兩端，應如何將此兩者拉扯、衡量，使之調整至最適當、合理及符合憲法之要求，為本文以下討論之實益所在。

第五項　義務概括繼受涉及之憲法課題

在理解繼受制度概念及存在之目的後，思考繼受制度如何建立、規劃其要件以前，必須先對「概括繼受」此一法律概念拉高至憲法層次加以俯視。蓋任何法律制度皆須釐清其涉及憲法基本權利之廣度以及干預、侵害之深度，始能論證出合於該法律制度之比例原則，進而建立合於憲法規範之義務繼受要件。

討論義務概括繼受所涉及之基本權利，由於「繼受」本身是指「同一義務變動於不同義務主體」之法律概念，對於繼受人而言，受到影響之關鍵可分為以下兩部分：其一，為具備繼承適格之合理性（「是否」應繼承）；其二，「義務」賦予繼受人的規制是否過當而須調整（具備繼承之適格，但要「如何」繼承）。有關繼承有無之部分，其根本之核心在於「繼承制度本身存在的正當性」，需對此加以討論。確認繼承制度存在於憲法下之定位，接著對於繼承人受移轉之「義務」本身，對繼承人而言所造成之限制，應進一步以憲法角度具體探究，以比例原則加以思考。

壹、「繼承制度」於憲法上之定位

一、「繼承」係本於財產權保障之意旨因應而生之制度

doi:10.6342/NTU202000774

探究繼承制度的由來及緣起，最早繼承的意義，是由封建時代開始，由於當時所著重者乃宗教祭祀及祖先之靈魂信仰作為社會之核心，故繼承最早的意義是以「身分上之延續確認」作為繼承之核心內涵；然而，近代意義之繼承，來自於封建社會的崩潰之後，現代國家所建立起「私有財產制度之保障」之概念，成為繼承制度不可或缺之要件，其兩者緊密的程度，可形容為無私有財產制即無私有財產繼承，故近代法秩序所確立的個人自主意思之尊重與憲法財產權的保障，使繼承制度的內涵，跳脫過去身份確認及祭祀之色彩，質言之，現代法下「繼承」意義，毋寧是以財產權之保障作為核心，乃私有財產權上之制度實踐之一環[29]。

由此可知，繼承制度現代的意義以「憲法之財產權保障」作為基礎，財產權是一種制度性保障之基本權利，對於人民財產權之實踐不只是要求國家放任不去干涉，國家尚負有形成一定之制度之義務，藉由這些制度之運作使財產權受到保障[30]。然而尋找我國法體系，繼承制度在我國憲法上尚無明文保障之基礎，而不若德國基本法第 14 條[31]對於繼承制度肯認具備憲法上之權利地位；續而探究釋憲實務見解，其中大法官釋字第 437 號解釋理由書乃唯一對於「繼承制度」有論述者，其指出「遺產繼承制度，旨在使與被繼承人具有特定身分關係之人，於被繼承人死亡之後，因身分而取得被繼承之財產，藉以保障繼承人之權利」，從解釋文之意旨似可推論，大法官肯認繼承制度涉及財產權之保障，然卻未進一步剖析繼承制度之內涵及具體之態樣加以析論，但並不代表我國之繼承制度不涉及任何基本權利之保障亦或是干涉，而是繼承制度的具體設計必須仰賴立法機關之形成，然而此種制度並非落於立法形成自由，而是立法

[29] 林秀雄（2017），《繼承法講義》，7 版，頁 1-2，台北：元照；黃宗樂、郭振恭、陳棋炎（2014），《民法繼承新論》，9 版，頁 1-2，台北：三民。
[30] 李惠宗（2015），《憲法要義》，7 版，頁 289，台北：元照。
[31] 德國基本法第 14 條第 1 項：「財產權及繼承權應予保障，其內容與限制由法院規定之」，轉引自司法院大法官書記處（2014），《德國聯邦憲法法院裁判選輯（十五）》，頁 337，台北：司法院。

doi:10.6342/NTU202000774

者所設計出之具體繼承制度仍須受到憲法秩序下之拘束，方為正當[32]。

然而尚須注意者，繼承制度係由「財產權」所導出，其保障財產權之繼承制度，所指涉之內涵具體為何，制憲者並未明確指示，似乎是將繼承制度的具體保障內涵交由立法者加以形塑。試著觀察立法者所制定之民法第 1148 條第 1 項，繼承的標的係包含被繼承人之「權利」及「義務」，由此可知財產權之繼承制度的具體內涵，不只是包含權利，尚包含被繼承人所負有之義務，均屬於財產權的保護範圍。

二、「遺產」的定位

遺產的定位之釐清，將涉及金錢給付義務的繼受範圍之認定。在法制層面上，偏重社會主義者則將傾向遺產乃屬於國家，在例外符合法律規定下使得由特定人繼承財產；亦有偏重於對人民財產權保障者，則傾向於人民之遺產原則分配予法定繼承人、受遺囑人，例外始由國家取得被繼承人之財產。我國現行民法之繼承制度屬後者，將死者之財產納入「財產權之保護」作為我國遺產制度的核心思想。進一步，對於遺產的概念、歸屬及定位，須分析我國法之繼承制度加以釐清，始能就其後探討金錢給付義務之繼受、執行部分，正確思考之。

遺產本身屬「權利客體」，權利客體必須有「權利主體」加以依附使得存續之[33]。遺產轉換所有權之權利主體地位之時點為何，從我國民法第 1147 條[34]、

[32] 蔡靜娟（2009），《行政法上義務人死亡義務繼受之研究》，國立中正大學法律學研究所碩士論文，頁 37。
[33] 蔡宗珍（2008），〈公法上無主義務之強制執行?〉，《中研院法學期刊》，2 期，頁 295。
[34] 民法第 1147 條：「繼承，因被繼承人死亡而開始」。

doi:10.6342/NTU202000774

第 1148 條[35]中之規定可以探知，上開條文乃規定被繼承人「死亡時」開始繼承，而繼承人於「繼承開始時」，承受被繼承人之權利義務，除非是專屬於被繼承人本身者。是以，從民法繼承編的規定可知，遺產的歸屬主體由被繼承人轉換於繼承人，係以**「被繼承人死亡時那一刻」**作為轉換之時點，所以被繼承人發生死亡事實前，該等財產屬被繼承人所有，但在被繼承人一發生死亡事實後，該等財產則屬繼承人所有之遺產。且被繼承人之財產概括移轉至繼承人之原因，並非來自於被繼承人與繼承人之法律行為，而是來自於法律（民法第 1147、1148 條）的規定，又在民法第 759 條[36]的規定下，繼承人在被繼承人死亡的瞬間受有遺產所有權的概括移轉，若被繼承人欲進一步對該遺產加以「處分」，尚必須辦理繼承登記，始得為之。

繼承人所取得之遺產，與繼承人自己固有財產，兩者均屬繼承人之所有財產無誤，唯一的差異乃「取得之來源」不同而已。故繼承人在發生繼承開始之事實時，所概括取得之遺產即是繼承人所有，即便該遺產源自於被繼承人，亦無法認為該遺產屬「被繼承人權利義務的延續」或是「被繼承人人格之延續」[37]。蓋法律關係中之所有權因繼承而概括取得，乃繼受取得所有權之態樣之一，繼受取得之法律關係乃具備所有權人之前手、後手存在，當前手所有之標的物，因法律行為或法律規範而移轉所有權於後手，前手即與標的物之法律關係即中斷，原則上後手對於該物之法律關係不受到前手之影響。

綜上所述，當被繼承人死亡事實發生時，其所有之財產（排除對被繼承人具有一身專屬性的權利義務）所有權之歸屬將瞬間移轉至繼承人所有，國家若

35 民法第 1148 條：「繼承人自繼承開始時，除本法另有規定外，承受被繼承人財產上之一切權利、義務（第一項）但權利、義務專屬於被繼承人本身者，不在此限。繼承人對於被繼承人之債務，以因繼承所得遺產為限，負清償責任（第二項）」。

36 民法第 759 條：「因**繼承**、強制執行、徵收、法院之判決或其他非因法律行為，於登記前已取得不動產物權者，應經登記，始得處分其物權」。

37 蔡宗珍（2008），〈公法上無主義務之強制執行?〉，《中研院法學期刊》，2 期，頁 296。

doi:10.6342/NTU202000774

欲對繼承人所有之遺產加以主張、執行，前提必須是繼承人已受有被繼承人公法上可繼受義務之移轉，始存在對繼承人所有之遺產加以執行之正當性，否則繼承人未受有任何公法上義務繼受之情況下，對於繼承人所有之遺產加以主張、執行，無疑對於未負有公法上任何義務之繼承人，就其所有之遺產（財產）課與為「他人義務」履行之負擔，將使繼承人蒙受財產減損或至剝奪的侵害，此種財產權侵害對於繼承人而言已達到特別犧牲之程度，國家是否能如此加以干預，勢必須有更堅強之說理始具備特別犧牲正當性，若無法具備特別犧牲合憲性檢驗之正當性，則不應以繼承人所有之遺產對他人之義務負責[38]。

三、繼承制度賦予繼受客體可繼受性之正當性考量

進一步探究繼受制度之內涵，繼承制度之被繼承之客體，有權利、義務、佔有之利益及被繼承人之遺體此四大類[39]。著眼於「法律關係」之繼承，應以「權利」及「義務」兩者為探究重點，其中繼承制度在「權利」繼受表現的層面上，充分展現了憲法對於財產權保障，使確保各類得自我負責的私有財產，不因死亡而消逝，藉由繼承制度加以延續其私有財產存續保障之功能，對於其所表現者乃相當於對人民財產權之制度性保障；然而繼承制度在「義務」繼受的表現層面上，則可認為係為追求基本權最佳化之實現，立法者得以在合乎繼承制度內涵下加以形塑義務的內涵，將義務授予其可繼受性之地位，進而即使義務主體死亡，也不因原義務主體之死亡造成義務履行之終止，尚可藉由繼承制度的運作，使義務得以「較高度之價值方式」加以發揮（使繼承人承接該義務而繼續履行之，此義務圓滿達成被履行之結果）[40]。

---

[38] 蔡宗珍（2008），〈公法上無主義務之強制執行?〉，《中研院法學期刊》，2 期，頁 296。
[39] 林秀雄（2017），《繼承法講義》，7 版，頁 80-81，台北：元照。
[40] 蔡靜娟（2009），《行政法上義務人死亡義務繼受之研究》，國立中正大學法律學研究所碩士論文，頁 37。

doi:10.6342/NTU202000774

四、賦予概括繼承客體具有可繼受性之憲法上利益權衡判斷

有關繼受制度對於其繼受客體「是否具備可繼受性（繼受能力）」之思考層次，借鏡德國基本法第 14 條[41]有關繼承權之文義解釋，權利與義務以具備可繼受性為原則，若否定其可繼受性，則需有「正當性之例外情況」，然而上述思考脈絡置於「權利」繼受之思考較為合理；反之，「義務之繼受」若與權利之繼受為相同脈絡思考似不恰當，原因在於義務與權利乃明顯相對之概念，義務的繼受無非對於人民為權利之干預，因此「義務繼受」與「權利繼受」需分別判斷較為合理，站在義務所具備的特徵，應以「不具備可繼受性」作為原則，在例外情形始可具備可繼受性較妥當，檢驗該是否具備該例外情況，以「公益目的」存在作為前提，且此種公益目的之存在，必須以建立通過合憲性事由檢驗之法律制度作為前提[42]。

因此「義務是否能加以繼受」之憲法正當性，應要考量的是，是否有比「義務高度發揮（繼續存續於繼承人）」以外，另有公益等「更高位階的利益或理由」存在，此利益或是理由之存在，將促使立法者具備放棄對於某義務設定具可繼受性之憲法上正當性，始得就該義務認定為欠缺可繼受性。

五、小結

藉由以上之分析，將繼承制度以「公法領域之義務繼受」置於重心，考量

[41] 德國基本法第 14 條第 1 項：「財產權及繼承權應予保障，其內容與限制由法院規定之」，轉引自司法院大法官書記處（2014），《德國聯邦憲法法院裁判選輯（十五）》，頁 337，台北：司法院。

[42] 蔡靜娟（2009），《行政法上義務人死亡義務繼受之研究》，國立中正大學法律學研究所碩士論文，頁 37-38。

doi:10.6342/NTU202000774

義務在繼承制度的運作，將使其履行切合目的而臻至完美，於私法領域有助於實現社會交易安全；於公法領域則使國家追求公益之目的不因而停滯。又，義務在繼受制度運作下對於繼承人而言乃不折不扣之權利限制，思考其是否成為繼承客體而具有可繼受性時，應較從嚴判斷，原則應不具有繼受性、例外具可繼受性作為標準。該義務是否成為「例外」的判斷，應該衡酌具體個案，是否有比繼受義務所能得到之高價值發揮，具有更重要的更高利益、位階之公益考量。

貳、「概括繼受」義務之基本權利干預探究

釐清繼承制度在憲法上存在之正當及判斷之利益權衡後，進一步對於人民對國家之義務之繼承情形，其所涉及之基本權利限制的探究，以較頻繁發生之作為義務中其**金錢給付義務及非金錢給付義務，作為本文概括繼承所干預基本權利之研究核心**，其乃涉及財產權、一般行為自由及生存權之規制，以下繼續詳述之。

一、財產權

（一）財產權概念及性質

我國財產權保障之依據來自於憲法第 15 條[43]，所謂財產權涉及人民社會經濟生活之基礎，古典的財產權觀念乃以物之所有權作為核心標的，在時代的變遷下，財產權之標的擴大包括債權領域及無體財產權領域；財產權之性質屬制

[43] 憲法第 15 條：「人民之生存權、工作權及財產權，應予保障」。

doi:10.6342/NTU202000774

度性保障之權利，目的在於使個人得以形成自我負責之生活，是以國家對於財產權之保障不只要求不去干涉，尚有對財產權以法律形成具體制度之義務存在[44]。

財產權之保護範圍最原始是對「物的所有權之存續狀態」為保護，近代對此則是強調財產權的防禦性功能，係著重於財產權之「存續狀態」保障，在我國釋憲實務[45]上，對於存續保障之標的除了最傳統的物之所有權以外，尚包括所有權之權限、債法上之請求及無體財產權，若公法上之債權若依法律規定已形成具體權利者則亦屬財產權保障之範圍；又，財產權之保障另外還包括對於「具有經濟上財產價值之權利」[46]，亦謂財產權之「價值保障」，其來自於私法上所有權所衍生出的經濟利益[47]。

（二） 財產權之限制與比例原則

財產權在過去十八世紀市民法治國時代乃認為絕對神聖不可侵犯，然而現今對於資本主義之反思及共產主義的反動下，對於財產權之保障則不若過去認為乃絕對性，國家基於公共利益對財產權之行使所課予之義務，若為合理而不致過重，則為憲法之所允許且不需應給予補償，蓋財產權在現代意義的概念下，具有「社會義務性」，是以國家可以透過限制私人財產權之手段達到對整體社會的和諧目的[48]。

---

[44] 李惠宗（2015），《憲法要義》，7 版，頁 289，台北：元照。
[45] 大法官釋字第 400、374、216、304、370、492、213、292、335、606、596、658 號解釋意旨。
[46] 例如：大法官釋字第 414 號解釋中認為藥物廣告乃對於獲得財產所從事之經濟活動係涉及財產權之保障。
[47] 李惠宗（2015），《憲法要義》，7 版，頁 290-291，台北：元照。
[48] 李惠宗（2015），《憲法要義》，7 版，頁 295-296，台北：元照。

doi:10.6342/NTU202000774

所謂財產權受有「社會義務性」之拘束，其根據學理可從我國憲法的 22 條[49]加以導出，因財產權之行使不得妨害社會秩序與公共利益，乃具有社會義務性，且在釋憲實務上，大法官釋字第 577 號解釋文及解釋理由書中，均有提及肯認財產權可能在社會義務性拘束下而受有合憲性之限制。又，財產權之內容雖交由立法者形成，但其內容所課予之「社會義務性拘束」是否妥當，仍須藉由憲法第 23 條所揭示比例原則加以審查之。

二、一般行為自由

（一）一般行為自由概念

一般行為自由之基本權利並非我國憲法列舉之基本權利，而是由釋憲實務提出之概括基本權利之一（憲法第 22 條[50]）。所謂概括基本權利，學理上有稱之為「憲法直接保障主義」，也及對於憲法保障所有自由權利，只要符合憲法第 22 條要件者，該自由即受憲法保障，其要件乃是該自由符合社會秩序及公共利益者，是以概括基本權利具有對於列舉基本權利尚具有「補遺」的功能，使憲法之保障更加全面[51]。

在釋憲實務上，大法官釋字第 689 號解釋理由書曾對一般行為自由定義加以論述，大法官認為，基於人性尊嚴之理念，個人主體性及人格之自由發展，應受憲法保障，為維護個人主體性及人格自由發展，除憲法已保障之各項自由外，於不妨害社會秩序公共利益之前提下，人民依其意志作為或不作為之「一

[49] 憲法第 22 條：「凡人民之其他自由及權利，不妨害社會秩序公共利益者，均受憲法之保障」。
[50] 憲法第 22 條：「凡人民之其他自由及權利，不妨害社會秩序公共利益者，均受憲法之保障」。
[51] 李惠宗（2015），《憲法要義》，7 版，頁 394-396，台北：元照。

doi:10.6342/NTU202000774

般行為自由」，亦受憲法第 22 條所保障。人民隨時任意前往他方或停留一定處所之行動自由，自在一般行為自由保障範圍之內。

上述大法官所闡釋之見解是以「人民隨時任意前往他方或停留一定處所之行動自由」作為一般行為自由內涵之理解，然而此項內涵之理解乃參考德國法學理及實務見解對於「身體移動自由」之定義，此種身體移動自由是來自於德國基本法上對於「人身自由」，其相當於我國憲法第 8 條之人身自由之概念，故學理認為大法官混淆「一般行為自由」與「人身自由」兩者之內涵，本於概念的正確釐清，應將一般行為自由正確定義為「做或不做某事之自由，且非以身體移動為必要」，可容納更多態樣之行為且較正確理解一般行為自由之內涵，本文從之[52]。

（二）一般行為自由之限制與比例原則

對於一般行為自由之限制，必須考量該行為對於人民其自我實現、人格尊嚴及人格發展所涉及的程度多寡，及課予其做不做某事之自由加以限制之目的，衡平考量限制其一般行為自由之比例原則拿捏。

三、概括繼受公法上義務將涉及對繼承人之限制

（一）繼受公法上義務將干預繼承人之財產權、一般行為自由

具體關注人民因概括繼承制度的運作下所背負之公法上義務之情況，就繼

[52] 李建良（2013），〈拒絕酒測與吊銷駕照的合理關聯與正當程序－釋字第 699 號解釋〉，《台灣法學雜誌》，235 期，頁 34-35。

doi:10.6342/NTU202000774

受公法上之「金錢給付義務」部分，被繼承人在私有財產制度下，死亡後其財產尚不因喪失所有，而是透過繼承制度，使被繼承人之財產得存續於具有繼承權之人，使繼承人取得財產之所有權，增加繼承人之財富。然而被繼承人在生前所負擔公法上金錢給付義務，透過繼承制度使繼承人背負時，無疑係對原非義務主體地位之繼承人，要求其承繼該地位而負對國家繳納金錢之義務，繼承人在此將受到必須以自己之財產（可能包括繼承所得財產及自己固有財產）減少之規制，完成他人（被繼承人）義務之履行。站在憲法財產權角度之觀察，被繼承人無疑受有財產權之限制。

另外，就人民繼受「公法上非金錢給付義務」的情況，則是使繼承人繼受其被繼承人未履行之義務，對於繼承人而言，在不具備責任歸責主體地位，卻因繼承制度的運作，而負有非金錢給付之規制，也即繼承人在此情況中乃受有「做或是不做某事自由之限制」而受有「一般行為自由」之概括基本權利干涉無誤。

（二）比例原則於繼受公法上義務之思考

1. 正當性公益目的追求

考量公法上義務繼受之合憲性之審查思考下，就繼受義務的正當性目的，可知藉由繼承人概括繼受義務，使國家之金錢債權及非金錢債權加獲得滿足，達到國家對於社會秩序之永續維護，不因義務人之死亡脫免其所應負之責任。又依前所述可知，公法的義務履行不單單是對於個人，尚有可能對於整個社會制度、環境加以影響，故行政法上義務得因「概括繼受」而加以履行，將對國家整體法秩序更周全的維護。

doi:10.6342/NTU202000774

2. 手段之適當性原則審查

著眼於「概括繼受」義務之手段，首先在比例原則「適當性」原則之審查，必須檢視繼承人對於該繼受之金錢給付義務之繳納，或是非金錢義務之履行，是否有助於上開個別具體義務目的之達成，其關鍵在於判斷該義務是否具備「一身專屬性」。換言之，該繼承人繼承而負擔履行該義務，是否亦能達到其規制義務之目的，蓋國家課予人民金錢給付義務、非金錢給付義務之目的本身不完全都是為整體法秩序之維護，尚有可能針對於個人心理產生壓力或生理產生某些影響作為規制的目的。例如行政執行之間接強制中「怠金」[53]之課予，該等義務是著重於賦予義務人心理之壓力，迫使該義務人若繼續不履行不作為義務或是不可替義務下，將會繼續受到剝奪其所有之金錢痛苦；又例如「強制接種疫苗」或行政執行法第 36 條第 2 項[54]中「對人的管束」之即時強制方法，則是對著重對於人之身體加以影響之義務規範，此種義務很明顯地必須是對於原義務人自己履行該義務，始能達到該義務所欲發揮之目的、效果，若將該義務主體轉換於繼承人，即便該繼承人履行，亦無法有助達成該義務欲追求之效果，將喪失其意義，例如在怠金之間接執行，行政機關既係欲以金錢的剝奪迫使該義務人受到心理痛苦的壓制、壓迫，若該怠金交由其繼承人履行繳納，受到金錢剝奪痛苦之人已非原義務人，怠金的作用目的亦將消失。當有此種情形之發生，則意味者被繼承人之義務具有「一身專屬性」之特徵，此種具有一身專屬性之義務，既然透過繼承人加以實踐仍無法完成該義務目的，若課予繼承概括繼受義務，則欠缺憲法第 23 條所揭示比例原則之「適當性」要求。職是之

[53] 行政執行法第 30 條：「依法令或本於法令之行政處分，負有行為義務而不為，其行為不能由他人代為履行者，依其情節輕重處新臺幣五千元以上三十萬元以下怠金。依法令或本於法令之行政處分，負有不行為義務而為之者，亦同」。

[54] 行政執行法第 36 條第 2 項：「即時強制方法如下：一、對於人之管束。二、對於物之扣留、使用、處置或限制其使用。三、對於住宅、建築物或其他處所之進入。四、其他依法定職權所為之必要處置」。

doi:10.6342/NTU202000774

故，在反面解釋下，只有「不具有一身專屬性」的公法義務，在面對繼受而義務主體轉換時，不因而受到影響，仍舊能透過不同主體之履行，達成原本義務標的內容所欲達成目的，得以通過適當性原則之考驗。

3. 手段之必要性原則審查

再者，對於必要性（最小侵害性）此要件之審查，繼承人繼受公法上義務對於社會秩序之整體維護，是否已屬最小侵害之手段，尚無其他較輕微侵害方式而可同樣達成該公益之維護。此處的重點在於判斷繼承人所承受者是否過當，賦予繼承人義務係應「原封不動」，抑或是調整至繼承人可合理負擔義務之內容，例如：民法繼承編第 1148 條第 2 項[55]及第 1153 條，在 2009 年修法以後，全面對繼承人所負擔之債務採「概括繼承有限責任」，可知民法對於繼承人概括繼受私法之財產上義務，乃限縮於繼承人「所繼承之遺產」為限始負清償責任，使繼承人無需以自己的固有財產向債權人負責之，此種原則充分展現「必要性原則」。蓋被繼承人生前所負之債務，在尚未死亡時，被繼承人對於其債務履行之程度頂多以其所有之財產加以清償，則債權獲得滿足之程度，應不因債務人（被繼承人）之死亡與否而有所改變。也就是說，債權人之債權能加以清償及能清償之程度，即是繼承人繼承該債權之目的，繼承人對於該繼受的債務加以清償以其所繼承之遺產即為已足，若尚需繼承人以自己固有之財產一併清償所有之債務，即便可得到債權人受清償之目的，但卻使債權人受領高於原本可受清償之額度，係已過度侵害繼承人之財產權，無法通過必要性原則檢驗。

[55] 民法第 1148 條：「繼承人自繼承開始時，除本法另有規定外，承受被繼承人財產上之一切權利、義務。但權利、義務專屬於被繼承人本身者，不在此限。繼承人對於被繼承人之債務，以因繼承所得遺產為限，負清償責任。」；民法第 1153 條：「繼承人對於被繼承人之債務，以因繼承所得遺產為限，負連帶責任。 繼承人相互間對於被繼承人之債務，除法律另有規定或另有約定外，按其應繼分比例負擔之」。

doi:10.6342/NTU202000774

對於必要性原則之思考，民法第 1148、1153 條所設定之「概括繼受有限責任」原則，在私法上義務與公法上義務之兩個法領域概括繼受，應無差異之考量，應可借鏡該原則，考量公法上義務概括繼受之適用。就公法上金錢給付義務繼受之場合，繼承人對於被繼承人所積欠對國家之非一身專屬性金錢債務，應以繼承人其所繼承之遺產範圍為限，承受對於國家之金錢債務。仔細觀之，有限責任之繼承，對於國家法秩序之維護目的達成並無減損，因被繼承人生前得以負責之公法上債務數額僅得以其所有財產作為清償之最大數額，繼承人只以承繼之遺產範圍內負責，而排除繼承人本身固有財產部分，對於繼承人之財產權限制手段上並未過當。

另外在公法上非金錢給付義務部分，則須思考繼承人對於繼受無一身專屬性之非金錢給付義務，對於其「一般行為自由」之限制是否有過當之嫌，在必要性原則下之思考，是否繼承人繼承該義務將難以履行而過當限制繼承之一般行為自由，而具體義務是否需調整，尚需仰賴主管機關視個案具體情況加以判斷是否應調整之。

4. 手段之衡量性原則審查

最後就概括繼受義務之衡量性，須判斷給予繼承人義務繼受之之目的——國家法秩序之完整維護，與繼承人所受有財產權、一般行為自由之干涉、限制兩者間相互衡量，是否相較於對繼承人所造成之損害，乃輕微於國家秩序之整體維護目的之利益，避免追求維護國家秩序維護及社會安定之利益下，卻與概括繼受制度間輕重失衡。

doi:10.6342/NTU202000774

四、法律保留原則於公法上概括義務繼受之思考

透過上開分析，概括繼受公法上義務於憲法層次之比例原則思考，無疑是對於繼承人之財產權抑或是一般行為自由之限制、侵害，然除了繼受制度的運作實質須通過比例原則之審查，尚必須通過「法律保留原則」之要求，以達到符合形式正當性之要求使人民得以預見。

有關公法上義務繼受之法律保留原則之適用及實定法上內容，涉及我國學理對於公法上義務概括繼受之法律保留寬嚴之爭議，而該爭議之整理及爬梳，將於本文其後第三章、第一節、第三項「概括繼受義務之法律依據」，加以詳述之。

第二節　行政法之「義務」內涵

第一項　行政法義務的概念與種類

壹、義務的基本定義及概念

所謂課予人民之「義務」，法律概念的起始係來自於西元 1795 年的法蘭西（France）憲法，其後各國均相沿仿效，我國亦於西元 1947 年正式將人民的義務首規定於憲法之中，「義務」是指法律對於特定人所規定的應作為，或是不作為之限制[56]。在私法領域中，權利與法律時常並舉，義務時常與權利作為對應存在者，其應可瞭解為：義務為一種規範面上之拘束力，拘束義務人為一定行

[56] 劉作揖（2014），《法學緒論》，12 版，頁 133，台北：三民。

doi:10.6342/NTU202000774

為或不行為[57]。

義務在思考上，不同於權利的思考，蓋「權利」所指幾乎是法律上之權利，然而義務卻可能分為法律上的義務及非法律上之義務，因義務乃具有規範上之拘束力，此「規範」可能來自於法律，亦有可能來自於道德[58]。另有認為所謂的義務，必須是源自於法律所課予者，始可稱之為義務，與道德、宗教上之拘束不同[59]。以下僅就「法律」拘束之義務之概念繼續討論之。

義務的範圍十分廣泛，在私法之財產法領域，通常所指者乃當事人負有提出給付之債務，然而在公法領域中所指義務，可分為國家對人民之義務，或是人民對國家之義務，本文所聚焦者乃後者「人民對國家之義務」，係國家本於法規範所課予人民之特定作為、不作為拘束之概念，所有制裁性之規範均表達了某種義務之存在，然而違反義務並不一定具有受到制裁之後果[60]。

簡而言之，義務的內涵具備「規範性」與「強制性」兩個要素，可定義為：對一定條件之人，其行為必須符合特定內容之法效性要求[61]。

貳、行政法上義務概念與種類

[57] 李太正、王海南、法治斌、陳連順、黃源盛、顏厥安（2014），《法學入門》，14 版，頁 26，台北：元照。
[58] 李太正、王海南、法治斌、陳連順、黃源盛、顏厥安（2014），《法學入門》，14 版，頁 27，台北：元照。
[59] 鄭玉波（2016），《法學緒論》，22 版，頁 136，台北：三民。
[60] 李太正、王海南、法治斌、陳連順、黃源盛、顏厥安（2014），《法學入門》，14 版，頁 28，台北：元照。
[61] 羅元慎（2005），《土壤及地下水污染整治法制之檢討－以行政法上義務與責任之視角觀察》，國立臺灣大學法律學研究所碩士論文，頁 13。

doi:10.6342/NTU202000774

一、行政法上義務之概念

公法上義務概念之釐清，必須從行政法律關係介紹起。行政法律關係是由法律主體就具體事件在行政法上所成立之法律關係，所構成行政法律關係之內容即為「權利」及「義務」，人民行政法義務大多與高權主體之權利相對應，法律直接對公行政授予權力，公行政則據此對服從公權力之人民，將其抽象之義務具體化[62]。質言之，人民在抽象的行政法法律地位中有種種的潛在的權利義務，待人民實現法律的構成要件，則從抽象的法律地位轉變為具體行政法法律關係，其內容以行政法規範為基礎，具體構成權利及義務而實現公共利益、完成行政任務[63]。

二、行政法上義務之種類

行政法上的義務，學理大致有分為以下幾種種類，第一種是就「義務人受規制的內容」大致可分為三種：作為義務、不作為義務、容忍義務[64]。所謂作為義務是指法律主體依法律之規定，或經由國家機關依據法律所為之要求，應為一定的積極行為；不作為義務與容忍義務兩者，雖均是對於應為一定消極行為之要求，但兩者仍不相同，不作為義務是指單純放棄本身的行為；容忍義務則是指對他人的作為不予以阻止或防禦者[65]。

第二種分類是以「積極或是消極」義務加以區分，前者是指義務涉及構成要件的實現，例如：人民的納稅義務；後者則是義務涉及構成要件的不實現，

[62] 陳敏（2016），《行政法總論》，9 版，頁 268，台北：新學林。
[63] 陳敏（2016），《行政法總論》，9 版，頁 251、268，台北：新學林。
[64] 林騰鷂（2012），《行政法總論》，3 版，頁 159，台北：三民。
[65] 陳敏（2016），《行政法總論》，9 版，頁 253，台北：新學林。

doi:10.6342/NTU202000774

例如：人民不違反交通規則的義務；第三種是以「對人或對世」的義務加以區分，前者義務是指存在於特定之單一或多數之主體，例如：公物所有人容忍經許可之特別使用的義務；後者則是指存在於不特定之多數主體，例如：人民不違規排放廢氣、遵守交通秩序之義務；第四種是以「人之關聯或是物之關聯」義務加以區分，前者是指法律主體相互間之行為有直接關聯之權利義務，例如：公立學校學生註冊入學及繳納學費之義務；後者則是指公行政主體經由法律之授權，直接對物為規制以形成該物之法律性質或是對該物引發事實上影響，因而產生之義務，公行政主體作此規制之權限，係基於國家對人及物一般權力，而非對物之特別支配權，例如：對土地所為之使用分區之規定，使土地所有人得就該土地為一定方法使用之權利或義務；第五種則是以「一身專屬性或非一身專屬性」之義務區分，所謂一身專屬性之義務是指義務人須自行履行義務始能達到目的，無法由他人代理或移轉、讓與義務，例如服兵役義務；非一身專屬性之義務係指無須由義務人自為履行亦能達到目的，例如人民的退稅請求權[66]。

再者，第六種則是以人民的義務履行可以分成直接達成行政目的（例如不違規排放廢氣之義務履行）或是間接達成行政目的（例如人民負有納稅義務之履行），後者學理有稱之為「公負擔」，人民行政法之義務大多數屬於公負擔（間接達成行政目的）之類型[67]。進一步言之，在「作為義務」中若人民係給付勞務、工作、實物或金錢者，學理上又稱之為公負擔。其中公負擔中以勞務、工作或實物之給付為內容者，稱為自然負擔；若是以金錢作為內容者則稱之為公課。另外若是「不作為義務、容忍義務」作為內容之公負擔，學理稱之為行政法之用役，係對於人民之特定財產課與一定限制[68]。

[66] 陳敏（2016），《行政法總論》，9 版，頁 254-257，台北：新學林。
[67] 陳敏（2016），《行政法總論》，9 版，頁 268-269，台北：新學林。
[68] 陳敏（2016），《行政法總論》，9 版，頁 269，台北：新學林；林騰鷂（2012），《行政法總論》，3 版，頁 159-160，台北：三民。

doi:10.6342/NTU202000774

第七種分類，則是以行政法上義務之「作成來源」不同以區分，有來自於法規上、行政處分、行政契約、事實行為及人民行為產生之義務。依法規而成立的行政法上義務的情況乃例外情況，原則上法規範尚須行政機關進一步具體化始發生具體義務，然仍有可能因法規範規定而使人民產生具體義務，例如稅捐義務；依行政處分而成立之義務乃行政法上實務最常見者；依行政契約成立之義務乃依行政程序法第 135 條以下，由行政機關與人民雙方同意就義務的設定，且當事人對契約義務內容的形成具有一定影響力；依行政事實行為所成立之義務，最典型的例子為行政機關事實上作為或不作為致使人民權利受損所生之侵權行為法律關係（國家賠償法律關係）；因人民行為所產生之義務，有可能來自於人民的事實行為或是法律行為，例如人民因受領無法律依據之利益所產生之行政法上不當得利返還義務[69]。

本文欲使用的行政法義務之區分，不採用上述第二種到第七種之行政法義務之種類，而是以第一種「義務人受規制之內容」加以區分，將行政法上作為義務、不作為、忍受義務作為三大主軸，就其中「作為義務」再細分為物之給付義務或是勞務給付義務，物之給付義務又可再區分為「金錢給付義務」及「非金錢給付義務」。所謂「金錢給付義務」之內容包括以追求財政收入目的，例如：租稅、規費、受益費及特別公課等，及非以財政目的，例如：罰鍰、怠金、滯納金等等）兩者；「非金錢給付義務」其內容包括「自然給付義務」，是指人民給付勞務、工作或實物作為內容者之義務，以及「行政法上財產之限制」，又可稱「行政法之用役」或是「對物性處分義務」，係指對人民之特定財產加上公法上之限制，使該財產之所有人、佔有人或使用人應就該財產為一定作為之限制；另外，不作為、容忍義務亦可分成行政法上財產之限制或非財產

[69] 李建良（2016），〈第六講－行政法律關係序說〉，《行政法基本十講》，6 版，頁 205-209，台北：元照。

doi:10.6342/NTU202000774

之限制，前者屬行政法上財產限制之表現態樣之一[70]。本文以下則以作為義務中之「金錢給付義務」及「非金錢給付義務」之區分作為概括義務繼受之討論主軸脈絡。

參、行政法與民法上義務之比較

一、民法上義務之內涵、解釋

民法的法律關係乃以權利義務作為內容，每個法律關係中，均至少須以一個權利作為要素，民法權利種類上有可能為債權、物權、身分權，每個權利都有其行使之權能，例如債權而言，債權人得向債務人請求給付等等；物權之所有權則是使所有人得以對其所有物為使用、收益及處分等等，身分權則是在具有一定身分關係下主張一定之要求[71]。權利之行使概念，乃相對於義務的履行，故**所謂的「義務」是指法律上的當為「要求」**，此範圍涵蓋債權關係、物權關係、身分關係之領域[72]。

進一步探究民法上義務的分類，學理有分為幾種，第一種是以「義務規制內涵」分作為義務、不作為義務及容忍義務，所謂作為義務，乃以積極行為作為內容，例如：民法第 482 條規定：「稱僱傭者，謂當事人約定，一方於一定或不定之期限內為他方服勞務，他方給付報酬之契約」，其中「服勞務」屬債法上作為義務之非金錢給付義務表現、「給付報酬」即屬債法上之作為義務之金錢給付表現；不作為義務是指義務人消極地有所不為而言，包括忍受他人行為或某種狀態，例如：企業與員工所訂定的競業禁止之條款，即是課予員工在離職之

[70] 陳敏（2016），《行政法總論》，9 版，頁 269-277，台北：新學林。
[71] 王澤鑑（2014），《民法總則》，增訂新版，頁 106，台北：自刊。
[72] 王澤鑑（2014），《民法總則》，增訂新版，頁 106，台北：自刊。

doi:10.6342/NTU202000774

後一定期間內，拘束其員工不得從事與該公司營業項目相同或類似之行業，使該員工受有不得為從事禁止行業之不作為義務的拘束；容忍義務則例如：民法第 787 條容忍他人通行其土地之義務，或是民法第 796 條第 1 項鄰地所有人對越界建築之房屋負有容忍之義務[73]。

另外，第二種分類則是區分「主給付義務及從給付義務」，前者乃契約法所固有、必備之義務，並以決定債之類型之基本義務，例如民法第 348 條規定買賣契約之出賣人負有交付標的物及移轉標的物所有權之義務；後者之從給付義務係指輔助主給付義務以確保債權人的利益能得到最大滿足，例如：民法第 296 條之債權讓與，讓與人應將證明債權文件交付並告知主張債權所必要的一切情況；第三種是「原給付義務及次給付義務」，前者是指債之關係上原有之給付義務，本於原本債之關係所產生之義務，後者是指原給付義務在履行過程中因特定事由所演變所生之義務，主要情況有原給付義務之給付不能（民法第 226 條）、給付遲延（民法第 229 條）或不完全給付（民法第 227 條）；第四種分類則是區分「先契約義務或後契約義務」，前者係指契約締結前發生違反保密或告知等義務之違反所生締約上過失（民法第 245 條之 1）等；後者則是契約消滅後當事人尚負某些義務，例如雇主開立以離職員工之工作證明；第五種則是「真正義務與不真正義務」，前者是指違反法律規定，債權人可要求其履行或請求損害賠償；後者則是指違反法律規定者並不會發生責任，只對債務人本身產生失權效[74]。

關於上開學裡有提出民法上義務之分類方法，第二種到第五種係針對債法領域之義務區別，無法完整適用於整個民法上義務的區分，然而第一種分類方

[73] 鄭冠宇（2016），《民法總則》，3 版，頁 226-227，台北：新學林；王澤鑑（2014），《民法總則》，頁 106，增訂新版，台北：自刊；王澤鑑（2006），《民法學說與判例研究（八）》，頁 125，台北：自刊。
[74] 鄭冠宇（2016），《民法總則》，3 版，頁 227-230，台北：新學林。

doi:10.6342/NTU202000774

法，在債法、物權及身分法領域均可全面適用而較為周全，故本文採此種分類方法繼續討論之。

據此，從第一種之分類方法可知，民法上之義務可分為作為、不作為義務及容忍義務，進一步，作為義務所給付的內容，可分為物之給付義務與勞務給付義務，物之給付義務中，以是否為金錢之債可區別為「金錢給付義務」或「非金錢給付義務」，例如在買賣契約下，買方應負之義務即為給付價金，屬金錢給付義務之一種；另外若是租賃契約中，出租人須對承租人交付其所有物之使用、收益之權限，此即為非金錢給付義務之一種。

二、公法與民法「義務」概念比較

從上所述，將民法的義務概念加以解構，可知其義務所涉獵的範圍包括債權債務關係、物權關係、身分法關係，其義務內涵面上，可以分成「作為義務」、「不作為義務」及「容忍義務」；再者作為義務所涉及的標的可區分為「金錢給付義務」及「非金錢給付義務」。可發現在分類上，與上開本文所採之公法上義務的分類方向，相互不扞格，且兩者所指者之定義概念亦可相通。據此，以下對於義務概括繼受制度的比較、適用上，民法領域之「義務」與公法領域上的「義務」思考，對於大前提之「義務」概念具備可相通性，具有繼續討論的實益。

第二項　行政法上義務與責任辨析

透過前述介紹何謂行政法義務之內涵，進一步了解行政領域之「秩序行政」概念，並辨析義務與責任兩者之定位，以了解義務與責任在行政法領域之

doi:10.6342/NTU202000774

全貌。



壹、秩序行政概念與內涵

「行政」領域中，若以行政之「手段」區分對人民之法律效力之不同，可分為「給付行政」與「秩序行政」兩大分類[75]。給付行政部分以社會生存照護為主要任務；秩序行政部分，又稱為干涉行政、干預行政，其目的乃致力於創造良好的公共秩序為目的之行政，該目的之達成，大多數係以法令限制人民作為手段，其限制的手段具有強烈命令、禁止、干涉、取締及強制之色彩[76]。

在國家的行政作用下，不論是以何種行政行為作為手段表現，均欲達到合憲秩序下的國家目的，故國家的行政目的，乃藉由各種行政行為作為手段加以展現、達成，進而可知行政目的具體化國家目的，而各種的行政行為則具體化了行政目的[77]。

秩序行政在國家行政目的角度以觀，乃為維護秩序與安全而形成，為了達到維護既有的秩序安全不受侵擾、破壞，若是具有足以威脅秩序及安全之狀態，將帶來失序、混亂、不安全之結果可能性時，即有秩序行政作用介入防範之可能，傳統上開啟秩序行政作用的基準點，即是法學上所稱之「危險」，也就是說當秩序與安全達到了「危險」程度時，秩序行政即開始有「介入」加以防制的正當性、必要性之存在，故秩序行政係透過具有強制力、干預性本身之危險發生前之防禦及危險發生後之排除作為手段，而追求維護公共秩序與社會安全不受侵擾，此與

---

[75] 陳敏（2016），《行政法總論》，7 版，頁 14-15，台北：新學林；蔡宗珍（2011），〈建築法上義務人之類型與具體義務人之判定：行政法上行為責任與狀態責任問題系絡的一個切面分析〉，《台大法學論叢》，40 卷 3 期，頁 914。

[76] 李震山（2014），《行政法總論》，10 版，頁 4，台北：三民。

[77] 蔡宗珍（2011），〈建築法上義務人之類型與具體義務人之判定：行政法上行為責任與狀態責任問題系絡的一個切面分析〉，《台大法學論叢》，40 卷 3 期，頁 913。

doi:10.6342/NTU202000774

德國傳統行政法上之警察行政概念密不可分[78]。

秩序行政又可稱之為警察行政，其與德國傳統行政法上之警察行政概念關係密切，進而探究德國法的脈絡下，可將「警察」一詞回溯至西元十六、十七世紀初之概念，其乃與現今國家依據組織法的固定編制的固定人員，受有特定任務履行所謂的「警察」有所不同，蓋當時所謂的警察之意涵相當廣泛，除指當時神聖羅馬帝國或帝國領邦、帝國城市所頒佈之警察法規之外，尚有形容一種具有「良善秩序之共同體狀態」之概念，可用來指涉警察、公衛、環保、消防、建管、工商等各個行政領域，若實質理解「警察行政」之「警察」之概念，其係指國家一切防止危險之行政行為者，並且擁有警察權（強制權）以免公共安全之危險及消弭侵擾之行政功能，換言之，當時所稱之警察行政乃係現今具備實質意義之警察，也即為晚近行政法所形成之「秩序行政」之概念[79]。

又，反觀我國釋憲實務見解，曾談論過廣義之警察概念（秩序行政）與狹義之警察概念。在大法官釋字第 588 號解釋中，有關憲法第 8 條之「警察機關」以及行政執行法第 19 條第 1 項執行拘提、管收之行政執行處執行人員於行政法上之定位，其解釋理由書進一步辨析，所謂「警察」一詞，係指以維持社會秩序或增進公共利益為目的，具強制（干預、取締）手段特質之國家行政作用或國家行政主體，概念上原屬多義之用語，有廣、狹，即實質、形式兩種意義之分。其採廣義、即實質之意義者，乃就其「功能」予以觀察，凡具有上述「警察」意義之作用、行使此一意義之權限者均屬之；其取狹義、即形式之意義者，則就組織上予以著眼，限於警察組織之形式－警察法，於此法律所明文

[78] 蔡宗珍（2011），〈建築法上義務人之類型與具體義務人之判定：行政法上行為責任與狀態責任問題系絡的一個切面分析〉，《台大法學論叢》，40 卷 3 期，頁 914。

[79] 蔡宗珍（2011），〈建築法上義務人之類型與具體義務人之判定：行政法上行為責任與狀態責任問題系絡的一個切面分析〉，《台大法學論叢》，40 卷 3 期，頁 914；王晨桓（2009），《行政法上金錢給付義務之繼受問題-以罰鍰及課稅為討論重心》，國立臺灣大學法律學研究所碩士論文，頁 16。

doi:10.6342/NTU202000774

規定之機關及人員始足當之，其僅具警察之作用或負警察之任務者。上述行政執行法既已就管收、拘提為明文之規定，並須經法院之裁定，亦即須先經司法審查之准許，則其「執行」自非不得由該主管機關、即行政執行處之人員為之。是憲法第 8 條第 1 項所稱「非經司法或警察機關依法定程序，不得逮捕、拘禁」之「警察機關」，乃採廣義，凡功能上具有前述「警察」之意義、即法律規定以維持社會秩序或增進公共利益為目的，賦予其機關或人員得使用干預、取締之手段者，概屬相當，並非僅指組織法上之形式「警察」之意。故大法官在此就我國法上所謂「警察」之概念，可區分為功能意義（廣義、實質）及組織意義（狹義、形式）兩者，而前者則屬秩序行政領域之概念；後者則屬組織法警察概念。

二次大戰後，德國聯邦漸漸開始區分「警察機關」與「秩序行政機關」[80]。然我國行政法對於廣義之警察與狹義之警察概念，在文句使用上並無如德國法如此明確區分。以下就行政法上責任及義務概念的辨析與內涵的理解，即是以廣義的警察概念（秩序行政）作為上位概念，加以說明之。

貳、責任是抽象的行政法規範，義務乃責任具體展現

一、我國法學緒論角度之理解

法學領域中，「責任」可分為民事責任、刑事責任、國家責任，以責任的概念內涵而言，法律上的責任基本上是以主觀主義為原則，輔以客觀主義加以修正、補充之，也即某種法律上有意義的事件或結果，乃因某個人主觀上之條件

[80] 王晨桓（2009），《行政法上金錢給付義務之繼受問題-以罰鍰及課稅為討論重心》，國立臺灣大學法律學研究所碩士論文，頁 17。

doi:10.6342/NTU202000774

或特徵，進而在法律上認定違規屬於此一行為人，意即行為人須對此一結果負起法律上責任，涉及支配、規範此法律制度運作原則也就是法學概念中的歸責原則；大部分的責任類型，對當事人預設有某種作為或不作為之義務，此等義務之違反，為責任得以成立之必要條件，故「義務」構成「法律上責任」得以成立的一個客觀規範要素，兩者間雖密切相關，但是卻不同的概念，然而亦有可能非必然關聯，蓋有些義務之違反並不會引起責任加以制裁[81]。

「義務」與「責任」在各個法領域均有此用語之存在，以法學基礎概念，可認為責任含有法律上負擔之意義當個人違反法律秩序，或有違反之可能時，法律關係將會使人居於接受制裁之地位，稱之為責任[82]。簡言之，責任乃違反義務者應受之一定制裁者也，兩者有時相伴而生，亦有可能不相伴隨，概念上兩者不宜認為屬同一[83]。

承上所述，以法學緒論的角度剖析下，對於「責任」的理解，前提乃先有一「義務」此種法律上拘束之存在，進而違反此義務時才會產生責任之後果。

二、公法（行政法）角度理解

有學理認為行政法概念下之義務是指，法律主體在法律的規定下，或經由國家機關根據法律所為之要求，應為特定之行為，其內容多半為特定的作為、不作為或容忍。人民負有行政法之義務大多數與高權主體相對應[84]。人民的行政法義務有直接來自其一般或特別的「法律地位」，例如：人民應服從公權力之

[81] 李太正、王海南、法治斌、陳連順、黃源盛、顏厥安（2014），《法學入門》，14 版，頁 29-30，台北：元照。
[82] 韓忠謨（1994），《法學緒論》，2 版，頁 168，台北：韓聯甲。
[83] 鄭玉波（2016），《法學緒論》，22 版，頁 136，台北：三民。
[84] 陳敏（2016），《行政法總論》，9 版，頁 268，台北：新學林。

doi:10.6342/NTU202000774

合法指示，容忍其合法干涉，不得侵害他人權利、違反法律、公共秩序及善良風俗，其法律地位亦即為其義務地位，然而人民的義務大多數係由法律規定而得出，有時尚必須經由行政措施對法律予以具體化現實化[85]。此種見解似乎與法學緒論領域之見解相似，認為義務乃法律上拘束，違反者始產生責任。

另有學理在此認為，上開以法學緒論觀念對於責任之理解，仔細推敲後不難得知，其係以民法及刑法脈絡思考作為基礎，然此種基礎是否能原封不動地帶入行政法領域適用，尚須斟酌，蓋行政法之領域，著重國家與人民之間的權利義務之互動，及帶有公益維護之思想，則行政法「責任」的理解，勢必聚焦於行政法規範之原理原則、目的，以界定及釐清觀念[86]。本文欲採此學理見解，以下就此學理見解進一步說明，介紹之。

（一）行政法中稱「責任」一詞之種類

由於行政法域中，「責任」一詞散佈於各個行政法規範中，首先必須加以分類、界定何種係本文欲探究之行政法之責任。故，探究其中，有定義為公務員違法應負法律上責任之意義[87]、行政之「任務」或「權限」之謂[88]、宣示性質之

[85] 陳敏（2016），《行政法總論》，9 版，頁 268，台北：新學林。
[86] 李建良（2008），〈論行政法上「責任」概念及責任人的選擇問題—兼評最高行政法院 93 年度判字第 628 號、95 年度判字第 1421 號判決及其相關判決〉，《2007 行政管制與行政爭訟》，頁 42、46，台北：中央研究院法律學研究所籌備處。
[87] 例如：訴願法第 100 條規定：「公務人員因違法或不當處分，涉有刑事或行政**責任**者，由最終決定之機關於決定後責由該管機關依法辦理」。
[88] 例如：地方制度法第 2 條第 1 項第 1 款：「二、自治事項：指地方自治團體依憲法或本法規定，得自為立法並執行，或法律規定應由該團體辦理之事務，而負其政策規劃及行政執行**責任**之事項」。

doi:10.6342/NTU202000774

意義[89]、行政執行對象之意義[90]、行政爭訟之舉證責任之謂[91]、名為「責任」然實質上屬「義務」之規定[92]以及屬「行政法上歸責」之意義，大致可分成以上七種類型[93]。

其中所謂屬「行政法上歸責之意義」此類，舉例而言，消防法第 19 條：「消防人員對火災處所及其周邊，非使用或損壞其土地、建築物、車輛及其他物品或限制其使用，不能達搶救之目的時，得使用、損壞或限制其使用。（第一項）直轄市、縣（市）政府對前項土地或建築物之使用、損壞或限制使用所致之損失，得視實際狀況酌予補償。但對應負引起火災**責任**者，不予補償。（第二項）」，其中第一項規定乃行政上即時強制的特別規定，第二項則針對因第一項即時強制而受到特別犧牲之人民給予損失補償之規定，蓋國家給予人民損失補償的原因在於，人民在未違反行政法所賦予之責任，卻受有即時強制，國家對於超出合理範圍之財產權社會責任容忍範圍之限制，必須給予財產保障（損失補償）加以彌補之；反之，若是人民違反行政法之規定者（有引起火災發生之歸責事由），則其自負有排除其所造成危險之義務，此類所稱的責任，乃是指「有行政法歸責之規定」，即屬本文欲探究責任類型與義務之間關係[94]。

---

[89] 例如：建築法第 12 條：「本法所稱建築物之起造人，為建造該建築物之申請人，其為未成年或受監護宣告之人，由其法定代理人代為申請；本法規定之義務與**責任**，亦由法定代理人負之。（第一項）起造人為政府機關公營事業機構、團體或法人者，由其負責人申請之，並由負責人負本法規定之義務與**責任**。（第二項）」。

[90] 例如：行政執行法第 18 條：「保人於擔保書狀載明義務人逃亡或不履行義務由其負清償**責任**者，行政執行處於義務人逾前條第一項之限期仍不履行時，得逕就擔保人之財產執行之」。

[91] 例如：行政訴訟法第 137 條：「習慣及外國之現行法為行政法院所不知者，當事人有舉證之**責任**。但行政法院得依職權調查之」。

[92] 例如：郵政法第 45 條：「依第二十六條第一項規定負輔助載運郵件**責任**者，有下列情事之一時，處新臺幣二萬元以上十萬元以下罰鍰：一、無正當事由拒絕載運郵件。二、故意延誤載運郵件」，從此條文的結構中可知，違反此責任直接設有罰鍰的法律效果。因此實質觀察之此種輔助載運郵件責任，其實是課與運送業者的輔助載運郵件「義務」。

[93] 李建良（2008），〈論行政法上「責任」概念及責任人的選擇問題—兼評最高行政法院 93 年度判字第 628 號、95 年度判字第 1421 號判決及其相關判決〉，《2007 行政管制與行政爭訟》，頁 42-44，台北：中央研究院法律學研究所籌備處。

[94] 李建良（2008），〈論行政法上「責任」概念及責任人的選擇問題—兼評最高行政法院 93 年度判字第 628 號、95 年度判字第 1421 號判決及其相關判決〉，《2007 行政管制與行政爭訟》，頁 45，台北：中央研究院法律學研究所籌備處。

doi:10.6342/NTU202000774

（二）聚焦以行政法上義務發生原因及其正當性基礎之「責任」

本文以「責任作為**行政法歸責**的面向」思考與義務間之關係，所謂的「責任」之概念，係定位於行政機關係「基於何種理由」可以課與人民一定的之義務，而非行政機關確定何為義務人之後應如何使之盡其義務（行為、不行為或容忍義務），換言之，在秩序行政之責任乃「行政法上義務之原因以及正當性基礎」，此概念不同於行政秩序罰上對於行為人其主觀上具備故意或過失之責任（參照行政罰法第二章）[95]。

（三）「行政法上責任」於秩序行政下之定位

進一步，將觀察的視角拉高於「秩序行政」的存在、發生與結果之層次，可大致分為「責任為什麼發生」及「責任違反之後果」，「行政法責任」在此視角下，即是對於「為什麼」要課與人民行政法之義務加以說明，而非單純究明法定義務之所在為何，亦非單純關心違反之後果。

質言之，行政法之責任係指「人民應該為某件事情或某些行為負起責任」，此屬行政法上義務其存在「前階段之正當性課題」，而非後階段之處罰、如何付出代價的課題（行政秩序罰），亦非後續如何收尾、善後之課題（行政執行），對於行政法責任與義務，必須體系性解析兩者之間的關聯性，使得全面理解[96]。

---

[95] 李建良（2008），〈論行政法上「責任」概念及責任人的選擇問題—兼評最高行政法院 93 年度判字第 628 號、95 年度判字第 1421 號判決及其相關判決〉，《2007 行政管制與行政爭訟》，頁 46，台北：中央研究院法律學研究所籌備處。

[96] 李建良（2008），〈論行政法上「責任」概念及責任人的選擇問題—兼評最高行政法院 93 年度判字第 628 號、95 年度判字第 1421 號判決及其相關判決〉，《2007 行政管制與行政爭訟》，頁

doi:10.6342/NTU202000774

據此，將義務及責任置於行政法之秩序行政領域脈絡思考，行政權的目的既係在於維持社會秩序、確保公共安全，行政機關自得對於將影響公共安全、社會秩序之人，除了自行或委託第三人防止或排除外，尚可在法律授權的範圍內，課予人民防止或排除危害之義務[97]。判斷是否有課予人民一定義務規制之正當性基礎，關鍵在於「責任」的賦予，其「責任」之依據，必須使人民得預見何種行為將受秩序行政規制，是以「法律保留原則」在秩序行政乃不法治國原則與人權保障之實踐。換言之，在行政法規範中，國家對於行政機關實施干涉行政之對象，無論是法人、自然人，皆必須將其在秩序行政下所應負何種拘束加以明確規定[98]，進一步使行政機關得據此對人民作出具體的規制義務。並且責任內容的設定，亦須切合法治國原則之下比例原則、平等原則之誡命。

透過上述秩序行政脈絡與法治國原則之實踐，可以得知「責任」扮演著十分重要的角色，乃行政機關採取管制或是排除危險措施之不可或缺之基礎。簡言之，**「責任」乃義務之成立基礎；而「義務」乃責任之後果體現**[99]。

第三項　行政法之責任類型

在秩序行政中，國家針對具體且可預先考量之情境，以一種利用要求或禁止等局部干預性的規制手段所進行的監督行政，必要時將會對人民權利或利益

46，台北：中央研究院法律學研究所籌備處。

97 李建良（2008），〈論行政法上「責任」概念及責任人的選擇問題—兼評最高行政法院 93 年度判字第 628 號、95 年度判字第 1421 號判決及其相關判決〉，《2007 行政管制與行政爭訟》，頁 48，台北：中央研究院法律學研究所籌備處。

98 黃啟禎（2002），〈干涉行政法上責任人之探討〉，《當代公法新論（中），翁岳生教授七秩誕辰祝壽論文集》，頁 291，台北：元照。

99 李建良（2008），〈論行政法上「責任」概念及責任人的選擇問題—兼評最高行政法院 93 年度判字第 628 號、95 年度判字第 1421 號判決及其相關判決〉，《2007 行政管制與行政爭訟》，頁 48，台北：中央研究院法律學研究所籌備處。

doi:10.6342/NTU202000774

加以限制，乃典型之干預行政[100]。為了達到維護公共秩序與公共安全，課予人民防止危害之任務，施以事前或事後禁制之行政作用，此種行政行為往往對人民之基本權利施以限制或侵害，又因危害事故發生時，案件往往錯綜複雜，所牽涉之人數眾多，如何界定責任類型與應負責任之人，對於案件處理的合法性及人民權益影響十分重大[101]。本於秩序行政中「責任」之設定涉及法律保留原則、比例原則與平等原則息息相關，行政機關應如何有效防止危害並維護公眾與個人之利益，則進一步對責任類型有加以探討之必要[102]。

壹、責任人概念

行政機關基於法律授權的範圍內，所課予人民防止或排除危害的義務，一般稱之為行政機關之危害防制職權與義務，不僅須有「法律上之依據」，尚必須是「對該危害之發生負有責任的人（責任人）為對象」[103]。其中所謂「責任人」乃秩序行政法之責任人，意謂行政機關得採取必要措施之對象，原則上屬危險之發生及情況需要負責之人[104]。

有關「責任人」此一詞，早期在德國行政法教科書中，曾與另一個名詞「警察義務人」相同而相互代替使用之，德文中「警察」一詞在學理上涵義甚廣，等同於干涉行政，然德國行政法使用之警察一詞有其文化、歷史背景，德

[100] 蔡宗珍（2011），〈建築法上義務人之類型與具體義務人之判定：行政法上行為責任與狀態責任問題系絡的一個切面分析〉，《台大法學論叢》，第 40 卷第 3 期，頁 914-915。
[101] 黃啟禎（2002），〈干涉行政法上責任人之探討〉，《當代公法新論（中），翁岳生教授七秩誕辰祝壽論文集》，頁 291，台北：元照。
[102] 黃啟禎（2002），〈干涉行政法上責任人之探討〉，《當代公法新論（中），翁岳生教授七秩誕辰祝壽論文集》，頁 291，台北：元照。
[103] 李建良（2008），〈論行政法上「責任」概念及責任人的選擇問題—兼評最高行政法院 93 年度判字第 628 號、95 年度判字第 1421 號判決及其相關判決〉，《2007 行政管制與行政爭訟》，頁 48，台北：中央研究院法律學研究所籌備處。
[104] 李建良（2008），〈論行政法上「責任」概念及責任人的選擇問題—兼評最高行政法院 93 年度判字第 628 號、95 年度判字第 1421 號判決及其相關判決〉，《2007 行政管制與行政爭訟》，頁 47，台北：中央研究院法律學研究所籌備處。

doi:10.6342/NTU202000774

國行政法學過去向來稱之為「妨害人」(或滋擾者),然今日則較少使用,我國法並無如德國法之歷史脈絡,是以對於責任人之名詞運用,以「責任人」之用語即已足,[105]。

貳、責任類型之區分

秩序行政的核心任務乃在維護社會秩序與安全,以排除已產生之侵擾、將妨害秩序之危險,此排除該侵擾及危險雖可由公權力直接為之,然立法者對此種侵擾、危險之情況,可立法要求對於危害發生負有責任之人,須負起排除危險之義務,故賦予其行政法之「責任」[106]。引起責任的發生者,不外乎兩大類因素,一類為**特定人的行為**(作為、不作為與容忍等表現形態),其著眼於人對自己行為之後果承擔之可能性與必要性,一般稱之為「行為責任」;另一類則是著眼於**特定人對其所具有實力支配可能之物的狀態**有關其操縱的可能性及必要性,一般稱之為「狀態責任」[107]。

秩序行政法之規定,人民所設定之應負之責任其所連接的因素若不是「人的行為」即是「物的狀態」此兩種類型,可將責任的歸屬分別追究「對人的行為」所為之管制(行為責任);或是「對物的狀態」所為之管制(狀態責任)兩者,若欲規制或排除之事態是源自於行為者,行為人或是需為此等行為負責之人,即成為行政法之責任人;若欲立法排除或規制的事態是源自於物的狀態者,則有權或實際支配處分該物之人,亦成為行政法上之責任人,故行為責任與狀態責任乃撐起秩序行政之建構不可或缺之兩大依據,兩者責任的形成及依

105 黃啟禎(2002),〈干涉行政法上責任人之探討〉,《當代公法新論(中),翁岳生教授七秩誕辰祝壽論文集》,頁 291-292,台北:元照。
106 蔡宗珍(2011),〈建築法上義務人之類型與具體義務人之判定:行政法上行為責任與狀態責任問題系絡的一個切面分析〉,《台大法學論叢》,40 卷 3 期,頁 915。
107 蔡宗珍(2011),〈建築法上義務人之類型與具體義務人之判定:行政法上行為責任與狀態責任問題系絡的一個切面分析〉,《台大法學論叢》,40 卷 3 期,頁 915。

doi:10.6342/NTU202000774

據有完全不同之基礎[108]。以下就此兩種責任析述之。



一、 行為責任

行為責任是指因作為或不作為而肇致公共秩序遭到危害之責任[109]。行為責任的歸責上，通常是來自於人的行為，所謂行為責任，謂引起危害之方式乃經由人的行為所引起，是以構成該種責任之基本要素有「行為」及「引起危險」此兩要素，以下就此兩個要素進一步說明之[110]。

（一）行為責任需具備「行為」之概念

首先就「行為」部分，其概念包括作爲、不作為在內，而且屬法律上應防免危險之行為[111]，行為責任下尚可以區分為「為自己行為負責」、「為不作為負責行為負責」及「附帶責任負責」三種。

第一種是「為自己行為負責」，其係因行為人自己之行為而產生責任，乃行為責任中最典型類型[112]。

---

108 蔡宗珍（2011），〈建築法上義務人之類型與具體義務人之判定：行政法上行為責任與狀態責任問題系絡的一個切面分析〉，《台大法學論叢》，40 卷 3 期，頁 916。

109 黃啟禎（2002），〈干涉行政法上責任人之探討〉，《當代公法新論（中），翁岳生教授七秩誕辰祝壽論文集》，頁 296，台北：元照。

110 李建良（2008），〈論行政法上「責任」概念及責任人的選擇問題—兼評最高行政法院 93 年度判字第 628 號、95 年度判字第 1421 號判決及其相關判決〉，《2007 行政管制與行政爭訟》，頁 50，台北：中央研究院法律學研究所籌備處。

111 李建良（2008），〈論行政法上「責任」概念及責任人的選擇問題—兼評最高行政法院 93 年度判字第 628 號、95 年度判字第 1421 號判決及其相關判決〉，《2007 行政管制與行政爭訟》，頁 50，台北：中央研究院法律學研究所籌備處。

112 黃啟禎（2002），〈干涉行政法上責任人之探討〉，《當代公法新論（中），翁岳生教授七秩誕辰祝壽論文集》，頁 297，台北：元照。

doi:10.6342/NTU202000774

第二種是「不作為之行為責任」，又可稱為「消極之妨害人」，在不作為之行為責任中，並非任何不作為均構成行為責任，反之必須以行為人有負擔「公法上之危險防止義務」為前提[113]，又行為人若只負私法上之義務，原則上不構成行政法上之不作為之行為責任[114]。

第三種則是「附帶責任負責」，屬為他人行為負責的類型，又可稱之為「附加責任」，是指個人因子女、家屬、受僱人發生秩序行政法之違反而需負責之情況，其主要有兩種情況，一種是監護權人對被監護者行為之責任負責；另一種是僱用人對受僱人行為之責任負責，後者是指受僱人因執行職務，違反法令而造成危險者，其僱用人應對該受僱人之行為負責，故主管機關得對僱用人作為採取措施之對象[115]。

（二）行為責任中「因果關係」之判斷

行為責任除了判斷「行為」以外，尚必須判斷該等「行為」與行為責任所欲防範的「危險」之間是否具有「因果關係」，必須具備此兩項，行為人始負行為責任。也就是說，行為人必須是引起危險之「肇致者」始論以行為責任[116]。

---

113 例如：動物保護法第 7 條規定：「飼主應防止其所飼養動物無故侵害他人之生命、身體、自由或財產」，飼主在本條所課予之責任下，乃是不得使其飼養的動物無正當理由而傷害他人之「不作為責任之行為責任」，又或例如土壤及地下水污染整治法：「污染行為人、潛在污染責任人、污染土地關係人或土壤、地下水污染管制 區內之土地使用人、管理人或所有人對於土壤、地下水污染整治計畫、污 染控制計畫或適當措施之實施，應予配合；各級主管機關得派員攜帶證明 文件到場檢查或命提供必要之資料，該等人員不得規避、妨礙或拒絕」。

114 李建良（2008），〈論行政法上「責任」概念及責任人的選擇問題—兼評最高行政法院 93 年度判字第 628 號、95 年度判字第 1421 號判決及其相關判決〉，《2007 行政管制與行政爭訟》，頁 50-51，台北：中央研究院法律學研究所籌備處。

115 李建良（2008），〈論行政法上「責任」概念及責任人的選擇問題—兼評最高行政法院 93 年度判字第 628 號、95 年度判字第 1421 號判決及其相關判決〉，《2007 行政管制與行政爭訟》，頁 51-52，台北：中央研究院法律學研究所籌備處；黃啟禎（2002），〈干涉行政法上責任人之探討〉，《當代公法新論（中），翁岳生教授七秩誕辰祝壽論文集》，頁 299，台北：元照。

116 李建良（2008），〈論行政法上「責任」概念及責任人的選擇問題—兼評最高行政法院 93 年度判字第 628 號、95 年度判字第 1421 號判決及其相關判決〉，《2007 行政管制與行政爭訟》，頁 51-52，台北：中央研究院法律學研究所籌備處。

doi:10.6342/NTU202000774

有關秩序行政下之行為責任的因果關係判斷，我國法上並未就該因果關係之判斷有明確之見解，反觀在民法中因果關係的認定通說，以相當性理論為依據[117]；刑法領域中由於涉及國家刑罰權之有無，在因果關係認定上則採因果關係客觀歸責理論作為通說。

然而在秩序行政法領域中，應該採何種因果關係判斷之理論，尚須針對秩序行政的目的與內涵加以選擇之。參考德國法的學說及實務見解的多數見解，乃採**「引起行為之直接性理論」**（又可稱之為「直接肇因說」），凡對原因鎖鏈中作出最終且具有決定性部分之行為者負其責任，此理論著重於區分「直接因素」及「間接因素」，必須是「直接」導致危險發生之因素，始具備因果關係，屬責任人（妨害人）；反之若只是「間接」導致危險發生之結果，則只是起因者尚非責任人（妨害人）[118]。

二、 狀態責任

狀態責任是指以物之法律上或事實上支配力作為責任的連結因素，非以人的行為作為責任之訴諸[119]。狀態責任乃對於物之所有權人及事實上有管領力之人所課予之責任，也就是說，若人民對於其所支配之物受有維護、照顧、管理之責任，而該物對秩序、安全造成危害時，該人民既然在法律上具有使用、收

[117] 陳聰富（2000），侵權行為法上之因果關係，國立臺灣大學法學論叢，29 卷 2 期，頁 176。
[118] 黃啟禎（2002），〈干涉行政法上責任人之探討〉，《當代公法新論（中），翁岳生教授七秩誕辰祝壽論文集》，頁 292-295，台北：元照；李建良（2008），〈論行政法上「責任」概念及責任人的選擇問題—兼評最高行政法院 93 年度判字第 628 號、95 年度判字第 1421 號判決及其相關判決〉，《2007 行政管制與行政爭訟》，頁 54，台北：中央研究院法律學研究所籌備處。
[119] 李建良（2008），〈論行政法上「責任」概念及責任人的選擇問題—兼評最高行政法院 93 年度判字第 628 號、95 年度判字第 1421 號判決及其相關判決〉，《2007 行政管制與行政爭訟》，頁 56，台北：中央研究院法律學研究所籌備處。

doi:10.6342/NTU202000774

益及處分權限之地位，立法者直接選擇以該人作為狀態責任人是最恰當的[120]。狀態責任與行為責任的差異在於觀察的角度不同，蓋狀態責任是以物本身所產生之危險觀察，並非如行為責任取決於人的行為[121]。

此種狀態責任之課予，與民法第 191 條之工作物、建築物所有人所應負之侵權行為責任十分類似，從兩者之法理依據均是對於所有權人之法定限制，加諸所有權人對於其所有之物有排除危險或是負有損害賠償之責任，均是展現其財產權在社會責任下的限制，有所不同的是民法第 191 條乃實踐於民法（私法）領域之中；秩序行政之狀態責任則是實踐於公法領域，且民法第 191 條之規定欲處理者乃侵權行為之損害賠償的分擔責任；狀態責任則是在確定誰負有對物的排除危險、維持安全之責任，進而釐清對於狀態責任違反，誰需進一步承受自費排除危險狀態、回復安全狀態之行為義務[122]。

（一）狀態責任不具備「行為」之要件

狀態責任的形成乃以「物的狀態」為中心，與人的行為之間並無必然或直接關聯性，凡屬於因物的狀態而承擔行政法上義務者，該等義務及與行為責任所承擔的義務完全不同，蓋行為責任已如前述必須具備「行為」之要件，然而狀態責任並無「行為」此一要素之構成必要，亦不問是否因特定行為而引致狀態責任之發生[123]。

---

120 蔡宗珍（2011），〈建築法上義務人之類型與具體義務人之判定：行政法上行為責任與狀態責任問題系絡的一個切面分析〉，《台大法學論叢》，40 卷 3 期，頁 917。

121 李建良（2008），〈論行政法上「責任」概念及責任人的選擇問題—兼評最高行政法院 93 年度判字第 628 號、95 年度判字第 1421 號判決及其相關判決〉，《2007 行政管制與行政爭訟》，頁 56，台北：中央研究院法律學研究所籌備處。

122 蔡宗珍（2011），〈建築法上義務人之類型與具體義務人之判定：行政法上行為責任與狀態責任問題系絡的一個切面分析〉，《台大法學論叢》，40 卷 3 期，頁 917。

123 蔡宗珍（2011），〈建築法上義務人之類型與具體義務人之判定：行政法上行為責任與狀態責任問題系絡的一個切面分析〉，《台大法學論叢》，40 卷 3 期，頁 918。

doi:10.6342/NTU202000774

狀態責任即使欠缺「行為」此一要素，亦不能與「不作為義務」概念加以混淆，原因在於秩序行政下所課予之狀態責任，為物所有人必須對其所有物之狀態維持其合法狀態之存在，所謂狀態責任之違反，是指受規範之物出現「不合法規範」之狀態，進而產生了秩序行政法所欲排除之危險，即使不合規定之狀態來自於不可抗力之天災所造成者，亦不因而改變，由此可知狀態責任本身並沒有預設「任何行為」要素，故當然不能謂狀態責任屬不作為義務之內涵[124]。且不作為義務係屬行為責任下之概念，其與作為義務之不同之點在於，不作為之責任構成以「作為義務」為前提，且必須具備法律上依據，而狀態責任毋寧只是因物的狀態或特性所生之危險，其與物之所有權人或有事實上管領力之人有無作為或不作為並無關聯[125]。

狀態責任與行為責任最大的差異係在於，責任「發生的原因」及「課責之對象」這兩個面向，就發生的原因而言，行為責任乃起因於違反行政法上義務之行為，狀態責任則是起因於標的物之危害狀態，不問行為人為何人；就課責之對象而言，行為責任由行為人承擔，狀態責任則是由責任標的物具聯繫因素的人承擔，若法規在課予責任之際，限於以「行為人」作為對象時，溯及其源頭之責任屬於行為責任，反之以「責任標的物具聯繫因素的人」作為對象時而不追問原因為何，則屬於狀態責任[126]。

另外如前所述，行政法之「責任」認定與責任人之故意、過失並無關聯，

---

124 蔡宗珍（2011），〈建築法上義務人之類型與具體義務人之判定：行政法上行為責任與狀態責任問題系絡的一個切面分析〉，《台大法學論叢》，40 卷 3 期，頁 918。

125 李建良（2014），〈「狀態責任」概念之辯正與運用：《台中大里區段徵收土地掩埋物清理案之一》—最高行政法院 102 年度判字第 370 號判決、台中高等行政法院 99 年訴字第 268 號判決重點評析〉，《台灣法學雜誌》，246 期，頁 48-50。

126 林三欽（2014），〈土壤汙染行為人責任之繼受與法律溯及適用－簡評大法官解釋第 714 號解釋〉，《法令月刊》，65 卷 1 期，頁 65-11-65-12。

doi:10.6342/NTU202000774

即使是因不可抗力之天然災害、意外事件而導致物的狀態有危險性，亦可能成立狀態責任；又狀態責任僅以物的狀態作為連結要素，可能將導致過苛的結果，對此現象，有認為該危險的原因應為大眾承擔之風險，然而如此解釋，將與因果關係之問題混為一談之嫌；另有認為，應等同非責任人處理，惟如此解釋將與行政法責任體系相互混淆，故有學理認為較為可行之方法，係透過裁量瑕疵理論及運用比例原則之禁止過度法理，於個案中加以調和較為妥當[127]。

（二）狀態責任無「因果關係」之判斷

狀態責任是針對源自於物的危險之排除，一種是來自於物本身的屬性；另一種是來自於其物於空間上所處之位置，故狀態責任之危險發生並不生因果關係之判斷，既無行為，亦無從判斷因果關係[128]。

（三）狀態責任之主體來源

負狀態行為的主體，通常是物之所有權人及物之使用人（事實上有管領力之人），「所有權人」的概念可從民法第 765 條規定[129]加以理解。除所有權人單一情況之外，尚可能有所有權人複數情況（共有之情形），亦能從民法物權編第四章共有加以理解，蓋所有權人對物所負之狀態責任範圍，應以該所有權之範圍作為其責任範圍。

---

[127] 李建良（2008），〈論行政法上「責任」概念及責任人的選擇問題—兼評最高行政法院 93 年度判字第 628 號、95 年度判字第 1421 號判決及其相關判決〉，《2007 行政管制與行政爭訟》，頁 56，台北：中央研究院法律學研究所籌備處。

[128] 李建良（2008），〈論行政法上「責任」概念及責任人的選擇問題—兼評最高行政法院 93 年度判字第 628 號、95 年度判字第 1421 號判決及其相關判決〉，《2007 行政管制與行政爭訟》，頁 56-57，台北：中央研究院法律學研究所籌備處。

[129] 民法第 765 條：「所以人於法令限制之範圍內，得自由使用、收益、處分其所有物，並排除他人之干涉」。

doi:10.6342/NTU202000774

另外，物的使用人亦可能作為狀態責任之主體，其所負之狀態責任應侷限以該物之實際支配範圍為限始為合理，行政機關應查明該物之使用人實際管控之範圍為何，始得正確認定其狀態責任[130]。

然而，尚值得注意者乃「物之使用人」此一概念應如何界定，蓋其界定之範圍將牽涉認定狀態責任之歸屬為何，行政及司法實務見解，對於使用人經常認為是「做成違規使用之人」，即是以「使用人」作為理解，然實務上如此解釋將會變成「使用人要承擔行為責任」之結果，進而實務見解[131]對於個案的處理，建立起所有權人非「違規行為人（使用人）」時，即應優先處罰行為人，第二次再查獲違規，則視情形併罰所有權人之制式處理方式，似乎只是對於處罰所有權人之要件更加嚴格認定，並含有使用人將為違規使用負責之意，然學理認為，重點在於建立起何為狀態責任下「物之使用人」之概念，應判斷「該人對於土地或建築物本身具有支配之實力」，只有該物有支配之實力之人才能有效維護物的安全狀態，進一步法律才能賦予該人對物的安全狀態之維護義務及危險排除義務[132]。該學理見解對於狀態責任之使用人概念十分合理，且符合狀態責任之本旨，本文從之。

---

130 李建良（2008），〈論行政法上「責任」概念及責任人的選擇問題—兼評最高行政法院 93 年度判字第 628 號、95 年度判字第 1421 號判決及其相關判決〉，《2007 行政管制與行政爭訟》，頁 58，台北：中央研究院法律學研究所籌備處。

131 最高行政法院 95 年 1 月份庭長法官聯席會議決議，決議文：「依 84 年 8 月 2 日修正公布之建築法第 90 條第 1 項（相當於現行建築法第 91 條第 1 項第 1 款）之規定，對於違反同法第 73 條後段（相當於現行建築法第 73 條第 2 項）規定擅自變更使用者，其處罰之對象為建築物所有權人或使用人。建築主管機關究應對建築物所有權人或使用人處罰，應就其查獲建築物違規使用之實際情況，於符合建築法之立法目的為必要裁量，並非容許建築主管機關恣意選擇處罰之對象，擇一處罰，或兩者皆予處罰。又行政罰係處罰行為人為原則，處罰行為人以外之人則屬例外。建築主管機關如對行為人處罰，已足達成行政目的時，即不得對建築物所有權人處罰。於本題情形，擅自變更使用者為乙，如建築主管機關已對乙處罰，並已足達成行政目的時，即不得對甲處罰」。。

132 蔡宗珍（2011），〈建築法上義務人之類型與具體義務人之判定：行政法上行為責任與狀態責任問題系絡的一個切面分析〉，《台大法學論叢》，40 卷 3 期，頁 921-923。

doi:10.6342/NTU202000774

（四） 狀態責任可藉由拋棄物之權利使責任消滅

因狀態責任之成立係以對物所有權作為聯繫之基礎，一旦喪失物之所有權，將導致狀態責任人與其應相連接之物喪失聯繫，此時狀態責任人即可脫免於狀態責任，然需注意者，狀態責任人即使可藉由拋棄物之權利而使其所附之狀態責任消失，尚可能另構成或新成立「行為責任」[133]。

另外，若違反行政法上狀態義務人，將其物之所有權以「移轉方式」至第三人時，原所有權人喪失物之所有權而狀態責任歸於消滅，然受移轉之第三人本於與該物新的所有權連結關係，須對該物負有狀態責任，乃是在前手狀態責任消滅之後，「新生」之狀態責任[134]，此種情況是否涉及屬義務概括繼受之態樣？此爭議於本文第三章、第二節詳述之。

三、 緊急責任

當人民非行為責任主體亦非狀態責任人之主體時，亦有可能受有秩序行政法之規制，此種類型稱之為緊急責任人，亦可以稱非妨害人之責任，其原因在於國家為了有效防範、排除危險之下，在不得已之情況不得不要求非責任人負擔排除危險之義務，其適用之情況屬例外，且因義務之課予非該緊急責任人所可歸責者，是以緊急責任之實施必須受較嚴格之比例原則限制（例如現時發生的重大危險、國家無法自行或命行為或狀態義務人採取措施或者是即使採取措

[133] 李建良（2008），〈論行政法上「責任」概念及責任人的選擇問題—兼評最高行政法院 93 年度判字第 628 號、95 年度判字第 1421 號判決及其相關判決〉，《2007 行政管制與行政爭訟》，頁 58，台北：中央研究院法律學研究所籌備處。

[134] 李建良（2008），〈論行政法上「責任」概念及責任人的選擇問題—兼評最高行政法院 93 年度判字第 628 號、95 年度判字第 1421 號判決及其相關判決〉，《2007 行政管制與行政爭訟》，頁 57-58，台北：中央研究院法律學研究所籌備處。

doi:10.6342/NTU202000774

施亦無效果、對緊急責任人需具有期待可能性、義務之時間長短及範圍必須有所限制），始為正當[135]。

參、行政法責任與行政秩序罰之區辨

一、以秩序行政脈絡以觀，兩者乃屬不同階段之概念

藉由上述說明可理解「行為責任」及「狀態責任」乃「秩序行政」對於人民課予義務之正當性基礎及原因依據，違反此責任將會產生「義務」以排除責任違反後產生之危險，是以**行為責任與狀態責任的存在及區分目的，係在判定人民負有何種責任、責任主體是誰，至於違反責任將產生之「效果」，則是行政法之「義務」之範疇**，該「義務」種類中可能包括「行政處罰」此種類型的存在，又「行政處罰」係針對「行為」違反法規所課予之行為責任下之「制裁」[136]，若是負有狀態責任之人，其違反狀態責任規定時因無「行為」存在，故無法以「行政處罰」對狀態責任人制裁，但非謂狀態行為人違反其維護物狀態之責任完全不生任何後果，蓋可能負有依法排除違規狀態之義務存在[137]。另外尚需注意，違反狀態責任後所產生之「排除危險之義務」，若人民對該排除危險之義務亦不加以履行，則此義務之違反可能使行政機關以行政執行手段迫使其履行、抑或是在法律有明文下以行政罰之方式非難其不為排除危險義務之行為。

---

135 李建良（2008），〈論行政法上「責任」概念及責任人的選擇問題—兼評最高行政法院 93 年度判字第 628 號、95 年度判字第 1421 號判決及其相關判決〉，《2007 行政管制與行政爭訟》，頁 59-60，台北：中央研究院法律學研究所籌備處。

136 從行政罰法第 1 條：「違反行政法上義務而受罰鍰、沒入或其他種類行政罰之處罰時，適用本法。但其他法律有特別規定者，從其規定。」及第三條：「本法所稱行為人，係指實施違反行政法上義務行為之自然人、法人、設有代表人或管理人之非法人團體、中央或地方機關或其他組織。之脈絡，可知行政罰法乃針對「行為」（作為、不作為）加以制裁之規範。

137 蔡宗珍（2011），〈建築法上義務人之類型與具體義務人之判定：行政法上行為責任與狀態責任問題系絡的一個切面分析〉，《台大法學論叢》，40 卷 3 期，頁 924-925。

doi:10.6342/NTU202000774

二、以定義及內涵以觀，兩者亦屬完全之概念

我國在使用「狀態責任」之概念時，往往會與行政罰法中的「責任」要件加以混淆，前者之責任係指負有行政法義務之原因、基礎，並不問其主觀要件；後者之責任則屬行政罰成立之要件之一，係指行政罰之行為人以其生理原因及心理原因，判斷有無辨識其行為違法之能力以及依其辨識而行為之能力，且行政罰之責任要件尚必須與行為人之故意或過失之咎責要件一同判斷，是以兩者乃截然不同之定義及內涵[138]，不應混淆之。

肆、行政法上責任與義務之體系辨析

如上所介紹行政法之義務與責任，釐清兩者之概念及內涵後，最重要者乃串連起其在行政法體系的定位，乃有助於後續對於繼受制度之思考。以下以事件脈絡進程，作為分項解析[139]：

一、階段一：尚處秩序行政法依據

關於此階段，由於國家在進行危險之排除及防禦時，本於法治國原則下之法律保留原則實踐，必須對於預想之危險態樣、情境加以明確描述於法規範

---

138 洪家殷（2008），〈行政罰之狀態責任及一行為不二罰原則—臺北高等行政法院九六年訴字第一二八八號判決簡評〉，《台灣法學雜誌》，104 期，頁 330；廖義男（2008），《行政罰法》，2 版，頁 92，台北：元照。

139 林昱梅（2015），〈土壤污染行為人整治責任概括繼受之法律問題－以德國法之比較為中心〉，《東吳法律學報》，26 卷 3 期，頁 49；李建良（2006），〈行政法上義務繼受問題初探－兼評高雄高等行政法院九十二年度訴字第八○六號判決暨最高行政法院九十四年度判字第六二二號判決〉，《2005 行政管制與行政爭訟》，頁 80-81，台北：中央研究院法律學研究所籌備處；蔡靜娟（2009），《行政法上義務人死亡義務繼受之研究》，國立中正大學法律學研究所碩士論文，頁 21-22。

doi:10.6342/NTU202000774

內，以便人民可預見其行為何者將違反行政權之管制。然而在此階段，尚以不特定之人作為抽象性規範之對象，還未有任何危險發生，亦未出現該當於行政法之責任人，當然亦無具體義務內容。

二、階段二：構成行政法上抽象責任

此階段則是危險已經發生，已有符合、該當於秩序法規範的事件發生，若是人的行為引發了公共秩序的危害，則其行為人產生行為責任；若是物的狀態產生對社會安全之危險，其物之所有人抑或實際支配物之人則產生狀態責任。申言之，該階段而言已有「責任人」之誕生，屬於行政法義務存在前之正當性階段，涉及行政機關判斷是否有責任及何人是負起責任之對象，此階段雖有符合秩序行政法規範之構成要件之事件，但行政機關尚未進一步明確認定、確認誰負有承擔違反責任下之義務及其義務內容。又因行政機關並未以具體對外法性之行政行為（行政處分）加以定型義務人及義務內容，故學理對此階段，有稱之為「抽象警察義務」(惟有學理為避免與「階段三」相混淆，認為宜稱之為「抽象警察責任」)，故本文對此階段，以「抽象行政責任」稱之。

三、階段三：發生具體行政法上義務

此階段是在具備階段一及階段二之「發動干預之行政法依據」及「對於該危害發生應負責之責任人」此兩者基礎之下，行政機關進一步以行政處分具體化負有義務之主體及義務履行內容，使危害社會秩序之危險得以在此階段透過行政機關具體之規制，課予特定人民透過具體義務之履行，達成維護社會秩序與公共安全之目的。此階段學理亦稱之為「具體警察義務」，而本文對此階段以「具體行政義務」稱之。

doi:10.6342/NTU202000774



doi:10.6342/NTU202000774



doi:10.6342/NTU202000774

第三章　義務概括繼受之要件及法依據探討

第一節　概括繼受義務思考脈絡及制度要件

透過上述對於公法上義務繼受之憲法層次比例原則探討，可得知公法上之義務繼受的思考，涉及者兩個利益之拉扯，分別是國家整體法秩序之永續維護之利益，及對於繼承人對於其財產權、一般行為自由受有保障之利益間拉扯。職是之故，對於公法上義務繼受要件的思考必須切合上開比例原則之思考，抽絲剝繭出行政權對於公益之貫徹以及繼承人基本權利侵害的合理界線，以該界線作為概括繼受要件之法規範基礎，始為妥當。

是以，以下整理我國學理對公法上義務繼受的思考層次與一般抽象要件，分別說明之。

第一項　發生繼受事實

本文欲探討者乃對於「概括繼受」公法上義務之議題，概括繼受之發生，係出自於法律事實發生，始產生概括繼受之效果，此階段乃開啟概括繼受程序、效果不可或缺之第一步。概括繼承事涉權利義務的移轉之事件發生，而此事件之規範，屬民法（私法）層面的問題[140]。是故，自然人發生概括繼受時，參考民法第 1147 條之規定[141]，以「死亡時」作為概括繼承發生事由，故自然人

[140] 李建良（2006），〈行政法上義務繼受問題初探－兼評高雄高等行政法院九十二年度訴字第八○六號判決暨最高行政法院九十四年度判字第六二二號判決〉，《2005 行政管制與行政爭訟》，頁 88，台北：中央研究院法律學研究所籌備處。

[141] 民法第 1147 條：「繼承，因被繼承人死亡而開始」。

doi:10.6342/NTU202000774

部分之概括繼受以「死亡時」作為發生繼受之事實，由民法上所規範[142]具備繼承適格之「繼承人」受有概括移轉之權利及義務。

就法人概括繼受部分，則是參考公司法[143]之公司將概括繼受之原因為「公司吸收合併」或「新設合併」而消滅，作為法人概括繼承事由，並且由其存續或新設之公司對於因合併而消滅公司的權利義務加以繼受。

再者就非法人團體部分，就獨資、合夥團體亦有可能有概括繼受的事由，依照民法第 306 條[144]的規定，與法人的概括繼受原因類似，也可能因合併而發生概括繼受權利義務。

第二項　義務具備「可繼受性」

確定已發生繼受事實之後，接著即是要確認該義務是否具備可繼受性，所謂可繼受性，又可稱為義務具備「移轉能力」、「繼受能力」或「繼受適格」，此階段的思考，係著墨於被繼承人在繼承事由開始前其所負擔之義務，到底該標的是否具有可繼受、可移轉性，而具「被繼受之資格」[145]。若確認不具備可繼受移轉性而無被繼受之資格，該義務則不生移轉於繼承人之效果，無須為後續繼受要件的思考。

---

142 民法第 1138：「遺產繼承人，除配偶外，依左列順序定之：「一、直系血親卑親屬。二、父母。三、兄弟姊妹。四、祖父母」；民法第 1139 條：「前條所定第一順序之繼承人，以親等近者為先」。

143 公司法第 75 條：「因合併而消滅之公司，其權利義務，應由合併後存續或另立之公司承受」。公司法第 316 條之 1 條：「股份有限公司相互間合併，或股份有限公司與有限公司合併者，其存續或新設公司以股份有限公司為限。股份有限公司分割者，其存續公司或新設公司以股份有限公司為限」。

144 民法第 306 條：「營業與他營業合併，而互相承受其資產及負債者，與前條之概括承受同，其合併之新營業，對於各營業之債務，負其責任」

145 李建良（2006），〈行政法上義務繼受問題初探－兼評高雄高等行政法院九十二年度訴字第八○六號判決暨最高行政法院九十四年度判字第六二二號判決〉，《2005 行政管制與行政爭訟》，頁 89，台北：中央研究院法律學研究所籌備處。

doi:10.6342/NTU202000774

考量義務是否具有可移轉、繼受性，而具備繼受能力，首先須先思考該義務是否已成熟、明確到可以被繼受之程度，以及該義務是否屬非一身專屬性之性質，也即該義務不具備一身專屬性之特徵，使繼承發生後仍然可移轉給繼承人加以負擔、履行。

壹、該義務須為「具體行政法上義務」

可被繼受的義務必須為「明確、具體」之內容者，為何限制「義務」需具備「具體、明確」始具有繼受能力之理由，應有兩個層面之考量，一個層面為對於繼承人而言，其必須受有移轉一明確、具體標的內涵之義務，始能就該義務加以履行，否則將使義務繼承人無所適從其應如何履行。

另一個層面，則為避免國家對於人民應負之義務濫行認定，必須先有一具體、個別性之公法上義務，始對於何人屬該義務之義務人乃一目了然，可據以認定「義務人」、「義務人之繼承人」，進而使機關發生錯誤認定主體的情況降到最低；且尚有最重要的原因在於，國家課與人民基本權利之限制（公法上義務）時，必須是基於法律明文規定，且該主體亦屬該法規範中所描述、規制之責任主體，本於立法權因無法因應社會事實的多變、個案情況的適度調整，因而賦予行政權具體認定該義務為何之權責，透過行政機關將抽象的法規範在切合行政法之原理原則之思量下，以具體、特定之行政處分作成方式，使義務人、義務標的內涵具體規制於公法秩序。只有經過行政機關本於抽象法規範而對該當要件之具體社會事實，作出具體判斷其後果之公法上義務，始有讓繼承人概括繼受而履行之正當性，避免抽象責任不斷擴大。

doi:10.6342/NTU202000774

進一步言之，行政法之義務，就其時序進程可分類為「階段一」：尚處秩序行政法依據、「階段二」：構成行政法尚抽象責任及「階段三」：發生具體行政法上義務[146]。在「階段一」時，人民所負擔者，尚單純處於行政法規範中抽象規範，也就是任何人皆負有義務，使其行為或其支配物之狀態不至於對公共安全及秩序造成妨害或干擾，在此階段下人民與國家之間尚無發生任何法律關係存在，故既然該階段無法律關係存在，亦當然無繼受之可能[147]。

在「階段二」部分則尚有爭議，因該階段已發生實際的危害，使法律上之規範於社會事實中實現，此時已浮現「責任主體」，構成主管機關可對於人民課予防止危害義務之基礎，然而該階段是否具備可繼受性，肯定者係基於主管機關之處分不過是對於原本已存在之危險排除義務加以確認，以方便成為執行名義而行政執行之；然否定說認為，秩序行政法中所設有之義務，僅為對主管機關授權之基礎，人民對於國家是否有具體義務之存在，乃於主管機關對於該人民做出具體之行政處分為限，未經行政處分加以具體化之責任，應根本否定其可繼受性[148]。本文認為，否定說符合秩序行政法下之脈絡觀點及人民基本權利之保障，肯定說對於人民課予義務負責之時點，似乎認定過於草率，蓋義務主體之認定與標的內容之斟酌，皆需仰賴主管機關對於實際情況的調查與判斷，以作成行政處分，且此等課與義務之行政處分亦非確認性質，而是下命性質之行政處分。故若人民尚處於階段二的情況，只處於「義務存在的正當性前提」地位，此種「正當性前提」並非具體而仍處抽象之程度，應不具備繼受能力。尚須注意者，雖原則上只有具體行政法上義務具有可繼受性，但不代表抽象行

146 詳細內容，參見本文第二章、第二節、第三項、肆、行政法上責任與義務之體系辨析。
147 李建良（2006），〈行政法上義務繼受問題初探－兼評高雄高等行政法院九十二年度訴字第八○六號判決暨最高行政法院九十四年度判字第六二二號判決〉，《2005 行政管制與行政爭訟》，頁91，台北：中央研究院法律學研究所籌備處。
148 李建良（2006），〈行政法上義務繼受問題初探－兼評高雄高等行政法院九十二年度訴字第八○六號判決暨最高行政法院九十四年度判字第六二二號判決〉，《2005 行政管制與行政爭訟》，頁91-93，台北：中央研究院法律學研究所籌備處。

doi:10.6342/NTU202000774

政法上責任完全無被概括繼受之餘地，若立法者考量其立法背景事實、涉及侵害之基本權利及欲維護之公益，仍可能以法規範明文抽象行政法上責任成為概括繼受之標的，因抽象行政法上責任並非已成立於國家與人民之間的具體法律關係，此種概括繼受抽象責任之規範，勢必在比例原則的檢驗上，更加嚴格判斷其追求之目的是否為重大公益，以及手段是否為適當且屬最小手段性，使公益與私益的衡量不失公平。

「階段三」則是行政機關已對於具體發生之危害事實，以行政處分對於特定義務人轉化課與具體義務之階段，此階段係已發生危害，且行政機關已透過行政調查及合義務裁量對於誰應負有義務、負有義務之內容為何具體判斷、說明之，故該階段之人民，除了具備成立義務之正當性基礎（責任）以外，行政機關亦本於該基礎課予該責任人應如何處理之具體之義務內容及主體地位，故該等義務已明確具體致使繼承人得加以繼受之，具備可繼受性。

貳、該義務不具備一身專屬性

一、一身專屬性之「判斷標準」

待確定義務已由行政機關加以具體化，屬「具體行政義務」，則進一步尚須判斷該義務本質上是否非一身專屬性，蓋「非一身專屬性」作為是否具備繼受能力之要求，其正當性基礎已如前述[149]，係來自對繼承人基本權利限制之比例原則「適當性要件」之要求，如何判斷該是否具備「一身專屬性」，學理曾提出許多判斷之方法，有認為取決於是否為行政裁量、義務內容為行為義務或是結果義務、義務可否具可替代性、係對物義務或是具有財產價值之義務、義務歸

[149] 參見本文第二章、第一節、第四項、貳、三、(二)、2. 手段之適當性原則審查。

doi:10.6342/NTU202000774

責事由可否或可能及於繼受人之判斷方式，然以上各個判斷方法均有其偏頗之處，因行政機關對於義務裁量與否，對於該義務是否具有一身專屬性毫無任何關聯；可代替之義務僅可作為判斷無一身專屬性之表徵；行為與結果義務之區分並非徑渭分明，以該不明確之概念區分有無一身專屬性尚有疑義；又歸責事由是否能及於繼受人之判斷，則混淆了義務之實質正當性與繼受制度兩者，蓋此兩者並無必然關聯性，因義務之繼受人本來就不需具備義務地位[150]。

故學理認為，是否具備一身專屬性之判斷應以**憲法比例原則之角度**加以觀之，也即判斷該義務是否與義務人緊密連結，以至於該義務人轉換時，將使原本義務之課予之法律目的無法達成，若為肯定則該義務屬於一身專屬性；反之若為否定則不具備一身專屬性，即使義務人加以轉換，亦可達到原本之目的，則此等義務具備繼受能力，得由其繼承人繼受[151]。本文肯定該學理之判斷，以比例原則適當性要件出發，可較全面性之判斷該義務是否具備一身專屬性與否而不偏頗。

二、一身專屬性之「消滅」

所謂一身專屬性之消滅，概念上乃是指具有一身專屬性的法律關係發生「特定情形、條件」，將使「一身專屬性」的性質消滅，轉變為「非一身專屬性」之法律關係。質言之，討論一身專屬性之義務消滅的「實益」在於，若發生一身專屬性消滅之事由，將使不具可繼受性之義務，轉變成為可繼受性之非一身專屬性義務，因而義務人之繼承人原無須概括繼受義務，卻在發生一身專

[150] 李建良（2006），〈行政法上義務繼受問題初探－兼評高雄高等行政法院九十二年度訴字第八○六號判決暨最高行政法院九十四年度判字第六二二號判決〉，《2005 行政管制與行政爭訟》，頁95-99，台北：中央研究院法律學研究所籌備處。

[151] 李建良（2006），〈行政法上義務繼受問題初探－兼評高雄高等行政法院九十二年度訴字第八○六號判決暨最高行政法院九十四年度判字第六二二號判決〉，《2005 行政管制與行政爭訟》，頁99，台北：中央研究院法律學研究所籌備處。

doi:10.6342/NTU202000774

屬性消滅之事由後，須加以概括繼受該義務，對其繼承人之影響可說是十分重大。據此，探究一身專屬性此種性質消滅的「事由」顯得尤其重要。以下整理三個實務及學說上討論一身專屬性消滅之事由，並評論有無作為一身專屬性消滅事由之正當性、合理性。

（一）行政處分形式存續力

1. 形式確定力之概念

行政處分之「形式確定力」又稱之為「形式存續力」、「不可爭力」或「不可撤銷力」，係指對於行政處分之相對人或是處分的利害關係人加以拘束其不得就該處分尋求法律救濟，發生形式確定力的原因，主要情形來自於，未在法定期間內提起行政爭訟救濟、上訴；判決經終審法院確定；當事人於救濟程序中放棄救濟權利[152]。由此可知，對於「形式確定力」其存在之法理基礎乃著重「法安定性之維護」，俾使行政處分在一定期間、情況下即確定，處分相對人及利害關係人即不得再為爭執之，使公法之法律關係趨於穩定，然而此種法安定性之維護並非絕對，尚須考量法正確性之衡平追求，故有例外，例如：原處分機關或上級機關在處分具有形式確定力後，得依職權為撤銷[153]，或是在一定情況下人民主張程序再開[154]。

---

[152] 洪家殷（2006），〈行政行為（二）－行政處分：第三講 行政處分成立與效力〉，《月旦法學教室》，41 期，頁 47。

[153] 行政程序法第 117 條：「違法行政處分於**法定救濟期間經過後**，原處分機關得依職權為全部或一部之撤銷；其上級機關，亦得為之。但有下列各款情形之一者，不得撤銷：一、撤銷對公益有重大危害者。二、受益人無第一百十九條所列信賴不值得保護之情形，而信賴授予利益之行政處分，其信賴利益顯然大於撤銷所欲維護之公益者。」

[154] 行政程序法第 128 條：「行政處分於**法定救濟期間經過後**，具有下列各款情形之一者，相對人或利害關係人得向行政機關申請撤銷、廢止或變更之。但相對人或利害關係人因重大過失而未能在行政程序或救濟程序中主張其事由者，不在此限：一、具有持續效力之行政處分所依據之事實事後發生有利於相對人或利害關係人之變更者。二、發生新事實或發現新證據者，但以如經斟酌可受較有利益之處分者為 限。三、其他具有相當於行政訴訟法所定再審事由且足以影

doi:10.6342/NTU202000774



2. 釋憲實務認為形式確定力具有使一身專屬性消滅之效力

然而，在釋字第 621 號解釋之彭鳳至、徐璧湖、許宗力、林子儀大法官協同意見書中，其認為：「依法生效之行政處分因不可抗爭而確定，稱為行政處分之不可爭力，學說上亦有稱為形式確定力者。其態樣……。訴願或行政訴訟進行中，當事人死亡而無人承受其訴願或訴訟者，則訴願或訴訟事件一經駁回確定，**系爭行政處分即隨之確定，並持續其效力。縱使法律明定此種行政處分不予執行，或因執行不可能而不予執行者，均非已生效之行政處分當然失效**。此與刑事訴訟進行中，法院因被告死亡而依刑事訴訟法第三百零三條第五款前段規定，諭知不受理之判決者，即無從為刑之宣告之情形不同。所謂「違規行為人於罰鍰處分之行政訴訟程序中死亡者，其當事人能力即行喪失。尚未確定之罰鍰處分，對該違規行為人也喪失繼續存在之意義而失效，實屬誤會」。

該號協同意見書似認為，一旦行政處分具備形式確定力後，即可持續該處分之效力，不論確定後其處分相對人是否死亡，均不影響該處分之效力。進而可推知，大法官在此認為行政處分之形式確定力，將會使處分賦予「財產性」之特徵，不論行政處分之內涵是否為一身專屬性之義務，只要處分一確定，效力不受處分相對人死亡而影響。換言之，若是一身專屬性義務之處分，一經確定，即使義務人死亡，該處分之效力亦不因之影響，似乎肯定行政處分之形式確定力具有將一身專屬性義務「轉化」為不具有一身專屬性（一般財產性）之效力。

響行政處分者。前項申請，應自法定救濟期間經過後三個月內為之；其事由發生在後或知悉在後者，自發生或知悉時起算。但自法定救濟期間經過後已逾五年者，不得申請。」

doi:10.6342/NTU202000774

3. 本文見解──形式確定力無法使一身專屬性質消滅

仔細探究，形式確定力其法理乃從「法安定性」出發，係拘束人民其爭執行政行為之效力，並無「轉化處分本身的性質」之正當性，使一身專屬性義務「轉變」為一般財產性之效力。且換個角度思考，一個具有一身專屬性義務之處分，因為已判決確定或是法定救濟期間經過等等原因導致具備形式確定力，僅僅改變該處分可爭執、可救濟性之有無，惟處分本身並不會因為義務人不能再爭執該處分合法性，使處分內涵產生「質變」之效果。據此，一身專屬性義務的處分確定後仍然是一身專屬性義務之處分，並不會因此成為一般財產性義務之處分。若處分相對人在處分確定後死亡，承前段所述，一身專屬性義務標的必須與特定義務主體兩者皆存在，始有該處分存在於法律世界之實益，即使在處分具備形式確定力而不得加以爭執，該義務仍因欠缺義務主體之存續而失其效力，進而處分歸於消滅，故形式確定力並無阻卻、拘束處分之實質存續力失效的效果。

（二）行政處分之作成

1. 學理見解

學理有認為一身專屬性之義務，可參考民法第 195 條第 2 項[155]之規定，在契約承諾或起訴之情況下，即可將一身專屬性之義務具體化為一般財產性之義務，則在公法領域中，對於已由行政機關 「作成行政處分」具體化之一身專屬性義務，亦能如同上開民法第 195 條第 2 項之規定，而轉變為一般財產性之義

[155] 民法第 195 條第 2 項：「前項請求權，不得讓與或繼承。但以金額賠償之請求權已依契約承諾，或已起訴者，不在此限」。

doi:10.6342/NTU202000774

務[156]。



2. 本文見解──行政處分的作成無法使一身專屬性質消滅

上開學理尚待檢討，蓋私法領域中「權利的實現及義務的履行」的發生，最典型者乃依循於民法第 199 條[157]之「債權人請求給付」方式而發生，在債權在尚未請求前，權利義務關係尚處於「潛在」的程度，此時義務只具有一般性，權利人尚未得對於特定義務人拘束其應履行何種義務內涵之地步[158]。然而，待權利人本於民法第 199 條賦予義務人以請求給付之意旨，依照具體適用之法律關係之請求權基礎，向相對人主張其權利時，被請求之相對人即產生具體法律關係的義務人地位，此私法領域之義務，法律並不會對此主動採取行動，而是取決於**權利人之行使**與否，然而權利人一旦決定行使權利，法律將會賦予權利人得向法院訴請履行之請求力；一定情況下得聲請強制執行之執行力；保有給付之法律上原因之保持力，使私法上之權利義務關係得以實現[159]。由此可知，私法領域之義務在不同的階段，有著不一樣的態樣。

然而若權利人尚未對於義務人請求給付之前，義務人即依債之本旨提出債務之給付，雖然權利人尚未行使其給付之請求，然雙方間的權利義務關係已成立，只是具體的權利義務關係**尚處潛在未顯化**，債務人所提出之給付不會成立不當得利，因兩者間法律關係已成立，乃屬「有法律上原因之給付」，只是債權人尚未行使其給付之請求權。

---

156 姚其聖（2015），〈公法上金錢給付義務人死亡如何執行〉，《全國律師》，19 卷 10 期，頁 92。

157 民法第 199 條：「**債權人基於債之關係，得向債務人請求給付**。給付，不以有財產價格者為限。不作為亦得為給付。」

158 王澤鑑（2014），《民法總則》，增訂新版，頁 106，台北，自刊。

159 王澤鑑（2013），《民法概要》，4 版，頁 162，台北，自刊；王澤鑑（2012），《債法原理－基本理論：債之發生、契約、無因管理》，3 版，頁 21-24，台北：自刊。

doi:10.6342/NTU202000774

公法領域中義務之產生，與私法領域的思考有所不同。仔細觀之，私法上義務的私法自治、權利義務間具有相互平等之特徵，反之，在公法上之義務，是具有上下、高權性特徵，兩者之差異，更顯現出人民對國家的義務產生與否勢必需要比私法上義務更加謹慎。是以，在義務的規制上，國家與人民之間具備權利義務之公法上法律關係與否，應無法容有「潛在」權利義務關係之空間存在，猶如本文前述[160]所分析，公法上（秩序行政）義務形成的過程，先從最抽象的行政法規範的明文；到人民的行為構成了法規範上的要件，而成為主管機關即將作出規制之責任人地位程度；最後則是主管機關針對個案作出應如何具體規制義務的內涵之義務人程度。上開義務產生的進程，只有在最後者之階段中，行政機關對於人民發出具體規制（作成書面行政處分並送達時），始產生公法上權利義務關係，在處分作成前，即使違反秩序行政規範之人民構成法規範所不容許之行為，產生行政法上責任人之地位，這種地位不代表即與國家產生潛在的權利義務關係。舉例而言，若是人民違反行政法義務，在國家尚未對人民作成罰鍰處分以前，該人民若自動向國家繳納罰鍰額，國家對此筆罰鍰額之受領，既然尚未作成罰鍰處分，則國家與人民間根本無權利義務關係成立而存在，故此受領不具備「公法上原因」，將產生國家對人民之不當得利返還義務。由此可知，在公法領域中，行政機關對於人民「作成行政處分」規制其所應負擔的義務，乃公法上權利義務之「創設」、存在法律世界之「開始」，而非對已存在的法律關係，從潛在轉變為具體的請求給付之性質。

據此，該學說以「行政機關作成處分」其性質相比擬為民法上「權利人請求給付」，兩者法理、性質上均不同，無法作為一身專屬性消滅之事由。更何況如此解釋，行政法上之義務將根本無一身專屬性性質之存在，而只有剩下非一

[160] 參照本文第二章、第二節、第三項、肆、行政法上責任與義務之體系辨析。

doi:10.6342/NTU202000774

身專屬性之義務，殊非的論。



（三）已起訴或是已契約承諾

1. 學理見解

學理見解有認為，對於立法例上，既然民法第 195 條第 2 項之意旨，對於一身專屬性之金錢賠償請求權若已「依契約承諾」或「已起訴」，具有將一身專屬性之義務轉變成非一身專屬性效果，則在公法上一身專屬性消滅的思考，亦能參照民法第 195 條第 2 項之「已契約承諾」或「已起訴」之事由，使欠缺一身專屬性之義務具體化，進而具備可繼受性[161]。

2. 本文見解──僅適用於國家賠償責任

公、私法兩者之間的法理若能有共通之基礎者，不妨就法規範欠缺明文者，援用共通之法理，以求法律整體之平等性及和諧性。是以，在探究公法與私法規範間能否相互援用，勢必先對於兩者援用之基礎法律性質，判斷有「無同質性」存在，有此種同質性存在，始有援用另一法規範的正當性、合理性存在。

首先探討民法第 195 條第 1 項之民法上一身專屬性之精神慰撫金請求權，其乃民法之侵權行為法下的一環，適用於侵害他人之人格法益，所生之非財產上損害賠償請求權，此種請求權之特徵在於，其所填補者，乃非財產上（精神

[161] 姚其聖（2015），〈公法上金錢給付義務人死亡如何執行〉，《全國律師》，19 卷 10 期，頁 92。

doi:10.6342/NTU202000774

上）之損害，此種損害之填補相較於財產上之損害填補，最大的差異在於，此種請求權的主張，乃取決於被害人精神上之觀感、感受，勢必經由被害人本人加以對加害人主張，始能表現出精神慰撫金的存在實益，無法藉由被害人以外之人對加害人他人精神上之主觀感受、痛苦，故具備一身專屬性之特色。

立法者於民法第 195 條第 2 項設定「已契約承諾」、「已起訴」的情況，其一身專屬性之性質消滅的原因在於，被害人其精神慰撫金之主張，已有契約承諾或已起訴時，其抽象的精神損害，已由被害人本於感受其精神上之痛苦，進一步為契約訂定而雙方承諾，或是起訴時藉由起訴狀的記載，將該抽象損害具體化為明確可請求之金錢數額，既然該精神慰撫金的請求已藉由被害人本人以契約承諾、起訴之方式，加以主張其具體之賠償數額，則該請求即無須限制其後亦必須由被害人本人主張之，換言之，賦予精神慰撫金具有一身專屬性的考量，在被害人以契約承諾、起訴之後即無存在之實益。

反思於公法領域中之一身專屬性義務，是否能援用民法第 195 條第 2 項之已契約承諾、已起訴之事由，作為一身專屬性之消滅原因，在基礎法律性質之相比擬下，應該只有「國家賠償法之國賠責任」可援用民法第 195 條第 2 項之規定。蓋公務員因故意或過失因違法行使公權力導致人民的自由或權利遭到侵害，而受到侵害的人民的依循國家賠償法的規定主張國家賠償責任[162]，此種國家賠償責任性質上實屬乃公法上之侵權行為，且依國家賠償法第 5 條規定：「國家損害賠償，除依本法規定外，適用民法規定」，可合理推論，國家賠償法的性質與侵權行為的性質雷同，國賠法規亦已明文本法未規定之部分適用民法，則在國家賠償法的領域對於具有一身專屬性之損害賠償之債者，例如公務員故意

[162] 國家賠償法第 2 條第 2 項：「公務員於執行職務行使公權力時，因故意或過失不法侵害人民自由或權利者，國家應負損害賠償責任。公務員怠於執行職務，致人民自由或權利遭受損害者亦同」。

doi:10.6342/NTU202000774

或過失違法行使公權力造成人民的人格法益受損害時，人民對於國家的國家賠償請求權，性質上即具備一身專屬性，須由被害人民加以主張之而無從概括繼受之，此種情況則有民法第 195 條第 2 項之類推適用，於已契約承諾或是已起訴之情況，一身專屬性之國家賠償請求權，將轉變成非一身專屬性。

除了國家賠償法，其他公法領域的一身專屬性義務，應無從援用民法第 195 條第 2 項之事由，使一身專屬性消滅，因為尚無其他種一身專屬性之義務與民法侵權行為之性質相類似者。本文認為，「已契約承諾」、「已起訴」此兩種事由應僅能適用於國家賠償之一身專屬性義務。

尚須注意者，本文所探究的義務概括繼受內涵，為「人民對國家之義務」面向，然國家賠償責任，係屬於「國家對人民所生之義務」，故已契約承諾或是已起訴此種事由，無繼續討論於本文之義務繼受實益。

第三項　概括繼受義務之法律依據

關於概括繼受之法律依據，又稱為「繼受之法律要件」、「移轉之構成要件」，此法律上之基礎作為義務繼受之要件，乃來自「法律保留原則之要求」，蓋在干預行政下對於人民所課予負擔、干涉，必須對於在法規範有所說明。概括繼受義務之制度，無疑是對於繼受人之權利規制，故具有法律保留原則適用。然而法律保留適用的程度應該拘束至何種層次，以及我國法律依據規定為何，以下繼續探究之。

壹、概括繼受行政法上義務之法律保留思考

doi:10.6342/NTU202000774

一、法律保留原則概念

所謂「法律保留原則」係在十九世紀，歐陸出現自由憲法運動，而打破君主權力壟斷的局面，進而奠定權力分立後，法律保留原則採概念始萌芽，其目的在於分配立法、行政兩權的秩序分配，其思想法理，乃來自於法治國原則下對於保障人權的訴求，使行政權對於人民權利所發動的規制，須受到法律的拘束，而不再受到君王的恣意統治；另外一方面則來自於民主思想之議會支配作為根據的法律，乃來自於人民代表所組成的議會所參與制定，始具有足夠之民主正當性[163]。

法律保留原則對於如分配立法、行政兩者權限，有不同的理論，德國聯邦憲法法院對此有提出「重要性理論」，該理論的內涵為，對於一個措施是否重要，以至於立法權須自行以法律規定，或是至少有授權明確之前提下而交給行政權決定，則基本權利之保護則成為重要與否的參考依據，也就是說，凡與基本權利關係中關係重大的領域，通常可認定為重要，而事涉「基本權利之實踐」重要者[164]。法律保留原則的寬嚴判斷，在上開標準以基本權利之實踐是否重要，乃充分展現憲法保障人權思想的實踐，然而整部憲法對於國家的運作，尚不能僅關注個人，尚必須放眼於全體及公共事務，而精緻化擴充「法律保留檢核清單」，是以，重要性理論的衡量標準，除了考量人民「基本權利實現是否重要」；另外亦須衡量「公共事務性是否重要」，可參考的標準有：受規範人範圍之大小、影響作用的長短、財政影響之大小、公共爭議性之強弱、現狀改革幅度之擺盪大小、與現行法比較等等，使法律保留原則所關切的領域，除了個人價值取向（基本權利）以外，尚包括超個人價值取向（公共事務）之領域而

[163] 許宗力（2006），《法與國家權力》，頁 118-122，台北：元照。
[164] 許宗力（2006），《法與國家權力》，頁 158-159，台北：元照。

doi:10.6342/NTU202000774

彰顯現代憲法之整體價值[165]。

觀察我國法之規範，在中央法規標準法第 5 條[166]之規定，其所明定以法律制定之事項，以文義解釋觀察，似乎使我國對於法律保留要求的範圍十分廣泛卻死板，然而學理認為，對於中央法規標準法第 5 條之規範，不妨以功能結面向作為活性化解釋，應以法律定之的指示，依中央法規標準法第 5 條第 2 項之規定，其所指示「涉及人民權利、義務之事項應以法律定之」，該款解釋尚得與德國聯邦憲法法院所提出之重要性理論之基本權利重要性加以涵攝、解釋[167]。另外就中央法規標準法第 5 條第 3 款「涉及國家各機關組織事項」得就基本權利重要性及公共事務重要性兩者重要與否，作為該款具體化法律保留原則的考量、判斷，而最後一款之「其他重要事項之應以法律定之者」，則是將基本權與公共事務重要性兩者靈活運用於解釋法律保留事項的指向規範[168]。

二、我國學理對於概括繼受義務之法律保留程度上有爭議

探討「概括繼受行政法上義務」之法律保留原則之適用，就人民受有概括繼受保律保留之侵害態樣，依前述，在較常見的作為義務概括繼受中，將產生財產權及一般行為自由之限制，此種限制所造成基本權的侵害深淺程度，會依照具體案例而有所不同，然在限制的「原因」上，繼受人均是因「繼承事由之發生」所導致，也就是說，概括義務繼受無疑使繼受人因「繼受事由」之發生而使他人的義務移轉至自身，除了義務本身帶給繼受人財產權上或是一般行為自由之侵害、限制，最重要者，乃繼受人本身並不具備義務歸責事由，卻因概

165 許宗力（2006），《法與國家權力》，頁 185-195，台北：元照。
166 中央法規標準法第 5 條：「左列事項應以法律定之：一、憲法或法律有明文規定，應以法律定之者。二、關於人民之權利、義務者。三、關於國家各機關之組織者。四、其他重要事項之應以法律定之者」。
167 許宗力（2006），《法與國家權力》，頁 205，台北：元照。
168 許宗力（2006），《法與國家權力》，頁 205-206，台北：元照。

doi:10.6342/NTU202000774

括繼受事由發生，須承受該「非自身所惹起」的義務，勢必國家應對於人民概括繼受行政法上義務之效力，以法規範明文使人民繼受行政法上義務時，不致於遭到突襲而無法預見。

進而，將行政法義務概括繼受的態樣，置於重要性理論下檢視，無疑是對人民基本權利之限制，且關係重大，非屬輕微，立法者必須對於義務概括繼受此一事項**至少須有「法律」之位階加以規範**，始符合法律保留規範之意旨。

對於法規範上應對行政法上義務繼受加以明文，始符合法律保留原則之意旨，程度上此種繼受公法上義務之效果，然而究竟法律保留之程度究竟該如何，目前學理有不同之看法，有不同看法的爭議核心在於，**行政法律關係如何適用公、私法兩元法體系之根本問題**，也就是說民法等私法規範是否能作為公法之法律保留之依據，其見解分析如下[169]。

（一）直接適用民法之繼承制度

德國有學理認為，在德國民法中有關繼承的標的，係規定「一切財產（遺產）」，不以私法為限，尚包括公法上權利、義務在內，故該條不僅為私法上權利義務概括移轉至繼承人之法律依據，尚可直接適用於公法領域，作為行政法權利義務繼受之法律基礎[170]。

（二）可類推適用民法之繼承制度

[169] 詹鎮榮（2015），《行政法總論之變遷與續造》，頁 320，台北：元照。

[170] 李建良（2006），（行政法上義務繼受問題初探－兼評高雄高等行政法院九十二年度訴字第八○六號判決暨最高行政法院九十四年度判字第六二二號判決），《2005 行政管制與行政爭訟》，頁 102，台北：中央研究院法律學研究所籌備處；詹鎮榮（2015），《行政法總論之變遷與續造》，頁 320，台北：元照。

doi:10.6342/NTU202000774

學理有認為行政法上權利義務概括繼受之效果，雖然無法直接適用民法繼承規定，但是仍可類推適用之，因行政法上權利義務繼承之構成要件與民法的繼承要件相似，本於兩者要件的相似，應可在解釋行政法上法律關係概括繼受時，類推適用民法繼承制度之法依據[171]。

（三）另立行政法上義務繼受一般性規定或是應類推適用特別行政法

此學理則是站在民法繼承的規定，認為其所涵蓋之事物性質，不具有公法規範之性質，也即民法所規範權利義務，不包括公法上的權利及義務，民法的規範無法作為行政法上義務概括繼受之依據。能作為行政法義務繼受之法依據者，必須以公法規定為限，始能將公法上權利義務加以移轉之，若公法領域尚欠缺繼受權利義務的一般性規定，或可考慮在特別行政法領域中有繼受規範之條款，以該條作為類推適用的基礎[172]。

三、小結

探討法律保留原則於行政法上義務繼受的適用，上開學說均可作為我國法行政法義務概括繼受之法律保留選擇之參考，尚須注意者，學理間的爭議，多以德國法上學理作為討論，本文欲進一步探究，以**我國法自身之關注作為基**

[171] 李建良（2006），（行政法上義務繼受問題初探－兼評高雄高等行政法院九十二年度訴字第八○六號判決暨最高行政法院九十四年度判字第六二二號判決），《2005 行政管制與行政爭訟》，頁 102，台北：中央研究院法律學研究所籌備處；詹鎮榮（2015），《行政法總論之變遷與續造》，頁 320-321，台北：元照。

[172] 李建良（2006），（行政法上義務繼受問題初探－兼評高雄高等行政法院九十二年度訴字第八○六號判決暨最高行政法院九十四年度判字第六二二號判決），《2005 行政管制與行政爭訟》，頁 101，台北：中央研究院法律學研究所籌備處；詹鎮榮（2015），《行政法總論之變遷與續造》，頁 321-322，台北：元照。

doi:10.6342/NTU202000774

礎，檢視目前我國既有的概括繼受義務之法依據，其法依據構成要件之解釋上，是否有「容納」、涵蓋、承載行政法上義務繼受的空間。

若能透過解闡釋繼受法規範，分析得出有行政法上義務的解釋空間，就上開學說上的爭議，是否另立行政法上一般性繼受法規範；或是類推適用特別行政法之概括繼受規範；抑或類推適用民法繼承編之規範等等，應可以從「實用」的角度暫時解決立法的不足。

據此，以下試著探究現行既有的法規範解釋，可否填補目前行政法上義務繼受之法律保留之空缺，解決上開學理之不同見解之爭議。對於我國行政法上義務繼受，自然人部分以民法繼承編之繼承制度作為探討；法人部分則以公司法第 75 條作為概括繼受之探討；非法人團體以民法第 306 條為探討。並且，再就行政執行法第 15 條、刑事訴訟法第 470 條第 3 項探究其內涵為何，是否在執行程序中有概括繼受的法依據存在。

貳、 自然人的概括繼受依據

一、民法繼承編之規範解析

關於自然人之概括繼受，民法繼承編第 1148 條規定，繼承自繼承開始，除另有規定外，須承受被繼承人「財產上一切權利義務」，但權利義務專屬於被繼承人本身者不在此限。民法第 1147 條規定，自然人的概括繼受時點，乃因被繼承人「發生死亡事實」開始[173]。在民法的規範下，「被繼承人的死亡」為自然人概括繼受的原因，此部分與行政法上義務繼受所發生之自然人概括繼受事由相

[173] 林秀雄（2017），《繼承法講義》，7 版，頁 79，台北：元照。

doi:10.6342/NTU202000774

同，並無差別。又，繼承人所概括繼受的標的，限於「財產上的一切權利義務」，並排除具有專屬於被繼承人之財產上權利義務，此部分是否能涵蓋並合致於「行政法上之義務」，續為以下之討論。

（一）民法第 1148 條第 1 項之「財產上義務」範圍

民法繼承編之第 1148 條第 1 項，係民法繼承制度「概括繼承」明文，其規定：「繼承人自繼承開始時，除本法另有規定外，承受被繼承人**財產上**之一切權利、**義務**。但權利、**義務**專屬於被繼承人本身者，不在此限」。其法條的構造及要件，重點在於發生死亡之被繼承人**「財產上的一切權利義務」**將由繼承人繼承之。所謂「財產上之一切權利義務」，概念上乃相對於「非財產上之一切權利義務」，非財產上之權利義務乃指身分關係（法益）及人格權，非民法繼承之標的，應排除之，只有財產上之權利義務得為繼承，然而，不包括具有一身專屬性之財產上權利義務，例如扶養請求權[174]、離婚之贍養費請求權[175]、精神慰撫金[176][177]。

1. 民法學理見解

聚焦於民法繼承制度標的之財產上「義務」其定義、內涵，對於其中「義務」的繼受，除了私法上的義務，是否尚包括公法上之義務？我國民法學理有認為，民法第 1148 條第 1 項所規定的繼承遺產中，義務部份只要不是被繼承人一身專屬性的債務，則不問其原因如何、屬作為或不作為義務、債權關係或是

[174] 民法第 1114 條以下。
[175] 民法第 1057、1082 條。
[176] 民法第 195 條第 2 項、第 977 條第 3 項、第 979 條第 2 項、第 999 條第 3 項、第 1056 條第 3 項。
[177] 林秀雄（2017），《繼承法講義》，7 版，頁 82，台北：元照。

doi:10.6342/NTU202000774

物權關係之下的義務應全部移轉於繼承人，不僅如此，不只有私法上之義務可以作為繼承標的，**縱然為「公法上之義務」，亦可作為繼承之對象**[178]。然而，雖民法第 1148 條第 1 項之「義務」所涵蓋公法上之義務，但並非所有公法上義務均得被繼承之，尚須參照該義務之性質、法規範明文而有所不同，例如有關被繼承人生前所負擔的罰金義務，借鏡日本法上之學理認為非遺產繼承之標的，不宜將被繼承人生前所負之罰金義務移轉於繼承人，且稅金義務及罰鍰義務亦應無從作為繼承的公法義務標的[179]。另外，我國其他民法學理亦認為，民法第 1148 條第 1 項所謂承受被繼承人財產上之一切權利、義務，其可被繼承的「義務」，除了私法上的債務，尚包括公法上之義務，其中應包括稅金義務，然而尚須注意者，公法上之義務尚須排除具有一身專屬性者使得被繼承之[180]。

整理民法學者對於民法繼承制度之標的，大多肯定繼承人可繼承者不僅僅為民法上的義務，**尚包含不具備一身專屬性的公法上的義務**，可藉由民法繼承制度作為移轉於繼承人之基礎。

2. 司法實務見解

民法第 1148 條之自然人繼受之依據，可否適用於公法領域，司法實務見解有採肯定之見解，例如：最高行政法院 105 年判字第 128 號判決即認為，民法第 1148 條係概括承受財產上一切之權利與義務，若繼承開始前被繼承人負有清除處理及償還費用等公法上行為或金錢給付義務，則應「適用」民法繼承的規定，由此可知，實務見解乃認為公法上的義務得直接適用民法繼承編的規定作

[178] 陳棋炎、黃宗樂、郭振恭（2014），《民法繼承新論》，9 版，頁 106，台北：三民。
[179] 陳棋炎、黃宗樂、郭振恭（2014），《民法繼承新論》，9 版，頁 106，台北：三民。
[180] 林秀雄（2017），《繼承法講義》，7 版，頁 81-82，台北：元照；戴炎輝、戴東雄、戴瑀如（2010），《繼承法》，頁 106-108，台北：自刊。

doi:10.6342/NTU202000774

為繼受依據。

又高雄高等行政法院 102 年訴字第 100 號判決，認為被繼承人生前所負不當得利返還義務，此種義務性質上乃單純之公法上財產請求權，故不具有一身專屬性，是以繼承人既未拋棄繼承或限定繼承，則繼承人需對被繼承人所負之財產債務，依照民法第 1148 條、第 1153 條的規定就被繼承人的債務負連帶責任。

另外，高雄高等行政法院 101 年訴更一字第 12 號判決，亦指出民法第 1148 條的規定，只要是被繼承人所負之債務，**不論是私法上或是公法上的債務，除被繼承人一身專屬之債務外**，依照我國學者通說及參酌日本國稅通則第 5 條的立法條例，**均得為繼承之標的**，惟繼承人得主張限定繼承或拋棄繼承，以避免以自己固有財產清償被繼承人之債務，公法上的租稅債權具有財產性，而不具有一身專屬性，對於被繼承人的公法上租稅債權，仍應依照民法繼承編的規定處理。

綜上所述，對於公法上的義務的繼受規範，就自然人死亡而概括繼受部分，我國司法實務見解認為可直接依據民法第 1148 條之規定，作為公法領域之義務概括繼受之法規範，繼承人須概括繼受不具有一身專屬性的行政法上義務。然而尚需注意者，實務見解認為，不只是民法第 1148 條及第 1153 條得作為行政法義務繼受之基礎法規範，就拋棄繼承[181]部分，除了被繼承人生前之私法上之權利義務得為拋棄繼承之標的，就公法上之權利義務部分亦可以加以拋棄繼承，此項見解亦有討論之價值。

[181] 民法第 1174 條：「繼承人得拋棄其繼承權。前項拋棄，應於知悉其得繼承之時起三個月內，以書面向法院為之（第一項）。拋棄繼承後，應以書面通知因其拋棄而應為繼承之人。但不能通知者，不在此限（第二項）」。民法第 1175 條：「繼承之拋棄，溯及於繼承開始時發生效力」。

doi:10.6342/NTU202000774

3. 本文見解

依本文前述[182]，民法上的義務及公法上的義務，在概念的比較上，公法與私法上之義務其兩者間均有一定特徵的分類、歸納，而具有相似之內涵。並且進一步觀察民法繼承制度中，其所可繼承的標的，乃**「財產」**上一切權利**「義務」**，從文義解釋而言，所謂「財產」上一切權利「義務」，民法第 1148 條第 1 項並非以財產法上並未以「財產法上之一切權利義務」描述，故在文義上，可以解釋為來自私法領域或是公法領域之財產上義務；另外，在體系解釋上，所謂財產上之一切義務，應是指對於**「人民財產權有所限制之拘束者」**，此種拘束可能來自於私人與私人之間，亦有可能來自於國家對人民所造成者，故概念上不只私法上義務，公法上義務亦有涉及「財產上之拘束」此種特徵描述，例如民法上之「債務」概念，及公法上的「金錢給付義務」概念，均可包括於該條規範之內，並無排除公法義務繼受之態樣。據此，民法第 1148 條第 1 項關於繼受的標的，所謂「財產上的義務」，從文義解釋、體系解釋，可導出不僅民法上的財產上義務，應可包括**「公法上涉及對人民財產權限制之義務」**。

須注意者，民法繼承的標的，雖可解釋出包括私法與公法上限制財產權之義務，然而仍須排除具有一身專屬性之公法上義務，蓋一身專屬性的排除，乃為繼承制度之「手段適當性」之展現，不論在私法或是公法關係之繼受，均受到適當性原則之拘束，故公法上之義務繼受亦須排除一身專屬性者，且民法第 1148 條第 1 項但書[183]亦已明文提醒之。

[182] 參照本文第二章、第二節、第一項、參、行政法與民法上義務之比較。
[183] 民法第 1148 條第 1 項但書：「但權利、義務專屬於被繼承人本身者，不在此限。」

doi:10.6342/NTU202000774

（二）民法「債務」範圍及概念

民法第 1148 條第 1 項所謂乃特定於「**財產上**」權利或「**義務**」為繼受標的，民法學理對此闡釋包括「**私法上之債務**」及「**公法上之義務**」[184]。又，民法第 1148 條第 2 項，概括繼承之有限責任，亦以「**債務**」加以描述。可知應掌握「民法財產上義務」與「債務」性質，兩者加以辨析，進而對應至「公法上義務」，以得出與何種公法上義務概念相通，以釐清比較我國公私法概括繼受概念、內涵。

1. 債務係指民法上具體給付關係之請求，排除物權法及單純身分法上義務

所謂債務，來自於人與人之間債之關係，所謂「債」係指一方當事人得向他方當事人請求特定行為（給付），而本於一定法律關係，特定人間得請求特定事項[185]。質言之，在債之關係中，債權跟債務乃同一給付關係之兩個面向，其中之「債權」，指基於債之關係下，權利旨在將某種利益在法律上歸屬某人，使債權人得向債務人請求給付；而「債務」則是債務人須向債權人給予給付之拘束。簡言之，所謂「債務」是在特定給付關係之下，債務人應為一定給付之之法律關係[186]。由此可知，民法上的「債務」之概念，乃是在「義務」層次下之子概念，也就是說，民法上的義務，乃廣義概念下之一定作為、不作為拘束、請求給付意義。

---

184 林秀雄（2017），《繼承法講義》，7 版，頁 81，台北：元照。
185 王澤鑑（2013），《民法概要》，4 版，頁 162，台北：自刊。
186 王澤鑑（2013），《民法概要》，4 版，頁 166-167，台北：自刊。

doi:10.6342/NTU202000774

「債務」概念上為義務之一，然義務並非當然均為債務，私法上義務領域，大致可分為債之關係、物之關係、身分關係，「債務」所指者，乃係發生於民法上債之關係的義務。物之關係領域中，並不會用「債務」這個用語，例如：民法第 767 條之「物之返還請求權」、「妨害防止請求權」及「妨害除去請求權」、民法第 860 條之普通抵押權等等，物權法上的義務，多半是以「請求權」加以描述。

再者，就「身分關係」中，均多以「義務」作為用語，例如：民法第 1001 條夫妻同居「義務」、第五章扶養編之扶養「義務」、第 1084 條父母對未成年子女之行使保護及教養之權利「義務」。並不會以夫妻同居債務、扶養債務、對未成年子女之行使親權之「債務」來表示。然而，在身分關係中，尚可能有債之給付關係存在，例如：夫妻間因法定財產制消滅，所產生之剩餘財產請求權[187]，其本質上即是因身分關係之消滅所產生之金錢給付義務，屬債務的概念；或訂婚無效、解除或撤銷時，贈與物的當事人，得要求受贈之一方負有返還該物之給付義務[188]，受贈人則將負有返還金錢，亦可能是返還金錢以外之物之債務存在。

總言之，**「債務」其內涵所指者，乃當事人之間的一定給付關係下之特定拘束、要求，而排除物權法上義務及單純身分關係下之義務**。

[187] 民法第 1030 條之 1：「法定財產制關係消滅時，夫或妻現存之婚後財產，扣除婚姻關係存續所負債務後，如有剩餘，其雙方剩餘財產之差額，應平均分配。但下列財產不在此限：一、因繼承或其他無償取得之財產。二、慰撫金（第一項）。依前項規定，平均分配顯失公平者，法院得調整或免除其分配額（第二項）。第一項請求權，不得讓與或繼承。但已依契約承諾，或已起訴者，不在此限（第三項）。第一項剩餘財產差額之分配請求權，自請求權人知有剩餘財產之差額時起，二年間不行使而消滅。自法定財產制關係消滅時起，逾五年者，亦同（第四項）。」

[188] 民法第 979 條之 1：「因訂定婚約而為贈與者，婚約無效、解除或撤銷時，當事人之一方，得請求他方返還贈與物」。

doi:10.6342/NTU202000774

2.「 債務」為財產上義務之下位概念

進一步，將「財產上之義務」與「債務」兩者概念相比較，藉由爬梳學理之定義可知，財產上之義務既是指「涉及財產權之規制者」，而債務所指者乃排除物權法上義務及單純身分關係之給付拘束。兩者內涵相比較，財產上之義務的範圍，大於債務的概念，由此可推論，債務乃財產上義務之下位概念。

有疑問者，例如：民法僱傭關係中，受僱人應給付之「勞務給付義務」，評價上屬私法上之債務無誤，但以公法角度以觀，本質上並非對於受僱人財產權之限制，其乃一般行為自由之限制，似乎不能涵攝「財產上義務」，本文以為可試著思考，私法上之僱傭契約的締結，本身即是憲法第 15 之財產權下之契約自由之具體展現，則就私法契約中勞務給付的部分，本身仍可評價為憲法第 15 條之財產權之規制拘束之一。故在私法契約下之勞務給付義務，亦屬於於民法第 1148 條第 1 項之財產上義務射程範圍。然而在公法領域中，國家與人民之間亦可能有私法契約之締結，此私法契約下人民所負有之勞務給付義務，亦屬於財產上義務之概念。

綜上所述，可推論「財產上義務」與「債務」間的意義，均是指「涉及財產權之具體規制」，然而「財產上義務」所涵蓋的內涵，較「債務」的概念更大，故民法繼承編第 1148 條第 1 項所謂繼承標的內涵，雖有身分法學者[189]認為債務與財產法上義務之概念相同，但經由上開解釋，債務的概念實不及涵蓋整個財產上義務，故解釋上，仍以民法第 1148 條第 1 項之文句「財產上義務」概念作為依歸較為妥當。

[189] 林秀雄（2017），《繼承法講義》，7 版，頁 81，台北：元照。

doi:10.6342/NTU202000774

二、公法上義務適用民法繼承編之探究



（一）民法第 1148 條第 1 項概括繼受部分

民法繼承制度，民法第 1148 條第 1 項的文句，繼承人繼承標的乃「**財產上**」之一切權利「**義務**」得解釋出，乃涉及「**人民財產權有所限制之拘束者**」，該等限制可能來自於私法領域，亦可能是公法領域。就私法領域，可具體解釋出包含作為義務中物之給付義務、私法契約之勞務給付及涉及財產權限制之不作為及忍受義務。

將此概念對應上公法領域，上開所闡釋的概念，亦可對應到公法上物之給付義務、國家與人民所締結私法契約之勞務給付義務及涉及財產權限制之不作為與忍受義務。是以，既然民法第 1148 條第 1 項之「財產上之義務」可藉由對應於上開義務，而無矛盾、牴觸之情況，本文以為上開公法上義務，可**類推適用民法第 1148 條第 1 項之規定**，作為其公法上概括繼受之依據。

另外，公法上非私法契約之勞務給付義務、非財產權限制之不作為及忍受義務，無從涵攝於民法第 1148 條第 1 項之「財產上義務」一詞之內涵，故無法類推適用該條作為公法上概括繼受之依據。然而，考量公法上義務繼受所追求的目的，不只是在保障私人財產權之延續保障，尚須考量國家對於公益的捍衛及維持，此乃私法上的繼承所無之目的。是以，被繼承人公法上非私法契約之勞務給付義務、非財產權限制之不作為及忍受義務，排除具有一身專屬性以外的性質者，亦應為行政法上義務繼受之標的，然該等義務之概括繼受之依據，**應由立法者另立公法上依據**，以符合法律保留原則之拘束。

doi:10.6342/NTU202000774

（二）民法第 1148 條第 2 項有限責任部分

民法繼承編第 1148 條第 2 項[190]，所指繼承人負**「有限責任」之「債務」**範圍，尚須注意其與上開分析的「債務」之定義有所不同，應只包括「物的給付義務」（金錢給付義務、金錢以外的物之給付義務），不包括勞務給付義務、不作為及容忍義務，其原因在於有限責任之立法目的係避免繼承人背負高於積極財產之繼承債務，而使繼承人自己須以固有財產清償之，故賦予有限責任使繼承人得向債權人主張只需以遺產為限，對外清償被繼承人之債務，可拒絕以自己的固有財產清償之[191]。既是避免繼承人以自己固有財產清償，前提必須是其概括繼受之義務規制的態樣上，屬於積極作為之態樣，始有以自己固有財產，另外為清償給付之必要，若是不作為或是忍受義務，概括繼受人並不須另外為積極之作為，有限責任並無介入之實益。又所謂以遺產為限負清償之責，則就勞務給付契約部分，雖屬積極作為之義務，但非屬物之給付義務，概念上不合於以遺產為限負清償義務，亦當然非有限責任之債務範圍。

據此，民法第 1148 條第 2 項有關以遺產為限負清償責任之有限責任「債務」，從上所述，民法繼承編所指，負有限責任之「債務」，僅指「金錢給付義務」及「金錢以外物之給付義務」。對應至公法領域，負有限責任的債務概念亦能及於「公法上金錢給付義務」及「金錢以外物之給付義務」。由此可得出，**公法上金錢給付義務及金錢以外物之給付義務，發生概括繼受時，應可類推適用民法第 1148 條第 2 條規定**，主張以遺產範圍為限，清償公法上之金錢及金錢以外物之給付。

---

[190] 民法第 1148 條第 2 項：「繼承人對於被繼承人之**債務**，以因繼承所得遺產為限，負清償責任」。

[191] 林秀雄（2017），《繼承法講義》，7 版，頁 150，台北：元照。

doi:10.6342/NTU202000774

另外，其他公法上之義務是否亦能主張有限責任？可思考的是，概括繼受之有限責任其法理，乃來自於對於繼承人受到概括繼受之基本權利侵害，憲法上比例原則之最小侵害性之展現，民法第 1148 條第 2 項乃立法者就金錢給付義務、金錢以外物之給付義務，以遺產之範圍作為界線，其比例原則之最小侵害性之明文提醒。在其他公法上義務種類中，若有發生義務概括繼受，即使無從類推適用民法第 1148 條第 2 項，仍必須對於繼受人履行概括繼受義務的具體態樣，考量義務的目的、繼承人的情況及現行義務履行程度等等，在能達成相同目的下適當調整，選擇對繼承人最小侵害之程度之義務履行內容。是以行政機關對於勞務給付義務、不作為、容忍義務之概括繼受，應以比例原則之最小侵害性法理作為調整繼承人概括繼受上開義務之內涵。

又值得討論者，有些非財產上義務的概括繼受，實際上可能會轉變成具體的金錢支出，在適用上有無類推適用民法第 1148 條第 2 項的空間？本文以為，應以最終、具體對於繼受人的義務規制作為考量，若事實上被繼承人所承受之義務履行，涉及具體金錢的支出，不妨仍得以主張類推適用民法第 1148 條第 2 項規定，以繼承人所繼承之遺產作為限額，較為合理。

公法上義務繼受法律依據圖表

作為義務
- **物之給付義務**：
  - **金錢給付義務**：類推適用民法第 1148 條第 1 項及第 2 項
  - **非金錢給付義務**：類推適用民法第 1148 條第 1 項及第 2 項

doi:10.6342/NTU202000774

勞務給付義務：

- **因私法契而成立**：類推適用民法第 1148 條第 1 項及比例原則最小侵害性法理
- **非因私法契約而成立**：另立公法上依據及比例原則最小侵害性法理

不作為義務

- **涉及財產權之規制**：類推適用民法第 1148 條第 1 項及比例原則最小侵害性法理
- **非財產權之規制**：另立公法上依據及比例原則最小侵害性法理

忍受義務

- **涉及財產權之規制**：類推適用民法第 1148 條第 1 項及比例原則最小侵害性法理
- **非財產權之規制**：另立公法上依據及比例原則最小侵害性法理

（三）繼承編之拋棄繼承部分

民法繼承編第 1174 條之拋棄繼承可否適用於公法上的權利義務？所謂的拋棄繼承，民法學理的理解，其所拋棄者並非被繼承人具體的權利義務，而是拋棄繼承人其法律所賦予之具身分性質之「繼承權」[192]。進而，繼承權拋棄的「效果」，會具體產生原本可繼承得到的權利義務，於拋棄繼承生效時，溯及既往於繼承發生喪失繼承權之效力，也就是溯及於被繼承人死亡的那一刻而脫離繼承人的地位。

考量拋棄繼承是否包括公法上之義務，首先是在民法學理的思考下，既然

[192] 林秀雄（2017），《繼承法講義》，7 版，頁 185，台北：元照。

doi:10.6342/NTU202000774

拋棄繼承的效力是在使原本的繼承人在繼承開始時使繼承人的地位消失，則拋棄繼承具體效果之標的，即是「原本繼承人應繼承的權利義務」。蓋民法繼承編規範繼承標的內涵，依前述解釋可得出，民法第 1148 條第 1 條所乘載的內涵，除了私法之債務之外，尚可類推適用於公法上金錢給付義務、金錢以外物之給付義務、私法契約下之勞務給付義務及涉及財產權限制之不作為、容忍義務之範圍，上開義務範圍原則上似乎可作為拋棄繼承之標的。

單純以民法拋棄繼承法條上之效力解釋，可得出以上之結果，然而私法領域的權利義務因具有平等性，故在義務拋棄的部分，立法者亦採取自由的態度，使人民間落實私法自治；但就公法上之義務部分，乃具有「高權性」之特徵，並且公法上義務的課與，均有比私法上義務更高的公益價值存在，而非僅僅牽連當事人之間而已，故公法上的義務，就拋棄繼承此一制度的適用上，是否需加以調整，有其思考的必要，本文在此認為應不宜承認公法上義務得拋棄繼承。

（四）生前財產分配、遺贈與概括繼受公法上義務之關係

或有思考者，自然人在生前，利用生前財產分配或是遺贈之方式，藉以使繼承人脫免民法第 1148 條概括繼受效力，避免繼承人須承受公法上之義務。在這部分的思考或可分成兩個部分，一個是金錢給付義務，另一為因物所產生的公法上義務部分。

關於第一個部分，義務人於生前分配其財產，使其積極財產在發生死亡時所剩無幾，藉使繼承人在有限責任的保護下，實際上負擔些微或是根本無需負擔所概括繼受之公法上金錢給付義務。關於這部分，行政機關可以考慮藉由行

doi:10.6342/NTU202000774

政執行法之金錢給付義務保全程序加以確保義務人的財產現狀。另外，在民法第 1148 條之 1[193]關於追加計算遺產數額之效力，是否適用於繼承人承受公法上金錢給付義務？就此部分公法學理並未有討論，然試著探究民法第 1148 條之 1 的結構，應由第 1148 條的概括繼承效力加以解釋，從前所述，既公法上物之給付義務得以藉由類推適用第 1148 條第 1 項使繼承人承受，則就**第 1148 條之 1 追加計算繼承人遺產的效力，亦應得類推適用之**。且第 1148 條之 1 追加計算遺產數額之立法目的，應係在於避免義務人藉由生前處分財產而減少其死亡時遺產總則，使債權人之債權能夠加以保全，此種保全的考量，應不只介入私法上的債權債務關係，於公法領域中為追求公益的金錢給付義務亦應有其正當性存在。

另外，就遺贈的部分，屬於義務人以遺囑此種要式行為方式，對於其死後財產處分的概念，義務人是否可能以遺贈的方式脫免繼承人承受之金錢給付義務？關於此疑問應該不太可能發生，原因在於，遺產總額首先必須先對外清償其債務關係，待完結對外關係後，依序以各繼承人之應繼分或是特留分、酌給請求權及遺贈分配對內關係的應繼遺產，由此可知，即使義務人生前將所有積極財產作成遺囑以遺贈的方式給予繼承人或是繼承人以外第三人，在遺產的清償順位上，仍須以對外債務為優先。換言之，不論是私法上的債權債務關係，或是公法上之金錢給付關係都須由遺產總額先為清償，始發生應繼分、酌給請求權及遺贈的分配，義務人應無從藉由遺贈達成迴避繼承人概括繼受公法上金錢給付義務之可能。

接著，就第二個部分，因物所產生公法上義務的部分，義務人若生前處分

[193] 民法第 1148 條之 1：「 繼承人在繼承開始前二年內，從被繼承人受有財產之贈與者，該財產視為其所得遺產（第一項）。前項財產如已移轉或滅失，其價額，依贈與時之價值計算（第二項）。」

doi:10.6342/NTU202000774

該物，是否對於繼承人有所影響，亦須進一步探究之。對此，可再分成因「狀態責任」或是因「行為責任」所產生。前者狀態責任所產生的公法上義務，既係因物的狀態使物之管領人承擔行政法上義務，若義務人在生前移轉該物於繼承人，由於狀態責任的特性，乃以物之管理人作為責任對象，繼承人將成為新的狀態責任人，義務人通常不太可能如此移轉，換言之，義務人若欲使自己及其繼承人脫免物之狀態責任，應會將物移轉給繼承人以外之第三人，在此種情況，的確義務人可藉由移轉狀態責任物之方式，使自己的狀態責任人地位消滅，其繼承人亦無從概括繼受該物之所有權而成為新的狀態責任人。此部分的規避如何避免，應該藉由立法明文的方式，將刻意脫免狀態責任人之行為，規範其為特別行政法行為責任之一，藉以警戒以此方式脫免狀態責任；或是以權利濫用及誠信原則之法理，將該移轉於第三人的行為評價為無效。因標的物所發生之行為責任部分，即使義務人移轉該物，亦無從消滅其行為責任，故此部分無討論之餘的。

最後，若是以遺囑的方式將標的物移轉於第三人，若被繼承人為狀態責任人，則該標的物可能藉由遺贈，使受遺贈人取得請求該物移轉的債權效力，若遺贈人取得該物之所有權，則可能成為新的狀態責任人，不過受遺囑人若於嗣後始知情狀態責任一事，可藉由主張民法第 1206 條[194]來拋棄其遺贈，其效力將溯及於義務人死亡之時。反之，若是行為責任，即使義務人以遺贈將該物給予他人，亦不因此影響其應所負之行為義務，其繼承人亦可能須承受。

[194] 民法第 1206 條：「受遺贈人在遺囑人死亡後，得拋棄遺贈（第一項）。遺贈之拋棄，溯及遺囑人死亡時發生效力（第二項）」。

doi:10.6342/NTU202000774

參、 法人的概括繼受依據



一、公司法之規範概述

法人的概括繼受事由，目前我國法規範中在公司法第 75、319 條及企業併購法中有對於公司合併作為法人概括繼受事由之規定。公司法的規範，相較於企業併購法的規範，乃法人合併之基本原則，處於普通法的規範，而企業併購法則是特別法的規範，在現行法制的運作上，通常直接以企業併購法作為適用基礎及法效之歸依，除非企業併購法未有規定，始回歸公司法加以補充適用[195]。然而，在探究所謂因「公司合併」而法人概括繼承事由於公法領域的適用與否，仍須以公司法第 75 條該基礎規範做為分析之基礎，故就法人概括繼受之部分，以下以公司法第 75 條之公司合併作為討論。

二、公司合併的概念

所謂公司合併，其概念乃兩個或兩個以上之公司，訂定合併契約，且依照公司法的規定，免經清算程序，而歸併成一個公司之行為，其原有之一的公司從而消滅，該消滅公司的權利義務則概括地由合併後存續的或另立的公司承受[196]。而吸收的態樣上，可分成吸收合併及新設合併，所謂「吸收合併」乃兩個或兩個以上之公司合併，其中一公司存續，其餘公司皆消滅，而消滅的公司之權利義務則由未消滅（存續）之公司加以概括繼受之；又「新設合併」則是指兩個或兩個以上的公司合併，參與公司合併的公司均全部歸於消滅，而另外成

[195] 劉連煜（2016），《現代公司法》，12 版，頁 147，台北：新學林。
[196] 柯芳枝（2013），公司法論（上），9 版，頁 62，台北：三民；劉連煜（2016），《現代公司法》，12 版，頁 148，台北：新學林。

doi:10.6342/NTU202000774

立一個新公司，此新設（另立）公司對於全部參與合併而消滅的公司其權利義務，均概括繼受之[197]。公司合併的效果除了造成一個或一個以上之公司歸於消滅及存續公司之章程勢必變更之效果，最重要者乃發生公司間之權利義務概括繼受之效果。

三、公司法第 75 條作為法人合併概括繼受依據之探討

（一）公司法學理見解

公司法第 75 條所指由存續或另立公司承受的**「其權利義務」**，立法者在文義上，並未明定何種法領域的權利義務，且就公私法之學理上並未有進一步說明公司合併所產生之概括繼受，其概括繼受的標的，究竟是單指私法上的權利義務，抑或是所有公、私法上之領域的權利義務均涵蓋在內。

（二）公法學理見解

公法學理對此有認為，不論在新設合併或是吸收合併的場合下，公司法第 75 條[198]之中「權利義務」，係指私法上之權利義務，民法與公司法的規定其射程範圍均不包括公法上的權利義務繼受，然依照「概括繼受之法理」，因合併所消滅的法人其公法上之權利義務仍需由合併後存續或另立的法人加以繼受之

[197] 柯芳枝（2014），公司法論（上），9 版，頁 62，台北：三民，劉連煜（2016），《現代公司法》，12 版，頁 148-149，台北：新學林。
[198] 公司法第 75 條：「因合併而消滅之公司，其**權利義務**，應由合併後存續或另立之公司承受」。

doi:10.6342/NTU202000774

[199]。此法人概括繼受之法理，在部分特別行政法中有加以明文，例如稅捐稽徵法第 15 條[200]、稅捐稽徵法施行細則第 5 條[201]規範，對於法人合併後，明文規定皆由合併後另立或存續的法人加以負擔，然而另外尚需注意所得稅法第 75 條第 1 項[202]的規定，是以現行稅捐法之明文規範，對於法人合併之租稅法上權利義務之繼受，僅有對於被消滅法人補稅或退稅的情況，才有概括繼受之適用[203]。故此學理乃認為公司法第 75 條並非法人公法上義務繼受之規範依據，而是本於「不成文的概括繼受法理」作為公法上義務概括繼受之基礎。

然另有公法學理認為，對於公司法第 75 條之規定，對於法人合併後，消滅公司之權利義務原則上由存續或另立法人承受，公法上的權利義務亦包含在其內，故公司法第 75 條本身得作為法人合併公法及私法義務概括繼受之基礎[204]。

（三）司法實務見解

進一步探究我國司法實務見解，有認為公司法第 75 條的規定，其概括繼受之效果，亦適用於公法上的權利義務，例如：最高行政法院 100 年判字第 503 號判決，其中法院即依照稅捐稽徵法第 15 條肯定對於合併前消滅公司之應納稅捐或營利事業合併前的應納稅捐，即應由合併後存續或另立的公司或營利事業

[199] 陳敏（2009），〈人民公法上權利義務之繼受〉，《政治思潮與國家法學：吳庚教授七秩華誕祝壽論文集》，頁 475-476，台北：元照。
[200] 稅捐稽徵法第 15 條：「營利事業因合併而消滅時，其在合併前之應納稅捐，應由合併後存續或另立之營利事業負繳納之義務」。
[201] 稅捐稽徵法施行細則第 5 條：「本法第十五條規定營利事業因合併而消滅時，其於合併前應退之稅捐，應由合併後存續或另立之營利事業受領。但獨資合夥之營利事業，在合併時另有協議，並已向稅捐稽徵機關報備者，從其協議」。
[202] 所得稅法第 75 條第 1 項：「營利事業遇有解散、廢止、合併或轉讓情事時，應於截至解散、廢止、合併或轉讓之日止，辦理當期決算，於四十五日內，依規定格式，向該管稽徵機關申報其營利事業所得額及應納稅額，並於提出申報前自行繳納之」。
[203] 陳敏（2009），〈人民公法上權利義務之繼受〉，《政治思潮與國家法學：吳庚教授七秩華誕祝壽論文集》，頁 476，台北：元照。
[204] 林三欽（2014），〈土壤汙染行為人責任之繼受與法律溯及適用－簡評大法官解釋第 714 號解釋〉，《法令月刊》，65 卷 1 期，頁 65-12-65-13。

doi:10.6342/NTU202000774

負責繳納之，且就罰鍰處分，亦須由合併後存續或另立之公司或營利事業承擔之。

又，最高行政法院 103 年判字第 666 號判決，法院亦肯定在公司合併的情況下，對於合併前其消滅公司應負依土壤及地下水整治法之整治義務，則其合併而概括繼受之法人，即應負起該整治義務而排除汙染行為責任。

（四）本文見解

1. 法人合併得類推公司法第 75 條規定概括繼受行政法上義務

在法人概括合併繼受之部分，對於其法律保留之探討，本文以為在公司法第 75 條的探討下，該條的規範乃「因合併而消滅之公司，其**權利義務**，應由合併後存續或另立之公司承受」，在文義解釋上，公司法第 75 條相較於民法第 1148 條第 1 項及第 2 項的規定，較為簡略而概括，對於僅有明文「其權利義務」由合併後之公司承受之，範圍上不如民法第 1148 條第 1 條「財產上之權利義務」之限縮文義。

聚焦在「義務」層面，透過上述[205]對於「義務」一詞的理解，概念上應可涵蓋公法上與私法上義務，並未限定為私法上義務。再者，雖公司法大致上是屬於規範私人商業活動的法規範，然其中不乏對公司進行行政管制的法條。例如：公司法第 19 條中，規範公司必須向經濟部為設立登記，否則不得以公司名義經營業務或為其他法律行為，此種登記之限制乃行政法上之秩序行政規制，該條定性上乃是具有管制色彩的公法性質。由此可知，公司法整部法律，並非

[205] 參照本文第二章、第二節、第一項、參、行政法與民法上義務之比較。

doi:10.6342/NTU202000774

全然只規範於私人之間，尚有國家與私人之間規範的部分。故公司法係具有公法管制與私法自治色彩交錯之法規範，就公司法第 75 條內涵，應包含公法與私法上的所有義務，均可加以解釋而不衝突，故本文以為，**公法上義務應可類推適用公司法第 75 條，使合併後存續或另立的公司加以概括繼受之**。

2. 法人合併概括繼受仍有比例原則的適用

從公司法第 75 條的條文結構中，可得出類推適用該條作為法人公法上之義務概括繼受之依據，然而該條並未有如民法第 1148 條第 2 項規定繼承人之有限責任明文，是否代表法人合併下，存續或另立公司必須完全負擔原先被繼受公司之義務內容？關於此點，本文以為關於自然人死亡情況下，立法者已對此明文就債金錢給付及金錢以外給付義務以繼承遺產為限負有清償義務，係立法者將比例原則以明文方式加以提醒，並不代表未對此明文之義務無比例原則適用，故法人之概括繼受，亦當然須具體檢驗其比例原則。

3. 公司法第 75 條概括繼受規範應為強行規定

公司合併所發生的概括繼受，與自然人死亡之之情況有所不同，原因在於公司之間發生合併之前，公司之間會先訂定合併契約，使確定雙方合併的日期、公司財務狀況等等細項。有疑問者，對於公司合併所產生的權利義務概括繼受效果，是否得由公司間的合併契約決定，而排除公司法第 75 條之概括繼受的效力？換言之，公司法第 75 條究竟為強行規定或是任意規定，此點必須加以研究。

公司法學理認為，公司合併產生概括繼受效果之法規範，主要來自於公司

doi:10.6342/NTU202000774

法第 75 條規定：「因合併而消滅之公司，其權利義務，應由合併後存續或另立之公司承受」。該條乃公司合併之法律效果，存續公司或是新設（另立）公司，對於已消滅公司的權利義務均需概括繼受，故不得就其中一部份之權利或義務以合併契約或是特約排除之，在權利的移轉上亦無須有移轉行為，只要公司合併成立且有效，即產生概括繼受之效果[206]。故公司法學理認為，公司法第 75 條應屬強行規定，不得由當事人自行約定排除。

又，進一步探究公司法的法規範，究竟為公司運作的強行規定或是任意規定，公司法學理對此認為，若以任意規定作為公司法規範之主體，其正當性基礎乃來自於私法自治作為基本原則，則應允許契約當事人得另行約定，公司法的規定係作為一標準化契約範本參考，可降低當事人間的交易成本，然而有可能促使當事人利用標準化契約範本而隱匿重要資訊，使一方以投機性策略行為；相反地，若以任意規定作擬定，得鼓勵雙方交換資訊有效討論契約，進而促使對於社會有益交易可以順利達成[207]。反之，若以公司法作為強行規定，其正當性基礎係站在保護投資人以觀，認為若放任契約自治將會損及投資人的利益，此外亦可約束公司經營階層的運作避免為投機行為；另外，強行規定的存在亦是著眼於公共利益的角度，另如股東有限責任[208]作為強行規定的設計下，使投資人得以分散投資，無須費心於監督公司的經營並可自由轉讓持股[209]。

以公司法學理的觀點，對於公司法究竟為強行規定或是任意規定的解釋，

---

206 柯芳枝（2014），公司法論（上），9 版，頁 62，台北：三民；王泰銓、王志誠（修）（2009），公司法新論，5 版，頁 205，台北：三民。

207 邵慶平（2007），〈公司法：第二講 組織與契約之間—經濟分析觀點〉，《月旦法學教室》，62 期，頁 40。

208 公司法第 154 條：「股東對於公司之責任，除第二項規定外，以繳清其股份之金額為限（第一像）。股東濫用公司之法人地位，致公司負擔特定債務且清償顯有困難，其情節重大而有必要者，該股東應負清償之責（第二項）」。

209 邵慶平（2007），〈公司法：第二講 組織與契約之間—經濟分析觀點〉，《月旦法學教室》，62 期，頁 41-42。

doi:10.6342/NTU202000774

其實各有優點及考量，並未有一定、絕對的對錯。觀察公司法第 75 條公司合併概括繼受的規範，可想像的是，對於公司合併下，公司間對於被繼受公司的權利義務，若由其合併契約約定是否承受、如何承受，就私法上權利義務部分爭議較小，其核心應在於公司治理之管制，原因在於，若被繼受公司與合併後存續或另立公司得透過另行協商的方式，對外就債權人或債務人另為約定，而非一律由另立或存續公司概括繼受，在無限、有限、兩合公司合併須透過全體股東同意加以控制；在股份有限公司則在合併前，董事會應就合併有關事項，作成合併契約，提出於股東會，使股東得在集會前或集會中，表示異議並請求公司按當時公平價格，收買其持有之股份達到控制的效果。

然而，就本文所探討公法上義務部分，若被繼受公司與另立或存續公司以合併契約排除掉對於公法上義務的概括繼受，可能不妥適，原因在於，公法上的義務並非如私法上權利義務一般，雙方當事人皆具備對私法領域權利義務的處分權。且換個角度觀之，公法上義務概括繼受的目的，既在維持公益運作的順暢，若肯定公司法第 75 條屬於任意規定，將輕易使公司間以合併契約將其公法上義務排除於另立或併存公司承受的範圍，無疑造成公司可透過此種方式，脫免其應承受之公法上義務。

據此，本文以為，公司法第 75 條之規定，就公法上權利義務之部分，應該採強行規定說，使另立或存續公司必須依照該條概括繼受公法上之權利及義務，較為妥當。

四、小結

承上所述，在公司法第 75 條中，對於法人之合併之義務概括繼受規定，概

doi:10.6342/NTU202000774

念上不只是私人間的義務，亦應包含於國家與被合併公司之義務，而無須拘泥於公司法之私法色彩而將公法上義務繼受之概念排除於外，故應認為法人之間合併所產失生公法上義務概括繼受之效果，得以類推適用公司法第 75 條作為概括繼受之依據。並且行政機關應該考量比例原則中最小侵害性，賦予繼受之法人合理的義務概括繼受內容。

確立法人間合併之概括繼受依據之後，可知另立或存續之法人應類推適用公司法第 75 條，概括承受其公法上義務。然若該義務可歸責於被合併法人之股東造成者，國家對此義務是否有「揭穿公司面紗原則」之適用，不無疑問。

所謂「揭穿公司面紗」其概念的內涵為，股東有限責任制度作為現代公司法制中最重要的內涵之一，在股東有限責任下，股東對公司的責任僅限於其所投資的部分，股東個人無須對公司債權人負責，公司具有獨立的法人格，使得公司與其股東的人格鄉分離，且兩者的財產亦分離獨立，公司可獨立為權利義務之主體；然而，公司獨立的法人格主體有可能遭到公司股東濫用，此種濫用的情況將會造成公司債權人保障不足，且使公司法人格遭到不當濫用，故揭穿公司面紗原則，即是指在股東有不當的控制公司，或是對於使公司對外債務有詐欺行為，否認公司與其股東各自獨立的人格及股東有限責任，責令公司股東對公司債權人負責[210]。

我國在 2013 年 1 月公司法修訂時，將「揭穿公司面紗原則」規定增訂於公司法第 154 第 2 項：「股東濫用公司之法人地位，致公司負擔特定**債務**且清償顯有困難，其情節重大而有必要者，該股東應負清償之責」。該條規定在法人之公法上義務概括繼受亦能有所適用？換言之，對於被合併公司向國家所負的公法

[210] 郭大維（2013），〈股東有限責任予否認公司法人格理論之調和──「揭開公司面紗原則之探討」〉，《中正財經法學》，7 期，頁 51-53。

doi:10.6342/NTU202000774

上債務，係可歸責於股東之重大詐欺行為所致，則該債務是否能例外不成為被繼受，以適用揭穿公司面紗原則，使被合併公司之特定股東負擔該債務，成為**法人公法上義務概括繼受之排除要件**？

此部分的思考，應可分成兩個方面。首先應考量到的是，法人與自然人兩者的差異，蓋法人對外所作出的法律行為，必須經由法人之內部機關完成，而其內部機關即是由自然人所討論、決議，不同於自然人本身直接的意思表示；另一方面，考量揭開公司面紗的立法目的，係為促進公司債權人的債權實現，避免股東濫用公司法人獨立之制度，則將此兩方面的考量放入「公法上義務概括繼受」的領域可以發現，並未有矛盾、衝突的地方。換言之，不論是私人或是國家為債權人，均有可能有公司股東欲以公司之法人格脫免責任。又，細究公司法第 154 條第 2 項之規定，其規範「致公司負擔特定**債務**」此要件，在理解上亦可包括公法上債務，若公司所負擔之公法上債務，係來自於公司股東濫用公司法人格，對外負擔公司無法履行之債務，欲以股東有限責任加以脫免時，則該公法上之債務，**應有公司法第 154 條第 2 項規定之揭穿公司面紗原則之類推適用**。

類推適用的結果，將導致該債務歸屬於該公司「股東」，使該債務則不屬於公司，其存續或另立的公司應無需概括繼受該等債務，故公司法第 154 條第 2 項應屬法人概括繼受之除外事由。換言之，在法人概括繼受下的思考，對於在本文納入公司法第 154 條第 2 項之考量下，在法人概括繼受的義務可繼受性之層次，除了檢驗義務是否為一身專屬性外，尚必須檢視該義務有無構成公司法第 154 條第 2 項之揭開公司面紗原則，若有該當，則該義務欠缺可繼受性。

doi:10.6342/NTU202000774

肆、非法人團體之概括繼受依據

非法人團體中，最常見的就是「獨資」、「合夥」形式，也可能會產生公法上義務之概括繼受情事，於民法第 306 條：「**營業與他營業合併**，而互相承受其資產及負債者，與前條之概括承受同，其合併之新營業，對於**各營業之債務**，負其責任」。也就是兩個以上營利事業，得依法定程序合併為營利事業，參與合併之營利事業皆解散消滅，另行創立一新營利事業時，則屬「新設合併」；若是參與合併的營利事業，除其中一者外，其他皆解散消滅，而併入皆繼續存在之營利事業時，則屬吸收合併，無論新設或是吸收合併，皆以互相承受資產及負債為要件，要合併中消滅的營利事業，其資產及負債應由合併後新設或存續之營利事業承受[211]。

所謂的「營業」，內涵上有法人團體及非法人團體，就法人的部分，公司法第 75 條已經有特別規定；非法人團體部分，應以該條作為非法人團體合併之概括繼受依據。該條概括繼受的標的就義務部分，民法第 306 條係以「負債」、「債務」加以闡述，其內涵為何？首先，就私法上的債務部分當然包含，較無疑義，然而是否有公法領域解釋的空間？民法第 306 條所指稱負債、債務之詞彙，實質上均是指「債務」，又債務一詞的內涵，依本文前所述[212]，其概念對應至公法領域，屬於財產權規制之下位概念，指一定給付關係下所生之給付拘束，具體而言可能包括公法上物之給付義務、涉及財產權規制之公法上不作為、容忍義務及公法上之私法契約勞務給付義務，均有可能加以涵蓋至民法第 306 條之「債務」一詞的內涵之中。據此，本文以為，該條就上開公法上義務，應可**類推適用民法第 306 條作為獨資、合夥合併概括繼受依據**。然而公法

[211] 陳敏（2009），〈人民公法上權利義務之繼受〉，《政治思潮與國家法學：吳庚教授七秩華誕祝壽論文集》，頁 475，台北：元照。
[212] 參照本文第三章、第一節、第三項、貳、一、（二）民法債務範圍及概念。

doi:10.6342/NTU202000774

上非私法契約所生之勞務給付義務及不涉及財產權規制之不作為、容忍義務，因無法由民法第 306 條解釋得出，故應交由立法者另立法規範為依據。

伍、執行程序之概括繼受依據

一、罰鍰於行政執行程序之繼受依據

（一）行政執行法第 15 條定位之辨析

行政執行法第 15 條本身究竟是「程序先行標的」抑或是「死後執行之依據」，尚有爭議，此爭議將會涉及於執行程序中，該條是否為義務人死後執行罰鍰的依據，以下試著從該條立法歷程及法體系解釋比較辨析行政執行第 15 條之性質、內涵究竟為何。

行政執行法第 15 條制訂時之立法說明，乃認為：「公法上金錢給付義務之執行，主要係對義務人之財產為執行，如義務人死亡而遺有財產者，為貫徹行政目的、迅速執行起見，自得對其遺產強制執行，爰參照財務案件處理辦法第 37 條訂定之[213]」。財務案件處理辦法第 37 條[214]乃規定：「納稅義務人或受處分人死亡遺有財產者，法院應對其遺產強制執行」。又，財務案件處理辦法第 37 條乃來自於舊強制執行法第 5 條第 2 項[215]之規定：「強制執行開始後，債務人死亡者，應對其遺產續行強制執行」。

[213] 立法院公報處（1998），《立法院公報》，87 卷 42 期，頁 196，台北：立法院。
[214] 財務案件處理辦法已於 83 年 1 月 14 日廢止。
[215] 於 86 年 4 月 22 日修正制定，現行法改以第 5 條第 3 項：「強制執行開始後，債務人死亡者，得續行強制執行」規範。

doi:10.6342/NTU202000774

由此可知行政執行法第 15 條之立法意旨，追本溯源乃參考舊強制執行法第 5 條第 2 項規定所制定[216]，且觀察行政執行法第 15 條與舊強制執行法第 5 條第 2 項兩者之法條結構、要件[217]幾乎相同，唯一的差異點在於舊強制執行法的規定，尚有明文**「強制執行開始後」**，然而行政執行法卻無如此明文，導致適用上產生究竟為執行中之程序規定；抑或是死後執行之依據，產生爭議。

既然行政執行法第 15 條之規定乃源自於舊強制執行法第 5 條第 2 項，仔細探究舊強制執行法第 5 條第 2 項之規範，係避免在執行程序中查封效力因債務人的死亡而受影響，使執行程序得以繼續執行，然而此條之運用乃限於金錢給付義務，反之在作為、不作為義務的執行則無適用之餘地[218]。實係一「金錢給付義務之執行程序當然停止例外規定」，並且參考舊強制執行法第 5 條第 2 項之立法理由，立法者乃認為，強制執行程序其兩造實體上之權義關係已經確定，與民事訴訟程序之性質不同，其程序開始後，即使債務人死亡亦無當然停止之必要（民事訴訟法第 168 條[219]參照）。由此可知，舊強制執行法第 5 條第 2 項之規定乃是針對強制執行之「執行程序」規定，即使執行義務人在強制執行中死亡，執行程序將非如訴訟程序因當事人死亡當然停止之，而是執行程序不因而終止，且執行名義之效力及於對原義務人（被繼承人）之遺產並加以執行之，並非規範義務人之繼承人將其所得之遺產移送強制執行之實體法法律依據。

行政執行法第 15 條之立法意旨，既係源自於舊強制執行法第 5 條第 2 項之

---

[216] 胡天賜（2012），〈債務人死亡後，如何執行其所遺不動產（二）－從釋字第 621 號解釋觀點評論法務部法律字第 0999047457 號函〉，《法務通訊》，2613 期，頁 5。

[217] 舊強制執行法第 5 條第 2 項：「強制執行開始後，債務人死亡者，應對其遺產續行強制執行」；行政執行法第 15 條：「義務人死亡遺有財產者，行政執行處得逕對其遺產強制執行」

[218] 張登科（2014），《強制執行法》，修訂版，頁 85，台北：三民。

[219] 民事訴訟法第 168 條：「當事人死亡者，訴訟程序在有繼承人、遺產管理人或其他依法令應續行訴訟之人承受其訴訟以前當然停止」。

doi:10.6342/NTU202000774

規定，可推論的是，立法者規範在金錢給付義務執行之程序章節[220]中，設想金錢給付義務之行政執行，亦有對於「遺產執行之可行性及便利性」，此點與私法領域之強制執行並無不同。

須注意者，雖行政執行法第 15 條與強制執行法規定兩者均只適用於「金錢給付義務」，然而，行政執行法之規定尚須區分該公法上金錢給付義務有無「一身專屬性」，且只有「無一身專屬性」者，始有行政執行法第 15 條之規定適用。原因在於，私法領域中對於一身專屬性之金錢給付義務，例如精神慰撫金之損害賠償請求權[221]或是夫妻間之剩餘財產分配請求權[222]，在此該等債權人尚未決定行使前，不得為執行之對象，然而在債權人決定行使該權利之後，即成為一般財產義務，而可得為執行之對象[223]。然而，在公法領域中，一身專屬性之義務不因國家「行使」而成為一般財產義務[224]，由於私法關係中，義務該當於法規範之要件即為「存在」，然而此種已存在之義務，尚須有權利人對此權利加以主張、行使之，待主張、行使之後，一身專屬性之義務即變成非一身專屬義務，此概念與公法領域有所不同。

行政執行法第 15 條乃執行中不因執行義務人死亡而停止之程序規範，使執行機關在義務人死亡後，得直接就遺產執行，此規範可推論出「作為執行依據

220 行政執行法第 15 條乃規範於該法第二章「公法上金錢給付義務之執行」。
221 民法第 195 條：「不法侵害他人之身體、健康、名譽、自由、信用、隱私、貞操，或不法侵害其他人格法益而情節重大者，被害人雖非財產上之損害，亦得請求賠償相當之金額。其名譽被侵害者，並得請求回復名譽之適當處分（第一項）。前項請求權，不得讓與或繼承。但以金額賠償之請求權已依契約承諾，或已起訴者，不在此限。前二項規定，於不法侵害他人基於父、母、子、女或配偶關係之身分法益而情節重大者，準用之（第二項）」。
222 民法第 1030 條之 1：「法定財產制關係消滅時，夫或妻現存之婚後財產，扣除婚姻關係存續所負債務後，如有剩餘，其雙方剩餘財產之差額，應平均分配。但下列財產不在此限：一、因繼承或其他無償取得之財產。二、慰撫金（第一項）。依前項規定，平均分配顯失公平者，法院得調整或免除其分配額（第二項）。第一項請求權，不得讓與或繼承。但已依契約承諾，或已起訴者，不在此限（第三項）。第一項剩餘財產差額之分配請求權，自請求權人知有剩餘財產之差額時起，二年間不行使而消滅。自法定財產制關係消滅時起，逾五年者，亦同（第四項）。
223 張登科（2014），《強制執行法》，修訂版，頁 97，台北：三民。
224 參照本文第三章、第一節、第二項、貳、二、（二）行政處分之作成。

doi:10.6342/NTU202000774

之處分不因原義務人於執行程序中死亡而失效」，並且在義務人死後「執行範圍尚及於其繼承人所得之遺產」此二者特徵。由此而知，解釋上行政執行法第 15 條之適用，應只適用於「非一身專屬性」之金錢給付義務之處分，蓋只有「非一身專屬性」義務之處分始具備「可繼受性」，得以在執行義務人死亡後，使義務移轉於繼承人而加以概括承受，處分不因喪失履行義務人及目的而失其效力。

反之，若是屬一身專屬性義務之處分，在行政執行程序中當事人死亡時，由於該一身專屬性義務欠缺可繼受性，則該處分將隨著義務人之死亡而失其效力，進而該執行名義則不再有效。又，繼承人既然無從繼受該一身專屬性之義務，則根本不受有該義務之規制及履行之負擔，其所得之遺產無從納入執行範圍，繼承人無須為他人已失效義務（處分）加以負責。是以，若是一身專屬性之處分，根本無從續行執行程序，亦無執行其繼承人所得遺產之正當性，當然無行政執行法第 15 條之適用之餘地，而應依照行政執行法第 8 條第 1 項第 3 款[225]的規定，對於此種「無法履行」之義務，執行機關得依職權或是其繼承人得申請「終止執行」，使執行程序終止之。

綜上，行政執行法第 15 條的規定，**屬行政執行程序中終止執行之例外規定**，並非處分生效後義務人死亡之死後執行之依據，如此解釋始符合該條之立法意旨、行政執行法體系及行政法上義務概括繼受之法理。

[225] 行政執行法第 8 條：「行政執行有下列情形之一者，執行機關應依職權或因義務人、利害關係人之申請終止執行：一、義務已全部履行或執行完畢者。二、行政處分或裁定經撤銷或變更確定者。**三、義務之履行經證明為不可能者**（第一項）。行政處分或裁定經部分撤銷或變更確定者，執行機關應就原處分或裁定經撤銷或變更部分終止執行（第二項）」。

doi:10.6342/NTU202000774

（二）小結

行政執行法第 15 條透過以上立法歷程分析，可知立法者因執行程序中當事人的權利義務已趨清晰，本於執行程序貴在迅速之法理，參考舊強制執行法所制定之程序先行標的規定，以避免因執行金錢給付義務人死亡而導致執行程序終止而拖延。故該條乃針對具備可繼受性的公法上金錢給付義務，在執行程序中就義務人發生概括繼受之時，執行程序例外不停止執行的規定，行政機關得直接對於繼承人所得的遺產逕為執行之規定，而非在執行程序中之實體法上義務概括繼受依據。進而，繼承人概括繼受金錢給付義務而受到遺產執行的依據，應該來自於類推適用民法 1148 條第 1 項之規範。

二、罰金於刑事執行程序之繼受依據

（一）刑事訴訟法第 470 條第 3 項之內涵

刑事訴訟法第 470 條第 3 項規定：「**罰金**及沒收，得就受刑人之遺產執行」，該條規範係對於刑事訴訟程序中，就刑事執行階段若受刑人發生死亡情事，得就其遺產加以執行，是否屬於刑事執行程序中就罰金的義務繼受依據？

該條文的定性，學理有認為我國在刑事訴訟法中明文罰金得就受刑人的遺產執行，可知立法者乃認為已成立罰金義務並不因受刑人死亡而消滅，且從德國刑事訴訟法第 459C 第 3 項明文規定：「對被判決人之遺產不得為罰金之強制執行」可知，我國與德國乃採不同的立法例，而肯定罰金性質上為可繼受的義務，並配合民法第 1148 條第 2 項的立法精神，僅得就受刑人的遺產範圍內為執

doi:10.6342/NTU202000774

行之[226]。

然而上開見解不無疑問，受有罰金義務的受刑人發生死亡時，該罰金義務是否由受刑人之繼承人加以繼承，關鍵應在於該**「罰金義務有無可繼受性」**。罰金與罰鍰兩者皆為金錢給付義務，前者性質屬刑罰；後者為行政罰，兩者的區別，參考刑事不法與行政不法區別理論，現今法學潮流乃朝向「量的區別說」，其認為刑罰與行政罰兩者間只是處罰手段不同而已，並不存在保護法益或制裁目的等之本質上差異[227]。換言之，違反行政法之行為，係對法律所保護法益乃較為輕微的侵害；而對於法益較為嚴重的侵害，才會具有刑罰的「可罰性」。由此可知，罰金與罰鍰兩者皆是對於人民財產上的剝奪，其差異在於罰金具有較高的倫理非難性，對於侵害法益情節嚴重之人民課與之；反之，罰鍰的倫理非難性較低，對於侵害法益情節較輕微之人民課與之[228]。

罰金及罰鍰義務，皆須有受罰人主觀上具備故意或過失此種歸責要件，又罰金義務是比罰鍰義務具有對義務人非難性「更高」的義務，探討罰金義務的可繼受性與否，不妨與罰鍰義務相比較之。司法實務見解[229]，對於行政法上之罰鍰義務認為，罰鍰係對違規行為人所施以財產上之制裁，此行政法上責任性質上不得作為繼承的對象。在實務見解中，認為罰鍰使義務人受有財產剝奪的痛苦，此種處罰乃具有一身專屬性，在義務人死亡後即無法達成處罰的目的，就「罰金」而言，本身亦是對於受刑人欲加諸財產剝奪之痛苦，此部分與罰鍰制裁的目的相同，就倫理非難性而言，甚至更高過行政法上之罰鍰。由此可

[226] 陳敏（2009），〈人民公法上權利義務之繼受〉，《政治思潮與國家法學：吳庚教授七秩華誕祝壽論文集》，頁 461，台北：元照。
[227]洪家殷（2010），〈行政罰法：第三講－行政罰上之一行為不二罰原則及其適用〉，《月旦法學教室》，88 期，頁 48。
[228] 許育典（2010），〈行政罰與刑罰之競合－評台北高等行政法院九十五年訴字第一四三六號判決〉，《月旦裁判時報》，3 期，頁 24。
[229] 參照最高行政法院 90 年 12 月份第 2 次庭長法官聯席會議決議、司法院民國 34 年 6 月 6 日院解字第 2911 號解釋。

doi:10.6342/NTU202000774

知，既然罰金與罰鍰兩者間並無制裁目的的差異，且刑罰的非難程度比行政罰更高，更應屬一身專屬性之義務方為合理，又此種一身專屬性的義務，應欠缺可繼受性，無從由受刑人的繼承人加以負擔之。



又就，「沒收」部分係不作為義務之展現，在刑法部分此種不作為義務已明文得由受罰人之繼承人加以概括繼受；反觀公法領域，沒收的概念，對應類似於「沒入」的概念，公法領域並未有類似刑事訴訟法第 470 條第 3 項的明文概括繼受規範，是否公法領域中的不作為義務，有類推適用該條的可能？本文以為，「沒入」為公法上的不作為義務的具體展現，本身尚須區辨為是否屬可繼受性義務，才有討論概括繼受之可能。且刑事訴訟法之沒收制度，是考量刑事犯罪行為非難情節較重大，刑事犯罪行為應不得保有其犯罪之利益，該等利益應加剝奪始符合公益，其目的有其合理性存在，故於刑事訴訟法明定受刑人之繼承人應概括繼受，有其。然而公法領域之沒入義務的產生，可能來自於不同特別行政法的規定，各個法規範對於沒入的目的內容有所不同，無法一概而論，故本文以為公法領域之「沒入」無從類推適用刑事訴訟法之規定。

（二）小結

刑事訴訟法第 470 條第 3 項的規定，直接明文罰金得就受刑人的遺產執行，檢討罰金的性質，可發現罰金是比罰鍰具有更高倫理非難性的金錢給付義務，乃著重該對於受刑人的財產限制所加諸的心理痛苦，且罰金刑尚須判斷受刑人行為時的主觀及客觀要件，若罰金在受刑人發生死亡時由其繼承人概括繼承，將無法達成使違反刑罰的受刑人，受有財產限制之痛苦非難的目的，故罰金本身屬於具有一身專屬性的金錢給付義務，欠缺可繼受性，應無從使受刑人之繼承人加以概括繼受。刑事訴訟法第 470 條第 3 項的規定實違反義務概括繼

doi:10.6342/NTU202000774

受的本質與要件，職是，該法第 470 條第 3 項對於罰金逕予執行之規定，應加以刪除較為合理，以符合義務繼受之法理。除非立法者能提出更具堅強之理由，合理化罰金義務具有可繼受性之說理。

第四項　我國公法上義務概括繼受之法體系建構及立法論建議

在法體系的建構上，對於公法上義務繼受法律依據之課題，法律保留程度的寬嚴爭議，誠如前述學理各有不同之見解，本文藉由對現行法對於自然人死亡概括繼受、法人合併、非法人團體及執行程序之概括繼受的探討，可發現即便公法領域尚未有義務概括繼受之基礎規範，可透過民法第 1148 條、公司法第 75 條及民法第 306 條規範之闡釋、分析，試著解釋有無涵蓋公法上義務的概括繼受概念。然而，考慮法律保留原則，除了告誡立法者對於侵害人民權利之事項須以法律制定，使該事項係透過具民主基礎的正當程序加以審議；尚有使被規範的人民能預見法規範評價的作用，在公法領域是否仍須另外明文制定概括繼受之基礎規範以符合較嚴格的法律保留原則的必要？

站在實用的觀點，若公法領域中另以明文制定了義務概括繼受的基礎，其規範內容亦與民法第 306、1148 條與公司法第 75 條文字規範幾乎無差異，實際上，只是在公法領域內，將民法及公司法相同事物之再次重申而已，似乎欠缺另定公法規範之實際意義。從現行法民法第 1148、306 條及公司法第 75 條的解釋與分析，的確可合理得出涵蓋公法上義務的空間，就自然人死亡部分，對於原義務人公法上作為義務中，金錢給付義務、金錢以外物之給付義務部分、私法契約下之勞務給付義務，及限制財產權之不作為或容忍義務，可類推適用民法第 1148 條第 1 條使繼承人概括繼受之；其餘非私法契約之勞務給付義務、非限制財產權之不行為、忍受義務部分，則應由立法另立公法上依據作為其概括

doi:10.6342/NTU202000774

繼受之基礎。就法人合併部分，合併前法人所負之公法上義務，則類推適用公司法第 75 條規定，作為合併後存續或另立法人之概括繼受法規範基礎。就非法人團體之合併部分，得是可藉由類推適用民法第 306 條，使合併後之非法人團體概括繼受公法上義務。

然而，仔細解析民法第 1148 條第 1 條的結構可知，其文字要件係繼承人自繼承開始時，「除本法另有規定外」，承受被繼承人財產上之一切權利、義務。由此可知民法的概括繼受法依據，立法者在其中加入**「除本法另有規定外」**的諭知，目的應在於除了自然人概括繼受的法依據以外，**立法者應盡量讓各個法領域的概括繼受均有法體系建構，以健全法規範**，雖然藉由現行民法第 306、1148 條、公司法第 75 條的規範要件，據以得出有類推適用部分公法上義務的空間，然在自然人死亡或是非法人團體合併情況，仍有部分的公法上義務無法分別從民法第 1148 條第 1 項解釋及民法第 306 條得出，尚待立法者另立新法。

由此可知，即使透過私法領域的用語可得出有公法概念解釋的空間，仍無法完全將問題解決，較為周全之道，應係立法者就公法上義務的概括繼受制定出一套完整的體系，就自然人、法人、非法人團體均加以規範，以改善現行法規範下類推適用的極限，及公法體系的不健全。

再者，就行政執行法第 15 條的規定，實屬一行政執行中之終止例外規定，現行大法官解釋及司法實務見解，對該條均多誤會屬於罰鍰死後執行之實體法上依據，而追本溯源之方法，應該是在立法技術上，立法者將現行之行政執行法第 15 條中，加入**「於執行程序中死亡」**之字句，改為：「義務人**於執行程序中**死亡遺有財產者，行政執行處得逕對其遺產強制執行」，如此修法，應可明確表示該條屬於執行程序中終止之例外程序規定，已減少司法實務之歧見與誤會。另外，就刑事訴訟法第 470 條第 3 項罰金義務概括繼受的規定，立法者應

doi:10.6342/NTU202000774

該另提出更具正當性之理由，說明受刑人之繼承人概括繼受非難性甚重之罰金義務合理化事由。

第二節　不真正繼受概念探討

義務人被課予之義務，可能來自於行為責任或狀態責任，此兩者之義務是否皆具備可繼受性，則有所爭議。介紹完典型概括繼受制度（真正繼受）之後，必須對「真正繼受」及「不真正繼受」加以分析區辨，使得完整了解繼受之樣貌。

第一項　行為責任與狀態責任下義務繼受之差異

概括繼受的概念要件為「主體不同一性」、「義務（標的）同一性」[230]，可以發現「行為責任」與「狀態責任」在「義務（標的）的同一性」思考，兩者將產生本質上差異。較無疑問者係「行為責任」下義務之繼受，因該種義務之基礎，是來自於前手之「行為」，因而背負之「義務」在具備可繼受性下，得以將該義務由其繼承人承繼而接續，該義務標的不因此中斷、改變其內涵進而移轉，可滿足「義務同一性」此一要件之要求，為典型的概括繼受。

然而，若是「狀態責任」，其發生係本於「物之所有權或是事實上管領」作為基礎，因物而負有狀態責任所生義務之前手，發生繼承事由後，繼承人則成為「新的所有權或是新的事實上之管領人」之地位，則前手因死亡或是合併喪失該所有權或是事實上管領之地位，原本因狀態責任所生之義務將失所附麗而消滅，繼承人負有該狀態責任之義務，係起因所有權之概括移轉而取得狀態責

[230] 參見本文第二章、第二節、第二項 概括繼受於公法領域中之適用之說明。

doi:10.6342/NTU202000774

任之標的物，進而以新的所有權人地位而成為新的狀態責任人，負有一「新的狀態責任內涵之義務」。故狀態責任下的義務，於概括繼受事由發生時，該義務係消滅了又發生新的義務，兩者義務內容即使相同，但已非原始「一個義務」之接續，進而欠缺「義務同一性」之要求，此種情況無法該當於的義務概括「繼受」之要素。據此，以「狀態責任」作為義務基礎之行政處分，受處分人如發生繼受事實，其繼承人並不受有該處分的移轉而具有義務地位之承繼，不屬於典型概括義務繼受之概念[231]。

第二項　不真正繼受概念爭議

此種狀態責任作為內涵之義務情況，對於其繼承人將產生的新的義務，行政機關應是否對繼承人作成新的行政處分；抑或是原先之處分效力當然及於繼承人，學理與實務見解尚有疑問。

有學理認為，此種以狀態責任為內涵之行政處分，無需另為行政處分，原因係該種行政處分係屬「對物之行政處分」及輔以「程序經濟」之角度考量，該種行政處分係針對於物、不動產、客體之規制，不論任何人作為該物或不動產之所有人或是事實上管領人，皆不影響該義務而繼續存續之，行政機關應無需再作成新的行政處分之程序，將有利於行政執行之程序進行，最重要者乃可避免原義務人利用物之移轉故意拖延行政執行之進行，故此說肯定以狀態責任為內涵之行政處分具備「處分效力繼受」特色，亦有稱此為「不真正繼受效力」，此見解在德國行政法院歷來之裁判亦肯定此種不成文的「對物性」繼受要

[231] 李建良（2006），（行政法上義務繼受問題初探－兼評高雄高等行政法院九十二年度訴字第八○六號判決暨最高行政法院九十四年度判字第六二二號判決），《2005 行政管制與行政爭訟》，頁 85-87，台北：中央研究院法律學研究所籌備處。

doi:10.6342/NTU202000774

件[232]。

另有認為，以狀態責任之「對物性」之特徵，尚不足以作為處分之效力得延續於另一主體之正當性基礎，蓋行政處分之基礎內涵，是以特定人作為義務設定對象，並非對於不特定人作為規制，除了某些單純屬物性之處分，例如道路提供公用之一般處分（行政程序法第 92 條第 2 項後段），此種針對物之一般使用緊密相關者以外，行政處分是否能具效力延續性，將挑戰法律保留原則之界線，以及人民享有之正當法律程序保障。雖然站在行政權之角度，其作成處分規制內容、目的皆相同，只是由不同的人去負擔，將行政處分之效力以「對物性」加以解釋似乎並無不妥，然行政處分之內涵，乃行政機關對於「特定人」為「具體內容」之對外法效規制，「特定人」乃作為行政處分構成之不可或缺之要素，若只看義務內容以「物」作為標的，將完全忽略「人（權利主體）」亦是受有規制之要件，將背離行政處分的原理，故單就狀態責任對物性之特徵的行政處分，乃無法填補法效延續之正當性基礎，且亦將剝奪物之繼受人依行政程序法所能享有之正當程序，即便考量程序經濟，亦無法犧牲當事人原應享有之程序利益作為代價[233]。

然仍可能發生例外的情況，例如：物之所有人為了脫免其義務，惡意將該物移轉於第三人，造成行政權執法之妨礙時，可以援引「權利濫用」之理論，使惡意之物之繼受人，受該處分之效力所及之拘束；另外亦有認為，當物之繼受人明知或或因重大過失而不知時，本於誠信原則之法理與行政便宜、法律保

232 李建良（2006），（行政法上義務繼受問題初探－兼評高雄高等行政法院九十二年度訴字第八○六號判決暨最高行政法院九十四年度判字第六二二號判決），《2005 行政管制與行政爭訟》，頁 105，台北：中央研究院法律學研究所籌備處。

233 李建良（2006），（行政法上義務繼受問題初探－兼評高雄高等行政法院九十二年度訴字第八○六號判決暨最高行政法院九十四年度判字第六二二號判決），《2005 行政管制與行政爭訟》，頁 105-106，台北：中央研究院法律學研究所籌備處。

doi:10.6342/NTU202000774

留原則之間的衡平，則該處分之效力應可能及於物之繼受人[234]。



第三項　本文見解

本文認為，狀態責任的特徵，依前述[235]狀態責任及義務之產生、存續，係因擁有物之所有權或實際管領而起；狀態責任及義務之消滅、係因失去、喪失物之所有權或實際管領而發生。仔細觀之，其實該處分效力並未延續，而是在移轉之瞬間中斷而消滅，後手頂多因該物之移轉取得而負有「原始之狀態責任人之地位」，僅僅如此而已，行政機關尚必須對該因移轉而成為新的原始狀態責任人，另作成新的行政處分，始得具體化其義務內涵及相對人。職是之故，以「對物之行政處分」作為行政處分效力延續之基礎乃欠缺正當性，且與行政法體系原理相悖離。然而，學理認為在惡意脫免義務而移轉物之所有權於他人及物之繼受人明知或因重大過失而不知之兩個例外情況，乃專指「個別繼受」之情況，也就是以「法律行為」處分該物，本文論述之核心──概括繼受之情況，於自然人死亡而概括繼承部分應無所適用之餘地。然而在法人或非法人團體，因合併而概括繼受部分，具備內部機關之自然人之意思存在，故惡意脫免義務或是明知因重大過失而不知之兩個例外之適用，尚有探究之餘地。

綜上，將狀態責任內涵之行政處分，認為具有「行政處分效力」之繼受效力者，實乃錯誤之理解。進一步探究，以狀態責任作為內涵之行政處分，在公法上義務繼受要件檢視下，既然因該狀態責任人的死亡或遭合併，將使該狀態責任下之義務失其依附而消滅，無從延續、移轉該義務，當然無法效繼受之可

---

234 李建良（2006），（行政法上義務繼受問題初探－兼評高雄高等行政法院九十二年度訴字第八○六號判決暨最高行政法院九十四年度判字第六二二號判決），《2005 行政管制與行政爭訟》，頁 107，台北：中央研究院法律學研究所籌備處；王晨桓（2009），《行政法上金錢給付義務之繼受問題-以罰鍰及課稅為討論重心》，國立臺灣大學法律學研究所碩士論文，頁 32。

235 參見本文第二章、第二節、第三項、貳、二、狀態責任。

doi:10.6342/NTU202000774

能，物之繼承人乃承繼乃「物之所有權」而已，故所謂「不真正繼受」、「行政處分法效繼受」此種概念不宜承認之。

第三節　概括繼受之正當法律程序建構

所謂「正當法律程序」，其理念乃源自於英國法之「自然正義程序」，所謂自然正義是指任何人不假思索，依其固有的理性即可判斷為正當也，其內涵包括三項要素，分別為在「公正的法庭前聽證之權利」、「獲悉指控之權利」、「就指控進行答辯的權利」，此三種要素充分體現「公平」、「公正」兩項古典正當程序之展現；近代的正當程序尚加入了美國法所提倡而普及之「公開」原則，此三項原則──「公平、公正、公開」，不僅僅適用於傳統之司法程序，尚擴及至行政程序中，聚焦於我國法行政程序法，學理有認為綜觀我國之規定，具有五項要素之實踐，分別為「公正作為義務」、「受告知權」、「聽證權」、「理由說明義務」、「行政資訊公開」[236]。

進一步，思考應賦予概括繼受人何種內涵之程序保障，可分為兩個層次，首先是「是否給予程序保障」此首要課題應先行釐清。蓋必須分析被繼受人所負有之義務是否具備可繼受性，若屬一身專屬性義務，抑或是尚未達到具體行政義務之程度時，則此義務既然欠缺可繼受性，該義務將因原義務人之死亡或合併而消滅之，其繼承人根本不受有該義務移轉而自始不受到該義務之規制。行政程序上，義務因義務主體因死亡或是合併消滅，致使行政程序主體欠缺當事人能力而程序終結，繼承人不概括繼受該義務而受有規制，無須對之踐行正當行政程序。

[236] 湯德宗（2003），〈論正當行政程序〉，《行政程序法論》，2 版，頁 8-9，台北：元照。

doi:10.6342/NTU202000774

反之，若義務具有可繼受性，概括繼受人具有移轉義務主體地位時，應賦予何種正當程序，屬「如何給予程序保障」之次要課題。此一課題的分析，應釐清概括繼受人在義務繼受體系下所受有之侵害態樣，將有助理解之。蓋繼受人因繼承事實發生，而受有義務地位之移轉及基本權利的干預，故釐清關於義務繼受的思考脈絡、要件判斷之後，對於受義務地位移轉之繼承人，賦予合理正當行政法程序之保障，能使行政機關透過正當程序之進行，正確判斷具體案例之公法上義務有無可繼受性、繼承人究竟為何，以及義務的賦予對於繼承人究竟是否過當而應調整至以其所繼受遺產為限等等，始能對繼承人所受到實體法之侵害中透過行政程序正當性之踐行，使其行政法上主體地位能受到尊重。

換個角度而言，原義務人被課予義務時，既受有告知、陳述意見、聽證及訴訟救濟等等完整之正當法律程序之保障，則概括繼承人同樣受有該相同義務內涵之規制，義務來自之原因係因「繼承之事實」而生，而非具有義務歸責事由，亦非屬在個別繼受情況具有繼受人之意思介入，則繼承人所受有之程序保障應至少與原義務人（前手）等之，始為公允。

概括繼受的正當法律程序之建構，可能使繼承人的程序利益與行政效能、有相互拉扯之情況，然可合理思考的是，應以繼受人之基本權利能受到完整程序保障作為原則，例外只有在「不侵害正當程序之重要內容」或「具有本質重要性而為規範秩序賴以成立之基礎」之情況下，始得例外以行政效能超越當事人程序保障作為考量[237]。

[237] 李震山（2007），〈程序基本權〉，《多元寬容與人權保障：以憲法未列舉權之保障為中心》，2版，頁 261-262，台北：元照。

doi:10.6342/NTU202000774

第一項　概括繼受之正當行政程序

壹、繼受義務之調查

行政機關必須對於義務繼受之事實加以調查，此調查依照行政程序法第36、39、40條[238]之規定，其方式原則上以行政機關職權調查事實與證據而不受當事人主張拘束，然行政機關另外亦可通知或要求相關當事人親自說明或是提出相關文書等協力事項。也即，對於事實之調查釐清，行政機關除了應本於職權調查外，就某些待證事實，人民掌有比行政機關更優勢之地位時，人民亦負有一定程度協力負擔，較為公平。

在概括繼受下，自然人因死亡之繼承事實所造成之義務概括移轉，並無繼承人之意思介入，對於該義務內容履行之程度、應履行之內容及標的，及繼承人認定及應如何履行、履行之程度等等，應交由行政機關加以職權調查較為妥當。

然而，法人或非法人團體因合併所造成新設或存續之法人或非法人團體，其合併事實上需透過其自然人所組成內部機關作成合併之決定及合併契約等，始能產生合併之效果，故法人及非法人團體合併之概括繼受，實際上具有其內部自然人意思介入存在，合理推知其內部自然人對於合併的決定與否，通常都會充分考慮彼此間法人或非法人團體之體質及財務狀況，對於概括移轉義務內容之掌握度，絕對高於在自然人死亡之繼承人能掌握之情況，其所握有之資訊

238 行政程序法第36條：「行政機關應依職權調查證據，不受當事人主張之拘束，對當事人有利及不利事項一律注意」、第39條：「行政機關基於調查事實及證據之必要，得以書面通知相關之人陳述意見。通知書中應記載詢問目的、時間、地點、得否委託他人到場及不到場所生之效果」、第40條：「行政機關基於調查事實及證據之必要，得要求當事人或第三人提供必要之文書、資料或物品」。

doi:10.6342/NTU202000774

相較於行政機關立於較為優勢之地位，故行政機關在此情況，應可對於該合併後新設或存續之法人或非法人團體，課與一定程度的事證調查之協力負擔，使該法人對於義務繼受之詳細內容加以提出，較為公允且適當。若法人不履行行政機關所課予事證調查之協力負擔，其後果應為就概括受義務之相關事實，就舉證責任上將受有不利益之認定[239]。

貳、另作成行政處分送達繼承人

確定完發生概括繼受之事實後，須對於繼承人為繼受義務之告知而送達行政處分，其乃正當行政程序中「受告知權」之展現，其內涵為行政程序中的當事人或利害關係人對於有即獲悉其利害攸關之事實及決定的權利，告知有三種，分別為在「行政程序中將實施之預告告知」(例如行政程序法第 39 條調查事證時，行政機關得通知相關之人陳述意見)、「作成終局決定之結果告知」(例如行政程序法第 100 條，應將書面行政處分送達於相對人或已知的利害關係人，若是書面以外之處分，則應該用其他適當的方法加以通知之)、「救濟途徑之教示」(行政程序法第 96 條第 1 項）[240]。

因繼承事實之發生，被繼承人因死亡或是因法人、非法人團體合併，使義務主體地位喪失而欠缺當事人能力，導致原處分失效，則行政機關自應將新受有義務地位之繼承人，對其作成新的行政處分，也就是改以「新的處分相對人（繼承人)」之行政處分加以告知，以符合行政處分之原理及繼承人享有受告知權之保障，使參與行政程序及終局決定之作成，更重要者，藉由新處分之作成，使救濟時效從送達該新處分時起算，使繼承人得加以爭執義務的適法性。

[239] 洪家殷（2010)，〈論行政調查中職權調查之概念及範圍－以行政程序法相關規定為中心〉，《東吳法律學報》，21 卷 3 期，頁 36。
[240] 湯德宗（2003)，〈論正當行政程序〉，《行政程序法論》，2 版，頁 21-22，台北：元照。

doi:10.6342/NTU202000774

又，德國學說上有認為，若原義務人在行政機關已送達原處分後始發生繼受事實時，因該處分已經生效，則此時不應對其繼承人再為送達，以避免繼承人本於新處分而導致程序重新開啟，尤其是指爭訟程序的重新開啟，致使程序延宕[241]。然本文以為此種見解應不可採，蓋原處分所欲拘束及規制對象為「被繼承人」，則該處分的形式存續力只存在於「被繼承人」身上，義務既然透過概括繼受制度的運作，使義務地位概括移轉於繼承人，則行政機關應無從以原處分的形式存續力拘束繼承人，進而限制繼承人在承繼該義務下應可享有之正當程序利益。且，即使給予繼承人行政程序法第 128 條[242]之「程序重開」程序亦無法滿足，因原處分根本不是對於繼承人為對象之規制，給予繼承人程序重開替代作成新處分等相關行政程序之實踐，仍根本欠缺其正當性，故本文以為仍必須對於概括繼承人作出新處分且送達，重新為形式存續力之起算。

參、繼承人應享有聽證權

所謂「聽證權」乃指當事人對於指控或不利決定進行答辯或防禦之機會，此權利乃「兩造兼聽」之展現。在行政程序法上對於聽證權之展現，分為正式（聽證程序[243]）及非正式（陳述意見之機會[244]）之聽證權[245]。

---

241 王晨桓（2009），《行政法上金錢給付義務之繼受問題-以罰鍰及課稅為討論重心》，國立臺灣大學法律學研究所碩士論文，頁 51。

242 行政程序法第 128 條：「行政處分於法定救濟期間經過後，具有下列各款情形之一者，相對人或利害關係人得向行政機關申請撤銷、廢止或變更之。但相對人或利害關係人因重大過失而未能在行政程序或救濟程序中主張其事由者，不在此限：一、具有持續效力之行政處分所依據之事實事後發生有利於相對人或利害關係人之變更者。二、發生新事實或發現新證據者，但以如經斟酌可受較有利益之處分者為限。三、其他具有相當於行政訴訟法所定再審事由且足以影響行政處分者。前項申請，應自法定救濟期間經過後三個月內為之；其事由發生在後或知悉在後者，自發生或知悉時起算。但自法定救濟期間經過後已逾五年者，不得申請。」

243 行政程序法第 54-66，107-109 條。

244 行政程序法第 102-106 條。

245 湯德宗（2003），〈論正當行政程序〉，《行政程序法論》，第二版，頁 26-28，台北：元照。

doi:10.6342/NTU202000774

繼承人因受移轉他人之義務，成為新的規制義務主體地位之人，核其性質屬行政程序法中之「當事人」[246]，符合屬於聽證程序中，得被通知參與程序之對象及得在聽證程序得提出意見、證據之對象，以及陳述意見程序中所規定的主體對象，原則上至少要給與繼承人陳述繼承該義務意見的機會，使行政機關能藉由其行政調查的結果與繼承人之陳述兩者加以斟酌，有助於將課予的義務內容作成貼近事實，且行政機關亦能針對個案情況適當調整之。

肆、處分中應為理由說明

行政機關給於人民之規制，必須說明其作成決策之理由，一方面是為了使人民充分知悉為何而來及如何做成該決定，另一方面當事人在進入行政救濟時能為有效的攻擊、防禦[247]。

依照行政程序法規定下，義務之概括繼受實為一侵益處分，並不符合第 97 條[248]之規定，是以作成書面之行政處分時，必須加以記載其理由方為適法。

第二項　概括繼受之正當爭訟程序

義務概括繼受的發生，有可能是在原處分人對於其受有義務之處分不服，而提起行政爭訟時，於行政爭訟程序中死亡，該程序的接續及如何給予正當程序，為概括繼受義務之課題中不可或缺之一環。

---

[246] 行政程序法第 20 條第 2 款：「二、行政機關所為行政處分之相對人」。

[247] 湯德宗（2003），〈論正當行政程序〉，《行政程序法論》，2 版，頁 28-29，台北：元照。

[248] 行政程序法第 97 條：「書面之行政處分有下列各款情形之一者，得不記明理由：一、未限制人民之權益者。二、處分相對人或利害關係人無待處分機關之說明已知悉或可知悉作成處分之理由者。三、大量作成之同種類行政處分或以自動機器作成之行政處分依其狀況無須說明理由者。四、一般處分經公告或刊登政府公報或新聞紙者。五、有關專門知識、技能或資格所為之考試、檢定或鑑定等程序。六、依法律規定無須記明理由者」。

doi:10.6342/NTU202000774

訴願程序或行政訴訟程序中，原處分人作為訴願人而提起訴願，或是作為原告提起行政訴訟時，在爭訟程序中死亡或是因合併而消滅，繼承人所應承受者，尚可以分為**「實體法上的義務繼受」**、及**「程序法上的程序主體承受」**兩個層次討論，且因義務是否具有可繼受性而有不同的討論，故以下將以訴願（訟）標的以「有無繼受性」區分並分別論述之。

壹、訴願（訟）標的義務具一身專屬性

若原處分之義務不具可繼受性，原處分人之繼承人並不概括繼受該義務，實體法上不受義務移轉之規制，然而在程序法上是否應承繼該訴願人地位而承受訴訟，具有探討之價值。

學理有肯定者認為，「實體法上義務可否繼受」與「程序法上地位是否承受」，此兩者間雖然關係密切，但是並非「充分必要條件關係」，質言之，具有可繼受性義務之行政處分，其訴願人之地位皆得由其繼承人承受其訴願程序，反之若訴願標的之行政處分中的義務不具備可繼受性時，則其繼承人「未必」不生訴願承受之問題，從大法官釋字第 621 號解釋中即可得知「…受處分人死亡而遺有財產者，依行政執行法第 15 條之規定，該遺產既得由行政執行處強制執行，至對其繼承人依民法第 1148 條規定所得繼承之遺產有所限制，亦應許繼承人以利害關係人身份提起或續行行政救濟…」，此釋字之脈絡中可知，罰鍰處分係具有一身專屬性，不具有被繼受能力，然即使訴願人的權利義務不能由繼承人繼受，繼承人仍然得以其繼承權受侵害為由而承受訴願人之地位而爭訟，可知實體法上義務繼受與否與程序法上程序主體地位之承受，兩者間並無一定

doi:10.6342/NTU202000774

之依存關係，皆須給予其繼承人程序上地位之承受資格[249]。

以上的學理見解，係以釋字第 621 號解釋作為論證之依據，該號釋字之結論，係認為在訴願（訟）標的不論有無可繼受性下，在行政爭訟程序中義務人即使死亡，即依行政執行法第 15 條[250]規定而可對於原義務人之遺產加以執行，故必須對於繼承人的程序利益亦須加以保障，且該號釋字見解亦透露現行實務的處理方式。

但該號釋憲實務之結論，尚非無置喙之餘地，蓋「程序法上地位之賦予」與否，始終須緊扣該主體是否在「實體法層面上基本權利上受到侵害、限制」，加以實質觀察之。據此，本文欲探究，究竟對於「欠缺可繼受性義務」內涵之處分，若其義務人於爭訟程序中死亡，是否對於繼承人產生實體法上之限制，及該實體法上限制之正當性是否存在？此乃必須先行釐清之第一個問題。若肯定有實體法上限制之正當性，則繼承人受到的限制範圍，究竟以被繼承人之遺產為限，抑或是除了遺產以外亦及於繼承人自己的固有遺產？則為第二個問題尚待釐清者。職是之故，繼承人是否、如何賦予爭訟程序上程序主體，必須先分析以上所提出之兩個問題，始能得到正解。

是以，若肯定具有限制繼承人實體法之正當性，繼承人將受到憲法第 15 條所保障財產權的限制，站在憲法第 16 條訴訟權之憲法有權利即有救濟原則，繼承人理所當然有權利於爭訟程序續行訴訟加以爭執之；反之，若對繼承人根本欠缺限制實體法上權利之正當性，則無從加諸繼承人繼受義務之負擔，繼承人既無義務，程序上繼承人將欠缺「訴訟權能」，該繼承人應無承接訴訟之地位或

[249] 劉建宏（2009），〈法定訴願承受制度之探討－兼論以死亡之人名義提起訴願之相關問題〉，《臺北大學法學論叢》，72 期，頁 17-19。

[250] 行政執行法第 15 條之規定：「義務人死亡遺有財產者，行政執行處得逕對其遺產強制執行」。

doi:10.6342/NTU202000774

是另提起訴訟之地位，訴願機關或法院應分別作不受理決定（訴願法第 77 第 6 款）、裁定駁回判決（行政訴訟法第 107 條第 3 款）。

綜上，須先釐清行政執行法第 15 條內涵，再以概括繼受制度之角度分析繼承人將受有之限制有無及內容，始得建構出繼受之正當爭訟程序。以下整理釋憲實務見解、司法實務見解與學說見解分析，最後試著提出本文之觀點。

一、釋憲實務見解

大法官釋字第 621 號解釋理由書及其協同意見對於行政執行法第 15 條之定性及適用見解，分項整理如下。

（一）行政執行法第 15 條乃行政執行之實體特別規定

文義及體系解釋上，行政執行法第 15 條之規定，乃「公法上金錢給付義務」應為強制執行及其執行標的之「實體特別規定」，而非應先執行標的之「程序問題」，且在行政執行法第 43 條[251]授權訂定之施行細則第 2 條[252]，已明定公法上金錢給付義務為何，具備授權明確性、法律明確性，此種明文與刑事訴訟法第 470 條第 3 項[253]規定相當。

（二）行政執行法第 15 條之適用不區分金錢給付義務「有無可繼受

[251] 行政執行法第 43 條：「本法施行細則，由行政院定之」。
[252] 行政執行法施行細則第 2 條：「本法第二條所稱公法上金錢給付義務如下：一、稅款、滯納金、滯報費、利息、滯報金、怠報金及短估金。二、罰鍰及怠金。三、代履行費用。四、其他公法上應給付金錢之義務」。
[253] 刑事訴訟法第 470 條第 3 項：「罰金及沒收，得就受刑人之遺產執行」。

doi:10.6342/NTU202000774

性」

歷史與目的解釋上，79 年 9 月法務部對於行政執行法修正草案，關於遺產執行的規定，立法理由乃指出公法上金錢給付義務之執行，主要係對於義務人之財產為執行，如義務人死亡而遺有財產，為貫徹行政目的，迅速執行起見，自得對其遺產強制執行，而參照財務案件處辦法第 37 條[254]訂定。從立法理由可知，系爭條文應為對於公法上金錢給付義務之執行強制執行及其執行標的之實體特別規定，且立法理由中亦未進一步區分該公法上金錢給付義務係「財產性」或是「一身專屬性」(有無可繼受性)，亦未論及系爭條文乃應先執行標的之「程序問題」。

（三）以死亡之義務人之「遺產」作為行政執行之界線，符合比例原則

合憲解釋上，對於死亡義務人之遺產加以強制執行，並不具備制裁繼承人之性質，並未違反「行為人自己原則」、「無責任即無處罰或是「罰（罪）及一身」之概念，立法者本於貫徹罰鍰之公益目的，對於因罰鍰而生之公法上金錢給付義務之義務人死亡而遺有財產者，在立法形成之自由下，立法者認為應優先考慮罰鍰制裁行為外不知結果之本質，而建立起法治秩序與促進公共利益之作用，不因義務人死亡而影響之。對於繼承人所得繼承之遺產雖有限制，但並未限制至繼承人之固有財產，其乃屬合理且必要，據此從文義、體系、歷史及目的解是以觀，將系爭條文解釋包含罰鍰得就義務人之遺產執行之實體特別規定，並未違憲。

[254] 財務案件處辦法第 37 條（已廢止）:「納稅義務人或受處分人死亡遺有財產者，法院應對其遺產強制執行」。

doi:10.6342/NTU202000774



（四）不論處分「有無確定」，仍不影響對遺產之執行

義務人死亡時，處分是否確定（具備形式確定力），並不影響執行，蓋行政執行法第 15 條中並未區分處分有無確定而異其適用，若如此區分將會排除行政執行法施行細則第 2 條內容之效果，而致違憲之結果，且縱使法律明定此種行政處分不予執行，或因執行不可能而不與執行者，均非已生效之行政處分當然失效。

（五）小結

以釋憲實務之見解，義務人若在爭訟程序中死亡之情況，不論生前負有「公法上金錢給付義務」所背負的義務有無可繼受性，均可對其之遺產加以執行，由此見解下可知，只有金錢給付義務人於爭訟程序死亡時，其繼承人將會因行政執行法第 15 條之規定，其遺產將受到執行，其繼承人之財產權所導出之繼承遺產權利將會受到限制，則繼承人當然得於在爭訟程序中承受爭訟程序，本於利害關係人之身分進行救濟之。

反之，若是「公法上非金錢給付義務人」於爭訟程序死亡，因行政執行法第 15 條的文義解釋及其行政執行法施行細則第 2 條所闡述之內涵，不包括「非金錢給付義務」部分，故該非金錢給付義務人之繼承人不會受到該條限制，亦無其他法規範明文非金錢給付義務人之繼承人將受到死後執行之依據，由此可知，該繼承人既無需概括繼受該義務，亦不生執行義務之任何負擔，非屬處分相對人抑或是利害關係人，故該繼承人將欠缺訴訟權能，無從承受訴訟或是另

doi:10.6342/NTU202000774

提起訴訟，訴願機關或法院應對此情況分別做成不受理決定[255]或裁定駁回之判決[256]，

二、法院實務見解

司法院 28 年 9 月 23 日院字第 1924 號解釋：「匿報契價之責任，既屬於死亡之甲，除甲之繼承人仍應照章補稅外，自不應再行處罰」。又，最高法院 89 年度判字第 2556 號判決要旨：「被繼承人劉○波補徵贈與稅部分，屬公法上之租稅債務，基於繼承之法則，固應由繼承人即原告等負清償之責。惟罰鍰部分，不論為行為罰或漏稅罰，均係對受處分人之違章行為加以處罰，具有專屬性，劉○波既已死亡，受處分之主體已不存在，且對已死亡者再作懲戒性行為亦無實質之意義」。另外，最高行政法院 90 年 12 月 27 日第 2 次庭長法官聯席會議亦指出：「行政罰鍰係國家為確保行政法秩序之維持，對於違規之行為人所施之財產上制裁，而違規行為之行政法上責任，性質上不得作為繼承之對象。如違規行為人於罰鍰處分之行政訴訟程序中死亡者，其當事人能力即行喪失。尚未確定之罰鍰處分，對該違規行為人也喪失繼續存在之意義而失效。又其繼承人復不得承受違規行為人之訴訟程序，受理行政訴訟之高等行政法院應適用行政訴訟法第 107 條第 1 項第 3 款，以裁定駁回違規行為人之起訴。」

可知司法實務見解認具有「一身專屬性」的金錢給付義務（罰鍰），將會因處分人之死亡而喪失處分欲達成之目的，也即財產權剝奪的心理痛苦，只有在處分人尚生存才有體會、感受之可能，若處分人死亡，此種一身專屬性的處

[255] 訴願法第 77 條第 3 款：「訴願事件有左列各款情形之一者，應為不受理之決定：三、訴願人不符合第十八條之規定者」、第 18 條：「自然人、法人、非法人之團體或其他受行政處分之相對人及利害關係人得提起訴願」。

[256] 行政訴訟法第 107 條第 3 款：「原告之訴，有下列各款情形之一者，行政法院應以裁定駁回之。但其情形可以補正者，審判長應定期間先命補正：三、原告或被告無當事人能力者」。

doi:10.6342/NTU202000774

分，將失去其存在之目的而使處分失其效力。

故司法實務見解，多認為具有一身專屬性的處分，處分人於爭訟程序死亡，該處分將會因處分人欠缺當事人能力而訴願機關應作成不受理決定、行政法院則應該作成裁定駁回之判決，且義務人之繼承人無從承受爭訟程序。

三、學說見解

大法官釋字第 621 號解釋之廖義男大法官不同意見書，對於該號釋字之多數意見指出反對見解及理由，分項整理如下。

（一）行政執行法第 15 條之適用範圍與該法施行細則第 2 條之範圍並不相同

行政執行法施行細則第 2 條之明文，係在說明行政執行法第 2 條所指之公法上金錢給付義務之概念、內容為何，並非對於行政執行法第 15 條中所謂死亡之義務人之「義務」範圍為何，故「公法上金錢給付義務之概念」與行政執行法第 15 條所指之死亡義務人所負之「義務」兩者並非相同。

（二）處分作成而生效後，不代表行政執行即有理由

多數意見認為罰鍰處分一旦作成即具備執行力，故義務人死亡而遺有財產者，行政執行處即得逕對其遺產強制執行，然後在現行法並非均如此，例如：

doi:10.6342/NTU202000774

稅捐稽徵法第 50 條之 2 的規定[257]、社會秩序維護法第 51 條的規定[258]，立法者乃要求必須在此兩種罰鍰的裁處確定後，也即行政救濟程序終結後，使得行政執行之，由此可知該號釋字多數認為「罰鍰之處分作成而具執行力，即得強制執行」，乃忽略其他法律不同的規定。

（三）一身專屬性義務之處分相對人於爭訟程序死亡，將使尚未確定之處分失效而不得對其遺產執行，繼承人無從承受程序而爭執之

罰鍰處分是對於行為人施以財產上之制裁使之心生警惕，具有一身專屬性，屬於不得繼承之標的，若該罰鍰義務人於爭訟程序死亡，處分之當事人能力亦因而喪失，罰鍰處分對於已死亡的義務人而言，已經無任何警惕的作用，則處分應因喪失其存在的目的而失其效力，進而當然無從對義務人之遺產加以執行。

又，義務人之繼承人基於高度屬人性（一身專屬性）之理由，應無從承受義務人之訴訟程序，即使賦予其繼承人承受訴訟程序之地位亦無實益，蓋罰鍰處罰之構成要件事實基礎，乃義務人本身知之甚詳，繼承人未必了解其中，繼承人即使加以承受訴訟程序，對於事實的合法調查亦無法有所幫助，繼承人承受訴訟乃無意義與必要。

（四） 小結

[257] 稅捐稽徵法：「依本法或稅法規定應處罰鍰者，由主管稽徵機關處分之，不適用稅法處罰程序之有關規定，受處分人如有不服，應依行政救濟程序辦理。但在行政救濟程序終結前，免依本法第三十九條規定予以強制執行」。

[258] 社會秩序維護法第 51 條：「違反本法案件之處罰，於裁處確定後執行」。

doi:10.6342/NTU202000774

該號釋字之廖義男大法官不同意見書的論點下，其認為行政執行法第 15 條之規定「並非」對於公法上金錢給付義務，在義務人繳納前死亡得逕對遺產執行之特別規定，若立法者立法本意真為如此，則應該限定適用於無一身專屬性金錢給付義務之範圍並加以明文，方為合理。否則僅以「立法形成之空間」空泛交代，將使比例原則、憲法保障人權之意旨落空。

其認為行政執行法第 15 條之規定，乃針對欠缺一身專屬性之公法上金錢給付義務始有適用，反之，對於具有一身專屬性的公法上金錢給付義務，一經義務人死亡，該處分即欠缺主體依附而失效，處分既因義務人死亡而失效，當然無從據對義務人之遺產加以執行，則在爭訟程序，訴願機關與行政法院對此情況應作成不受理決定及裁定駁回之判決。又，繼承人對於原處分之事實並非知之甚稔，即使加以承受爭訟程序亦無實益，故繼承人在此無須給予承受訴願、行政訴訟之必要。

四、本文見解

（一）一身專屬性義務之處分相對人死亡，即構成行政處分解消之事由

所謂「行政處分的解消」，學理有稱「行政處分的解決或消滅」，乃依據行政程序法第 110 條第 3 項之規定：「行政處分未經撤銷、廢止，或未因**其他事由**而失效者，其效力繼續存在」。是以，所謂行政處分的失效之概念，是指處分之效力「不復繼續存在」[259]。

[259] 李建良（2002），〈行政處分的「解決」與行政救濟途徑的擇定〉，《台灣本土法學雜誌》，40 期，頁 106。

doi:10.6342/NTU202000774

造成處分效力不復存在的原因，來自於以下幾種情況：「撤銷」、「廢止」、及「其他事由」，前兩者所謂「撤銷[260]」、「廢止[261]」，均有行政程序法規定其事由及效力；然最後者，所謂因「其他事由」而失效，其範圍十分廣泛，但如何界定尚未有定論，通常是以行政處分的廢棄是否毫無實益加以判斷，所謂「實益」的有無，乃取決於事實狀態或是實體法規範加以探究，大約可分成以下的類型：因處分附有解除條件成就或失效期限屆至而失效[262]、因處分標的的滅失或不存在而解決[263]、**屬人性（一身專屬性）之處分因當事人死亡而解決**[264]、因規範目的無法實現而解決[265]、其他法律特別規定[266][267]。

是以，具一身專屬性義務之處分，義務標的與特定義務主體之結合乃義務存續之必要要件，若特定義務主體死亡，其一身專屬性之義務因欠缺可繼受性而無從移轉至第三人，該義務將因喪失義務主體之履行，致使處分欲追求之目的、意義落空，該處分即無存在法律世界之實益，其效力將隨之失效，屬於行政處分消滅之事由之一。

（二）行政處分具備形式確定力，無法使一身專屬性義務「轉化」

[260] 行政程序法第 117-121 條。
[261] 行政程序法第 122-127 條。
[262] 行政程序法第 93 條第 2 項第 1、2 款：「前項所稱之附款如下：一、期限。二、條件」。
[263] 例如：處以扣留處分之標的物因火災而燒毀、即將要拆除的違章建築因地震而倒塌、工廠被處以限期改善之處分因該工廠歇業而無從改善。
[264] 例如：駕駛執照的所有人死亡，該駕駛執照之處分即失去效力而解決。
[265] 例如：行政處分因情事變更而無法達成目的，使之其效力解決。
[266] 例如：大法官釋字第 516 號解釋理由書（節錄）：「至若應增加補償之數額過於龐大，需用土地人（機關）需動支預備金支應，或有其他特殊情事，致未能於十五日內發給者，仍應於評定或評議結果確定之日起於相當之期限內儘速發給之，否則徵收土地核准案，即應**失其效力**」，其中乃認為土地徵收後，若行政機關未於法定期間內核發補償金，則該徵收處分將失其效力而解決。
[267] 李建良（2002），〈行政處分的「解決」與行政救濟途徑的擇定〉，《台灣本土法學雜誌》，40 期，頁 106-108。

doi:10.6342/NTU202000774

為一般財產性之義務

從釋字第 621 號解釋之彭鳳至、徐璧湖、許宗力、林子儀大法官協同意見書中，其認為：「依法生效之行政處分因不可抗爭而確定，稱為行政處分之不可爭力，學說上亦有稱為形式確定力者。其態樣……。訴願或行政訴訟進行中，當事人死亡而無人承受其訴願或訴訟者，則訴願或訴訟事件一經駁回確定，系爭行政處分即隨之確定，並持續其效力。**縱使法律明定此種行政處分不予執行，或因執行不可能而不予執行者，均非已生效之行政處分當然失效**。此與刑事訴訟進行中，法院因被告死亡而依刑事訴訟法第三百零三條第五款前段規定，諭知不受理之判決者，即無從為刑之宣告之情形不同。所謂「違規行為人於罰鍰處分之行政訴訟程序中死亡者，其當事人能力即行喪失。尚未確定之罰鍰處分，對該違規行為人也喪失繼續存在之意義而失效，實屬誤會」。

由此可知，該協同意見書似認為一身專屬性義務之行政處分，其將會因具備形式確定力而持續處分效力，不因處分義務人之死亡而受到影響，可推論協同意見書似肯定「處分之形式確定力」得作為一身專屬性質之義務消滅事由。

對此，本文就「一身專屬性之消滅」此一課題，就「形式確定力」得否作為一身專屬性消滅事由，前已為詳述[268]。本文所採結論，認為形式確定力乃拘束處分相對人不得再為爭執之效力，法理著眼於法安定性之維護，以避免公法上之事件爭議一再發生，即使處分相對人已不得再爭執其處分之合法性，其處分之一身專屬性性質，不因此「質變」成為非一身專屬性之義務，且亦無合理之法理基礎可導出，形式確定力將改變其處分本身一身專屬性之內涵。是以，該協同意見書對於形式確定力得消滅一身專屬性特徵之義務而轉變為非一身專

[268] 參見本文第三章、第一節、第二項、貳、二、(一) 行政處分形式存續力。

doi:10.6342/NTU202000774

屬性之論點，尚有待檢討。



（三）行政執行法第 15 條只是執行程序標的，非死後執行之依據

行政執行法第 15 條明文規定：「義務人死亡遺有財產者，行政執行處得逕對其遺產強制執行」，該條本身並非公法上義務繼受之法規範依據，原因在於行政執行法第 15 條係規範於「行政執行中」義務人死亡情況下，執行程序例外不停止的規定，使執行程序的查封效力得以繼續及於遺產部分，屬於**「執行程序先行標的」**，執行程序不因義務人死亡而停止，而非義務人死亡後仍得加以執行的實體法依據。

即使行政執行法第 15 條其性質乃「不停止執行」的程序規定，所適用的前提仍必須是對於可繼受性的金錢給付義務，始得對繼承人所得遺產範圍內執行[269]。

（四）繼受之有限責任乃來自於民法 1148 條第 2 項規定，而非行政執行法第 15 條

釋憲實務之解釋可能將行政執行法第 15 條「得逕對其**遺產**強制執行」的文句，作為概括繼受義務之有限責任根據的誤導，然正本清源該條定位，其乃「終止執行之例外程序規定」，並非死後執行之實體依據。又該條對於「以遺產強制執行」之明文，是指繼承人概括繼受非一身專屬性之義務，而立於新的義務主體地位加以履行之，其概括繼受義務的範圍，依公法上金錢給付義務繼受

[269] 參照本文第二章、第一節、第三項、伍、一、（一）行政執行法第 15 條定位之辨析。

doi:10.6342/NTU202000774

之有限責任，係類推適用民法第 1148 條第 2 項之規定，使繼承人僅以其所得之遺產為限負責，則執行機關對於繼承人之執行，當然限於其所取得之遺產為限。故，行政執行法第 15 條「得逕對其**遺產**強制執行」之規定，不過是對可繼受性之金錢給付義務，僅僅重申類推適用民法第 1148 條第 2 項之有限責任規定，本身無從作為概括繼受有限責任之依據

總結而論，執行機關基於行政執行法第 15 條的規定，就負有可繼受性之金錢給付義務人於執行程序中發生死亡情事時，例外不停止執行程序；並重申類推適用民法第 1148 條第 2 項有限責任意旨，只執行概括繼受人就其所受有的遺產範圍。

（五） 釋憲實務將造成金錢給付義務及非金錢給付義務之差別待遇，卻未有合理之理由

仔細觀察行政執行法第 15 條的規定：「對於義務人死亡遺有**財產**者，行政執行處得逕對其遺產強制執行」，又釋憲實務認為係針對該死亡之義務人「遺產」為強制執行，既然是針對死後義務人所有之「遺產」執行，可知該條所稱死亡之「義務人」應限縮於負有「公法上金錢給付義務之義務人」始得有死後執行之適用。可以發現，如此適用將造成負有金錢給付義務人與非金錢給付義務人，在死亡後將會受到不同的差別待遇，換言之，只有金錢給付義務人繼承人將遭受所得遺產執行之限制，然而非金錢給付義務者卻是在死亡後，其義務將一筆勾銷，其繼承人無須被執行機關加以執行該義務。義務是否具備金錢給付之性質，將使繼承人受有截然不同之限制。其差別待遇之正當性為何？釋憲實務未意識到如此解釋之結果，造成適用之結果產生如此差別待遇，而未就此差別就平等原則加以檢視之，似有所疏漏。

doi:10.6342/NTU202000774



（六）行政爭訟程序如何進行

1. 原義務人提起之撤銷訴願、訴訟部分程序駁回

具有一身專屬性之義務乃欠缺可繼受性，原義務人死亡後則該處分因未能有特定義務主體履行而喪失存在之目的而解消其效力，將欠缺撤銷訴訟之訴訟標的，不符形式合法要件。又，其繼承人既不概括繼受該義務，當然不受該義務之規制，對於其繼承人而言，乃欠缺訴願、訴訟權能，無從承受其訴願、訴訟程序，故訴願機關或是行政法院應分別作不受理撤銷訴願之決定（訴願法第 77 第 6 款）、裁定駁回該撤銷訴訟之判決（行政訴訟法第 107 條第 3 款）。

2. 繼承人可提起確認處分違法之訴

繼承人雖無承受原撤銷訴訟之實益而續為爭執其合法，然繼承人是否可另外為已死亡原義務人，提起確認處分違法之訴，尚有討論的實益。原因在於，原義務人在生前所負擔的公法上義務，因不服該義務課予之合法性提起行政爭訟，於行政爭訟程序中死亡，因一身專屬性之義務乃欠缺可繼受性而使訴願不受理、訴訟裁定駁回之結果，看似該義務已因義務人死亡而「灰飛煙滅」，然實際上義務人對於其受到違反行政法規範之評價及課予義務合法性與否，卻未受到平反，只因程序不合法使爭訟程序終止，實體法上之評價仍停留於原義務人違法而應課予義務之狀態。對於已死亡之原義務人而言，其名譽權之評價，立於社會之客觀判斷上，將可能受有名譽權之減損。故在探討繼承人可否對已消滅之原處分，提起確認處分違法之訴，關鍵在於，已死亡原義務人之名譽權的保護，是否能符合「確認利益」（權利保護必要）的構成，使繼承人得以適法提

doi:10.6342/NTU202000774

起確認處分違法之訴。



（1）死者名譽權之概念

所謂死者名譽權的概念，多是民法領域之人格權部分的討論，學理及實務見解[270]認為，民法所保護之「名譽權」[271]，乃人格在社會上的評價，換言之，係指每個人就其自身屬性及價值所獲得的社會評價而享受該利益之權利，係屬人格權之其中一種，其內涵為保有及維護已獲得之名譽，使自己的名譽不降低或不喪失；在自己名譽處於不佳的狀態時，用自己的實際行動加以改進；對於侵害其名譽者，得依法請求司法保護及救濟[272]。

人的權利能力，依民法第 6 條之規定乃始於出生，終於死亡，換言之，人得以享受權利負擔義務之資格、能力，在人出生後，包括「人格權」在內的一切權利均得享受，然在人死亡後，權利能力當然消滅而不再為權利義務之歸屬主體，在財產上之權利部分，法規範上設有繼承制度，使適法之繼承人得以在民法繼承制度的運作下，承受財產上之權利義務，但人格權（人格利益）部分，因具備一身專屬性，無法移轉由繼承人承受之，但是否全部的人格權均因人死亡而全部歸於消滅，並非可一概而論[273]。

人死亡後，其名譽權仍可能繼續作用，因死者其生前之屬性及評價，將會

---

[270] 最高法院 90 年台上 646 號判決。

[271] 民法第 18 條：「**人格權**受侵害時，得請求法院除去其侵害；有受侵害之虞時，得請求防止之（第一項）」。前項情形，以法律有特別規定者為限，得請求損害賠償或慰撫金（第二項）。」；民法第 195 條：「不法侵害他人之身體、健康、**名譽**、自由、信用、隱私、貞操，或不法侵害其他人格法益而情節重大者，被害人雖非財產上之損害，亦得請求賠償相當之金額（第一項）。其名譽被侵害者，並得請求回復名譽之適當處分。前項請求權，不得讓與或繼承（第二項）。但以金額賠償之請求權已依契約承諾，或已起訴者，不在此限（第三項）。前二項規定，於不法侵害他人基於父、母、子、女或配偶關係之身分法益而情節重大者，準用之（第四項）。」

[272] 劉春堂（2011），〈侵害死者名譽之民事責任〉，《輔仁法學》，42 期，頁 124。

[273] 劉春堂（2011），〈侵害死者名譽之民事責任〉，《輔仁法學》，42 期，頁 128。

doi:10.6342/NTU202000774

獲得立於社會之評價，然而，死亡之人不會再有新的言論及行為產生，是以對於死者的名譽，乃停止於生前所表現的名譽態樣，換言之，其生前所表現的名譽態樣，不因死亡而消滅、抹去社會及人民的印象，反倒以其生前所產生、表現的客觀態樣存在於社會及人民的印象，進而「固定」了對死者名譽評價[274]。

既然人於死亡之後，其名譽將會因生前所受有評價繼續持續於社會，不因與死亡而消滅此種評價，其死者之名譽權仍能繼續作用，本於有權利必有救濟之法理，死者應當受有名譽權「直接」保護。另外，死者名譽權，亦可能影響到其近親本身受有名譽權侵害，使之背負其死亡之近親社會評價貶損低落，進而使生存近親「自己名譽權」亦受到社會評價的減損；另一方面，近親對於已死亡之親屬敬仰愛慕之「身分法益」，將會因死者死後名譽的低落、貶低而受到侵害[275]。

然而，由於民法對於權利能力的明文[276]，使死者之名譽權有受侵害之情事時，民事侵權行為的救濟，無法以喪失死者本人之名譽權遭到侵害作為標的，惟民法第 195 條第 4 項對於特定親屬之「身分法益」已有明文保障，故，在私法救濟上，我國司法實務見解有認為，得以特定親屬對於已死亡之親屬敬仰愛慕之「身分法益」作為標的對於侵權行為之標的提起侵權行為之訴，以達到回復死者名譽權的目的[277]。

（2）死者名譽權於憲法中基本權利之思考

[274] 劉春堂（2011），〈侵害死者名譽之民事責任〉，《輔仁法學》，42 期，頁 128。
[275] 王澤鑑（2015），《侵權行為法》，增訂新版，頁 209-211，台北：自刊；劉春堂（2011），〈侵害死者名譽之民事責任〉，《輔仁法學》，42 期，頁 137-140。
[276] 民法第 6 條：「人之權利能力，始於出生，終於死亡。」
[277] 王澤鑑（2015），《侵權行為法》，增訂新版，頁 209，台北：自刊。

doi:10.6342/NTU202000774

雖然死者名譽權尚未有民法明文保障，但可透過法學方法演繹所得而出，侵權行為之救濟可經由民法的在世親屬之身分法益作為標的，使死者名譽權間接獲得救濟。雖在私法領域之侵權行為中無法直接救濟，並不代表此種權利非屬憲法中基本權利所保障，蓋大法官釋字 656 號解釋理由書中，其論述「名譽權」旨在維護個人主體性及人格之完整，為實現人性尊嚴所必要，受憲法第 22 條所保障，可知名譽權乃受到憲法第 22 條之概括基本權利所涵蓋。

憲法所保障之名譽權，「生存之人」理所當然受有保障外，是否亦即於「死亡之人」？可合理推論的是，並非所有基本權利的存續，均以人生命之存續作為存在的必要條件，而須視其性質有無「延續性」之特徵，例如「人身自由」、「集會結社自由」、「工作權」等等則須以權利人生存時始有主張之實益，反之，「財產權」下之遺產，則設有繼承制度之制度性保障，使死亡人之財產得以透過繼承，不因權利能力之喪失而使財產成為無主物，而是分配該財產予法定繼承人使之延續；又在財產權概念下「智慧財產權」中的著作權，於著作權法第 30 條[278]中規定，對於著作財產權之保障亦得延續至死後 50 年。

由此可知，並非所有憲法上所保障人民的基本權利均在人死亡時即止步，仍須考量特定基本權利之性質有無死後延續性、權利的保護有無延續於死亡後之正當性以及保護之必要性，對於特定權利延長其保障於死後。名譽權的內涵在於保障客觀上社會對於人格之評價，則死者留於人世之評價仍舊持續，應具有保障之可能，且後世之人亦有為死亡後「平反」之可能，使死者受侵害之名譽於死後獲得回復，亦間接保障死者親屬之名譽權。據此，應肯定在權利保障的清單中，應包括「死者名譽權」。

[278] 著作權法第 30 條：「著作財產權，除本法另有規定外，存續於著作人之生存期間及其死亡後五十年（第一項）。著作於著作人死亡後四十年至五十年間首次公開發表者，著作財產權之期間，自公開發表時起存續十年（第二項）」。

doi:10.6342/NTU202000774

（3）繼承人可本於原義務人之死者名譽權侵害為由，提起確認處分違法之訴

肯定名譽權在人死後受有憲法保護，進一步可釐清，「死者名譽權」在私法領域中所產生侵害的態樣，乃來自於私人與私人之間之行為；在公法領域中可能發生的侵害的態樣，應來自於人民受有「國家」對其「不利評價」，減損其客觀上社會、人民對其享有人格上之利益。對此，可想像的是，所謂國家對人民的不利評價，最有可能情形為國家對人民以行政處分「宣告」了其違反法規範，進而須接受行政罰、秩序罰、某種不利的後果，使該人民給予整體社會之印象、評價乃「違反法規範」、「須履行某種義務的不利結果」，帶有人格減損之效果。

若此種評價結果，至處分相對人死亡後皆未獲得撤銷或無效之宣告，其名譽至死亡後將會持續受到社會、民眾之貶損。據此，義務人之繼承人得以義務人之「死者名譽權」受到侵害為由，對於其生前所受有之不利處分提起救濟。尚須注意者，由於具有「一身專屬性」之不利處分，自原處分人死亡其處分效力亦隨之解消，故無法提起撤銷之訴，繼承人應提起者乃「確認處分違法之訴」（行政訴訟法第 6 條第 1 項後段），請求法院對於確認該處分違法，使已死亡之原處分人之名譽權獲得回復，亦使繼承人之名譽權間接獲得回復。

附帶論者，欲提出一個值得思考的問題，在義務人死亡前，已履行其一身專屬性之義務，然死後其繼承人發現該處分違法，有無可能在死後為其提起行政爭訟？關於這個問題，按照之前本文的理解，該處分的效力應已因義務人死亡歸於消滅，然如此解釋，可能造成未履行義務之人，在死亡後該義務消滅，

doi:10.6342/NTU202000774

其繼承人無須繼受，且繼承人尚可為其提起確認處分違法之訴；然而，若是已履行義務之人死亡後，因處分已消滅，欠缺訴願、訴訟之標的，其繼承人將無法提起行政爭訟，爭執該義務的合法性，似乎兩者情況間有所輕重失衡。本文對此認為，已履行一身專屬性之義務人，於死亡後其繼承人應可爭執義務的合法而提起撤銷訴訟

，原因在於，該一身專屬性的義務已經由原義務人加以履行，此情況不同於未經原義務人履行之一身專屬性義務，質言之，未經履行之一身專屬性義務，因無法由他人履行，效力上當然無繼續存在之實益，故該處分因而解消；惟已履行之一身專屬性義務，無須考量是否交由他人履行，並無效力解消之考量。再者，考量義務人既已履行其義務，其合法性之爭執，應該不因義務人死亡而喪失接近訴訟的機會。據此，若是已履行一身專屬性義務之處分，效力不因義務人死亡解消，其繼承人得提起撤銷訴訟加以爭執之。

（七）行政執行法第 15 條若作為死後執行之依據必須有堅強之說理

依釋憲實務之看法，將該條定性為死後執行之依據，對於所有公法上金錢給付義務，一律在義務人死後，國家均得依據該條對遺產執行。可解讀出繼承人須以自己所有之遺產，對他人之金錢給付義務加以負責，在合憲性之思考上，以自己之財產他人的義務負責並非禁止，而是必須有比「為自己義務負責程度更高」的正當性存在，始能通過憲法第 23 條之比例原則檢驗，本文贊同學理見解[279]。釋憲實務如此解釋，已構成繼承人財產權之「特別犧牲」，且仔細探究，繼承人乃是為他人「已消滅的金錢給付義務義務」負責，更是侵害其財產權甚鉅而超乎財產權公益負擔之界線，檢視該條之合憲正當性勢必須更加嚴格，釋憲者必須盡其說理義務，卻未見大法官對此規範的合憲性內涵加以詳細

[279] 蔡宗珍（2008），〈公法上無主義務之強制執行?〉，《中研院法學期刊》，2 期，頁 296-298。

doi:10.6342/NTU202000774

論述，只單純以行政執行法第 15 條與行政執行法第 43 條授權訂定之施行細則第 2 條之文義解釋，得出對於已死亡之義務人，其因死亡而消滅之金錢給付義務，由其繼承人遺產加以執行之合憲意旨，未深入探究金錢給付義務上有區分有無一身專屬性與否而有著不同性質、義務人死亡後之效果。且亦未意識被繼承人死亡事實發生之剎那，繼承人即取得遺產之所有權，屬於繼承人所有，不再帶有任何被繼承人人格上之延續意味，釋憲實務卻未對金錢給付義務加以探究其內涵；亦未對遺產本身的性質加以釐清，據以作成行政執行法第 15 條作為死後執行的合憲解釋，尚有疑問。

貳、訴願（訟）標的義務非一身專屬性

若訴願人所爭執之標的義務非一身專屬性，此種義務具有可繼受性，因訴願人發生概括繼受事由之後，將會使繼受人在實體法上受有義務地位之移轉，繼受人即具有新的處分相對人地位，在現行法規範下，於訴願程序中，依照訴願法第 87 條[280]之規定，繼承人將承受其「訴願人之地位」而續行訴願之；另外，在行政訴訟程序中，依據行政訴訟法第 186 條[281]準用民事訴訟法第 168、169 條[282]及行政訴訟法第 181 條[283]規定，繼承人得承受該訴訟程序之爭訟當事人地位而續行救濟之。

[280] 訴願法第 87 條：「訴願人死亡者，由其繼承人或其他依法得繼受原行政處分所涉權利或利益之人，承受其訴願（第一項）。法人因合併而消滅者，由因合併而另立或合併後存續之法人，承受其訴願。（第二項）依前二項規定承受訴願者，應於事實發生之日起三十日內，向受理訴願機關檢送因死亡繼受權利或合併事實之證明文件（第三項）。」

[281] 行政執行法第 186 條規定：「民事訴訟法第一百六十八條至第一百七十一條、第一百七十三條、第一百七十四條、第一百七十六條至第一百八十一條、第一百八十五條至第一百八十七條之規定，於本節準用之」。

[282] 民事訴訟法第 168 條規定：「當事人死亡者，訴訟程序在有繼承人、遺產管理人或其他依法令應續行訴訟之人承受其訴訟以前當然停止」。

[283] 行政訴訟法第 181 條規定：「訴訟程序當然停止後，依法律所定之承受訴訟之人，於得為承受時，應即為承受之聲明（第一項）。他造當事人亦得聲明承受訴訟（第二項）」。

doi:10.6342/NTU202000774

然而，繼受人既是本於新的義務人地位受有義務之移轉，行政機關本就應對繼受人重新為行政程序之正當程序實踐，使繼受人擁有自己的程序保障地位，而非將原義務人之程序主體地位「延續」給予繼受人而共用之。故對於「救濟期間」，繼受人應有獨立享受之地位，行政機關應對其作出新的處分而送達，以重新起算救濟時間，並可於救濟期間獨立提起訴願、行政訴訟救濟，而非只有續行訴願、訴訟程序一途可選擇，繼受人可自由選擇逕以承受原義務人之訴願、訴訟地位；抑或是在法定救濟期間內自行提起新的獨立之訴。

程序法的地位上承認繼受人擁有完整的救濟程序，始能合理化在實體法上加諸繼受人義務移轉之負擔，充分保障繼承人所享有之憲法所保障之訴訟權，本於有權利必有救濟，繼受人受有該義務之概括繼受移轉，亦須完整保障繼承人尋求救濟之路保持通暢，方切合憲法之意旨。

第三項　繼受之正當執行程序

於行政執行中的義務人死亡之情況，對於執行機關應如何其執行程序，就該義務是否具有一身專屬性而有不同的效果。

壹、義務具有一身專屬性

具有一身專屬性之義務，與義務人之間具有緊密關聯性，該處分因義務人死亡等概括繼受事由發生時，將使該等義務欠缺履行之主體而效力解消，則該處分不再成為有效的行政執行名義，此時，執行機關應該依行政執行法第 8 條第 1 項第 3 款[284]之規定終止執行之。

[284] 行政執行法第 8 條規定：行政執行有下列情形之一者，執行機關應依職權或因義務人、利害

doi:10.6342/NTU202000774

貳、義務不具有一身專屬性

不具有一身專屬性之處分，在義務人發生概括繼受事由時，行政執行應如何進行，分為以下析述。

首先就公法上金錢給付義務部分，行政執行法第 15 條的性質已如前述[285]，乃公法上金錢給付義務之執行程序的終止例外規定，係規範不具有一身專屬性之金錢給付義務，於執行中發生繼受之情事下，執行機關應如何執行之程序規定。此情況執行機關應依照行政執行法第 15 條之規定，對該義務繼受人之遺產逕為執行標的而執行之。然而，繼受人於此執行程序中，所概括繼受之金錢給付義務，亦當然有爭執之救濟權利所在，可對於該執行名義不服，依循行政執行法第 9 條[286]之規定為「聲明異議」，若聲明異議被駁回，繼受人可進一步對該處分提起撤銷訴願及訴訟，以獲得救濟。

另外公法上其他行為、不行為義務在行政執行法中，並未有如行政執行法第 15 條之續行執行規定，且亦無準用強制執行法之規定。由此推論，負有公法上金錢給付以外之義務者，其義務主體發生概括繼受事由而消滅時，執行程序應無從續行之，故行政機關應依照行政執行法第 8 條第 1 項第 3 款之規定終止執行。然而，因義務不具有一身專屬性，行政機關得另對繼承人作成行政處分

關係人之申請終止執行：一、義務已全部履行或執行完畢者。二、行政處分或裁定經撤銷或變更確定者。**三、義務之履行經證明為不可能者**（第一項）。行政處分或裁定經部分撤銷或變更確定者，執行機關應就原處分或裁定經撤銷或變更部分終止執行（第二項）」。

285 參照本文第二章、第一節、第三項、伍、一、（一）行政執行法第 15 條定位之辨析。

286 行政執行法第 9 條：「義務人或利害關係人對執行命令、執行方法、應遵守之程序或其他侵害利益之情事，得於執行程序終結前，向執行機關聲明異議。前項聲明異議，執行機關認其有理由者，應即停止執行，並撤銷或更正已為之執行行為；認其無理由者，應於十日內加具意見，送直接上級主管機關於三十日內決定之。行政執行，除法律另有規定外，不因聲明異議而停止執行。但執行機關因必要情形，得依職權或申請停止之」。

doi:10.6342/NTU202000774

課予概括繼受義務之移轉，執行機關可據該新的處分作為新的行政執行標的。

doi:10.6342/NTU202000774



doi:10.6342/NTU202000774

第四章　我國法概括繼受實例探討

第一節　土汙法整治義務之概括繼受

第一項　概說

土壤及地下水汙染整治法（以下簡稱為土汙法）中，有課予汙染行為人[287]、汙染土地關係人[288]及潛在汙染責任人[289]此三種類型主體作為土壤整治責任人[290]。土壤整治義務人可能在自然人死亡或是公司、非法人團體合併的情況下，產生整治義務概括繼受的可能，本文以近期「司法院大法官釋字第 714 號解釋」之事實背景，作為整治義務概括繼受的前導案例，探究「汙染行為人」整治義務有無可繼受性，行政機關對於未履行的義務得否要求繼受人履行。另外，就該釋字所涉及的舊土汙法第 48 條的施行前溯及適用規定，將整治義務概括繼受與施行前的溯及既往規範為一併之思考、整理。

第二項　案例事實

中國石油化學工業開發公司（下稱中石化公司）於民國 72 年間奉經濟部令

[287] 土汙及地下水污整治法第 2 條第 15 款：「污染行為人：指因有下列行為之一而造成土壤或地下水污染之人：（一）洩漏或棄置污染物。（二）非法排放或灌注污染物。（三）仲介或容許洩漏、棄置、非法排放或灌注污染物。（四）未依法令規定清理污染物」。

[288] 土汙及地下水污整治法第 2 條第 19 款：「污染土地關係人：指土地經公告為污染控制場址或污染整治場址時，非屬於污染行為人之土地使用人、管理人或所有人」。

[289] 土汙及地下水污整治法第 2 條第 16 款：「十六、潛在污染責任人：指因下列行為，致污染物累積於土壤或地下水，而造成土壤或地下水污染之人：（一）排放、灌注、滲透污染物。（二）核准或同意於灌排系統及灌區集水區域內排放廢污水」。

[290] 林昱梅（2015），〈土壤污染行為人整治責任概括繼受之法律問題－以德國法之比較為中心〉，《東吳法律學報》，26 卷 3 期，頁 68-69。

doi:10.6342/NTU202000774

合併台灣碱業公司（下稱台碱公司），台碱公司因而消滅由中石化公司作為存續公司。於 93 年間台南市政府認原屬台碱公司安順廠等廠址有戴奧辛及汞汙染情形，原因係台碱公司自 54 年至 67 年間生產五氯酚等產製過程及剩餘產敏露天堆放滲入土壤所造成，是以台碱公司屬汙染行為人應負舊土汙法第 48 條[291]之整治義務，因中石化公司既為合併存續公司，依照公司法第 319 條準用第 75 條，其應概括繼受台碱公司之權利義務，故台南市政府命中石化公司繳納 652,221 元整治費用。中石化對此命繳納處分不服而提起訴願、行政訴訟及上訴均遭到駁回，因而以終局確定判決所適用之舊土汙法第 48 條牴觸憲法為由，聲請大法官解釋。

第三項　大法官釋字第 714 號解釋意旨

對於舊土汙法第 48 條之解釋，大法官認為該規範是課予汙染行為人，就土汙法於 89 年 2 月 2 日施行後仍「繼續存在之汙染狀況」，有避免汙染擴大及除去之整治等相關義務，以防止或減輕該污染對國民健康及環境之危害，並對違反土污法所定前述義務之處罰及強制執行，該規範係適用於土汙法施行前已發生土壤或地下水污染之污染行為人，使其就土污法施行後之污染狀況負整治義務等，係指前述整治義務以「仍繼續存在」之污染狀況為規範客體，不因污染之行為發生於土污法施行前或施行後有所不同；反之，施行前終了之污染行為，如於施行後已無污染狀況，系爭規定則無適用之餘地，是尚難謂牴觸法律不溯及既往原則。依土污法第 2 條第 12 款規定，污染行為人指為該款所列各目行為之人。是系爭規定係以為上開污染行為之行為人為規範對象。至污染行為人之概括繼受人是否承受其整治義務，非屬系爭規定之規範範疇。

[291] 舊土汙及地下水污整治法第 48 條：「第七條、第十二條、第十三條、第十六條至第十八條、第三十二條、第三十六條、第三十八條及第四十一條之規定，於本法施行前已發生土壤或地下水污染之污染行為人適用之。」（89 年 2 月 2 日施行公布）。

doi:10.6342/NTU202000774

從上開解釋理由書意旨的節錄，可以發現大法官就舊土汙法第 48 條的規定，並未深究該條所可能涉及土汙法整治義務繼受之課題，而是將重心置於溯及既往原則、信賴保護原則及比例原則之審查，殊為可惜。大法官認為，對於舊土汙法第 48 條的規定，若在施行後仍繼續存在汙染狀況，始負有整治義務；反之，施行後已無汙染行為當然無適用餘地。從大法官語意之推敲，似乎認為以「汙染狀態」作為法律規範事件，該事件於土汙法施行前尚未結束，繼續於施行後，屬法律「不真正」溯及既往的情況，且此情況不違反法律不溯既往原則而合憲。又該條的規定對於土汙法施行前的汙染行為人之非法行為，當然無信賴值得保護之情況，故不得主張信賴保護原則。最後，就舊土汙法第 48 條的規範，認為雖涉及人民工作權、財產權及營業自由之限制，但在比例原則的考量上，仍是最小侵害性之手段，得通過比例原則的檢驗。

第四項　整治義務可繼受性探討

對於土汙法整治義務之概括繼受討論，本文將聚焦舊土汙法第 48 條規範「施行前」已發生土壤或地下水汙染之「汙染行為人」的整治義務作為探討，又舊土汙法的規範，在現行法的規範係移至第 53 條，故以下就現行之土汙法第 53 條作為論述。

大法官釋字第 714 號解釋背景事實及對於舊土汙法第 48 條之違憲疑義，其法律爭點可分層次釐清，一為涉及汙染行為人所負之責任為何；二為對於施行前對於整治義務溯及既往的類型及其適法性；三為「溯及既往原則」與「義務概括繼受義務」兩者於土汙法之交集應如何處理。藉由上開爭點釐清，抽絲剝繭出汙染行為人之整治義務可繼受性及施行前溯及既往適用之內涵為何。

doi:10.6342/NTU202000774

壹、土汙法之「汙染義務人」係負行為責任

定性該條汙染義務人是否有義務概括繼受的空間，必須先了解土汙法之汙染義務人其所負的義務內容為何，始能進一步分析。蓋公法上義務概括繼受原則上，以行為責任為內容的義務作為標的，始符合義務概括繼受之特徵──「義務同一性」,「義務主體非同一」；反之若是狀態責任，則不涉及義務概括繼受，無繼續討論之實益。

依據土汙及地下水污整治法第 2 條第 15 款：「污染行為人：指因有下列行為之一而造成土壤或地下水污染之人：（一）洩漏或棄置污染物。（二）非法排放或灌注污染物。（三）仲介或容許洩漏、棄置、非法排放或灌注污染物。（四）未依法令規定清理污染物」。從上開條文對於汙染行為人的描述，拆解該條可發現，其組成乃「汙染」、「行為」、「人」，所謂人包括自然人、法人及非法人團體；而污染則是指造成土壤及地下水汙染；行為則是指洩漏、棄置、排放、灌注、仲介、容許、應清理而未清理的行為[292]。作為汙染行為人之原因，乃來自於「行為」不符合土汙法的規範，而成為土汙法所欲規範之人。此條文文義可推論，土汙法所對於汙染行為人管制的重心在於其「行為」導致出對土壤、地下水的環境汙染，概念上屬「行為責任」之內涵。

據此，行政機關對於負有行為責任之汙染行為人課予之整治義務，若發生概括繼受事由，產生繼承人概括繼受整治義務的可能性，有義務概括繼受之空間。

[292] 李建良（2007），〈釋義土壤及地下水汙染整治法之汙染行為人－闡析台鹼安順廠汙染事件之整治責任及行政法院相關判決〉，《2006 行政管制與行政爭訟》，頁 153，台北：中央研究院法律學研究所籌備處。

doi:10.6342/NTU202000774

貳、土汙法第 53 條規範辨析

對於土汙法第 53 條之溯及規定，必須先判斷其溯及為何種規範事實為基礎及何種溯及既往類型，始能進一步判斷其適法性有無。

一、以「行為責任」作為溯及既往之基礎

土汙法第 53 條明文汙染行為人責任溯及於施行前適用之規範，究竟是針對汙染狀態（狀態責任）的溯及；抑或是對於汙染行為（行為責任）的溯及必須釐清。在釋字第 714 號之解釋理由書中，並未明確說明該條以何種責任溯及既往之基礎。對此，學理對此有認為，該條乃是針對「汙染狀態」整治加以規範，而非單純針對汙染行為追究責任，故該條的構成要件，並非以污染行為終了或是汙染狀態出現即完全實現，而是以法律適用時汙染狀態仍然存在為必要構成要件事實，否則若汙染狀態已不存在，即無整治義務溯及適用之可能；換言之，若解讀以行為責任作為構成要件，不論汙染狀態是否在施行後存續，都將不影響行為責任的究責，將與釋字第 714 號解釋理由書所述「施行前終了之汙染行為，如於施行後以無汙染狀況，系爭規定則無適用之餘地」不符[293]。

然而，以土汙法第 53 條文義可知，其明文以**「汙染行為人」**作為對象，應以該文義上所規範作為主要之解釋依歸。承前所述，「汙染行為人」在土汙法上所負的責任乃「行為責任」，係立法者針對「行為人」做出「汙染土壤或地下水行為」，而破壞環境生態保護之目的所產生出之責任。據此，土汙法第 53 條，既是立法者欲將汙染行為人應負的責任，溯及既往於土汙法施行前，理所當然是指施行前所發生該當於土汙法之行為責任的汙染行為人，亦應課與土汙法的

[293] 大法官釋字第 714 號蘇永欽大法官協同意見書。

doi:10.6342/NTU202000774

整治義務之負擔。如此解釋，邏輯上較符合土汙法第 2 條第 15 款對於污染行為人之意義以及其負有行為義務內涵。若解釋為狀態責任之溯及，將扭曲土汙法第 2 條第 15 款對於污染行為人之內涵。

另外，在解釋理由書中，大法官以「汙染狀態施行後仍須存在」作為溯及前提，並不因此可推論屬狀態責任之溯及既往。原因在於，產生整治義務的前提，須是「具備汙染原因之汙染行為」發生後產生污染狀態，故橫跨土汙法施行前後的現實上汙染狀態，是整治義務存在之事物本質使然，若無現實上汙染狀態存續，則表示其行為所引起行政法上管制之危害，已不復存在，行為責任亦失所附麗，不具有溯及課與整治義務的前提要件，當然無溯及發生整治義務之正當性存在[294]。

綜上，土汙法第 53 條的溯及規定，是針對持續至施行後的汙染狀況，其汙染狀況來自於施行前之汙染行為人之行為，且該當於施行後土汙法之汙染行為人之**行為責任**者，溯及課與該行為人土汙法之整治義務規定。

二、屬適法之「真正溯及既往」規定

該條溯及規定，以行為責任作為溯及既往之標的，其溯及既往的適法性有無，應先釐清屬真正或不真正溯及既往，使能進一步確認。

學理認為，真正與不真正溯及既往的區分，係以新法秩序所適用的社會事實是否終結加以區分，若是新法秩序適用於「已終結」之社會事實者，屬真正

[294] 林三欽（2014），〈土壤汙染行為人責任之繼受與法律溯及適用－簡評大法官解釋第 714 號解釋〉，《法令月刊》，65 卷 1 期，頁 65-12-65-14。

doi:10.6342/NTU202000774

溯及既往，原則上禁止；若新法秩序適用「尚未終結」之社會事實，則屬不真正溯及既往，原則上不禁止，將此標準涵攝至土汙法第 53 條，依上段分析，該條是針對「行為責任」為標的，將施行後的整治義務，溯及課予施行前「已結束汙染行為的行為人」，可知將土汙法整治義務適用於施行前「已終結」的土壤及地下水汙染「行為」，本身應屬「真正溯及既往規定」；除非污染行為人的汙染行為「不斷地」行為從施行前至施行後，此種例外情況，始構成不真正溯及既往[295]。本文的討論重心置於原則之情況，定性於真正溯及既往規定繼續討論之。

真正溯及既往之適法性判斷，原則上為禁止，然並非均不得制定真正不溯既往規範，而是須通過比例原則的檢驗，此部分須衡量所欲追求的公益及人民的信賴利益。實務見解[296]對此提出些許參酌方向，例如：人民預見法律將有所變更、現行法律規定有不清楚或紊亂之現象，立法者欲藉由溯及性法律加以整理或清除、現行法律違憲而無效，立法者以新規定取代、因溯及性法律所造成之負擔微不足道、溯及性法律係為達成極為重要之公益目的，且其重要性高於法安定性之要求。

藉由實務所提出之參酌方向，可以發現，土汙法於 89 年制定以前，我國對於土壤及地下水環境的保護，尚處於環保法規不完備而無完整體系之情況，未有如土汙法較為完整的法規範；嗣後，國家對於國家環境維護意識之抬頭，始制定土汙法較為完備規範。且土汙法所課予之整治義務，對於環境整體的保護十分重大，藉由落實環境調查與整治義務，始能貫徹環境保護的意旨，若對 89 年土汙法施行前的土壤或地下水汙染行為，均無法對其的汙染行為人溯及課與

[295] 林三欽（2014），〈土壤汙染行為人責任之繼受與法律溯及適用－簡評大法官解釋第 714 號解釋〉，《法令月刊》，65 卷 1 期，頁 65-14-65-16。
[296] 最高行政法院 98 年 12 月份第 2 次庭長法官聯席會議。

doi:10.6342/NTU202000774

整治義務，將使土汙法的立法目的嚴重落空。

學理亦認為汙染行為人並非從合法評價翻轉為違法，而是考量汙染行為的違法性、危害性、背後牽扯的經濟對價、社會公平等公益相互衡量[297]。據此，土汙法第 53 條之真正溯及既往規範的考量，藉由以上分析，可發現公益考量之著重顯大於法安定性之要求，應屬適法之行為責任真正溯及既往規範無誤。

參、汙染行為人之整治義務具有可繼受性

汙染行為人之整治義務[298]是否具有可繼受性的討論，可分成兩個層次，一為是否屬行政法上具體義務，二為是否為非一身專屬性。首先前者，汙染行為人所負有的義務必須是經由行政機關具體化的行政法上義務，否則即使特定人民有汙染行為而該當行為責任人，然僅僅代表該人民屬引起危險人而有作為義務人之可能性，然負有義務的有無及內容，必須待至行政機關對該行為責任人以行政處分具體化始存在[299]。是以，經行政機關對污染行為人作成行政處分之整治義務，原則上始具有被繼受的資格。

再來，就整治義務有無一身專屬性的討論，應取決於義務目的，是否能經由繼受人對義務的履行而達成，倘若該目的在對於原義務人的身體、心理、對其特定身分、資格或能力有所規制（例如行政罰），或是對於身體的干預（施打預防針）等等，此等義務欲達到之目的，若經由概括繼受而轉換於繼受人履

[297] 林三欽（2014），〈土壤汙染行為人責任之繼受與法律溯及適用－簡評大法官解釋第 714 號解釋〉，《法令月刊》，65 卷 1 期，頁 65-16-65-17。
[298] 例如土壤及地下水汙染整治法第 7 條、第 12 條至第 15 條、第 22 條、第 24 條、第 25 條、第 37 條、第 38 條及第 43 條第 1 項至第 3 項、第 5 項、第 7 項至第 9 項規定。
[299] 李建良（2007），〈釋義土壤及地下水汙染整治法之汙染行為人－闡析台鹼安順廠汙染事件之整治責任及行政法院相關判決〉，《2006 行政管制與行政爭訟》，頁 143-144，台北：中央研究院法律學研究所籌備處。

doi:10.6342/NTU202000774

行，將無法達成原先的目的，此種義務即屬一身專屬性，無法作為繼受之標的，而學理認為，整治義務與污染行為人之身分、資格、能力均無關，且此等義務尚得經由第三人代為履行，不具有一身專屬性[300]。觀察土汙法課與污染行為人之整治義務，例如命完成調查工作及擬定汙染控制計畫[301]或是代履行評估、命停工、停業[302]等等，其本身欲達成之目的，乃追求對於土地與地下水環境的永續維護，此種維護的目的，即使變更為其繼受人加以履行，亦能達成整治義務之意旨，本文在此亦肯定學理見解，整治義務應無一身專屬性。

實務見解對此亦認為，土汙法上整治義務不具有一身專屬性，其理由與學理見解雷同，認為整治義務與制裁行之罰鍰處分不同，與行為人本身資格或能力無涉，故不具有一身專屬性，仍得由概括繼受人承受義務[303]。

須注意者，土汙法之整治義務中，尚得對污染行為人作出罰鍰處分之規定[304]，此種處分作為整治義務之內涵，是否具有一身專屬性不無疑問，蓋對於土汙法之罰鍰處分，是為非難污染行為人未遵守土汙法之規定，乃具有裁罰性不利處分之性質，著重違反土汙法之行為人之作為，此罰鍰處分轉換至繼受人履行，無法達成原本譴責行為人不遵守法令之行為，應不具備一身專屬性。據此，土汙法之整治義務，排除「罰鍰處分」此種類型，均為不具一身專屬性之特徵，而具備可繼受性。

---

300 李建良（2007），〈釋義土壤及地下水汙染整治法之汙染行為人－闡析台鹼安順廠汙染事件之整治責任及行政法院相關判決〉，《2006 行政管制與行政爭訟》，頁 146-147，台北：中央研究院法律學研究所籌備處；林昱梅（2015），〈土壤污染行為人整治責任概括繼受之法律問題－以德國法之比較為中心〉，《東吳法律學報》，26 卷 3 期，頁 73。

301 土壤及地下水汙染整治法第 12、13 條。

302 土壤及地下水汙染整治法第 15 條。

303 最高行政法院 96 年判字第 1953 號判決、最高行政法院 104 年判字第 656 號判決、最高行政法院 103 年判字第 701 號判決。

304 土壤及地下水汙染整治法第 38 條。

doi:10.6342/NTU202000774

綜上所述，污染行為人之整治義務（排除罰鍰處分），經由行政處分具體化後，不具有一身專屬性，屬可繼受之義務，得由繼受人概括繼受之。

肆、行為責任溯及既往與義務概括繼受之交集探討

土汙法第 53 條對於汙染行為人可能所適用的情況，學理[305]分成以下三種情況，藉由此三種情況的辨析，歸納溯及既往與義務概括繼受兩種制度之調和。

一、施行前發生污染行為，施行後行政機關先對行為人課予整治義務，後再發生概括繼受事由

原行為人於土汙法施行前所為之汙染行為，得依照土汙法第 53 條的真正溯及既往規定，使施行前污染行為人受到土汙法規範所及，溯及負有行為責任。進一步，行政機關對於行為人作出行政處分以具體化其應負之整治義務內涵。嗣後發生概括繼承事由時，承前所述，此整治義務乃具體且不具備一身專屬性，繼受人應加以概括。又整治義務概括繼受之依據，應視義務規制的類型及自然人、法人或非法人團體的區別，可能類推適用民法第 1148 條第 1 項或是另立公法上依據，或是類推適用公司法第 75 條、或民法第 306 條作為基礎。

二、施行前發生汙染行為，施行後發生概括繼承事由且行政機關對繼承人課與整治義務

[305] 林昱梅（2015），〈土壤污染行為人整治責任概括繼受之法律問題－以德國法之比較為中心〉，《東吳法律學報》，26 卷 3 期，頁 82。

doi:10.6342/NTU202000774

施行前的發生汙染行為後，施行後即發生概括繼承事由，則行政機關是否得向概括繼受人作成整治義務之處分？由於繼受人於發生繼承當下，其被繼承人並未受有行政機關所課予之整治義務，行政機關是否得以第 53 條及概括繼受依據向繼受人課予整治義務，重點在於**繼受人是否繼承汙染行為人之「抽象行為責任」**。

依義務概括繼受制度觀點，原則上須經由行政機關以行政處分作成的義務，始有可被繼受之資格；然並非皆以具體化義務所為限，始具備可繼受性，蓋在立法基於特別需要及考量下，仍得於法規範內特別規定，使抽象的行政法上責任，具備可繼受性[306]。

對於施行前已發生汙染行為，土汙法施行後發生概括繼受事由，污染行為人於存續時，只存在抽象的行為責任，尚未有具體的整治義務存在，此種抽象的行為責任，參考土汙法第 53 條之規範，目的係因過去環保法規的不完整，避免環境汙染現存的事實無限擴大，故立法者考量環境維護此重大的公益及過去立法的欠缺，給予土汙法第 53 條具有真正溯及既往的效力。

故汙染行為人之抽象整治責任地位，應可由其繼承人概括繼受，原因在於在土汙法施行後，主管機關可能在尚未調查汙染事實而對汙染行為人作出整治義務之處分前，汙染行為人即死亡或是因合併而消滅，考量土汙法第 53 條的立法意旨，此種抽象土汙法上責任應肯定得由其繼承人概括繼受，使行政機關得對繼承人進一步作出具體整治義務之處分。土汙法第 53 條真正溯及既往的意旨，應不因污染行為人是否產生概括繼受事由而改變，否則法人可能藉由合併

306 李建良（2007），〈釋義土壤及地下水汙染整治法之汙染行為人－闡析台鹼安順廠汙染事件之整治責任及行政法院相關判決〉，《2006 行政管制與行政爭訟》，頁 145-146，台北：中央研究院法律學研究所籌備處。

doi:10.6342/NTU202000774

的方式，脫免應負之整治義務。據此，此種情況應解釋繼承人有概括繼受該抽象責任的合理性。

承上所述，土汙法第 53 條的規範，可作為抽象行為責任可作為繼受客體之特別明文規範。故在此類型，行政機關仍得依據土汙法第 53 條，將施行前土汙法之行為責任溯及至已不存在的汙染行為人，再類推適用民法第 1148 條第 1 項、立法者另立公法上依據或是公司法第 75 條、民法第 306 條的繼受依據，並參照土汙法第 53 條解釋作為抽象責任例外可被繼受的規範，使繼承人概括繼受該土汙法之抽象行為責任，行政機關再向繼承人為對象以行政處分具體作出整治義務。

三、施行前先發生汙染行為，再發生概括繼承事由，施行後行政機關對繼承人課與整治義務

此情況與第二種差別在於，第三種情況汙染行為與概括繼承事由均發生在施行前，繼承人繼承時尚未有土汙法規範，無從預見有土汙法責任之概括繼受，嗣後行政機關可否溯及既往污染行為人之「行為責任」，並使繼承人溯及既往概括繼受？觀察土汙法第 53 條的規範，依前所分析乃一「行為責任真正溯及既往」規定，可知立法者在制訂該規範時，可以預見土汙法施行前的汙染行為人無從受有土汙法的規制，行政機關亦無從以土汙法為基礎，向汙染行為人課予具體之整治義務，該溯及既往的規定，可能適用於施行後污染行為人尚存在的情況；亦有可能適用於施行前汙染行為人「已不存在」（例如自然人已死亡、公司已合併）之情況，就後者的情況，土汙法第 53 條正給予了抽象行政法上責任可被繼受之例外特別規定，可解釋出立法者欲將土汙法抽象的整治責任溯及於已不存在的汙染行為人，使繼受人概括繼受該行為責任，須進一步負整治義

doi:10.6342/NTU202000774

務，如此始能展現真正溯及既往之目的，以彌補過去環保法規的過去的匱乏，及現實上法律背景考量[307]。

土汙法第 53 條可作為抽象責任例外被繼受之特別規定，行為責任溯及至不存在的汙染行為人，嗣後發生概括繼承事由，亦應由其繼受人概括繼受該行為責任之，故在施行後，行政機關可依照土汙法第 53 條規定向其繼承人課予整治義務。土汙法第 53 條之規定不只具有溯及既往抽象行為責任之效力，另有溯及既往概括繼受之效力，使繼承人承受概括繼承當下不存在之行為責任。

然此種情況，較特別的是，因繼承人在繼承當時根本無從預見有土汙法之規制，繼承人所繼受之整治義務可能得主張「信賴保護原則」。相較於上述第一、二種溯及繼受之類型，若概括繼受的發生均在土汙法施行後，繼承人概括繼受時即可預見其整治義務，應無從主張信賴保護原則；然而，若是在土汙法施行前即發生概括繼受事由，雖然已有土地汙染之行為而造成汙染狀態，但因土汙法根本尚未施行，繼承人對於整治義務亦無可預見性，乃不同於前兩種情況，應有信賴保護原則的適用，其信賴利益屬值得信賴時，應可依照個案情況，減輕或免除整治責任[308]。又，信賴保護尚須檢視施行前之概括繼受人，對於該繼受之土地有無知情其受有汙染等情事，考量信賴利益是否值得保護而調整之，而非一律均有免除、減輕整治責任之適用[309]。

---

307 李建良（2007），〈釋義土壤及地下水汙染整治法之汙染行為人－闡析台鹼安順廠汙染事件之整治責任及行政法院相關判決〉，《2006 行政管制與行政爭訟》，頁 146，台北：中央研究院法律學研究所籌備處。

308 林昱梅（2015），〈土壤污染行為人整治責任概括繼受之法律問題－以德國法之比較為中心〉，《東吳法律學報》，26 卷 3 期，頁 82、86。

309 李介民（2007），〈干涉行政法整治責任之繼受及界限－以土壤及地下水汙染及整治法為範圍－兼評高雄高等行政法院 93 年度訴字第 941 號判決〉，《警學叢刊》，38 卷 3 期，頁 87。

doi:10.6342/NTU202000774

四、小結

土汙法第 53 條屬污染行為人之行為責任真正溯及既往規範，若在施行後，該施行前之污染行為人發生汙染概括繼受事由，因整治義務不具有一身專屬性，屬概括繼受義務之標的，只是在涉及土汙法第 53 條之溯及既往態樣有所不同。若在繼承前，被繼受人已受有行政處分而具體規制其整治義務內涵者，繼受人則應概括繼受該具體整治義務而履行；反之，若被繼承人存續時，未有具體整治義務存在，基於土汙法第 53 條係行為責任之「真正溯及」規定，可分析出立法者肯定抽象行為責任在土汙法領域，例外具備可繼受性，繼承人應概括繼受該溯及之抽象行為責任，行政機關得對繼承人作成整治處分。最後，若是汙染行為與概括繼受事由發生均發生於施行前，仍亦有溯及繼受行為責任之適用，然而在此情況應考量繼承人之信賴保護，在個案為減輕或免除整治義務之調整。

伍、概括繼受土汙法行為責任或整治義務之比例原則適用

不論是整治義務或土汙法抽象行為責任的概括繼受，仍應思考其繼受之界限、範圍，亦須考量比例原則，因概括繼受人畢竟非真正原先的汙染行為人，故需賦予概括繼受人合理之繼受內容。在土汙法領域中，關於責任或義務概括繼受，學理試著提出以下幾種情況，作為比例原則的具體思考方向。

首先第一種考量因素，是以概括繼受「類型」加以區分，若是「自然人死亡」所發生之概括繼受，若繼承人未參與土壤汙染行為，對於其所概括繼受之整治義務或是責任，應限定其所繼承之遺產範圍作為整治義務的界線；若是因「法人合併、非法人團體」所發生之概括繼受，造成污染行為人之法人格或非

doi:10.6342/NTU202000774

法人團體消滅，存續公司或非法人團體應負擔污染行為人之整治義務或責任，若只是法人組織形式上之改組，例如：有限公司改為股份有限公司，污染行為人實質上並未消滅，改組後的法人應概括繼受原污染行為人之所有範圍、內容之整治責任；或是若合併後存續法人對於汙染行為人之組織及營運有實質影響力，應負所有之整治責任[310]。若是其他情況，並非一律概括繼受與汙染行為人相同的整治責任或義務的內容，尚須考量到個案上有無減輕、免除之事由存在，例如：概括繼受之法人有無繼續為汙染行為，若為肯定，其概括繼受之整治義務或責任，應與原先相同；反之，若是合併後概括繼受人並未為汙染行為，則整治責任或義務應限縮於整治土地及有法律上或經濟上關聯的全部財產為限，不得以概括繼受法人之現有全部財產，作為履行整治之範圍[311]。

第二種考量因素，以概括繼受人「是否知情或是汙染情形已公開」加以區分，若概括繼受人在概括繼受時或是之後，得知土地受汙染或是汙染情形已公開，卻未採取排除或防止汙染之措施，應概括繼受全部之整治義務；若繼受人於概括繼受時對於土壤汙染不知情、非因重大過失而不知或是尚未公開汙染情形，其繼受之整治義務或責任範圍應有所限制，依個案適量減輕或免除其整治之負擔[312]。

第三種考量因素，以概括繼受人因繼受該土地所獲得之財產價額考量整治義務之範圍多寡；最後，第四種考量因素，則以整治標的土地的價值判斷[313]。

---

310 林昱梅（2015），〈土壤污染行為人整治責任概括繼受之法律問題－以德國法之比較為中心〉，《東吳法律學報》，26 卷 3 期，頁 86。

311 李介民（2007），〈干涉行政法整治責任之繼受及界限－以土壤及地下水汙染及整治法為範圍－兼評高雄高等行政法院 93 年度訴字第 941 號判決〉，《警學叢刊》，38 卷 3 期，頁 94。

312 林昱梅（2015），〈土壤污染行為人整治責任概括繼受之法律問題－以德國法之比較為中心〉，《東吳法律學報》，26 卷 3 期，頁 86；林三欽（2014），〈土壤汙染行為人責任之繼受與法律溯及適用－簡評大法官解釋第 714 號解釋〉，《法令月刊》，65 卷 1 期，頁 66-14。

313 林三欽（2014），〈土壤汙染行為人責任之繼受與法律溯及適用－簡評大法官解釋第 714 號解釋〉，《法令月刊》，65 卷 1 期，頁 66-14。

doi:10.6342/NTU202000774

第五項 釋字第 714 號之背景事實評析

在大法官釋字第 714 號解釋中，台鹼公司係於 54 年到 67 間在安順廠之廠址土地生產五氯酚等產製過程及剩餘產敏露天堆放滲入土壤，所造成戴奧辛及汞汙染情況，當時台鹼公司對於所生產的五氯酚未符合 63 年公布之廢棄物清理法有關事業廢棄物之規定[314]，可知台鹼公司在土汙法 89 年施行前，即有符合土汙法第 2 條第 15 項第 4 款[315]之汙染行為人定義，該當於施行後土汙法之行為責任人。嗣後在 72 年間由中石化公司合併台鹼公司，台鹼公司因而法人格消滅，惟中石化公司應依公司法第 319 條準用第 75 條之規定，將台鹼公司之權利義務一併概括繼受之。直到土汙法於 89 年施行後，中石化公司是否依照舊土汙法第 48 條規定（也即現行土汙法第 53 條），溯及概括繼受台鹼公司之行為責任，對中石化公司課予該場址之整治義務而應繳納 652,221 元整治費用？

從台鹼公司的汙染行為及與中石化合併後消滅之時點以觀，可發現屬於**「施行前發生汙染行為及概括繼受事由」**之類型，依前所述，舊土汙法（現行土汙法第 53 條）係對於污染行為人之行為責任真正溯及既往之法規範，立法者當然可能預測在施行前，汙染行為人無從依據土汙法的規定課予整治義務，據此舊土汙法第 48 條之溯及既往規定可合理推斷立法者給予土汙法具體義務繼受之例外──土汙法之抽象行為責任亦得為概括繼受之標的。進而土汙法施行後，台南市政府於 93 年得以中石化公司為台鹼公司權利義務之概括繼受人，依土汙法第 53 條及類推適用公司法第 319 條準用第 75 條之規定，溯及既往使汙染行

314 舊廢棄物清理法第 12 條第 1 項：「產生事業廢棄物之事業機構，其廢棄物應自行或委託民營廢棄物清除處理機構負責清除處理之」、第 13 條：「事業廢棄物應妥為貯存，其運輸工具及清除處理方法，應符合主管機關之規定。」（民國 63 年 7 月 26 日公布）。

315 土壤及地下水污染整治法第 15 項第 4 款：「十五、污染行為人：指因有下列行為之一而造成土壤或地下水污染之人：（四）未依法令規定清理污染物」。

doi:10.6342/NTU202000774

為人台碱公司之行為責任，由中石化公司概括繼受，進而本於其繼受之行為責任地位，向中石化公司課與土汙法之整治義務，應繳納 652,221 元整治費用。

然而，有關中石化公司所應負之整治義務內涵及範圍，尚必須考量中石化公司有無繼續為汙染行為、與台碱公司合併時是否已知悉該安順廠址有受戴奧辛及汞汙染情況、合併台碱公司時因而獲得之財產總額以及該筆安順廠址之土地價值之多寡，作為課予中石化公司就該被污染之廠址其整治義務調整應加以考慮之面向，是否對中石化公司所負的返還義務為合理減輕或免除，抑或是就所以之整治義務負責。

最後，就中石化公司可否主張概括繼受時無法預見土汙法溯及規定而主張信賴保護原則，就此部分可否主張，著重探詢中石化公司對於該有無值得保護的信賴利益，例如：是否在合併時對安順廠址之土地受汙染一事，相關文書資料即可顯見等等，加以判斷其信賴利益是否值得保護，進而適當減免整治義務。

第六項　小結

關於土汙法之汙染行為人的整治義務可繼受性的探討，如上所述該污染行為人所負整治義務，係來自於造成汙染結果之「污染行為」本身，屬行為責任之具體呈現。又，整治義務目的在於環境保護之維持，即使將該義務轉換於繼受人負擔，亦得達成原先目的，不具備一身專屬性，得成為概括繼受標的。另外，尚須注意者，土汙法中的「罰鍰義務」具有一身專屬性之特徵，應排除於可繼受之整治義務範圍。

doi:10.6342/NTU202000774

再者，土汙法第 53 條乃土汙法上之抽象行為義務之真正溯及既往規定，施行前的汙染行為人，若因死亡或合併發生概括繼承事由，除了發生土汙法整治義務的概括繼受，例外就土汙法「抽象的行為責任」亦得成為概括繼受之客體，無論概括繼受人在施行前或施行後發生繼受原因，均得承受原污染行為人之行為責任，進而行政機關得向繼受人作成整治義務之處分。然若是施行前已發生繼受事由者，因繼受人當時無法預見土汙法之施行，將有信賴保護原則適用之可能，而酌減或免除其應履行之整治義務，但須探究繼受人有無對汙染情事知情等等，考量有無值得保護之信賴利益。

因整治義務通常涉及大規模的土壤整治或經費支出，該等義務概括繼受亦當然有比例原則之適用，學者對此亦提出多種考量的具體面向，例如：土地價值、繼受人是否有參與污染或是繼續為汙染等等，作為衡量其整治義務的範圍多寡及內容，使繼受人所負擔的整治義務趨於合理。

第二節　罰鍰義務之概括繼受

第一項　概說

罰鍰義務為行政法義務發生之大宗，此種罰鍰義務是否具備可繼受性，將對於行政機關及人民極大的影響，以下以大法官釋字第 621 號的背景作為本節之前導案例，加以探討罰鍰義務的可繼受性。

第二項　案例事實

doi:10.6342/NTU202000774

彰化縣稅捐稽徵處認甲違反土地稅法第 55 條之 2[316]（業於 89 年 1 月 26 公布刪除）等規定，裁處罰鍰新臺幣 260 餘萬元。甲不服，於逾訴願期間始提起訴願、再訴願，均遭程序駁回。提起行政訴訟後，於甲於 89 年間訴訟繫屬中死亡，臺中高等行政法院以 89 年度訴字第 201 號裁定不合法駁回；其甲之繼承人等人聲明承受訴訟並提起抗告，亦經最高行政法院於以 91 年度裁字第 230 號裁定不合法駁回。原處分機關於案件確定後即移送強制執行，甲之繼承人，先後向原處分機關及財政部陳請免對繼承人執行，均未獲准。

第三項　大法官釋字第 621 號解釋意旨

罰鍰處分後，義務人未繳納前死亡者，其罰鍰繳納義務具有一身專屬性，至是否得對遺產執行，於法律有特別規定者，從其規定。蓋國家以公權力對於人民違反行政法規範義務者科處罰鍰，其處罰事由必然與公共事務有關。而處罰事由之公共事務性，使罰鍰本質上不再僅限於報應或矯正違規人民個人之行為，而同時兼具制裁違規行為對國家機能、行政效益及社會大眾所造成不利益之結果，以建立法治秩序與促進公共利益。行為人受行政罰鍰之處分後，於執行前死亡者，究應優先考量罰鍰報應或矯正違規人民個人行為之本質，而認罰鍰之警惕作用已喪失，故不應執行；或應優先考量罰鍰制裁違規行為外部結果之本質，而認罰鍰用以建立法治秩序與促進公共利益之作用，不因義務人死亡而喪失，故應繼續執行，立法者就以上二種考量，有其形成之空間。

罰鍰之處分作成而具執行力後義務人死亡並遺有財產者，依行政執行法第

316 舊土地稅法第 55 條之 2：「依第三十九條之二第一項取得之農業用地，取得者於完成移轉登記後，有左列不繼續耕作情形之一者，處以原免徵土地增值稅額二倍之罰鍰，其金額不得少於取得時申報移轉現值百分之二：一、再移轉與非自行耕作農民。二、非依第二十二條之一規定之各項原因，閒置不用者。三、非依法令變更為非農業用地使用。前項應處罰鍰之土地，不繼續耕作面積未達每宗土地原免徵土地增值稅土地面積之五分之一，其罰鍰得按實際不繼續耕作面積比率計算。但以一次為限。」

doi:10.6342/NTU202000774

15 條規定意旨，該基於罰鍰處分所發生之公法上金錢給付義務，得為強制執行，並無不予強制執行之法律依據。惟上開行政執行法第 15 條規定，係針對行政執行處所為強制執行之特別規定，其執行標的僅以義務人死亡時所留遺產為限。而司法院院解字 2911 號認為「法院依財務法規科處罰鍰之裁定確定後，未執行前，被罰人死亡者，除法令有特別規定外，自不能向其繼承人執行」，係指如無法令特別規定，不能向其繼承人之固有財產執行而言; 罰鍰處分生效後、繳納前，受處分人死亡而遺有財產者，依行政執行法第 15 條規定，該遺產既得由行政執行處強制執行，致對其繼承人依民法第 1148 條規定所得繼承之遺產，有所限制，自應許繼承人以利害關係人身分提起或續行行政救濟。

從大法官釋字第 621 號解釋脈絡可知，首先提出對於罰鍰義務是否具有一身專屬性，提出兩種方向之思考，若是以報應或為矯正違規人民其個人行為之本質作為目的，若罰鍰義務人死亡，該此種義務應已不具備對其警惕之功能，應隨著義務人死亡而消滅而應具備一身專屬性；反之，若認罰鍰處分重點，在於制裁違規行為結果之本質，以建立法治秩序及促進公共利益之作用為目的，則罰鍰義務不具備一身專屬性而可由義務繼承人加以繼受之。但大法官對罰鍰處分本身並未表示其目的究竟為何種，認為立法者有形成之自由。然而大法官話鋒一轉，即指出行政執行法第 2 條[317]、第 15 條[318]及行政執行法施行細則第 2 條[319]的規定下，可知立法有明文規定，罰鍰處分既屬公法上金錢給付義務之一種，依行政執行法第 15 條屬於公法上金錢義務執行的規範，規定對於遺有遺產之義務人死亡，得逕對該遺產強制執行，行政執行法的規範既然肯定得對遺產

[317] 行政執行法第 2 條規定：「本法所稱行政執行，指公法上金錢給付義務、行為或不行為義務之強制執行及即時強制」。，行政執行法施行細第 2 條規定：「本法第二條所稱公法上金錢給付義務如下：一、稅款、滯納金、滯報費、利息、滯報金、怠報金及短估金。二、罰鍰及怠金。三、代履行費用。四、其他公法上應給付金錢之義務」。

[318] 行政執行法第 15 條：「義務人死亡遺有財產者，行政執行處得逕對其遺產強制執行」。

[319] 行政執行法施行細第 2 條規定：「本法第二條所稱公法上金錢給付義務如下：一、稅款、滯納金、滯報費、利息、滯報金、怠報金及短估金。二、罰鍰及怠金。三、代履行費用。四、其他公法上應給付金錢之義務」。

doi:10.6342/NTU202000774

強制執行，可推論立法者肯定罰鍰義務「不具有一身專屬性」之特徵。



第四項　罰鍰義務可繼受性探討

大法官釋字第 621 解釋意旨，似以行政執行法第 2 條、第 15 條之文義反推罰鍰義務不具有一身專屬性，故可由罰鍰義務人之概括繼受人承受，以其所受有之遺產加以執行罰鍰。然此種論證方法不無疑問，蓋探討義務有無具有可繼受性，應先釐清罰鍰義務之本質、目的，始能進一步對於其有無一身專屬性、具體與否為確認。本文以下整理罰鍰義務其性質及內涵。

壹、行政秩序罰之概念

罰鍰義務，乃公法上金錢給付義務，依行政罰法第 1 條[320]規定屬於「行政罰」之一種，可知罰鍰義務兼具公法上金錢給付義務與行政處罰之特質。對於「行政罰」的概念的釐清，將有助於罰鍰義務的內涵理解。

「行政罰」概念上有廣義及狹義行政罰之分，所謂廣義行政罰係指國家及公共團體基於行政目的之達成，要求人民負擔各種行政法上之義務，若人民違背其應盡之義務，對其所施壓之制裁，其內涵包括行政刑罰[321]、行政上之強制執行[322]、懲戒罰[323]及秩序罰的概念；狹義的行政罰專指秩序罰，又可稱行政秩

320 行政罰法第 1 條：「違反行政法上義務而受**罰鍰**、沒入或其他種類行政罰之處罰時，適用本法
。但其他法律有特別規定者，從其規定。」

321 所謂行政刑罰，係指對違反行政法上之義務科以刑法上所定刑名之制裁。廖義男（2008），《行政罰法》，2 版，頁 25-26，台北：元照。

322 所謂行政執行罰，係指對於違反行政法上義務之人，督促其將來履行義務之處置，規範於行政執行法。廖義男（2008），《行政罰法》，2 版，頁 26，台北：元照。

323 所謂懲戒罰，係指基於公法上職務關係所生之制裁，著重於某一職業內部秩序之維護，大多依據公務員懲戒法或是公務人員考績法。廖義男（2008），《行政罰法》，2 版，頁 26，台北：元

doi:10.6342/NTU202000774

序罰，其乃行政機關維持行政秩序為目的，對於過去違反行政法上義務者，施以刑罰以外之處罰作為制裁，行政罰法所規定者屬行政秩序罰之概念[324]。是以，罰鍰義務既是行政罰法所規定之一種處罰方式，性質上屬行政秩序罰之一種，乃狹義之行政罰之概念。

行政秩序罰的特徵，具有制裁及防阻繼續違法為目的，以違反行政法上義務之一般人民作為處罰對象，並且以刑罰之外方式作為處罰手段；其性質具有藉由對違反行政法上義務之人施加不利益，藉由此種不利益的課予非難其違法，藉以發揮阻嚇之作用，故具有「制裁性」之「不利處分」之特色；另外，行政秩序罰係著重對過去已違反行政法上義務之人處罰，必然是已有違法的行為發生，至於受處罰者是否未來將實現其未履行之義務，並非其主要目的[325]。

因行政秩序罰的構成，與違反刑事法上應受刑罰制裁的行為相近，皆是由國家對行為人為處罰，故構成犯罪行為的「主觀及客觀構成要件該當」、「違法性」及「有責性」此三項檢驗，在行政秩序罰亦須具備。

貳、罰鍰義務的目的

罰鍰處分為行政秩序罰下之一種型態，使違反行政法上義務之人受有財產上之不利益作為制裁之內容，以罰鍰作為秩序罰手段之目的，係**「壓制」、「預防」、「剝奪」**所得之三種功能所結合，所謂「壓制」，係指藉由罰鍰的裁罰使相對人深切了解自己的行為已經違反秩序而為不法，因此受到制裁，此種行為亦為一般行政罰所共同具備之特徵；而「預防」功能，尚可分成特別預防及一般

照。

[324] 洪家殷（2008），《行政罰法論》，2 版，頁 4-5，台北：五南。

[325] 洪家殷（2008），《行政罰法論》，2 版，頁 5-14，台北：五南。

doi:10.6342/NTU202000774

預防，前者是指藉由罰鍰警告行為人已違反義務以免將來再犯，後者是指不只警告該行為人而已，尚有讓其他人知悉進而阻止其他人在類似狀況下之違反秩序行為；最後，「剝奪」功能，係著重罰鍰義務限制義務人之財產權，尚有剝奪行為人經由不法獲得經濟利益的作用，進而阻止不法利益的獲得，在經濟上之活動此功能更加明顯[326]。

參、罰鍰義務可繼受性探討

罰鍰義務有無可繼受性之探討可分成兩個層次，一為是否屬行政法上具體義務，二為是否為非一身專屬性。就前者部分就無爭議，蓋必須是行政機關對於違反行政法上義務之行為人，以行政處分作成具體之罰鍰處分，始對行為人產生罰鍰義務。然而，罰鍰處分是否具有一身專屬性則屬本文討論之核心，以下整理實務見解及學理分析之。

一、實務見解

司法院院解字第 2911 號解釋認為：「法院依財務法規科處罰鍰之裁定確定後。未執行前。被罰人死亡者。除法令有特別規定外。自不能向其繼承人執行。又被罰人。於提起抗告後。未經抗告法院裁定前。既已死亡。即無庸再就該抗告為任何裁定」，該號解釋的意旨，乃認為罰鍰義務具有一身專屬性，除非有法律另外特別規定，若罰鍰義務人死亡之後，其罰鍰義務無從由其繼承人繼承之。又，最高行政法院 90 年 12 月份第 2 次庭長法官聯席會議認為：「行政罰鍰係國家為確保行政法秩序之維持，對於違規之行為人所施之財產上制裁，而違規行為之行政法上責任，性質上不得作為繼承之對象。如違規行為人於罰鍰

[326] 洪家殷（2008），《行政罰法論》，2 版，頁 38，台北：五南。

doi:10.6342/NTU202000774

處分之行政訴訟程序中死亡者，其當事人能力即行喪失。尚未確定之罰鍰處分，對該違規行為人也喪失繼續存在之意義而失效。其繼承人復不得承受違規行為人之訴訟程序，受理行政訴訟之高等行政法院應適用行政訴訟法第一百零七條第一項第三款，以裁定駁回違規行為人之起訴」。早期實務見解，肯認罰鍰義務目的在於對行為人作成財產上之制裁，則此義務具有一身專屬性，行為人若死亡而尚未履行其罰鍰義務時，其繼承人無須概括繼受該義務。

然而，大法官釋字第 621 號解釋作成後，司法實務見解對於罰鍰義務是否具有一身專屬性部分多引用釋字第 621 號解釋意旨，但論述的脈絡略有不同。有判決[327]肯定罰鍰義務具有一身專屬性，然依行政執行法第 15 條之明文，罰鍰義務仍可以義務人遺產範圍內為執行。另外，有判決[328]認為罰鍰義務本身根本不具備一身專屬性，義務人若死亡，該罰鍰義務亦不消滅，依行政執行法第 15 條，當然得逕就其遺產加以執行。

由此可知，大法官釋字第 621 號解釋並未明確辨析罰鍰義務是否具有一身專屬性，造成司法實務見解上對此看法並非一致，有認為罰鍰義務本身著重對於行為人之非難性而具有一身專屬性；另外則是以行政執行法第 15 條為依據，既然得以就遺產範圍內執行罰鍰義務，則反推罰鍰義務不具有一身專屬性。然而，不論如何認定罰鍰義務是否具備一身專屬性，司法實務見解均肯定，罰鍰義務即使在義務人消滅後，仍得依照行政執行法第 15 條的規定，以義務人之遺產範圍逕為執行。

327 參照最高行政法院 101 年度判字第 857 號判決。
328 參照最高行政法院 103 年度判字第 136 號判決。

doi:10.6342/NTU202000774

二、學理見解

我國學理見解認為，罰鍰義務應具備一身專屬性，不得由繼承人加以繼受，因罰鍰處分乃行政機關針對人民違反行政法上義務之行為，依法裁罰一定金錢之處分，係對特定行為人違規行為之處分，故罰鍰處分本身始終是因特定的違規行為而生，無獨立存在的可能，因此罰鍰處分的合法性與正當性，必須建立於特定的違規行為之上，換言之，罰鍰處分雖係課予一定金錢給付義務，但並非任何人皆可被要求承擔該等金錢給付義務，只能針對特定違規行為人，故該行為人所創設之違規行為即具有一身專屬性，不得成為概括繼受之標的[329]。

然而，另有認為從刑事訴訟法第 470 條第 3 項出發，既然在我國就金錢刑罰的部分，肯定不因受罰主體死亡而消滅，被繼承人生前如已自行繳納罰金或罰鍰，繼承人繼承者乃已減除罰金或罰鍰之的遺產數額；反之，被繼承人生前未履行其罰金或罰鍰義務，則繼承人乃繼承未減除罰金及罰鍰之遺產數額，但亦應負有繳納該罰金或罰鍰之義務，因上開兩者情況，繼承人因繼承所增加之財產利益應均相同，且由繼承人繼受該罰金或罰鍰義務，並不意味對繼承人之法律上非難；換個角度視之，對於非難性較高的罰金義務既然已明文得就其遺產範圍執行，則非難性較小的行政罰鍰亦應得其遺產範圍執行之，故罰金義務應可類推刑事訴訟法第 470 條第 3 項或是配合民法第 1148 條第 2 項限定繼承責任將使罰鍰義務在遺產範圍內執行之[330]。

329 蔡宗珍（2008），〈公法上無主義務之強制執行?〉，《中研院法學期刊》，2 期，頁 289-290。
330 陳敏（2009），〈人民公法上權利義務之繼受〉，《政治思潮與國家法學：吳庚教授七秩華誕祝壽論文集》，頁 489-490，台北：元照。

doi:10.6342/NTU202000774

三、本文見解

罰鍰義務是否具有一身專屬性，釋字第 621 號解釋並未明確指明，司法實務判決對此亦未有一致的見解；然而就對遺產執行部分，結論上均遵照該號釋字見解及行政執行法第 15 條，均認為罰鍰義務得逕以義務人之遺產執行。學說見解則有以實質財產權觀點及相比較刑事訴訟法第 470 第 3 項規定，認為能就義務人之遺產範圍內執行；另有學理則聚焦於產生罰鍰義務之違規行為本身，而推論屬一身專屬性之性質。

首先，應釐清者乃罰鍰義務的可繼受性之有無，藉由對於罰鍰義務目的的討論，可知乃罰鍰係藉由限制違反行政法上義務人其財產權所對其造成之痛苦，進而非難其行為，並且預防該行為人再發生相同的違法行為並警戒他人若違反亦將受有相同的制裁，最後則是剝奪行為人的財產，使其因不法行為而獲得的經濟利益無法繼續保有之。是否具有一身專屬性，應以比例原則角度觀察，該罰鍰義務若移轉於繼承人由繼承人履行其罰鍰義務時，是否亦得達到上開所追求者。

就「壓制」目的，給予違反義務人痛苦的非難而言，既是著重給予心理上之壓抑、痛苦，若轉換於其繼承人加以承受，可想而知無法達成壓制之目的，蓋繼承人並非原本違反行政法上義務人，剝奪財產之痛苦無法給予原義務人，即使由繼承人承受剝奪財產之痛苦，仍無法達成原先目的；再者就「預防」目的而言，藉由罰鍰義務的課予，使原義務人嗣後不再犯相同的違法行為，此種產生行為上制約之目的，若移轉至其繼受人，很明顯地無法達成使原義務人受到行為制約目的，就一般人亦受到警戒部分，既然繼受人本身非違反行政法上義務之行為人，即使對繼受人課予罰鍰義務的制裁，亦無法使一般人受到行為

doi:10.6342/NTU202000774

制約之警戒。

就「剝奪」的功能，經濟利益的剝奪，是否就繼承人所得遺產範圍內加以執行，仍可達成對於原義務人不法利益的收回目的？關於此疑問，主要在於釐清遺產的定性，從本文前所述[331]，所謂「遺產」乃依法律規定取得之財產，在被繼承人發生死亡事實之那一刻，其生前所有之財產即因民法第 1147 條、第 1148 條之規定，成為繼承人所有之財產，故遺產非屬被繼承人權利義務或是人格之延伸。既遺產概念上自被繼承人死亡起，即為繼承人所有，且屬被繼承人依民法繼承編的規定而合法取得，國家對於被繼承人所得之不法利益由遺產追回的正當性，不無疑問。可思考的是，罰鍰義務帶有使義務人喪失其不法取得之利益，前提應是剝奪義務人「所有」且「取得原因為不法」之財產，若追及至繼承人繼承受有之遺產，無疑是對於繼承人「合法取得」之財產命其繳回，與原先罰鍰義務的目的並不合致。據此，遺產與被繼承人之間關聯，僅僅存在「取得原因」是來自於被繼承人之死亡之事實，除此以外無任何關係。故剝奪功能部份，以繼承人合法所取得之遺產，繳回原義務人所受有不法利益，此種方式並無法達成該功能目的。

綜上所述，罰鍰之三大目的，既無法藉由其繼受人履行而達成，推論罰鍰義務本身應不具備一身專屬性，不具備可繼受性的罰鍰義務，應隨著原義務人之死亡而消滅。另換角度視之，罰鍰處分本身的作成前提，尚須檢視行為人的主觀及客觀構成要件是否該當、阻卻違法事由及有責性是否具備，每一階段的檢驗接著重行為人作成違法行為當下之行為態樣及主觀意識，與行為人本身的人格息息相關，具有高度屬人性之特徵，可推論罰鍰義務與義務人之行為兩者間具有緊密關聯性。

[331] 參照本文第二章、第一節、第五項、壹、二、「遺產」的定位。

doi:10.6342/NTU202000774

然而，關於釋字 621 號肯定行政執行法第 15 條，就公法上金錢給付義務部分由遺產逕以執行之合憲解釋，依本文前所述[332]，行政執行法第 15 條並非對於罰鍰義務得由繼承人概括繼受之明文，而是行政執行程序中，對於受執行義務人死亡時，就不具備一身專屬性之金錢給付義務不停止執行之例外規定。另外，學說見解有以刑事訴訟法第 470 條第 3 項出發，以舉重以明輕之法理認為，罰鍰義務由繼承人承受，逕由其遺產執行。但此種見解不無疑問，因罰鍰義務的本質，係國家刑罰權之一環，本於罪刑法定主義的概念包括「禁止類推適用」之內涵，罰鍰處分是否能由其繼承人概括繼受，應不得從其他法律的意旨加以類推，當然不得以舉重以明輕之法理為依據，使繼承人承受罰鍰義務。

肆、釋字第 621 號之背景事實評析

甲違反舊土地稅法第 55 條之 2 規定，受有罰鍰新臺幣 260 餘萬元，於撤銷訴訟繫屬中死亡，嗣後臺中高等行政法院以逾期提起訴願程序而以程序不合法駁回甲之行政訴訟，甲之繼承人聲明承受訴訟並向最高行政法院抗告，最高行仍裁定不合法而駁回之，彰化縣稅捐稽徵處即以該案件確定而移送行政執行。

甲受有一罰鍰處分，嗣後甲於行政訴訟繫屬中發生死亡事實，構成概括繼受事由，然而罰鍰處分乃具有一身專屬性，甲生前所負有 260 餘萬之罰鍰義務，應因甲之死亡而該罰鍰義務隨之消滅，不屬甲繼承人之概括繼承標的，進而中高行應以未遵守訴願期間及當事人已死亡為由，將原處分依行政訴訟法第 108 條第 1 項第 3 款、第 6 款裁定駁回之。因甲之繼承人未概括繼受該罰鍰義

[332] 參照本文第三章、第一節、第三項、伍、一、（一）行政執行法第 15 條定位之辨析。

doi:10.6342/NTU202000774

務，不具備訴訟權能，故不得聲請承受該撤銷訴訟。然而甲之繼承人仍可考慮該罰鍰處分對於甲死者名譽權的影響，提起「確認處分違法之訴」（行政訴訟法第 6 條第 1 項後段），請求法院對於該處分確認違法，使已死亡甲之名譽權獲得回復，亦使繼承人之名譽權間接獲得回復。

再者，罰鍰義務因具備一身專屬性，隨著甲死亡而消滅，故甲之繼承人不須概括繼受該罰鍰義務，彰化縣稅捐稽徵處不得移送執行，據此行政機關既然對甲之繼承人欠缺行政執行法第 11 條[333]之執行事由，當然不得對甲所有之遺產執行該已消滅之 260 萬餘元之罰鍰義務。

第五項　小結

行政執行法第 15 條係行政執行中，義務人若發生死亡情事時，對於其生前所負有之可繼受性金錢給付義務例外不停止執行之程序規定，而非實體法上對於肯定罰鍰義務具有可繼受性而可向繼承人所有遺產逕予執行之規定，據此不得以該條作為罰鍰義務得以概括繼受之立法特別明文，應回歸罰鍰義務之本質、目的加以討論。

藉由探討罰鍰處分所追求的目的，可清楚發現，該等義務所追求的壓制、預防、剝奪之三大目的，無法藉由原處分之繼承人承受後履行而達成，且罰鍰義務成立的前提，與原義務人之違規行為當下之主觀、客觀態樣密不可分，由此可知罰鍰處分具有一身專屬性，不具備義務可繼受性，其繼承人無須概括繼

[333] 行政執行法第 11 條：「義務人依法令或本於法令之行政處分或法院之裁定，負有公法上金錢給付義務，有下列情形之一，逾期不履行，經主管機關移送者，由行政執行處就義務人之財產執行之：一、其處分文書或裁定書定有履行期間或有法定履行期間者。二、其處文書或裁定書未定履行期間，經以書面限期催告履行者。三、依法令負有義務，經以書面通知限期履行者。法院依法律規定就公法上金錢給付義務為假扣押、假處分之裁定經主管機關移送者，亦同。」

doi:10.6342/NTU202000774

受該罰鍰義務，行政機關亦不得就繼承人所得之遺產移送行政執行。



第三節　不當得利返還義務之概括繼受

第一項　概說

不當得利的發生，民法與公法領域上均有此問題存在，在民法領域，不當得利返還法律關係當事人均為私人之間，不當得利的返還義務人在生前未（完全）履行其返還義務而發生死亡情事者，將可能依照民法繼承編的規定，成為其繼承人概括繼承之標的。在公法領域內，公法上不當得利的發生，主要是發生在國家與人民之間，本節所聚焦者，乃人民對國家的不當得利返還義務，該種義務在義務人生前未完全履行時，是否亦有繼承人概括繼受的可能，屬本節所探尋者。對此課題，須將公法上與私法上之不當得利返還制度介紹，比較兩者法律關係之差異；再就兩者返還義務之發生方式更精細比較，以梳理出公法上不當得利返還義務是否、如何成立。確認公法上返還義務已成立後，再進一步釐清返還義務之可繼受性與否，以解決本節之核心問題意識。以下以高雄高等行政法院 102 年訴字第 100 號判決作為本節之事實引導案例，探討公法上不當得利人死亡後，不當得利返還義務與義務繼受兩者之交集應如何思考、處理。

第二項　案例事實

甲於任職於高雄市立民生醫院（以下簡稱民生醫院），分別於 70 年 12 月、72 年 3 月及 73 年起利用下班之餘，於自宅開業看診並收取醫療費用。然而，甲仍依照省市立醫療機構醫師專勤服務辦法（88 年 10 月 6 日修正為行政院衛

doi:10.6342/NTU202000774

生署，自 102 年 7 月 23 日更名為衛生福利部，以下仍稱衛生署〉暨直轄市政府衛生局所屬醫療機構醫師專勤服務辦法，下稱專勤服務辦法）第 2 條及第 7 條規定，簽立承諾書，領取專勤獎金，乃違反上開專勤服務辦法而詐領專勤獎金，自 75 年 7 月 1 日起至離職日止所領取的全部獎勵金一共 57,707,069 元，民生醫院於 88 年 10 月 18 日發 A 函向甲應返還從 75 年 7 月 1 日起至其離職日止所領取的全部獎勵金 57,707,069 元。然甲不服遂提起訴願，後於 89 年 8 月 25 日提起行政訴訟，經高雄高等行政法院以 89 年度訴字第 182 號因認定 A 函非行政處分而裁定駁回。嗣後，甲於民國 94 年 9 月 15 日死亡，然甲死亡前該等應返還之獎勵金仍未返還於原告民生醫院，故原告民生醫院對甲之繼承人提起行政訴訟，主張甲之繼承人應返還其繼承甲全部獎勵金之公法上之不當得利，共計 57,707,069 元。

第三項　法院見解

高雄高等行政法院在此認為，A 函的確屬行政處分且屬撤銷原違法核發獎勵金授益行政處分，A 函於 88 年 10 月 18 日作成時，甲即與民生醫院產生基於授益行政處分之不當得利之法律關係，甲負有返還民生醫院該全數獎勵金的義務。嗣後甲於 94 年 9 月 15 日死亡，因民生醫院對甲的不當得利返還請求權，屬單純之公法上財產請求權，故返還獎勵金之義務，依照民法第 1148 條之規定自屬甲之繼承人繼承之標的，然而該 A 函於 88 年 10 月 18 日作成後，即產生民生醫院對甲的不當得利返還請求權，而該等請求權屬公法上請求權，其時效因在行政程序法第 131 條施行前，依實務見解應至 95 年 1 月 1 日即時效屆滿而消滅。而民生醫院於作成 A 函之後，亦未在請求返還，而遲至於 102 年 3 月始

doi:10.6342/NTU202000774

向甲之繼承人請求返還。據此，該返還請求權已罹於時效而消滅，甲之繼承人自不負返還義務。

由法院的見解，可以發現行政法院並未意識到該案件涉及不當得利返還義務之概括繼受課題，故並未加以處理，而是以罹於時效為由，駁回民生醫院的要求。

第四項　不當得利返還義務之可繼受性探討

壹、不當得利返還制度內涵

不當得利返還制度乃公法與私法共通的法律制度，現行我國法制上，私法（民法）上對於不當得利返還制度，其係指無法律上原因而受利益，致他人受損害者應負返還之義務，可知具有「無法律上原因」、「一方受利益」及「一方受損害」之三項要件，私法上不當得利屬「債之發生原因」之一，且為「法定之債[334]」發生原因之一種，其目的在於調節欠缺法律上原因的財產變動及保護財產之歸屬，於民法第 179 條至 183 條對於不當得利的構成要件、返還例外、客體、範圍均設有規定；又實務及民法學理對於「無法律上之原因」此一要件，進一步區分「給付[335]型」及「非給付型」不當得利，前者係指受領給付因欠缺一定給付目的而發生不當得利，此種情況常發生於私法契約終止或解除，抑或是發生通謀虛偽意思表示之情況；後者則指因給付以外之事由所發生之不當得利，此種情況通常發生於因侵害他人權益而受益類型[336]。私法上的不當得

[334] 意即因「法律規定」而發生之債，不同於因「法律行為」所發生之意定之債。王澤鑑（2012），《債法原理－基本原理：債之發生、契約、無因管理》，3 版，頁 6-7，台北：自刊。
[335] 所謂「給付」，係指有意識地，基於一定目的而增加他人財產。王澤鑑（2015），《不當得利》，增訂新版，頁 46-47，台北：自刊。
[336] 王澤鑑（2015），《不當得利》，增訂新版，頁 2-7、45-48，台北：自刊。

doi:10.6342/NTU202000774

利返還制度中，其法律關係主體乃存在於「私人與私人」之間，受損人得依據民法第 179 條以下主張不當得利返還之債發生而為返還請求權人；受益人[337]因該當民法第 179 條之構成要件而為返還義務人。據此，民法上的概括繼受制度下，民法之受益人在未（完全）履行返還義務下，其義務均有依照民法第 1148 條概括繼受的可能。

公法領域亦有不當得利返還的問題，相較民法第 179 到 183 條較為完整的規定，公法領域內關於不當得利的法律規範及制度尚未有一般性規定，在行政程序法第 127 條僅有規範基於「行政處分」無效或失效情況下其返還義務的產生、返還範圍及返還義務產生之方式。關於公法上不當得利，其概念學理認為屬行政法上債權債務發生的原因之一，係指在公法的領域範疇內，欠缺法律上原因而發生財產變動，至一方受有利益，而他方受有損害，受損害的一方得請求返還所受利益之情形，調整公法上無法律原因之財產流動而確保財產之歸屬；另外公法上不當得利返還制度，除了調整不法財產流動以外，尚有追求憲法層次之法治國原則的依法行政原則，此目的乃民法之不當得利欲調和私人間利益衝突有所不同[338]。

公法上不當得利返還制度，關於其法律關係主體，概念上分為「國家與私人之間」、「私人及私人之間[339]」及「國家與國家之間」三種，關於後兩者並非

[337] 本文以「受益人」一詞描述公法上或是民法上不當得利下受有利益的一方，不同於民法第 180-183 條稱受有不當得利之一方為「受領人」，原因在於所謂「受領」係帶有具備意識地受有無法律上原因給付之意。然而，不當得利返還制度不只是具有給付型，尚具有非給付型（非因給付而受有利益），故本文以下對於受有無法律原因利益之人稱之為「受益人」，較為全面描述不當得利受有利益之狀態，而不稱為受領人，合先敘明。

[338] 林錫堯（2002），〈公法上不當得利法理試探〉，《當代公法新論(下)》，頁 268。

[339] 私人與私人之間可能會成立公法上不當得利之可能，可能發生的情況是在私人之間若有締結行政契約的可能，則在行政契約有無效或解除事由時，公法上不當得利制度將可能適用於私人之間。而關於私人之間有無締結行政契約的可能，德、日學理大多肯認，又我國過去實務上民國 81 年 2 月 1 日公布之公害糾紛處理法第 30 條第 2 項規定，私人與私人之間可能成立締結「公害管制協定」，而該協定係由日本法所引進，參考日本通說及實務均認為屬公法契約，似乎開啟了我國有私人間締結行政契約之空間。然而，有學理以契約標、目的及形式加以檢驗，認

doi:10.6342/NTU202000774

本文所聚焦者故暫不討論；前者尚可細分為「國家為返還義務人；人民為返還請求權人」或是「國家為返還請求權人；人民為返還義務人」兩種，關於前者國家作為返還義務人之情況，由於國家不可能如私人一般發生死亡等繼受事由，故國家負有對人民之不當得利返還義務無義務繼受討論的可能，故不探究之。後者則是以人民作為返還義務人情況，則可能發生如死人或法人合併之繼受事由，此種類型始有討論義務繼受之實益存在。

進一步，就「人民對國家負有不當得利返還義務」之類型，其返還義務發生的原因，學理認為如同民法上不當得利制度，亦可再區分為「給付型」及「非給付型」公法上不當得利[340]。後者因未有公法上之給付意思表示，通常發生的情況可能是無權占有國土等等此種侵害國家利益型之不當得利。前者給付型的不當得利，又可分為基於行政處分之給付、基於行政契約之給付、基於法規之給付、基於行政契約之給付或是基於事實行為之給付，實務上以「基於行政處分之給付」之公法上不當得利此類型為發生之大宗[341]。本文欲討論的類型即是「基於行政處分所產生的公法上不當得利」類型，並限縮於「基於金錢授益處分所生公法上不當得利」之返還義務，作為義務繼受的探討之標的。

為私人間並無高權地位而得對於公法關係具有可處分權；在公法目的的檢驗上，達成為公益的目的之前提應是至少有一方當事人為高權主體；有以當事人的地位以觀，除非雙方均為行政委託下之受託人下而締結受託事項之契約，否則兩者所締結權利義務主體乃具有歸屬每個人之特徵，不具有一方高權主體之地位，故私人間應無從成立行政契約，除非是私人間係本於受託行使公權力之地位本於受託事項締結契約，始有成立私人間行政契約之可能。然而，該私人乃具有功能意義上的行政高權主體地位，不宜認定為私人之間行政契約之意義。錢建榮（1995），《行政契約之主體與範圍》，輔仁大學法律學研究所碩士論文，頁 208-224。依照該學理的見解下，我國對於私人間既無成立行政契約的可能，進而私人間亦應無從有發生公法上不當得利之可能。

[340] 學理對於公法上之不當得利，是否有如民法學理區分為給付或是非給付型尚有爭議，有認為公法上只有給付型不當得利發生之可能，蓋必須藉由給付認定是否為無法律上原因；然而另有學理認為在非給付而受利益之情況只要該利益具有公法性質或是財產變動間具有公法上關係，即可成立非給付型公法上不當得利，本文採後說之。林錫堯（2002），〈公法上不當得利法理試探〉，《當代公法新論(下)》，頁 270。

[341] 劉建宏（2007），〈行政主體向人民主張公法上返還請求權之法律途徑及其返還範圍－以授益處分經自行撤銷之情形為例〉，《東吳法律學報》，19 卷 2 期，頁 177-178。

doi:10.6342/NTU202000774

試著將人民對國家負有之金錢授益處分不當得利返還義務，與自然人發生死亡之概括繼受兩者融合，在金錢授益處分相對人，作為公法上不當得利之受益人，嗣後發生死亡情事，是否亦有公法上不當得利返還義務概括繼受之發生？藉由確定「何種情況」有返還義務之發生、返還義務是否具備可繼受性及繼承人應如何繼受？

貳、成立金錢授益處分之不當得利「返還義務」

討論不當得利返還義務繼受之概念前，須先確定人民公法上不當得利返還義務「已成立」，否則將無繼續討論之實益。將公法與民法上之不當得利返還義務成立相比較，有助於理解兩者法領域間，對於受益人與返還義務人兩者概念的辨析，以及公法上返還義務成立之思考脈絡。以下以「金錢授益處分」此類型為核心，先釐清公法與民法上不當得利返還義務之差異，分析公法上不當得利「受益人」與「義務人」概念內涵是否相同，再探討產生公法上不當得利返還義務的要件，並提出類型加以分析。

一、公法與民法上不當得利返還義務之比較

在民法上之不當得利制度中，其構成要件乃規定於民法第 179 條[342]，也即在「無法律上之原因」而「受利益」,「致他人受損害者」，即負返還該不當利益之義務。不當得利制度在民法領域屬法定之債，只要法律事實該當該條之要件，不待當事人另為意思表示，即因該條規定而產生私法上債權債務之關係，據此民法上不當得利領域中，不當得利「受益人」直接依據法律規定而具有

[342] 民法第 179 條：「無法律上之原因而受利益，致他人受損害者，應返還其利益。雖有法律上之原因，而其後已不存在者，亦同」。

doi:10.6342/NTU202000774

「返還義務人」之地位，受損人不需對受益人為任何法律行為，僅需依據民法不當得利之規定，即可本於不當得利返還請求權人之地位，向受益人主張履行返還義務，故民法不當得利受益人當然負有返還義務。除非是該欠缺法律上原因之利益流動於受無償讓與之第三人，依民法第 183 條[343]規定該第三人負有返還義務，始發生不當得利受益人與返還義務人不同一之例外情況。

然而，公法不當得利之受益人是否如民法一般負有返還義務，當然具備返還義務人之地位？答案應為否定。原因在於公法上不當得利返還義務，並非如民法領域內規範為「法定之債」明文其構成要件及該當之返還效果。依行政程序法第 127 條第 3 項[344]規定，可知立法者在此認為返還義務應透過書面行政處分向受益人作成。據此，公法上不當得利返還義務是否發生，首先需檢驗是否「產生公法上不當得利[345]」，若該當於公法上不當得利發生之要件，不當得利受益人並不等同於負有返還義務，因行政機關尚須對受益人另外「作成具體之書面返還義務」，受益人始負有返還該利益之義務，否則受益人即便受有不當得利，仍不負有返還義務。

承上所述，公法上之不當得利受益人並不等同於返還義務人，須另外檢視行政機關是否向受益人作出書面返還義務之行政處分，受益人始具有返還義務人地位。民法與公法領域不當得利返還義務產生的差別，可以從兩者法領域所追求之目的不同而探究其原因。民法之不當得利制度係為追求私人間利益的調和及衡平，故不當得利的產生以法定之債之方式產生，使受損人便於追求其調

[343] 民法第 183 條：「不當得利之受領人，以其所受者，無償讓與第三人，而受領人因此免返還義務者，第三人於其所免返還義務之限度內，負返還責任」。

[344] 行政程序法第 127 條：「行政機關依前二項規定請求返還時，應以書面行政處分確認返還範圍，並限期命受益人返還之」。

[345] 產生公法上不當得利之事由為「在公法的領域範疇內，欠缺法律上原因而發生財產變動，至一方受有利益，而他方受有損害」。林錫堯（2002），〈公法上不當得利法理試探〉，《當代公法新論(下)》，頁 268。

doi:10.6342/NTU202000774

整私人間的利益；然而，公法之不當得利制度，除了調整不當利益流動外，尚有追求依法行政之正確性，故返還義務的產生，自須明確使人民得以預見，展現法治國原則之貫徹，故返還義務的發生，須透過行政機關作成具體明確的返還處分，人民始負擔之。

二、公法上不當得利返還義務成立要件

首先，行政機關已作成金錢授益處分而發生財產變動致使國家受損害，使金錢授益處分人受有利益，產生國家與人民間利益之流動，又該利益流動係以金錢授益處分為給付之依據，屬公法上之給付，為公法領域之財產流動，此部分較無爭議[346]。

再者，該金錢授益處分欠缺法律上原因，意謂該金錢授益處分產生溯及失效之事由，處分相對人所受之金錢利益不具備法律上之正當性。在金錢授益處分可能的發生情況為該處分「自始無效」與「嗣後失效」。前者依照行政程序法第 111 條[347]各款規定，處分自始無效；而後者之嗣後處分失效事由，依行政程序法第 110 條第 3 項之規定[348]及第 127 條第 1 項規定[349]，金錢授益處分可能因

[346] 關於公法上不當得利，前提為財產流動係屬公法性質，若是給付型不當得利，則以給付之原因判斷是否為公法性質；若給付無依據，則依給付動機判斷屬公法責任；若是非給付型不當得利，則以受益人與受損人之間是否具有公法性質關聯而定。林錫堯（2002），〈公法上不當得利法理試探〉，《當代公法新論(下)》，頁 271。

[347] 行政程序法第 111 條：「行政處分有下列各款情形之一者，無效：一、不能由書面處分中得知處分機關者。二、應以證書方式作成而未給予證書者。三、內容對任何人均屬不能實現者。四、所要求或許可之行為構成犯罪者。五、內容違背公共秩序、善良風俗者。六、未經授權而違背法規有關專屬管轄之規定或缺乏事務權限者。七、其他具有重大明顯之瑕疵者」。

[348] 行政程序法第 110 條第 3 項：「行政處分未經撤銷、廢止，或未因其他事由而失效者，其效力繼續存在」。

[349] 行政程序法第 127 條第 1 項：「授予利益之行政處分，其內容係提供一次或連續之金錢或可分物之給付者，經撤銷、廢止或條件成就而有溯及既往失效之情形時，受益人應返還因該處分所受領之給付。其行政處分經確認無效者，亦同」。

doi:10.6342/NTU202000774

違法而撤銷溯及失效[350]、因未履行負擔之附款而遭廢止溯及失效[351]、因解除條件之附款成就而處分失效[352]等等。實務上對於金錢授益處分欠缺其法律上原因多半以處分違法撤銷而溯及失效為大宗[353]，故本文以下以「處分違法撤銷」作為無法律上原因之事由，繼續討論不當得利返還制度。

以上的情況已構成金錢給付義務發生不當得利之要件，但僅能表示「授益處分相對人」成為公法上不當得利之「受益人」如此，並不代表受益人負有返還義務，尚需待「行政機關對受益人以書面的方式作成返還之行政處分」，具體規制返還之內容、範圍，該受益人始負返還義務，以符合行政程序法第 127 條第 3 項[354]之規範及法治國原則之內涵。故返還義務並非在原授益處分被撤銷時即發生[355]，而需行政機關進一步以書面行政處分方式，命不當得利受益人返還始發生。簡言之，授益處分相對人不等於不當得利受益人，不當得利受益人亦不等於返還義務人，各個階段是否產生新的地位，必須分別檢視。

三、返還義務產生之類型討論

釐清不當得利返還義務何時、如何產生後，在義務概括繼受的脈絡思考

---

350 行政程序法第 118 條：「違法行政處分經撤銷後，溯及既往失其效力。但為維護公益或為避免受益人財產上之損失，為撤銷之機關得另定失其效力之日期」。

351 行政程序法第 123 條第 3 款：「授予利益之合法行政處分，有下列各款情形之一者，得由原處分機關依職權為全部或一部之廢止：三、附負擔之行政處分，受益人未履行該負擔者」；行政程序法第 125 條但書：「但受益人未履行負擔致行政處分受廢止者，得溯及既往失其效力」。

352 行政程序法第 93 條：「行政機關作成行政處分有裁量權時，得為附款。無裁量權者，以法律有明文規定或為確保行政處分法定要件之履行而以該要件為附款內容者為限，始得為之。前項所稱之附款如下：一、期限。**二、條件**。三、負擔。四、保留行政處分之廢止權。五、保留負擔之事後附加或變更」。

353 例如：最高行政法院 105 年判字第 60 號判決、最高行政法院 104 年判字第 484 號判決、最高行政法院 104 年判字第 333 號判決。

354 行政程序法第 127 條第 3 項：「行政機關依前二項規定請求返還時，應以**書面行政處分**確認返還範圍，並**限期命受益人返還**之」。

355 關於返還義務發生的時間點，學理另外有認為在原授益處分遭撤銷時即已發生，而不待行政機關另作成返還處分。詹鎮榮（2016），〈人民公法上不當得利返還義務之繼受〉，《行政法總論之變遷與續造》，頁 328-329，台北：元照。

doi:10.6342/NTU202000774

下，金錢授益處分相對人必須在發生死亡事實時，具備公法不當得利之要件，並已負有返還義務，始有討論其繼承人是否繼受返還義務。以下就授益處分相對人是否產生返還義務之不同態樣分析。

（一）授益處分相對人於「死亡前」行政機關已對其作成撤銷處分

行政機關對於原處分相對人開啟違法處分予以撤銷之行政程序，授益處分相對人與撤銷處分相對人均屬同一對象[356]。在撤銷原處分後，授益處分相對人即成為不當得利受益人，然是否負有返還義務，需端視「行政機關有無對該受益人作成書面返還處分」，若為肯定，受益人負有返還該金錢之規制，則具有返還義務無誤；反之若為否定，受益人尚未產生返還義務。

（二）授益處分相對人於「死亡後」行政機關始向其繼承人作成撤銷處分

授益處分相對人與撤銷處分相對人非屬同一對象，若以「授益處分相對人之繼承人」為撤銷處分相對人，是否成立公法上不當得利？又是否可進一步發生返還義務，尚有疑義。

思考的重點在於，既撤銷處分的效力係針對原先授益處分的違法而加以撤銷，對於「撤銷處分」的效力與相對人而言，行政機關可否藉由對「處分相對人的繼承人」作成撤銷處分的方式，使撤銷效力藉由對繼承人作成，追及至原先的授益處分產生公法上不當得利？以下就實務及學說見解加以分述之。

356 詹鎮榮（2016），〈人民公法上不當得利返還義務之繼受〉，《行政法總論之變遷與續造》，頁330，台北：元照。

doi:10.6342/NTU202000774

1. 我國實務見解

在我國行政及司法實務上，原處分機關常有在受益人死亡後，轉而向「受益人之繼承人」作出撤銷原授益處分之行政處分，並且一併請求返還受益人溢領之金額，對此，我國行政實務及司法實務上對此種「授益處分之受益人」與「撤銷處分之相對人」不同一的情況，皆持肯定見解[357][358]。其理由在於，授益行政處分之相對人若已死亡，本於民法第 1148 條乃概括繼受被繼承人財產上的一切法律關係之法理，倘欲撤銷該授益行政處分，自得以其「繼承人」為對象，並向其請求公法上不當得利返還。故實務見解乃認為，向原授益處分相對人或是其繼承人做為撤銷處分之相對人效力均相同，皆使原授益處分溯及失效，可向繼承人主張不當得利返還義務。

2. 我國學理見解

我國學理提及德國法之學理作為比較，德國學理認為，討論金錢給付授益處分相對人及撤銷處分相對人「非同一」情況，在德國聯邦行政程序法中關於以違法行政處分為給付原因所建構之公法上不當得利制度，先後乃存在三個具有內在關聯性之行政處分：首先，為提供金錢給付之「同意決定」；再者，為撤銷同意決定之「撤銷處分」；最後，為請求人民返還溢領金額之「給付裁決」[359]。

[357] 例如：內政部 102 年 4 月第 1020140036 號訴願決定、台北高等行政法院 102 年訴更一字第 137 號判決、最高行政法院 100 年度判字第 75 號判決。

[358] 詹鎮榮（2016），〈人民公法上不當得利返還義務之繼受〉，《行政法總論之變遷與續造》，頁 330，台北：元照。

[359] 詹鎮榮（2016），〈人民公法上不當得利返還義務之繼受〉，《行政法總論之變遷與續造》，頁 331-332，台北：元照。

doi:10.6342/NTU202000774

就「撤銷處分」、「給付裁決」相對人抉擇上，原則上為授益行政處分之相對人、受益人，以及其他因行政處分而權益受影響之利害關係人；若原相對人或利害關係人死亡或因其他原因而不復存在，在發生權利義務概括繼受時，撤銷處分尚可對「受益人之繼承人」作成之[360]，析言之，德國學說及實務見解認為，因受益行政處分相對人死亡而發生概括繼承之情況，繼承人作為「撤銷處分」及「給付裁決」之相對人地位皆受到肯定，對繼承人作為撤銷處分對象，仍可達成撤銷原授益處分之效果，使授益處分溯及既往失效，已死亡之處分相對人即負有返還義務，由繼承人概括繼受之[361]。

我國學理認為能否以「受益人」作為撤銷原授益處分相對人，應將撤銷處分相對人之地位以行政法釋義學的角度觀察，繼承人究竟繼受了被繼承人（授益行政處分之相對人）何等「權利」或是「義務」，致使取得了「撤銷處分相對人地位」，使行政機關得以繼承人為撤銷處分之相對人[362]。

以「義務」角度以觀，授益處分相對人（被繼承人）截至死亡時為止，行政機關既未對受益人撤銷原先授益處分，無從發生不當得利返還義務，繼承人無從概括繼受之，繼承人當然無從作為撤銷處分相對人；再者，轉向考慮「權利」的繼受，按相對人本身依據合法授益行政處分所獲得之權利，為公法上金錢給付請求權，若已受領將成為其總財產一部分之金錢收入，性質上不同於公法上金錢給付請求權，不具有一身專屬性，發生死亡之繼受事實後，可能成為遺產之一部而由繼承人加以繼受，繼承人具有利益最終實際歸屬者之地位，然

360 蔡茂寅、李建良、林明鏘、周志宏（2013），《行政程序法實用》，4 版，頁 290-291，台北：新學林。
361 詹鎮榮（2016），〈人民公法上不當得利返還義務之繼受〉，《行政法總論之變遷與續造》，頁 332，台北：元照。
362 詹鎮榮（2016），〈人民公法上不當得利返還義務之繼受〉，《行政法總論之變遷與續造》，頁 333，台北：元照。

doi:10.6342/NTU202000774

此地位應只足以正當化作為「不當得利返還義務」之相對人，但無從作為「撤銷處分相對人」，原因在於，繼承人即使繼承利益之實際歸屬，卻不因此繼成被繼承人之公法上金錢給付請求權[363]。

繼承人若能具備撤銷處分的相對人地位，學理認為法理基礎應在於「行政處分效力之繼受」，此種「處分效力之繼受」經常存於以物之狀態責任作為基礎之處分，然而不具有一身專屬性的金錢給付，亦有能發生處分效力繼受，據此可區分處分中公法上金錢給付是否具備一身專屬性加以判斷，若原處分之金錢給付內容不具備一身專屬性，授益處分效力及於繼承人，行政機關得可對繼承人作出撤銷處分；反之，若具有一身專屬性的金錢給付，其處分效力將因受益人的死亡而歸於消滅，無法由繼承人繼受，其金錢給付即混同於遺產中，無法以其繼承人作為撤銷處分相對人[364]。

3. 本文見解

授益處分相對人之繼承人，得否作為撤銷原處分之相對人，重點在釐清「繼承人有無受授益處分之效力所及」，授益處分的效力究竟是否延續於其繼承人，或許可從現行民法與行政程序法的規定加以觀察。授益處分相對人死亡時，其權利能力因而消滅[365]，公法上之權利義務動態狀態，於相對人發生死亡時即停止，故死亡時相對人所受領的金錢，即停留在有法律上原因受領之狀態。再者，依照行政程序法規定，尚無「行政程序承受」的制度，繼承人無從取得授益處分相對人的資格地位，行政機關無法向繼承人作成撤銷處分而成立

363 詹鎮榮（2016），〈人民公法上不當得利返還義務之繼受〉，《行政法總論之變遷與續造》，頁333-334，台北：元照。
364 詹鎮榮（2016），〈人民公法上不當得利返還義務之繼受〉，《行政法總論之變遷與續造》，頁336-338，台北：元照。
365 民法第 6 條：「人之權利能力，始於出生，終於死亡」。

doi:10.6342/NTU202000774

公法上不當得利及產生返還義務。另外，學理所提出之行政處分效力之繼受概念，依本文前所述見解[366]，由於可能忽略受處分人以外第三人之程序權利保障，應不宜承認處分效力繼受之概念。

「授益處分效力」部分既無法及於繼承人，轉而考量處分相對人生前受有「金錢給付權利」是否有被繼承人概括繼受的可能，本文見解贊同上開學說見解，金錢給付之請求權一經處分相對人具體受領之後，該權利轉變成現實的金錢收入，性質上已非金錢給付請求權，無法以繼承人承受金錢給付權利為由而作為撤銷處分相對人。

退步言之，即使肯定實務見解，認為得直接向繼承人作成撤銷處分並對繼承人要求返還金錢，抑或是學理見解對非一身專屬性之金錢給付繼承人得繼受該處分效力，而作為撤銷處分相對人，課予遺產範圍內之返還義務之見解。似乎變成返還義務係「自始發生於繼承人」，非發生於原金錢授益處分相對人。質言之，繼承人負擔返還義務的原因，係自始為返還處分相對人，不具備義務同一性、義務主體非同一性之特徵，應無義務概括繼受討論之空間，屬不當得利返還義務主體之範圍議題，非本文探究核心。

綜上所述，現行法下未設有行政程序承受制度，處分相對人死亡時，其繼承人並不受該處分效力之延續；又金錢給付請求權一經具體實現，即無從以該財產流動，解釋繼承人概括繼受該金錢給付請求權。據此，行政機關不得以繼承人作為撤銷處分之相對人，原授益處分仍處未失效狀態，無從發生不當得利，當然也無從產生返還義務。

366 參照本文第三章、第二節、第三項 本文見解。

doi:10.6342/NTU202000774

（三）小結

不當得利返還義務成立的前提，藉由上述類型分析可以得知，行政機關必須「**在授益處分相對人死亡前，已向原處分相對人撤銷該授益處分，並對其作成返還處分**」，始產生公法上不當得利返還之義務。

反之，若行政機關未即時在授益處分相對人死亡前撤銷該處分，因行政程序法無程序承受的規定，該授益處分的效力無法及於其繼承人時，繼承人既不受授益處分效力所及，當然無從以其繼承人作為適格撤銷相對人；又，金錢給付請求權一經授益處分相對人生前具體受領，其繼承人不產生金錢給付請求權之概括繼受。據此，受益人於「死亡後」，行政機關始以「繼承人」為相對人作成撤銷處分之情況，乃欠缺撤銷處分適格的相對人而無從撤銷，故不具備公法不當得利之事由，無從產生返還義務。

參、公法上不當得利返還義務概括繼受容許性探討

確認授益處分相對人已負有不當得利返還義務後，接著進入本文核心，探究「公法上不當得利返還義務」有無可繼受性。

一、屬具體行政法上義務

不當得利返還義務為是否屬行政法上具體之義務部分較無爭議。若金錢授益行政處分欠缺公法上原因，行政機關依行政程序法第 110 條第 3 項[367]規定，

[367] 行政程序法第 110 條第 3 項：「行政處分未經撤銷、廢止，或未因其他事由而失效者，其效力繼續存在。無效之行政處分自始不生效力。」

doi:10.6342/NTU202000774

行政機關作成撤銷處分使違法金錢授益處分溯及失效，構成公法上不當得利。行政機關須再依據行政程序法第 127 條第 3 項，以書面行政處分方式，具體課予受益人返還義務而調整不當的利益流動，此種情況下始產生返還義務。據此，不當得利返還義務的產生，係行政機關對受益人以行政處分具體化其返還義務，屬具體行政法上義務無誤。

二、屬非一身專屬性義務

公法上不當得利返還義務是否屬「一身專屬性高度屬人性」，須端視返還義務內容及目的，是否與返還義務人之間是否存有不可分割緊密關聯性？就此疑問分述如下。

（一）學理見解

學理認為，思考不當得利返還義務一身專屬性與否，傳統學理上認為依據行政法上釋義學，從財產權價值之行政法上義務性質加以觀察，對於有財產價值之義務，原則上皆認為具有可繼受性，其立論係基於，以民法的一般法理，所有權人財產乃具有處分權限[368]，得本於自由意志轉讓之，故財產標的乃具可移轉的法律地位，而不當得利返還義務的內涵，即為對於具有財產權價值之金錢或是可分物的給付作為內涵，不同於其他較為複雜的作為、不作為或忍受之行為義務或是狀態責任下的義務，以此角度以觀，不當得利返還義務的財產價值性此一特徵，似可認為不具有一身專屬性之特徵；然現今行政法學理已揚棄上開觀點，認為行政法上的金錢或可分物之給付往往具有特定行政目的之特性

368 參考民法第 765 條：「所有人，於法令限制之範圍內，得自由使用、收益、處分其所有物，並排除他人之干涉」。

doi:10.6342/NTU202000774

以觀，故仍須以給付的「內容」與「目的」具體判斷有無一身專屬性[369]。

聚焦不當得利返還義務，乃人民無法律上原因而受領之利益而負有返還利益義務，其可繼受性判斷，可從大法官釋字第 621 號解釋理由書獲得些許啟示，該號解釋中，大法官認為「罰鍰處分」此種公法上金錢給付義務具有制裁受處分人違規行為的目的，具有一身專屬性之特徵，進而比較「返還義務」與「罰鍰義務」兩者間，可發現不當得利返還義務，乃起因於先前受領之金錢給付其「無法律上原因」所致，返還義務人乃經歷「金錢授益處分」與「撤銷原處分」兩種相斥的公法上金錢給付權利與義務之「反向性結構」，不同於基於罰鍰所產生的單一的義務結構；且從公法上不當得利返還義務本身的內容與目的以觀，係在調和得利者與受損者之間的不當利益流動，始回復財產未變動前的合法秩序，此種在依法行政下調和違法財產流動之義務，應屬具有一般可繼受性義務，較為合理[370]。

（二）本文見解

關於公法上不當得利返還義務，不妨從不當得利返還義務產生的歷程加以判斷，原則上會經歷以下三個階段，依序為授益處分、撤銷處分及返還處分。授益處分部分，其金錢給付本身會依據具體的給付有無與受益人不可分割性，有可能屬於一身專屬性或是非一身專屬性。然而，不論是有無一身專屬性的給付，嗣後遭到撤銷的原因，均是指向「無法律上原因」，撤銷後產生不當得利之狀態，行政機關得對受益人作成課予返還義務之行政處分。可發現此種義務本

[369] 詹鎮榮（2016），〈人民公法上不當得利返還義務之繼受〉，《行政法總論之變遷與續造》，頁 313-315，台北：元照。
[370] 詹鎮榮（2016），〈人民公法上不當得利返還義務之繼受〉，《行政法總論之變遷與續造》，頁 315-318，台北：元照。

doi:10.6342/NTU202000774

身是來自於原給付撤銷後對於「不當利益流動的客觀調整」，被撤銷的給付的性質有無具備一身專屬性並非返還義務所考量。最重要者，將命返還不當利益之手段，其對象由受益人置換至其繼承人，亦能達到原先返還義務的目的，使財產回歸於合法狀態利益的狀態，不因義務人的轉換而喪失原先的意旨。

退步言之，若是非一身專屬性之給付在撤銷後，其返還義務之可繼受性較無爭議；若是一身專屬性之給付在撤銷後，亦應不影響返還義務可繼受性的性質，原因在於，撤銷處分將合法歸屬於受益人之給付效力始溯及失效，該失效的給付，無從對受益人產生一身專屬性的連結，由此可知，返還義務本身是否具一身專屬性無從納入考量。

綜上所述，本文認為公法上不當得利返還義務，既是客觀對於不當利益流動之矯正，原給付本身是否為一身專屬性並不作為返還義務性質之考慮，更何況原給付既已遭撤銷而失效，給付之一身專屬性與否早已與受益人失去連結，而無任何參酌價值，應回歸不當得利返還義務之意旨──財產的合法狀態，由繼承人負擔返還義務，亦能達成不當得利制度的意旨，且符合比例原則的考量，可合理推論返還義務屬「非一身專屬性」。本文見解與學理見解結論相同，應不具一身專屬性，得由其繼承人加以概括繼受返還義務。

三、概括繼受返還義務之方式

新修正之行政程序法第 127 條第 3 項[371]中，立法者已明文對於公法上不當得利的返還方式乃採行政機關作成書面行政處分，然該條文明文命「受益人」

[371] 行政程序法第 127 條第 3 項：「行政機關依前二項規定請求返還時，應以書面行政處分確認返還範圍，並限期命受益人返還之」。

doi:10.6342/NTU202000774

返還之用語，該似乎是以受益人與返還義務人乃「同一人」情況作為前提。然而受益人發生死亡情事，返還義務由繼承人概括繼受之情況，屬受益人與返還義務人「非同一人」時，是否行政機關亦能依該條規定，向受益人之「繼承人」作成書面行政處分方式請求返還？對於此問題，本文以為應擴張解釋行政程序法第 127 條第 3 項之「受益人」，應解釋亦包括在受益人死亡後其概括繼承返還義務之繼承人，方為合理。

然而須注意者，行政程序法第 127 條第 3 項，於 104 年始修正，修法前所產生的不當得利返還義務，若行政機關未以書面行政處分作成，而是提起一般給付之訴請求者，新舊法的過渡期應如何認定尚有待討論，本文以為若修法前已提起一般給付之訴者，應認為已產生返還義務，較為妥當。

第五項 案例評析

針對高雄高等行政法院 102 年訴字第 100 號判決，其案例事實中，甲係受有專勤獎金之受益處分相對人，因甲仍自行開業看診收取醫療費用，違反專勤服務辦法第 2 條及第 7 條的規定，故民生醫院即在 88 年 10 月 18 日作成 A 函向甲主張應返還自 75 年 7 月 1 日至其離職日止所領取全部獎勵金共新台幣 577,07,069 元。關於 A 函的性質，應具有兩種處分的內涵，一為撤銷原給付的行政處分，使甲從 75 年 7 月 1 日到離職日起所受領的專勤獎金之處分效力溯及失效，進而甲所受領專勤獎金屬無公法上原因而受領，使高雄市立民生醫院受損，構成公法上不當得利之狀態；二為本於該公法上不當得利之狀態，醫院向甲請求返還該全部獎勵金之返還處分。

在 88 年 10 月 18 日 A 函作成時，甲即負有公法上不當得利之返還義務，

doi:10.6342/NTU202000774

甲不服而提出行政訴訟請求撤銷 A 函，因高雄高等行政法院當時認為 A 函並非為行政處分故裁定駁回確定，嗣後於 94 年 9 月 15 日甲發生死亡事實，民生醫院在 102 年始向之繼承人提起一般給付之訴而請求返還全部獎勵金。

由於行政程序法第 131 條規定，國家對人民之公法上請求權時效乃 5 年，民生醫院在 88 年 10 月 18 日作成 A 函課予甲返還義務後，即未再對甲請求，直到 102 年才向甲之繼承人請求返還。依照司法實務見解[372]，對於成立於行政程序法施行前的請求權，其自施行後最多應至 94 年 12 月 31 日前請求，否則將罹於時效。甲於生前所負擔的返還義務，於 94 年 9 月 15 日發生死亡事實時仍有效存在，且不當得利返還義務具有可繼受性下，甲之繼承人在類推適用民法第 1148 條第 1 項的規定下，應一併概括繼承該不當得利獎勵金之返還義務而須對民生醫院負返還之義務。

然甲死亡後至 94 年 12 月 31 為止，民生醫院並未向甲之繼承人主張應履行其概括繼受之返還義務，而遲至 102 年才以甲之繼承人為被告，提起返還繼承獎勵金之一般給付之訴，在此情況，該返還義務在 95 年 1 月 1 日起逾公法上請求權時效，依據實務見解[373]，該義務已發生權利消滅事由，據此甲之繼承人原先因甲死亡而應概括繼承之返還義務，因醫院請求罹於時效而義務消滅，故不得向甲之繼承人請求。

綜上所述，本案例甲之繼承人的確在甲死亡時，概括繼承其獎勵金不當得利之返還義務，應向民生醫院負返還之責。然而，因民生醫院罹於公法上請求權時效之故，其繼承之不當得利返還義務因此消滅而無法請求。由此可知，本案民生醫院不得向甲繼承人請求返還的原因，並非為繼承人未概括繼受該義

[372] 參照最高行政法院 92 年度判字第 818 號判決、96 年度判字第 914 號判決。
[373] 參照最高行政法院 95 年 8 月份庭長法官聯席會議。

doi:10.6342/NTU202000774

務，而是醫院怠於在公法上請求權時效內請求導致義務消滅而無法主張、請求。



第六項　小結

不當得利返還義務概括繼受之成立，必須是金錢授益處分相對人「死亡前」，行政機關已向相對人撤銷原處分並作成書面返還處分，始產生返還義務，成為概括繼受之標的。又返還義務的產生係來自行政機關對相對人作出書面返還處分，屬具體之行政法上義務。且其本身是一種調整不法財產流動的手段，與原先給付有無一身專屬性之特徵無涉，即使由受益人之繼承人加以返還，亦能達到不當得利制度之意旨，故返還義務不具有一身專屬性，具備可繼受性，其繼承人得加以概括承受之。

另外，金錢給付義務之概括繼受的依據，於在自然人死亡的情況，得類推適用民法 1148 條第 1 項；若是法人合併消滅的情況，則可類推適用公司法上第 75 條；若是非法人團體部份，則類推適用民法第 306 條，行政機關依據以上向受益人之繼承人請求返還。又，主張返還的方式，可擴張解釋行政程序法第 127 條第 3 項的規定，將受益人之繼承人涵蓋於內，進而以書面行政處分的方式向其繼承人請求履行其繼受之返還義務。

doi:10.6342/NTU202000774



doi:10.6342/NTU202000774



doi:10.6342/NTU202000774

第五章　結論

第一節　行政法上義務概括繼受基本體系建構

我國學理對於行政法上義務概括繼受制度之要件，多半係從比較法上的文獻引進，實務見解對此亦未有成熟的體系建構以遵循、適用，導致我國對於行政法上之義務概括繼受的討論與發展尚未足夠。然而，義務之概括繼受無疑是現行社會事實持續不斷發生者，仍須正視此等議題就如何建構。思考之基礎在於理解概括繼受之意義、概括繼受於憲法上所存在之定位及義務的內涵，始能正確打下制度建構之根基。

第一項　行政法上義務概括繼受概念

壹、行政法上義務之辨析

所謂行政法上義務，其概念為人民在實現法律的構成要件，據此負有一定具體之規制。義務的內涵可分為作為義務、不作為義務及忍受義務，作為義務尚可進一步區分為金錢給付義務及非金錢給付義務，就義務概括繼受之發生，實務及學理以作為義務為主要之討論，也即公法上金錢給付義務及非金錢給付義務作為概括繼受之主要爭議。

行政法上義務與行政法上責任兩者為不同概念，因「責任」乃義務之成立基礎；而「義務」乃責任之後果體現，故發生行政法上義務的進程可列為以下三種層次：具備行政法依據、人民的行為構成行政法上「行為責任」；或是物之

doi:10.6342/NTU202000774

狀態使管領人構成「狀態責任」、行政機關對該人民以行政處分作成「具體行政法上義務」。

相較於民法上之義務，藉由檢視兩者間之義務分類及所指涉之內涵，民法與行政上之義務均可以分為作為、不作為及忍受義務，且作為義務亦可以再區分為金錢或非金錢給付義務，彼此間的內涵均可相通，可發現民法與公法上之「義務」一詞所指涉者均不相扞格，概念對應具有共通性。

貳、行政法上概括繼受之辨析

本文所研究之核心，人民與人民之間發生概括繼受其行政法上義務，在早期學理認為公法上義務具有高度屬人性，然近代學理均肯定公法上義務有概括繼受之適用。首先就「概括繼受」概念上乃相對於個別繼受，係指因發生法律規定之法律事實，導致義務人之義務全面移轉於繼受人，其特徵具有「義務同一性」、「義務主體不同一性」。關於現行行政法規範，尚未有概括繼受之基礎規範，但在民法繼承編之第 1148 條第 1 項，即規範自然人發生死亡情事其概括繼受；另外在發生法人合併之場合，公司法第 75 條作為法人概括繼受之依據，以及非法人團體，依民法第 306 條作為營業合併之概括繼受依據。

第二項　憲法框架下之義務概括繼受

義務概括繼受置於憲法框架下思考，可知義務繼受人概括繼受公法上義務，其追求之目的，考量公法上義務多來自於秩序行政下公益維護之目的，此特色乃私法上義務所無者，當未履行義務之人民死亡或是法人消滅時，背負著秩序行政目的之義務產生「無人履行之狀態」，社會秩序的妨礙及已發生之危害

doi:10.6342/NTU202000774

卻依舊存在，為避免此種情況產生，行政法上義務概括繼受之制度因蘊而生，使社會秩序之維護不因義務主體消滅而中斷。此制度的運作最重要者係在國家貫徹公益的要求及行政法上義務人受到基本權利的侵害，尋求對於兩者間最佳的衡量與調整，以切合憲法之要求。

行政法上義務之概括繼受，可能涉及概括繼受人憲法上財產權、一般行為自由之限制，概括繼受此手段在比例原則適當性要件之考量上，必須將排除具有一身專屬性之義務；必要性要件則是考量義務履行之狀況及繼受人之狀態課予合理之繼受內容，例如：金錢給付義務以遺產為限之有限責任；最後即是衡量繼受人負擔義務與義務履行之公益兩相比較有無輕重失衡。

另外在公法上概括繼受之法律依據部分，其法律保留原則之寬嚴，亦為學理上所爭論者，依據概括繼受所涉及對繼受人財產權或一般行為自由之限制，應至少有法律位階作為依據。然而，現實法規範考量，公法上義務概括繼受依據實屬欠缺，但現行民法繼承編、公司法第 75 條及民法第 306 條上均有已有自然人、法人及非法人團體之概括繼受依據，故本文試著分析上開其他法領域之概括繼受標的的描述，有無涵蓋行政法上義務之空間，以暫時解決公法規範的空洞。

第二節　釐清義務繼受思考流程

第一項　發生義務概括繼受事由

發生概括繼承之事由，係義務主體消滅始發生，具體而言係自然人發生死

doi:10.6342/NTU202000774

亡情事或是法人、非法人團體發生合併。尚須注意者，發生概括繼受情事時，前提是被繼受人存續時義務已發生，例如：公法上不當得利返還義務的產生，必須是原授益處分失效，並進一步作成書面返還處分，始發生不當得利返還義務，成為概括繼受之標的。

第二項　義務具有可繼受性

壹、具體行政法上義務

原則上，必須是行政機關對已具體化行政法上責任，依據法規範作出具體義務之規制，人民始須履行其具體行政法上義務，公法上法律關係始存在於國家與人民之間，始有成為概括繼受標的之資格，具備可繼受性。

然而應注意，在特別法領域之義務中，立法者仍得考量公益的維護重要程度，例外指示就行政法上之抽象責任，亦得成為概括繼受之標的，例如：土汙法上之整治義務，因土汙法第 53 條之行為責任真正溯及既往規範下，可得解釋出立法者肯定尚處於土汙法抽象行為責任，得由繼承人繼承該抽項責任地位，進一步行政機關對該繼承人作成課予整治義務之處分。

貳、不具備一身專屬性

義務有無具有一身專屬性，係指義務有無與義務人緊密連結性，判斷上應以憲法上比例原則出發，考量其承受之義務，是否在義務在轉換於繼承人時，

doi:10.6342/NTU202000774

能透過由繼承人履行，達成原先該義務所追求之目的。若仍能藉由繼承人履行概括繼承之義務達成義務之目的者，該等義務不具備一身專屬性，具備可繼受之資格。一身專屬性之檢驗於憲法之層次上，是手段適當性之具體展現，以確保其行政法上義務，的確有使繼受人概括繼受而負擔履行之實益。

例如：罰鍰之目的在課予違反行政法上義務人心理壓制之痛苦並促使行為人及其他人警戒再犯，且剝奪其不法獲得之經濟利益，上開目的即使移轉至繼受人，亦無法達成罰鍰處分欲達成之目的。據此，罰鍰義務由此推論具備一身專屬性，不具備可繼受性，無從作為由繼承人概括繼受而履行。

第三節　建構我國法公法上概括繼受法律依據

公法上概括繼受制度，對於基本權利的干預並非輕微，法律保留原則的要求，須至少有法律位階作為規範，本文先就現行法之概括繼受規範，試著加以解釋有行政法上義務之空間。

首先，因自然人死亡所發生概括繼受，分析民法第 1148 條第 1 項其所規範概括繼受之標的，該條文所指涉「財產上義務」，乃作為義務中物之給付義務、私法契約所勞務給付義務及涉及財產權限制之不作為容忍義務。藉由本文前開對於民法上與公法上義務種類的對照，可發現上開民法上義務，可無衝突地對應至公法上作為義務中物之給付義務、國家與私人間締結之私法契約勞務給付義務及涉及財產權限制之公法上不作為、容忍義務。故本文以為，上開義務應可類推適用民法第 1148 條第 1 項作為公法上概括繼受之依據；另外就公法上非私法契約之勞務給付義務、非涉財產權限制之不作為、容忍義務因無從由民法第 1148 條第 1 項之「財產上義務」一詞之解釋涵蓋，故無法類推適用之，對此

doi:10.6342/NTU202000774

立法者應另立公法領域內法律依據，始能滿足法律保留原則。

再者，就法人合併所發生之概括繼受事由，依公司法第 75 條條文以「其權利義務」描述，可發現對於義務一詞未限制為何種義務，有此可推論係指涉一切私法上與公法上義務。據此，法人所負有之行政法上義務，均可藉由類推適用公司法第 75 條之規定作為概括繼受之依據。非法人團體之合併，藉由民法第 306 條之「債務」一詞的解釋，可類推適用至公法上物之給付義務、涉及財產權規制之公法上不作為、容忍義務及公法上之私法契約勞務給付義務。然其他義務，尚待由立法者另行明文。

然民法第 1148 條第 1 條的結構加入「除本法另有規定外」的諭知，目的在於使立法者應盡量完整建構各個法領域的概括繼受制度。即使透過法條字句規範解釋涵蓋公法上義務，但仍有所極限，例如：自然人死亡或是非法人團體合併情況，仍有部分的公法上義務無法分別從民法第 1148 條第 1 項解釋及民法第 306 條得出，尚待立法者另立新法。較為周全之道，立法者應就公法上義務的概括繼受制定一套完整的體系，將自然人、法人、非法人團體均加以規範，以改善現行法規範下類推適用的極限，及公法體系的不健全。

第四節　建立概括繼受之正當法律程序

第一項　行政程序

因發生繼承事由，繼承人發生義務地位之移轉，致使負有該義務應履行之負擔，對於概括繼承人之基本權利干預，行政機關於行政程序應踐行職權調查

doi:10.6342/NTU202000774

概括繼受義務之繼承人及義務內容，並另作成行政處分而送達於繼承人，且賦予繼承人充分之聽證權及處分中盡其理由說明義務。藉由上開正當程序的進行，給予
繼承人合理之行政法上主體地位。

第二項　行政爭訟程序

在行政爭訟程序中，若發生概括繼受情事，訴願機關或是行政法院應踐行之正當爭訟程序，會因義務有無可繼受性而不同。若爭訟標的（義務）係具有一身專屬性，義務因義務人死亡而解消，此時欠缺爭訟標的，不符爭訟之形式合法要件，訴願機關應作成不受理撤銷訴願之決定（訴願法第 77 第 6 款），或是行政法院裁定駁回該撤銷訴訟之判決（行政訴訟法第 107 條第 3 款）。繼承人在此情況，因實體法上並不受義務移轉而之規制，欠缺其訴願、訴訟權能，無須承受訴願或訴訟程序，但考量被繼承人生前所受之義務規制，未能於爭訟程序中加以抗辯，繼承人應可另提出確認處分違法之訴，以回復被繼承人之死者名譽權。

另一方面，若爭訟標的不具有一身專屬性，該等義務可能在發生概括繼承事由時，繼承人承受該義務，成為新的義務主體，在程序法上繼承人即具有訴願、訴訟權能，繼承人可承受訴願程序（訴願法第 87 條）或是承受訴訟程序（行政訴訟法第 186 條準用民事訴訟法第 168、169 條及行政訴訟法第 181 條規定），續以爭訟當事人地位續行救濟之。然而，繼承人本身具有新的義務人地位，應享有獨立的程序保障地位，故行政機關仍應對繼承人另作成行政處分，使繼承人可選擇另外獨立提起訴願、行政訴訟。

doi:10.6342/NTU202000774

第三項　執行程序

就具有一身專屬性之義務，於執行程序中發生概括繼受事由發生時，該義務效力解消，該處分不再成為有效的行政執行名義，此時，執行機關應依行政執行法第 8 條第 1 項第 3 款之規定，終止執行之。

再者，不具有一身專屬性之處分，就公法上金錢給付義務部分，義務人死亡後，繼受人將會在行政執行中承受該義務。因行政執行法第 15 條的性質，係執行機關就遺產作為執行標的，繼續執行不停止執行程序規定，而非實體法上對於金錢給付義務之死後執行之依據。是以，執行中發生概括繼受之情事，執行機關應依照行政執行法第 15 條之執行程序終止例外規定，就義務人之遺產範圍內，逕為執行之。繼受人在執行程序，其所繼受之金錢給付義務，當然有爭執之救濟權利所在而主張對執行名義不服，進而依循行政執行法第 9 條之規定「聲明異議」，若聲明異議被駁回，繼受人可進一步對該處分提起撤銷訴願及訴訟，以獲得救濟。

另外，若是公法上其他行為或不行為義務人，因行政執行法並未對此明文或準用強制執行法續為執行之規定，就此部分，執行機關應依照行政執行法第 8 條第 1 項第 3 款之規定終止執行。

第五節　行政法上義務繼受之展望

藉由分析行政法概括繼受制度之意義，及解析「概括繼受」及「義務」名詞之內涵，思考其憲法上層次之目的與手段，整理義務概括繼受之思考流程與

doi:10.6342/NTU202000774

要件，試著讓行政法上義務概括繼受此一課題，能有更清楚、細膩的觀察。另外，現行義務概括繼受制度，面臨幾個須討論的課題，有關現行法規範，欠缺公法領域之概括繼受規範，本文嘗試整理我國學理及實務見解，試著以現行法之角度，解釋行政法上義務概括繼受之法規範依據的空間，以暫時符合法律保留原則之要求，當然在立法論上，仍須呼籲立法者制定健全之公法上義務概括繼受規範。另外，概括繼受義務之正當法律程序之思考，使繼受制度不只是著眼於實體法上之課題，尚能與程序法規範加以結合，建構較為全面之行政法上義務概括繼受制度。最後，以罰鍰義務、土汙法之整治義務與公法上不當得利返還義務之案例，進一步思考在概括繼受制度下應為如何之思考。透過本文以上之整理、分析，盼能給予我國行政法上義務繼受制度更為全面、完善的理解與應用。

doi:10.6342/NTU202000774



doi:10.6342/NTU202000774

參考資料

一、專書（依姓氏筆畫排列）

王泰銓、王志誠（修）（2009），公司法新論，5 版，頁 205，台北：三民。

王澤鑑（2006），《民法學說與判例研究（八）》，台北：自刊。

王澤鑑（2012），《債法原理：基本理論、債之發生、契約、無因管理》，3 版，台北：自刊。

王澤鑑（2013），《民法概要》，4 版，台北：自刊。

王澤鑑（2014），《民法總則》，增訂新版，台北：自刊。

王澤鑑（2015），《不當得利》，增訂新版，台北：自刊。

王澤鑑（2015），《侵權行為法》，增訂新版，台北：自刊。

司法院大法官書記處（2014），《德國聯邦憲法法院裁判選輯（十五）》，台北：司法院。

李太正、王海南、法治斌、陳連順、黃源盛、顏厥安（2014），《法學入門》，第 14 版，台北：元照。

李建良（2016），《行政法基本十講》，6 版，台北：元照。

doi:10.6342/NTU202000774

李惠宗（2015），《憲法要義》，6 版，台北：元照。

李震山（2007），〈程序基本權〉，《多元寬容與人權保障：以憲法未列舉權之保障為中心》，2 版，台北：元照。

李震山（2014），《行政法總論》，10 版，台北：三民。

林秀雄（2017），《繼承法講義》，7 版，台北：元照。

林騰鷂（2012），《行政法總論》，3 版，台北：三民。

柯芳枝（2013），公司法論（上），9 版，台北：三民。

洪家殷（2008），《行政罰法論》，2 版，台北：五南。

張登科（2014），《強制執行法》，修訂版，台北：三民。

許宗力（2006），《法與國家權力》，台北：元照。

陳敏（2016），行政法總論，9 版，台北：新學林。

陳棋炎、黃宗樂、郭振恭（2014），《民法繼承新論》，9 版，台北：三民。

湯德宗（2003），〈論正當行政程序〉，《行政程序法論》，2 版，台北：元照。

doi:10.6342/NTU202000774

詹鎮榮（2016），《行政法總論之變遷與續造》，台北：元照。

廖義男（2008），《行政罰法》，2 版，台北：元照。

劉作揖（2014），《法學緒論》，12 版，台北：三民。

劉連煜（2016），《現代公司法》，12 版，頁 119，台北：新學林。

蔡茂寅、李建良、林明鏘、周志宏（2013），《行政程序法實用》，4 版，台北：新學林。

鄭玉波著、黃宗樂修訂（2016），《法學緒論》，22 版，台北：三民。

鄭冠宇（2016），《民法總則》，3 版，台北：新學林。

韓忠謨（1994），《法學緒論》，2 版，台北：韓聯甲。

二、期刊文章（依姓氏筆畫排列）

立法院公報處（1998），《立法院公報》，87 卷 42 期，台北：立法院。

李介民（2007），〈干涉行政法整治責任之繼受及界限－以土壤及地下水汙染及整
治法為範圍－兼評高雄高等行政法院 93 年度訴字第 941 號判決〉，《警學叢刊》，38 卷 3 期，頁 57-96。

doi:10.6342/NTU202000774

李建良（2002），〈行政處分的「解決」與行政救濟途徑的擇定〉，《台灣本土法學雜誌》，40 期，頁 105-115。

李建良（2006），（行政法上義務繼受問題初探－兼評高雄高等行政法院九十二年度訴字第八○六號判決暨最高行政法院九十四年度判字第六二二號判決）。收於：湯德宗、劉淑範（編），《2005 行政管制與行政爭訟》，頁 75-122。台北：中央研究院法律學研究所籌備處。

李建良（2007），〈釋義土壤及地下水汙染整治法之汙染行為人－闡析台鹼安順廠汙染事件之整治責任及行政法院相關判決〉，收於：李建良、湯德宗（編），《2006 行政管制與行政爭訟》，頁 101-158。台北：中央研究院法律學研究所籌備處。

李建良（2008），〈論行政法上「責任」概念及責任人的選擇問題—兼評最高行政法院 93 年度判字第 628 號、95 年度判字第 1421 號判決及其相關判決〉，收於：黃舒芃（編），《2007 行政管制與行政爭訟》，頁 29-104。台北：中央研究院法律學研究所籌備處。

李建良（2013），〈拒絕酒測與吊銷駕照的合理關聯與正當程序－釋字第 699 號解釋〉，《台灣法學雜誌》，第 235 期，頁 29-44。

李建良（2014），〈「狀態責任」概念之辯正與運用：《台中大里區段徵收土地掩埋物清理案之一》—最高行政法院 102 年度判字第 370 號判決、台中高等行政法院 99 年訴字第 268 號判決重點評析〉，《台灣法學雜誌》，246 期，頁 39-56。

doi:10.6342/NTU202000774

林三欽（2014），〈土壤汙染行為人責任之繼受與法律溯及適用－簡評大法官解釋第 714 號解釋〉，《法令月刊》，65 卷第 1 期，頁 65-6-65-17。

林昱梅（2015），〈土壤污染行為人整治責任概括繼受之法律問題－以德國法之比較為中心〉，《東吳法律學報》，26 卷 3 期，頁 41-97。

林錫堯（2002），〈公法上不當得利法理試探〉，收於： HARRO VON SENGER · Konosuke Kimura · ORTLOFF · PETER BADURA MUNCHEN SCHMIDT-ASMANN · 木村弘之亮 · 王玉葉 · 江耀國 · 吳東都 · 李惠宗 · 林三欽 · 林明昕 · 林明鏘 · 林素鳳 · 林錫堯 · 姜皇池 · 洪德欽 · 孫迺翊 · 宮崎良夫 · 張文郁 · 子　龍 · 郭介恆 · 郭明政 · 陳宜倩 · 陳怡凱 · 陳英鈐 · 彭南元 · 彭鳳至 · 焦興鎧 · 黃宗樂 · 葉百修 · 葛克昌 · 雷文玫 · 劉孔中 · 劉宗德 · 劉建宏 · 蔡志方 · 蔡宗珍 · 蕭文生（編），《當代公法新論(下)》，頁 267-286。台北：元照。

邵慶平（2007），〈公司法：第二講 組織與契約之間—經濟分析觀點〉，《月旦法學教室》，62 期，頁 34-44。

洪家殷（2006），〈行政行為（二）－行政處分：第三講 行政處分成立與效力〉，
《月旦法學教室》，41 期，頁 42-52。

洪家殷（2008），〈行政罰之狀態責任及一行為不二罰原則—臺北高等行政法院九六年訴字第一二八八號判決簡評〉，《台灣法學雜誌》，104 期，頁 328-332。

洪家殷（2010），〈行政罰法：第三講－行政罰上之一行為不二罰原則及其適

doi:10.6342/NTU202000774

用〉，《月旦法學教室》，88 期，頁 42-54。

洪家殷（2010），〈論行政調查中職權調查之概念及範圍－以行政程序法相關規定為中心〉，《東吳法律學報》，21 卷 3 期，頁 1-42。

胡天賜（2012），〈債務人死亡後，如何執行其所遺不動產－從釋字第 621 號解釋觀點評論法務部法律字第 0999047457 號函（下）〉，《法務通訊》，2613 期，頁 5-6。

姚其聖（2015），〈公法上金錢給付義務人死亡如何執行〉，《全國律師》，19 卷第 10 期，頁 88-101。

許育典（2010），〈行政罰與刑罰之競合－評台北高等行政法院九十五年訴字第一四三六號判決〉，《月旦裁判時報》，3 期，頁 20-25。

郭大維（2013），〈股東有限責任予否認公司法人格理論之調和──「揭開公司面紗原則之探討」〉，《中正財經法學》，7 期，頁 49-105。

陳敏（2009），〈人民公法上權利義務之繼受〉，收於：陳新民・蔡英文・陳思賢・李念祖・蕭高彥・張旺山・姚朝森・李俊增・李震山・蘇永欽・湯德宗・董保城・蔡震榮・蔡庭榕・廖元豪・陳淳文・陳敏・黃錦堂・劉孔中・林明鏘・林三欽・陳清秀・李建良・詹鎮榮・簡玉聰・賴恆盈・吳秦雯・張文郁（編），《政治思潮與國家法學：吳庚教授七秩華誕祝壽論文集》，頁 461-505。台北：元照。

陳清秀（2007），〈稅捐債務可否繼承-評析釋字第六二二號解釋-〉，《台灣本土

doi:10.6342/NTU202000774

法學雜誌》，91 期，頁 299-309。

陳聰富（2000），侵權行為法上之因果關係，國立臺灣大學法學論叢，29 卷 2 期，頁 175-307。

黃啟禎（2002），〈干涉行政法上責任人之探討〉。收於：Dr. Dr. h. c. Heinrich Scholler・Dr. h.c. Gü・nter Pü・ttner・Reinhard Mussgnug・克立斯提安.史塔克・吳信華・吳煜宗・李　麒・李仁淼・李念祖・李震山・周志宏・林三欽・林明昕・林昱梅・林騰鷂・法治斌・徐正戎・翁曉玲・張嘉尹・清水秋雄・許育典・陳世民・陳淑芳・陳慈陽・陳愛娥・陳新民・陳耀祥・普特諾・湯德宗・黃俊杰・黃昭元・黃錦堂・葉俊榮・廖福特・蔡宗珍・蕭　樂・顏厥安・蘇永欽（編），《當代公法新論（中），翁岳生教授七秩誕辰祝壽論文集》，頁 289-322。台北：元照。

劉建宏（2007），〈行政主體向人民主張公法上返還請求權之法律途徑及其返還範圍－以授益處分經自行撤銷之情形為例〉，《東吳法律學報》，19 卷 2 期，頁 175-222。

劉建宏（2009），〈法定訴願承受制度之探討－兼論以死亡之人名義提起訴願之相關問題〉，《臺北大學法學論叢》，72 期，頁 1-46。

劉春堂（2011），〈侵害死者名譽之民事責任〉，《輔仁法學》，42 期，頁 115-162。

蔡宗珍（2008），〈公法上無主義務之強制執行?〉，《中研院法學期刊》，2 期，頁 275-314。

doi:10.6342/NTU202000774

蔡宗珍（2011），〈建築法上義務人之類型與具體義務人之判定：行政法上行為責任與狀態責任問題系絡的一個切面分析〉，《台大法學論叢》，40 卷 3 期，頁 907-954。

三、學位論文（依姓氏筆畫排列）

王晨桓（2009），《行政法上金錢給付義務之繼受問題-以罰鍰及課稅為討論重心》，國立臺灣大學法律學研究所碩士論文。

徐傑輝（2004），《秩序行政與行政秩序罰》，淡江大學公共行政學系公共政策碩士論文。

蔡靜娟（2009），《行政法上義務人死亡義務繼受之研究》，國立中正大學法律學研究所碩士論文。

錢建榮（1995），《行政契約之主體與範圍》，輔仁大學法律學研究所碩士論文。

羅元慎（2005），《土壤及地下水污染整治法制之檢討－以行政法上義務與責任之視角觀察》，國立臺灣大學法律學研究所碩士論文。

四、訴願決定、判決判例及會議決議

內政部 102 年 4 月第 1020140036 號訴願決定。

doi:10.6342/NTU202000774

司法院民國 34 年 6 月 6 日院解字第 2911 號解釋。

台北高等行政法院 102 年訴更一字第 137 號判決。

最高法院 90 年台上 646 號判決。

最高行政法院 90 年 12 月份第 2 次庭長法官聯席會議決議。

最高行政法院 92 年度判字第 818 號判決。

最高行政法院 95 年 1 月份庭長法官聯席會議決議。

最高行政法院 96 年度判字第 914 號判決。

最高行政法院 96 年判字第 1953 號判決。

最高行政法院 98 年 12 月份第 2 次庭長法官聯席會議。

最高行政法院 100 年度判字第 75 號判決。

最高行政法院 101 年度判字第 857 號判決。

最高行政法院 103 年判字第 701 號判決。

最高行政法院 103 年度判字第 136 號判決。

最高行政法院 104 年判字第 333 號判決。

最高行政法院 104 年判字第 656 號判決。

doi:10.6342/NTU202000774

最高行政法院 104 年判字第 484 號判決。

最高行政法院 105 年判字第 60 號判決。

最高行政法院 95 年 8 月份庭長法官聯席會議。

doi:10.6342/NTU202000774